

Gonzalo Bustamante
Diego Sazo (Compiladores)



Democracia y poder constituyente



Gonzalo Bustamante
Diego Sazo (Compiladores)



Democracia y poder constituyente



POLÍTICA Y DERECHO

Gonzalo Bustamante (Santiago, Chile) Filósofo y doctor en Culture of Economics, Erasmo University Rotterdam. Ha sido investigador visitante en el Institut für Sozialforschung de Fráncfort así como en la Università degli Studi di Padova. Junto a Andrés Estefane, es compilador de *La agonía de la convivencia, violencia política, historia y memoria* (2014). Actualmente, es profesor de Filosofía y Teoría Política de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Diego Sazo Muñoz (Santiago, Chile) Cientista político, Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue director del Centro de Análisis e Investigación Política (CAIP) y editor de la revista *Pléyade*, dedicada a estudios de ciencias sociales y humanidades. Es compilador de *La revolución de Maquiavelo. El príncipe 500 años después* (2013). Actualmente, se desempeña como asesor político en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

SECCIÓN DE OBRAS DE POLÍTICA Y DERECHO

DEMOCRACIA Y PODER CONSTITUYENTE

GONZALO BUSTAMANTE
DIEGO SAZO
(COMPILADORES)

Democracia y poder constituyente

AUTORES

Diego Sazo · Andreas Kalyvas · Miguel Vatter · Gonzalo Bustamante ·
Poul F. Kjaer · Sandro Chignola · Giuseppe Duso · Aldo Mascareño ·
Valentina Verbal · Francisco Zúñiga · Renato Cristi · Fernando Atria



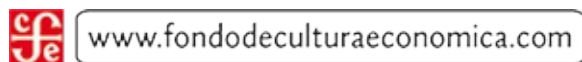
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

MÉXICO - ARGENTINA - BRASIL - COLOMBIA - CHILE - ECUADOR - ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA - GUATEMALA - PERÚ - VENEZUELA

Primera edición, FCE Chile 2016
Primera edición electrónica, 2017

© Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile

D. R. © 2016, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México



Comentarios:
editorial@fondodeculturaeconomica.com
Tel. (55) 5227-4672

Registro de Propiedad Intelectual N° 270.822

Coordinación editorial: Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Cuidado de la edición: Sonia López Baena
Diseño de portada: Macarena Rojas Líbano
Imagen de portada: Ints Vikmanis /Shutterstock.com
Diagramación: Gloria Barrios A.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-5207-2 (ePub)

Hecho en México - *Made in Mexico*

ÍNDICE

Introducción. Ecos del debate constituyente global
Diego Sazo

Primera Parte

APROXIMACIONES CONCEPTUALES AL PODER CONSTITUYENTE

I. Poder constituyente: una breve historia conceptual
Andreas Kalyvas

II. Poder constituyente y representación
Miguel Vatter

III. Poder constituyente: ¿un mito católico versus un símbolo protestante?
Gonzalo Bustamante

IV. Órdenes normativos transnacionales: el constitucionalismo del derecho intra y transnormativo
Poul F. Kjaer

Segunda Parte

DEBATE CONSTITUYENTE EN EL MUNDO

V. Estado, constitución. Una lección
Sandro Chignola

VI. Más allá del nexo soberanía-representación ¿un federalismo sin

Estado?

Giuseppe Duso

VII. Hacia una deconstitucionalización del particularismo normativo en América Latina

Aldo Mascareño

Tercera Parte

DEBATE CONSTITUYENTE EN CHILE

VIII. El debate constitucional en Chile. La Cuestión de la legitimidad

Valentina Verbal

IX. Potestad constituyente

Francisco Zúñiga

X. Proceso constituyente originario

Renato Cristi

XI. Nueva constitución y poder constituyente: ¿qué es “institucional”?

Fernando Atria

Bibliografía

Agradecimientos

Índice de autores

INTRODUCCIÓN ECOS DEL DEBATE CONSTITUYENTE GLOBAL

Diego Sazo

Una Constitución no es el acto de un gobierno, sino el de un pueblo constituyendo a un gobierno¹.

THOMAS PAINE

ANTECEDENTES

En 2011, la influyente revista *Time* provocó a sus lectores con una portada insólita. Como pocas veces en ocho décadas, sus editores desearon escoger como “Persona del año” a un destacado político, científico o artista, y se inclinaron por una opción no convencional. Se trató de un sujeto de rostro semicubierto, de mirada desafiante y nombre desconocido, pero con reconocido poder simbólico en las calles del mundo durante ese año: el manifestante social². Esa fue la ingeniosa forma del semanario estadounidense para relevar el fenómeno de las protestas que, alojadas en distintos puntos del globo, marcaron pauta sin distinguir fronteras.

Transcurrida la primera década del siglo XXI, el balance de la agenda mundial era difuso, indefinido —o líquido, en palabras de Zygmunt Bauman—, en cuanto carecía de un eje político transversal al acontecer de los países. Fue en ese escenario de orfandad temática donde emergió como factor común a las democracias occidentales una ola de disenso, donde voces activistas se levantaron contra el poder, no solo con quejas y consignas contestatarias, sino también con demandas específicas hacia la autoridad. Tuvo un efecto dominó: la masiva adhesión de ciudadanos

abrumó a los gobiernos, la simultaneidad de los casos potenció los movimientos y la originalidad de sus repertorios cautivó a los medios de comunicación. Ese año nadie fue indiferente al poder en movimiento.

Si bien los procesos de acción colectiva están lejos de ser un fenómeno exclusivo de nuestro tiempo —reconocemos su presencia intermitente desde la era de las revoluciones del siglo XVIII³—, lo novedoso es que varias de las recientes movilizaciones tienen en su anatomía un desafío evidente: cuestionar las estructuras tradicionales de dominación y exigir una revisión a los modos en los que se ejerce el poder. Y es que estas oleadas de protesta buscan esclarecer, en último término, *quiénes* son los encargados de instituir las formas de autoridad política y, en consecuencia, organizar la vida en sociedad. ¿Dónde reside la soberanía en la democracia de nuestros días? La pregunta —dinamita para los sectores conservadores, sean de izquierda o de derecha— alberga la inquietud por la naturaleza del *poder constituyente*⁴, ubicando el debate inevitablemente en el grado cero de la política: la constitución.

LA CONSTITUCIÓN COMO ASUNTO RADICAL

La constitución es la norma suprema de un Estado, destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política. En ella, se traza el horizonte ideológico, aquel que inspira y otorga legitimidad al modo de vivir colectivo. La llamada “comunidad imaginada”⁵ encuentra en la constitución su soporte normativo. Por eso, discutir sobre ella es plantear la pregunta sobre el país que se aspira, abriendo la opción para redefinir los principios del pacto social y modificarlo por valores renovados de convivencia común.

Para dar origen a un cambio constitucional es clave el inconformismo y la rebeldía. El primero, porque instala la insatisfacción frente al orden político; la segunda, porque azuza el ánimo para oponerle resistencia. Sin ellos, el *status quo* no se inmuta; más bien, prevalece y se consolida. También es crucial el protagonismo que vaya a adquirir la clase política —en complicidad, en algunos casos; en antagonismo, en otros— con los movimientos sociales, ya que son ellos los que empujan los procesos de transformación ante coyunturas críticas⁶.

Muchos temen la discusión sobre el cambio de la constitución porque el problema se traslada al momento originario de la sociedad, previo a las instituciones y a lo que los contractualistas llamaron *pactum societatis*. En ese terreno, el orden vigente se vuelve profano, objeto de interpelaciones y críticas que develan sus carencias y socaban sus pilares esenciales. Qué duda cabe: el asunto constitucional es de naturaleza trascendente y radical.

Algunos insinúan que este debate es materia exclusiva del derecho y de constitucionalistas. Se equivocan. Por su esencia y objetivo, no existe cuestión más *política* que la disputa constitucional. Esto se justifica al menos en tres sentencias. Primero, porque es un asunto que, inevitablemente, emplaza a tomar postura ante principios fundamentales en pugna. Por ejemplo, frente a la pregunta por el principio de subsidiaridad o el alcance de los derechos sociales, resulta imposible prescindir de una valoración. Como indicó Leo Strauss, los fenómenos políticos son polémicos, “llevan en su esencia no ser un objeto neutro”⁷. Segundo, porque lo que se resuelve en torno a esos principios fundamentales rige para todos los miembros de la comunidad⁸. Es decir, lo decidido involucra autoritativamente al conjunto de los actores. Tercero, porque en la constitución se trazan las relaciones de poder al interior del colectivo social, determinando su origen, titularidad y límites. Y, lo sabemos, la política es un imperecedero asunto de poder⁹.

No está claro el momento en que las sociedades democráticas se plantean transformaciones constitucionales. En algunos casos, se suscita como el trágico desenlace de crisis institucionales; en otros, como la necesaria adecuación ante cambios de ciclo político¹⁰. Como sea, en ambas situaciones, el factor común corresponde al agotamiento de los fundamentos de la estructura de dominación que configura la vida social y la forma legal que la valida.

¿Qué ocurre estos días con la legitimidad de los regímenes políticos?
¿Estamos frente a un incipiente proceso constituyente global y local?
¿Existen vientos de cambio constitucional en las democracias de hoy?

En palabras del viejo Marx, se puede afirmar que un fantasma recorre Asia, Europa y América: el fantasma de la protesta social. Basta escuchar la radio, leer el periódico, ver la televisión o conectarse a las redes sociales. Ahí están, diariamente, ciudadanos descontentos y movilizados en las calles, irrumpiendo con fuerza insospechada en la discusión pública mundial. Los casos abundan: del anhelo democrático en Hong Kong a las consignas antiausteridad en Grecia; del independentismo en Cataluña al reclamo por la corrupción en Brasil; del inconformismo del *Occupy* estadounidense a las críticas ciudadanas contra los gobiernos de Egipto, Turquía, Tailandia y Venezuela, entre varios otros. No solo eso, también han tomado fuerza movimientos y figuras políticas que expresan la rebelión de las bases contra la elite. De los primeros, encontramos el ascendente posicionamiento electoral de Podemos en España y Syriza en Grecia; de los segundos, el auge de Jeremy Corbyn, el díscolo líder del Partido Laborista en Reino Unido, y Bernie Sanders, el candidato socialista que prometía una revolución política en Estados Unidos.

Ante este panorama, no son pocas las voces que alertan sobre una izquierdización del proceso político, instigado por el eco selectivo de los medios de comunicación tradicional. Mala noticia para los agoreros, porque tal diagnóstico falla en uno y otro argumento. Primero, porque estos estallidos han comprendido demandas amplias, que superan el exclusivo domicilio ideológico de la izquierda, como son la exigencia de mayores grados de participación o el aumento en los estándares de transparencia. Segundo, porque la relevancia mediática que han adquirido estas protestas responde esencialmente al auge de la “autocomunicación de masas” (Internet y redes sociales) y no a las preferencias de agenda de los editores periodísticos¹¹.

No descartemos lo evidente: la simultaneidad global de estos procesos es el síntoma de patologías no resueltas al interior de los Estados modernos. Es cierto, si se compara entre los países, las protestas difieren en sus objetivos declarados porque, mientras al ciudadano egipcio lo mueve la lucha por el ejercicio de libertades civiles, al griego lo anima exigir un rol más protagónico del Estado y al mexicano, un mayor respeto hacia los derechos humanos. Pero en lo sustantivo, en el corazón del asunto, todos los casos comparten el malestar común de una ciudadanía incómoda con la arquitectura política vigente e insatisfecha con el ideario que la inspira. Por este motivo, se moviliza y desborda el

espacio público, para infundir cambios que reconozcan la fuente originaria del poder, que, en último término, corresponde a los propios ciudadanos.

Así las cosas, no es atrevido afirmar que nuestra época enfrenta un ascendente déficit de *legitimidad* del modelo democrático representativo a partir de la disociación de intereses que existe entre gobernantes y gobernados¹². La clave es que, detrás de estas tensiones sociales, más que ciclos regulares de acción colectiva, se esconde una renovada búsqueda de mayor incidencia en los procesos de toma de decisión, donde la resolución sobre valores políticos responde más a la interacción de muchos que a la opinión de unos pocos. Dicho en simple, estamos frente a una ciudadanía con signos de evolución, que ha mudado su actitud hacia el poder político, pasando de un consentimiento pasivo a un activismo crítico, y que no duda en despojar de ropajes sacros a sus representantes para asegurar participación en las decisiones que la afectan.

Como todo organismo vivo, los cuerpos políticos requieren de ajustes ante los desafíos que acechan. Hoy, la democracia representativa se encuentra en la mira de distintos ciudadanos del mundo que alzan la voz para recuperar el poder de decisión que les pertenece. Ante tal diagnóstico, la revisión de las reglas del juego político —en concreto, la constitución— asoma como el proceso ineludible y necesario para relegitimar la narrativa democrática. Las lecciones de la historia son contundentes: los regímenes que se resisten y no se adaptan al devenir de los tiempos encuentran antes el camino de la ruina que el sinuoso sendero de la supervivencia.

ESTALLIDOS CONSTITUYENTES EN EL *FINIS TERRAE*

Históricamente, Chile ha tenido un alto nivel de sincronía con los acontecimientos globales. No importa que estemos ubicados en el fin del mundo, somos parte innegable de la política mundial. Esto posiciona a nuestras latitudes como un microescenario de los procesos desarrollados a nivel planetario¹³. Fue así cómo, en el contexto global de agitación callejera, Chile irrumpió como un actor más, encontrando en las marchas

estudiantiles de 2011 su rostro más visible y llamativo.

A pocos les cabe duda de que la movilización de ese año marcó un antes y un después en el desarrollo político del país. Y es que la masiva apropiación del espacio público como teatro de reclamación alteró las prácticas de una ciudadanía que, tras la caída de Pinochet, había optado por volcarse a la esfera privada en vez de empujar demandas de orden colectivo¹⁴. No fueron solo consignas estudiantiles, sino también ambientalistas, regionalistas y de derechos civiles. Fue tan potente su magnitud y frecuencia que el 2011 ha sido considerado como el año de mayor activismo social desde el retorno de la democracia¹⁵. Esta intensidad originó inevitablemente la atención de medios internacionales, que catalogaron el fenómeno como el “Invierno Chileno”¹⁶ y no dejaron de asimilarlo —en sus formas— con la “Primavera Árabe”¹⁷ y los indignados en Europa¹⁸.

El agitado panorama social provocó un aluvión de interpretaciones en académicos y analistas que intentaron dilucidar la naturaleza del problema. Mientras algunos, desde una trinchera más crítica, atribuyeron las protestas a un evidente signo de desmoronamiento del modelo económico¹⁹, otros las consideraron un proceso de empoderamiento de los ciudadanos, con aspiraciones hacia un régimen de lo público²⁰ y con énfasis en una democracia más activa y deliberativa²¹. Otras lecturas apreciaron los hechos como una rebelión contra el poder, focalizado en su forma de distribución y uso, por la cada vez más escasa legitimidad del sistema político²². Por último, también hubo relatos menos dramáticos, que relativizaron el malestar, atribuyéndolo a una condición histórica de los países en desarrollo²³ o bien a una exigencia ciudadana por una profundización del “modelo de desarrollo chileno” y ajustes a lo que ya existía²⁴.

Lo cierto es que, ese año, Chile cambió y las señales apuntaban a una nueva etapa política y social. Una que dejaba atrás la lógica de la transición a la democracia, excesivamente preocupada por las cifras económicas y la mejora en las condiciones materiales de existencia, por otra de valorización de la política, entendida como el interés por la deliberación de los asuntos comunes. Sin imposturas, el PNUD bautizó el actual devenir del país como “los tiempos de la politización”²⁵, al volver a estar en juego las definiciones básicas sobre lo que se puede decidir en

sociedad. Algunas cifras son reveladoras en el contenido de la acción colectiva: si, en 2009, las movilizaciones que demandaban transformaciones políticas correspondía a un 19%, esa cifra aumentó a un 45% el año 2012²⁶. Y, tan solo dos años después, el 71% de la ciudadanía mostraba su apoyo a una nueva Carta fundamental²⁷.

Pero atención, como todo proceso de mutación, estos tiempos también muestran señales confusas y que parecen arrojar por el suelo el diagnóstico de la politización. Hablamos de la altísima desconfianza hacia las instituciones tradicionales (gobierno, Congreso y partidos políticos, que casi bordean el margen de error) y la mezquina participación electoral (cada día votan menos y el padrón se envejece). ¿Estamos frente a una opinión pública que se contradice? No, la ambivalencia se evapora al comprender que somos testigos de una ciudadanía renovada, interesada en incidir en las decisiones que la afectan, pero en un marco normativo que trasciende los anquilosados dispositivos de dominación que rigen hasta hoy.

LA ENCRUCIJADA CONSTITUCIONAL EN CHILE

En la papeleta para la elección presidencial de 2013 hubo siete candidatos. De ellos, seis plantearon la necesidad de impulsar una nueva constitución para el país. Fue entonces cuando el espíritu constituyente, que soterradamente se incluía en las principales movilizaciones sociales, asumió la condición de promesa de campaña y relevó el debate en la esfera pública. El abrumador triunfo de Michelle Bachelet (2014-2018) aseguró el avance de este cambio, al incluirlo como uno de los ejes estructurales de su programa y al fijar un método de elaboración: un proceso “participativo, democrático e institucional”. Se dijo “participativo” porque buscaba estimular la intervención de todos los ciudadanos, a través de diálogos y cabildos constituyentes en comunas y regiones. “Democrático”, porque incluía horizontalmente la voz de los distintos actores políticos presentes en la sociedad. Y, finalmente, “institucional”, porque encauzaba legalmente el proceso de cambio, sin trampas ni atajos, al habilitar al próximo Congreso para decidir el mecanismo en que se iba a discutir la nueva Carta fundamental.

Sin embargo, para arribar a este escenario de proceso constituyente, hubo una escabrosa antesala que posibilitó el camino. Y es que la Constitución de Pinochet, desde que fue aprobada el 11 de septiembre de 1980, enfrentó sucesivas embestidas que buscaban revocarla, tanto por lo cuestionado de su origen²⁸ como por su acentuado contenido conservador²⁹. Las arremetidas fueron esfuerzos combinados de la ciudadanía y parte de la elite política, quienes apuntaron a restituir gradualmente el poder constituyente originario. La consigna era evidente: la constitución debía responder a lo decidido por el pueblo y no a la Junta Militar y sus asesores. Al menos, tres fueron los hitos significativos.

El primero ocurrió tras el plebiscito de 1988 y fue iniciativa de los partidos opositores al régimen militar. El triunfo del “No” había pulverizado los deseos presidenciales de Pinochet y resentido su proyección institucional. Fue entonces cuando la Concertación, victoriosa y con espalda electoral, movió las piezas para exigir reformas a la “protegida” estructura constitucional, que en su diseño tutelaba el poder a la alianza cívico-militar más allá de las mayorías circunstanciales³⁰. La apuesta resultaba clave para desatar los nudos más rígidos del modelo y entregar gobernabilidad a la naciente democracia³¹. A pesar de las desavenencias iniciales, oficialismo y oposición consensuaron 54 reformas que dieron el primer barniz democrático a la Carta al flexibilizar su procedimiento de modificación, asegurar el pluralismo político y moderar los estados de excepción. Los más críticos las consideraron insuficientes; otros, un avance en la medida de lo posible.

El segundo hito tuvo lugar en 2005 y provino desde la elite política tras intensas negociaciones entre el gobierno de Ricardo Lagos y la oposición agrupada en la Alianza. La llave para abrir esta reforma constitucional fue pragmatismo puro. Por un lado, la exasperación de la administración Lagos ante la vigencia de los enclaves autoritarios que eclipsaban las credenciales democráticas del país y, por el otro, la consciencia de la centro-derecha acerca de su progresiva pérdida de poder en el Congreso. La Constitución de 1980 había caído en su propia trampa pues, tras 16 años, los dispositivos de control se hacían ineficaces para concentrar la hegemonía del poder en la segunda mayoría electoral. Ante la evidencia de perder cada vez más escaños en el Congreso y el Tribunal Constitucional, la Alianza tuvo que rearticular las cuotas de

influencia que le quedaban. Hay que reconocerlo, fue astuta y se anticipó a la catástrofe electoral que se avecinaba. Accedió a 54 modificaciones (el mismo número que en 1989), cediendo a la eliminación de los cupos de parlamentarios designados, el fin de la inamovilidad de los jefes de las Fuerzas Armadas y la disminución de las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, exigió el aumento de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados (su último reducto político) a través de la creación de comisiones, interpelaciones y acusaciones constitucionales, y redujo un tercio el periodo del mandato presidencial. Fue un contrapeso de poder al Ejecutivo, que tampoco incomodó a la Concertación, sellando así el acuerdo más trascendente desde el retorno a la democracia en Chile³².

El tercer y último hito aconteció en 2011 y fue liderado por una ciudadanía que, como pocas veces en el pasado, se movilizó por miles para expresar su malestar a la autoridad por conflictos específicos a lo largo del país. Primero, fueron las protestas en la zona extrema de Magallanes; luego, la resistencia multirregional al proyecto HidroAysén; y, finalmente, la arremetida nacional de los estudiantes contra el sistema educativo. Al final, todas ellas confluían en un descontento hacia los modos del ejercicio del poder —y, por extensión, al modelo de desarrollo sostenido por los gobiernos de la Concertación—, exigiendo una revisión a la estructura del orden político vigente, la misma que la elite ya consideraba zanjada a partir de las modificaciones de 2005. Por eso, si bien en este tercer hito no se incorporaron reformas legales específicas, se instaló la masa crítica que puso en marcha la moción de llevar a cabo un cambio constitucional sustantivo. En este nuevo marco, irrumpieron iniciativas ciudadanas como “Marca tu voto AC”, abocada a promover una Asamblea Constituyente, o bien la “Bancada Transversal ac”, agrupación de congresistas de un amplio espectro político movidos por el mismo objetivo. También se cuenta el ambicioso proyecto digital del expresidente Lagos³³, orientado a recoger propuestas, incentivar la discusión constituyente y hacer pedagogía sobre la eventual nueva constitución. La ciudadanía, primero, y la clase política, después, se convencieron de empujar el carro del cambio constitucional.

En la actualidad, Chile se enfrenta a un proceso extrañamente único: alcanzar una Carta fundamental legítima en un marco democrático, sin el trauma de una guerra civil a cuestas (1833), el apremio del ruido de

sables (1925) o la retórica del miedo (1980)³⁴. Visto en perspectiva, un paso más en la consolidación institucional de la República. Lo que resta ahora por resolver son dos elementos centrales del proceso: el mecanismo que dará origen a la nueva constitución (comisión bicameral, convención de ciudadanos y legisladores, Asamblea Constituyente o plebiscito, entre los que escogerá el Congreso chileno elegido en los comicios de 2017) y el conjunto de principios dogmáticos (valores básicos, derechos y garantías) y orgánicos (forma jurídica del Estado, forma de gobierno) que nutrirán su contenido. En otras palabras, falta por definir *cómo* se impulsará el cambio y *qué* ideales configurarán el horizonte ideológico común. Las cartas ya están sobre la mesa de la política chilena.

SOBRE ESTE LIBRO

El triunfo de Bachelet abrió los fuegos. Si bien hubo aproximaciones previas, ese instante representó la incursión sin retorno del cambio constitucional, al diluirse la promesa electoral y transformarse en compromiso gubernamental. Hubo ruidos, quejas y alarmas, pero finalmente el proceso constituyente había zarpado. Desde entonces, la sociedad chilena alberga un genuino espacio de deliberación, de creciente amplitud, donde distintos agentes dialogan y hacen uso público de la razón en torno al tipo de sociedad que aspiran. Una especie de “esfera pública” habermasiana³⁵, que piensa y discute el ideario político más conveniente para el destino del país. El propio Michael Sandel, célebre filósofo estadounidense que estuvo de paso por Chile, testimonió una inspiradora “energía cívica”³⁶. Un vistazo a la agenda constituyente de los últimos dos años también lo confirma: múltiples seminarios organizados por universidades³⁷ y centros de estudios³⁸, propuestas elaboradas por partidos políticos³⁹, reportajes de prensa⁴⁰ innumerables columnas de opinión e, incluso, espacios televisivos sobre el tema⁴¹. Además se cuenta la activa producción de conocimiento, en soporte impreso y digital, de libros y artículos en revistas académicas.

En este fecundo contexto se inserta la presente obra. Su contribución, sin embargo, se plantea desde un enfoque diferente, uno

que sintoniza con *amplias preguntas y escasas respuestas* en torno a los fundamentos de la democracia y el poder constituyente. El objetivo de este libro es claro: exponer los principales debates contemporáneos y proporcionar las herramientas conceptuales y analíticas que permitan comprender las razones del cambio constitucional a la luz de los acontecimientos de Chile y el mundo. Mientras que otros trabajos concentran sus esfuerzos en el contenido más conveniente o en la búsqueda del mejor mecanismo, este lo hace indagando sobre los motivos que fundamentan una nueva constitución en una democracia posmoderna. O dicho de otro modo, unos libros responden al *qué* ⁴², otros al *cómo* ⁴³; en cambio, esta obra responde al *por qué* y *para qué* del cambio constitucional. Simultáneamente a estos propósitos, se busca acercar a los ciudadanos la lectura de discusiones políticas contingentes, contribuyendo así al cultivo de un pensamiento crítico frente a los fenómenos globales con alcance local.

Los trabajos que aquí se presentan son, en su gran mayoría, piezas inéditas en español⁴⁴ y su autoría corresponde a académicos de reconocida trayectoria en la teoría política y el derecho constitucional, provenientes de distintas universidades del mundo y con enfoques disciplinarios múltiples, como la sociología, la ciencia política, el derecho y la filosofía.

En cuanto a la audiencia del libro, dado que el texto recoge la experiencia constituyente mundial y nacional, su contenido no discrimina fronteras y logra empatizar con todos los interesados en profundizar intelectualmente los modos posibles de organización política en una época de cambios. Para el caso de Chile, el público objetivo corresponde a los actores que participan en el debate por una nueva Carta para el país, como son las autoridades de gobierno, legisladores, juristas, asesores constitucionales, profesores y estudiantes universitarios de las ciencias sociales, jurídicas y humanidades. También, los distintos agentes ciudadanos que conforman las instancias operativas del llamado “proceso constituyente” (observadores, monitores, delegados y participantes, entre otros). En definitiva, esta obra está destinada a todos los involucrados a incidir en el trazado de la nueva sociedad que, como ciudadanos, aspiramos a construir.

PRIMERA PARTE
APROXIMACIONES CONCEPTUALES
AL PODER CONSTITUYENTE

I. PODER CONSTITUYENTE: UNA BREVE HISTORIA CONCEPTUAL

Andreas Kalyvas

Εἰ δὴ τις ἐξ'αρχῆς τὰ πράγματα φυόμενα βλέπειν, ὥσπερ
ἐν τοῖς ἄλλοις καὶ ἐν τούτοις κάλλιστ' ἂν θεωρήσειεν¹.

ARISTÓTELES

EL PODER constituyente es la verdad de la democracia moderna. Esto, por dos razones centrales: una histórica y otra analítica. En primer lugar, el nacimiento de la doctrina moderna de la soberanía popular coincide con la aparición conceptual del poder constituyente. Ambos son cooriginales y coetáneos². La supremacía política de la multitud por sobre príncipes, reyes, emperadores y papas fue formulada, inicialmente, en términos del poder originario de una comunidad para determinar las formas políticas de su existencia colectiva. Es durante el volátil periodo entre la baja Edad Media y la Modernidad temprana en que la multitud fue identificada como el sujeto constituyente soberano y, respectivamente, la democracia fue reimaginada como la política de las fundaciones populares. Así, desde un punto de vista histórico, el poder constituyente y la democracia moderna se encuentran intrínsecamente asociados, desde sus orígenes, en el idioma de la soberanía popular. En segundo lugar, existe una profunda y sistemática analogía conceptual entre poder constituyente y democracia en cuanto que ambos describen actos colectivos de autolegislación y eventos públicos de autoalteración. A partir de esta afinidad electiva, la política democrática constituyente evoca el principio de libertad como autonomía política, en la cual los miembros de una colectividad constituyen deliberadamente las formas políticas de autoridad con el fin de organizar e institucionalizar su vida común³. Los destinatarios de la ley se convierten en sus autores. Por tanto, formular la

soberanía popular como poder constituyente es afirmar el valor democrático y básico del autogobierno.

Esta mutua articulación histórica y analítica del poder constituyente y la democracia debe ser enfatizada. La soberanía, como el poder de constituir, es poco reconocida en los discursos democráticos contemporáneos, careciendo de un lugar en nuestro vocabulario político. A menudo, se la considera elusiva e indeterminada, apenas un concepto, rayando en lo ideológico, ya sea un simple hecho o una ficción metafísica, y, por tanto, poseedora de un bajo interés teórico y significancia política⁴. “El problema capital del derecho público”, según Carré de Malberg, es tratado desde entonces como una anomalía legal, una irregularidad perturbadora y una amenaza política⁵.

De hecho, sobre la larga historia del pensamiento político occidental moderno, la soberanía como poder constituyente fue sistemáticamente eclipsada por la doctrina de la soberanía en competencia, entendida como “el más alto poder de comando”, la que fue orgullosamente enunciada en 1576 por Jean Bodin en su célebre tratado⁶. Su nueva definición absolutista y unitaria se esparció rápidamente a través de varios discursos políticos y jurídicos, y apareció en diversos contextos históricos y destacados sistemas teóricos de variados pensadores canónicos. Thomas Hobbes convino que el “poder soberano” es “este derecho a dar órdenes”⁷, una visión propagada por Samuel Pufendorf y, desde Jeremy Bentham y John Austin hasta Max Weber, adoptada incluso por Baruch Spinoza quien, como tantos otros, mientras discutía la democracia absoluta, formuló la pregunta por la soberanía a la luz de quién “tiene el derecho soberano de imponer toda orden que le plazca”⁸. Este paradigma de la soberanía, que atraviesa, aunque de modos distintos, tanto la jurisprudencia natural como el positivismo legal, identifica al soberano como aquel que comanda sin estar sujeto al comando de otro, eso es, de un superior⁹. La soberanía de Bodin es la de un “comandante incomandado”¹⁰. La relación política esencial es vertical, entre “él, quien comanda” y “él, quien debe obediencia”, es decir, entre soberanos y sujetos, entre gobernantes y gobernados¹¹. Este poder de comandar es absoluto, inalienable y perpetuo, fundado en el derecho divino; permanece subordinado a este derecho y al natural, y es jerárquico, unitario y personificado, habitualmente identificado con prerrogativas

ejecutivas. Internamente, no puede ser dividido o compartido; externamente, no debería ser superado o degradado.

La teoría de la soberanía de Bodin se convirtió en paradigma de la modernidad política, una propiedad esencial de la comprensión moderna del Estado, su autoridad y unidad¹². De hecho, él propuso una teoría de la soberanía del Estado, y, al hacerlo, sentó las bases, al cierre del siglo XVI, de lo que vendría a ser la teoría ejemplar en el pensamiento político y legal occidental. El discurso de la soberanía de Bodin también fue influyente en la formación del derecho internacional y el sistema europeo interestatal. La institución del Estado es soberana sobre su propio territorio y posee jurisdicción absoluta sobre sus sujetos¹³. La codificación del principio de no intervención por un Estado en los asuntos de otro, generado en la Paz de Westfalia (1648), introdujo el reconocimiento mutuo entre Estados soberanos y consagró el poder de comandar como la norma organizadora del derecho y la política internacional. La definición de Bodin es la primera declaración autoritativa de la teoría moderna de la soberanía del Estado, de acuerdo a la cual dentro de cada comunidad política que ha sido delineada hay una autoridad política suprema, un poder de comando determinado, absoluto y último, que no está sujeto, en modo alguno, al comando de otro¹⁴.

Cuando toca dar cuenta del advenimiento de la democracia moderna, el paradigma del comando tiende a explicarla en términos de una transferencia de soberanía del rey al pueblo, desde el uno hasta los muchos¹⁵. La inauguración moderna de la democracia como soberanía popular da cuenta de un traspaso del comando desde un portador hasta el otro, en donde el gobierno personal es transformado en uno colectivo. En este traspaso, la soberanía democrática invierte el paradigma monárquico: el pueblo se apropia del poder del rey, poniendo de cabeza las fuentes de autoridad política. La democracia es retratada como posmonárquica, en cuanto que la abolición de la realeza no elimina necesariamente el discurso absolutista de la soberanía como comando, sino que reemplaza a un comandante supremo por otro. La soberanía cambia de manos, pero esencialmente permanece igual¹⁶. De esta manera, el discurso del comando no solo trata las normas constitucionales como constricciones externas, sino que también tiende a reducir la democracia moderna a la forma del Estado. La doctrina del Estado-nación es, también, una historia sobre la democratización gradual

del absolutismo de la soberanía monárquica.

La teoría de la soberanía de Bodin dominó con éxito la teoría política moderna y su práctica, dando forma a las comprensiones prevalecientes de la democracia. Su compromiso con la primacía del comando coercitivo sugiere una concepción estatista y estática de la soberanía, que consiste en una fuerza represiva, proveniente desde arriba, jerárquica y unitaria, sostenida por una administración centralizada y que requiere de *checks and balances* externos. Michel Foucault describió este modelo jurídico de soberanía como “anti-energía [...] un poder que solo posee la fuerza de lo negativo a su lado, un poder para decir no; que no está en condición de producir, que solo es capaz de establecer límites”¹⁷.

La historia conceptual del poder constituyente habla directamente en contra de esta gran narrativa de comando y sometimiento¹⁸. Ilumina dimensiones importantes, aunque negadas, de la experiencia democrática y revela otro entendimiento de soberanía. Puesto negativamente, el moderno advenimiento de la democracia no puede y no debería ser tratado como una mera transferencia de soberanía desde el rey al pueblo, como un despliegue inmanente dentro de la ininterrumpida continuidad del paradigma estatista del comando supremo. En términos positivos, democracia como poder constituyente devela una idea distinta de soberanía, no solo históricamente anterior, sino también analíticamente distinta del paradigma real, opuesta y antagonista a este: el poder del pueblo de constituir. Así, la modernidad política puede verse conformada por dos formas de poder soberano y dos visiones de lo político: el democrático y el monárquico, el constitucional y el absolutista, el federalista y el estatista, el poder de los muchos para constituir versus el poder de uno de comandar.

En lo que sigue, intento recuperar esta teoría alternativa de la soberanía como poder constituyente, la cual se aparta significativamente del paradigma canónico de comando, con el fin de investigar sus implicancias democráticas. En la primera sección, trazo los orígenes conceptuales del concepto, desde los significados etimológicos del verbo latino ‘constituir’ hasta su articulación medieval inicial establecida en contra del modelo monárquico. Las secciones dos y tres revisitan episodios formativos en la historia conceptual del poder constituyente y consideran sus diversas, pero sobrepuestas, trayectorias teóricas y políticas, en cuanto que se concentran en torno a las ideas de

desobediencia, resistencia y revolución. La última parte intenta reconstruir las reglas discursivas y los principios inmanentes que organizan sobre el tiempo la inteligibilidad del concepto, y toma en cuenta los retos que estos ponen a los (mal)entendimientos de la democracia.

1. INICIOS

El verbo ‘constituir’ proviene de la palabra latina ‘*constituere*’, la cual es una combinación del prefijo *con-* y el verbo ‘*statuere*’. El prefijo *con-* tiene varios significados gramaticales, siendo el más importante de estos “con” o “juntos”. El verbo ‘*statuere*’, por su parte, proviene de ‘*staíño*’, que significa “causar”, “colocar”, “establecer”, “construir”, “ubicar”, “erigir”, “establecer” o “crear”¹⁹. La palabra ‘*constituere*’, por tanto, da cuenta literalmente del acto de fundar juntos, de crear en forma conjunta o de coestablecer²⁰.

En la antigua Roma, el verbo ‘*constituere*’ era usado para indicar en el vocabulario económico de relaciones de intercambio un acuerdo con otro respecto de algo, un pacto entre una pluralidad de individuos. Más aún, en el derecho público romano, se nombraba a un tipo específico de práctica legislativa que era considerada superior a la legislación ordinaria, esto es, a actos extraordinarios que establecían o alteraban las leyes fundamentales e instituciones de la República²¹. Por ejemplo, en la forma jurídica del *rei publicae constituendae*, se daba cuenta del poder para iniciar cambios legales radicales²². La oficina del dictador, el *decemvir*, los triunviratos y otras comisiones, regulares y especiales, eran tratados como instituciones con poder constituyente. Sin embargo, debido a que una autoridad más alta autorizaba sus poderes a través de una comisión especial, estas magistraturas no se consideraban soberanas. De igual forma, el título de *cónstitutor* significaba “quien establece”, “aquel que ordena”, “el fundador que ejerce el poder” y “la autoridad para reformar y transformar”²³. Después del colapso de la república, el poder para constituir fue tomado por el emperador romano y pasó a describir sus decisiones judiciales, sus grados ejecutivos y sus promulgaciones (*constitutio*)²⁴.

A estos primeros significados etimológicos y sus diversas

aplicaciones económicas, políticas y legales le siguen ciertas conclusiones preliminares. La primera remite al origen del término 'constituir', el cual emerge con anterioridad y fuera de la teología del imaginario judeocristiano. Profundamente arraigada en el mundo político y jurídico de Roma, formalizada en variados códigos legales y magistraturas oficiales, enredada en las guerras sociales entre patricios y plebeyos, y fuertemente ligada a la suerte de la República, el término —y sus usos— tuvo fuertes connotaciones mundanas, adjuntas a valores cívicos y cercanas a las artes productivas y artísticas. Adicionalmente, sugiere las inescapables presuposiciones de una práctica colectiva. Es la práctica de una pluralidad de actores, quienes públicamente se relacionan unos con otros, asociándose y actuando concertadamente, para erigir y establecer algo juntos mutuamente, para fundar algo en conjunto. Finalmente, el término está asociado históricamente con episodios transformadores y críticos en la historia de la república romana. Así, 'constituir' también da cuenta de los actos extraordinarios de fundar y refundar, eventos discontinuos que transformaron la constitución de la ciudad al alterar las normas, reglas e instituciones que determinaban el espacio de la política normal.

Durante la alta Edad Media, los usos políticos del término 'constituir' prácticamente desaparecieron, perdiendo su antiguo significado legal y político para volverse puramente descriptivo, reducido, literalmente, a la facultad de hacer o construir. Fue también invocado por variados discursos médicos para describir el ordenamiento anatómico de un ser vivo, su cuerpo físico y constitución material²⁵. Pero reaparece en el vocabulario político de la baja Edad Media, dotado de un nuevo significado: el acto de designar. Desde el siglo x en adelante, *constituir* significa designar un oficial, dotar a una persona de ciertos poderes específicos, atribuir funciones públicas, concretas y particulares, a un individuo, elegir a alguien para una oficina; en corto: autorizar. Es dentro de esta armazón conceptual del uso medieval donde el concepto de poder constituyente fue inicialmente incubado y formado. Dos importantes innovaciones fueron, no obstante, necesarias para hacer posible esta nueva formación conceptual, ambas llevadas a cabo a principios del siglo xiv por Marsilio de Padua. Su contribución estableció los fundamentos de una nueva concepción de soberanía y abrió el camino para la reinvención moderna de la democracia²⁶.

La primera innovación de Marsilio remite al poder de designación y elección. Su reconocido y controversial texto, *Defensor pacis*, fue completado en 1324, durante el turbulento conflicto entre Luis iv, el Santo, y el papa Juan xxii. Marsilio lo planteó como una intervención política concreta en un momento de crisis severa y también como una justificación a su inequívoca decisión de ponerse del lado del emperador en contra del papa y, así, defender la autoridad secular en contra de la espiritual²⁷. La disputa entre ambos sobre el *locus* último de la soberanía produjo un quiebre temporal de legitimidad y creó una fisura desde dentro de la cual la soberanía popular, finalmente, apareció. Marsilio destacó el hecho de que ninguno de los dos podría ser soberano, dado que ambos carecían del poder último para nombrar, ya sea a sí mismo o al otro. Ni el emperador ni el papa podrían resolver esta disputa. En esta situación extrema, proponía Marsilio, siempre existe una autoridad final que decide en la materia. Es la multitud, afirmaba, la que posee el derecho de nombrar a sus gobernantes seculares y espirituales, es decir, autorizarles a gobernar. En el espacio que separa a las dos soberanías instituidas, en el vacío abierto por su conflicto por la supremacía entre lo secular y lo espiritual, un nuevo sujeto político hacía así su aparición: la multitud, con su derecho supremo de nombrar a sus emperadores y sus papas.

Marsilio atribuyó el poder de nombramiento a la multitud, antes que a autoridades constituidas, magistraturas o personas. Articuló este poder en términos de un derecho colectivo que empoderaba al gobernado para nombrar a sus líderes. El gobernado nombraba a sus gobernantes, los sujetos elegían a sus líderes y la multitud establecía a sus reyes. Además de los elementos de consentimiento y contrato que sus argumentos invocaban, la intervención de Marsilio tuvo consecuencias de más largo alcance en cuanto que cuestionaba directamente las bases normativas del edificio político medieval. Aunque los juristas, canonistas, glosadores y teólogos que lo antecedieron ya habían tocado este punto, especialmente desde la crisis causada por la Controversia de la Investidura, Marsilio fue el primero en proclamar explícitamente y presentar sistemáticamente los principios centrales de una nueva teoría de la soberanía (popular)²⁸:

El poder eficiente para *establecer* o elegir al gobernante pertenece al legislador o a todo el cuerpo de ciudadanos [...]. Y al legislador pertenece, de modo similar, el poder de hacer

cualquier corrección del gobernante e incluso deponerlo si esto es conveniente al beneficio común. Por lo que esta es una de las más importantes materias en el sistema de gobierno; y tales materias incumben a la completa multitud de ciudadanos [...]²⁹.

La segunda novedad de Marsilio marca otra contribución: reconoció a la multitud, no solo como un sujeto real y verdadero, con la autoridad suprema de nombrar a sus gobernantes, sino que extendió también su ámbito hasta incluir la formación del gobierno, el establecimiento de sus leyes fundamentales y la creación de las oficinas públicas. Por ello, afirmaba que “pertenece al legislador [por ejemplo, la multitud] corregir a los gobiernos o *cambiarlos* completamente, así como *establecerlos*”³⁰. De hecho, Marsilio transforma el acto de nombramiento en un acto de fundación, introduciendo así la idea de soberanía en términos de una multitud productiva, “una causalidad universal activa” que “forma”, “establece” y “diferencia” a las partes del Estado³¹. Define a este poder soberano, que reside “en el cuerpo completo de ciudadanos o de sus partes más pesadas”, como un originario y productivo “poder de generar” (*generare formam*) nuevas formas legales e instituciones políticas:

Desde que, por tanto, pertenece a todo el cuerpo de los ciudadanos el generar la forma, esto es, la ley de acuerdo a la cual todos los actos civiles deben ser regulados, será visto que pertenece al mismo cuerpo total el determinar la materia de esta forma, es decir, al gobernador, cuya función es ordenar, de acuerdo a esta forma, los actos civiles del hombre [...]. Por lo que a quien sea que le toque *generar* alguna forma, también le toca *determinar* el sujeto de esta forma³².

Esta singular formulación del poder soberano de la multitud como “forma de dar” sugiere una fuerza extrainstitucional, la cual institucionaliza la autoridad política, determina la forma del gobierno y establece un orden constituido y justo. Vale la pena observar aquí que la teoría de la soberanía popular de Marsilio arranca desde la ideología teológica de la Edad Media. En vez de depender de la lógica de transcendencia y el modelo de una figura divina demiúrgica como poder ordenador externo, se vuelve hacia las antiguas tradiciones materialistas con una fuerte orientación biológica³³. Combinando creativamente el texto de Aristóteles *Obra biológica (De partibus animalium)* y el tratado

de Galeno *Sobre la formación del feto (De formatione foetus)*, Marsilio describió el poder de constituir en términos de una natalidad física y comparó el acto soberano creativo con el nacimiento animal³⁴. La constitución política de una comunidad es similar, “de modo análogo”, a la constitución orgánica del animal³⁵. La acción soberana, argumentaba, “al establecer apropiadamente al Estado y sus partes, ha sido proporcionada, por lo tanto, a la acción de la naturaleza en la formación de la perfección del animal”³⁶. Su incipiente teoría del poder, constituyente de la multitud, es informada así por un materialismo físico-biológico y fundada sobre un razonamiento naturalista, vaciado de todo trascendentalismo, desplazando satisfactoriamente la metáfora Paulina, teológica y mística, del cuerpo político sagrado. En un gesto audaz, describe la institución de la comunidad política en términos de la anatomía animal y el deseo físico, iniciando así la más ambiciosa desacralización y desteologización de lo político en el contexto de la filosofía medieval³⁷. A través de la metáfora del animal, el cuerpo político expresa su inmanencia al mundo material y mortal de los seres humanos y sus relaciones. Con Marsilio, el moderno advenimiento de la democracia proviene desde una teoría de la política profana y antirreligiosa, y es llevada a cabo por medio de un método materialista.

Con estas dos innovaciones centrales, Marsilio introdujo la idea general del poder constituyente como soberanía popular. Es importante, por tanto, clarificar estos nuevos elementos que permanecen presentes en las subsecuentes trayectorias políticas del concepto.

La originalidad de Marsilio descansa, en primer lugar, en la apropiación de la antigua figura del legislador, en orden a retrabajarla, no en la dirección de un mítico “proveedor de leyes” (*lawgiver*) y fundador de ciudades, sino que en el sentido de una comunidad actual: “la multitud de los necesitados”, “la multitud reunida”³⁸. El “legislador primario” es una “autoridad primaria”, y la multitud es siempre el legislador por lo que tiene el poder supremo de establecer y abolir sus gobiernos y deponer a sus gobernantes³⁹. En consecuencia, las leyes derivan su autoridad del legislador, es decir, de la multitud. Con esta síntesis, Marsilio reúne al legislador, al soberano y a la multitud en la nueva forma de un poder colectivo de los muchos para constituir su mundo político. Los muchos, el pobre y el *vulgus* son nombres intercambiables, usados para describir al soberano como un fundador colectivo que puede decidir la forma política

de su existencia común, ya sea en una asamblea primaria de todos a través del gobierno de la mayoría o a través de sus representantes electos⁴⁰.

Más aún, al utilizar tanto la facultad de constituir como de incluir al poder para formar y establecer gobiernos, Marsilio sugirió una distinción crucial, diferenciando entre dos actos separados: el acto de hacer leyes y el acto que establece a un gobierno. El último da cuenta de un momento fundacional, temporal y ontológicamente anterior a cualquier gobierno. Es la fuente de la autoridad, la legitimidad de las leyes ordinarias, y del juez final. La distinción entre el legislador y el gobierno apunta a un concepto binario de poder diferenciado, dividido entre la *universitas civium* de la multitud y la *pars principans* del gobierno. Es, de esta forma, que Marsilio anticipa la distinción clave entre una comunidad constituyente y la mancomunidad constituida, la cual se volverá central en ulteriores doctrinas del constitucionalismo moderno como *pouvoir constituant/pouvoir constitué*⁴¹

Además, Marsilio afirma la superioridad de aquellos que participan en el establecimiento de un gobierno sobre aquellos que gobiernan, legislan y comandan dentro de un marco institucional dado⁴². El acto de establecer/ formar es superior al acto de comandar. Una razón importante es que la vida común de la multitud no emana desde, o depende de, los gobernantes o el gobierno. Es una vida compartida que avanza de modo inmanente y autosuficiente desde los muchos, es decir, de modo autónomo a la forma del Estado. Existe así una dimensión de externalidad de la multitud en relación a sus instituciones, en cuanto que es reconocida como un sujeto político que puede existir fuera de la ley positiva. Mientras los muchos pueden existir fuera del Estado, el Estado no puede vivir apartado de ellos. Adicionalmente, gobernar depende de, y es inferior a, constituir porque, como lo planteó Marsilio, al desplegar categorías aristotélicas de causalidad, el primero se subordina al último del mismo modo que una causa es siempre anterior y superior a los efectos que genera. Además, la supremacía de los muchos sobre los pocos es sostenida por la lógica de que “cada todo [...] es mayor en masa y virtud que cualquier parte de sí tomada separadamente”⁴³. Finalmente, también hace resonar a Aristóteles cuando propone que la multitud es también superior en términos de su sabiduría, mejor a cualquier parte tomada separadamente⁴⁴. En esta elaborada defensa del principio de la

soberanía popular, los muchos son tratados como supremos porque ellos anteceden a todas las autoridades constituidas, autosuficientes, capaces de virtud y sabiduría, y, por esta razón, los autores de sus formas políticas. Marsilio es el primer autor en definir la soberanía popular en términos del poder de la multitud para constituir.

Hay una última palabra que decir respecto del presunto origen teológico del poder constituyente, poderosamente capturado por la influyente afirmación de Carl Schmitt de que es simplemente otro concepto teológico devenido en secular en la moderna teoría del Estado⁴⁵. La incipiente invención de Marsilio de la soberanía democrática desafía a esta narrativa político-teológica, y se separa de nociones metafísicas y trascendentes del poder y la política. Su intervención sitúa a los inicios de la democracia moderna separados del imaginario religioso judeocristiano monoteísta. Su teoría de la soberanía popular opera estrictamente en el plano de la inmanencia. Es una afirmación de los poderes de este mundo, la que prescinde de causación externa. Marsilio entendió la política constituyente como “aquellos métodos para establecer gobiernos que son afectados por la voluntad humana”⁴⁶. La existencia de un gobierno no está divinamente ordenado ni tampoco descansa en ideas de pecado y transgresión bíblica; más bien, emana materialmente desde la actividad social actual de la multitud que desea una vida libre, pacífica y suficiente⁴⁷.

2. ACTOS SOBERANOS DE RESISTENCIA

Dos siglos y medio después del “descubrimiento” del poder constituyente de Marsilio, en un tiempo de otro intenso conflicto, justo en las repercusiones de la Matanza de San Bartolomé, varios escritores hugonotes franceses, conocidos como los monarcómacos (“aquellos que combaten reyes”), renovaron este discurso democrático de la soberanía popular intentando defender su radical doctrina del tiranicidio⁴⁸. Al radicalizar aspectos de la filosofía de Marsilio, aunaron la resistencia activa y el poder constituyente para promover sus doctrinas de la soberanía y, finalmente, establecer los fundamentos para posteriores teorías de la rebelión, la revuelta, la insurrección, y la revolución⁴⁹. Con los monarcómacos, el poder constituyente se vuelve revolucionario. La resistencia activa, incluso la violencia, son tratadas como legítimas

fuerzas extralegales del cambio político, legítimamente ejercidas por el pueblo o sus representantes en casos excepcionales de necesidad y autodefensa. Basándose en la sugerencia de Marsilio de que la multitud puede deponer a los gobernantes injustos y suspender la ley en tiempos de crisis, los monarcómacos fueron más allá, explorando efectos rebeldes y sediciosos de la política constituyente y repensando la naturaleza conflictiva y revolucionaria de la soberanía popular.

De hecho, ese repensar anticipa el derecho de la revolución democrática. El derecho de un pueblo a desobedecer, resistir, deponer o matar a sus (tiránicos) gobernantes deriva de su poder soberano de determinar las formas políticas de su vida común⁵⁰. La resistencia contra un gobierno tirano es una manifestación de la política constituyente y una afirmación de la soberanía popular⁵¹. Los monarcómacos, de hecho, presentaron una nueva justificación basada en la lógica democrática de que “aquellos que *constituyen* una Forma, habrían de *derogarla*”. Esto es, sobre el principio de la soberanía popular, de acuerdo al cual el pueblo, en la forma del poder constituyente, es anterior y superior a las formas que constituye, incluyendo a los reyes⁵². Este derecho colectivo que compele al legado monárquico descansa en el poder de constituir de los muchos. Ofrece validez normativa y política al recurso excepcional de legitimar la resistencia de parte del pueblo. Para los monarcómacos es la soberanía del pueblo la que decide en la situación extrema del tiranicidio. De esta forma, ellos pueden ser justamente reconocidos por inventar la primera teoría democrática moderna de la resistencia.

El énfasis en el exceso revolucionario del poder constituyente conlleva un doble significado. Por un lado, revela la existencia condicional y autorizada de todos los poderes constituidos, y, por lo tanto, pone límites al deber de obediencia de los sujetos, lo que es una obligación condicional que depende del desempeño del gobernante⁵³. Las formas políticas son desnaturalizadas al punto de que son consideradas como creaciones humanas históricas, el resultado de la acción colectiva, reversibles y revocables, sujetas a ser modificadas, transformadas y/o reemplazadas. Por otro lado, da fundamentos a un chequeo extraconstitucional en las autoridades constituidas, un dispositivo justo para mantener el reinado de la ley y limitar los peligros de la arbitrariedad y la tiranía. Así, los gobernantes están sujetos a limitaciones y restricciones establecidas por los muchos en su capacidad

constituyente. Los primeros trazos del constitucionalismo moderno ya son visibles en este sedicioso intento de determinar los límites del poder y de establecer las salvaguardas políticas en contra de la transgresión del orden constituido. Aquí, la noción de un gobierno limitado y regido por la ley aparece al interior de la doctrina democrática de la resistencia activa, es decir, es intrínseco al poder de constituir⁵⁴.

En 1573, François Hotman afirmó “que el pueblo se reserva para sí todo el poder, no solo de *crear*, sino que también de *abdicar* a sus reyes”⁵⁵. Un año después, el protestante francés Théodore de Beze proclamó el primer principio de esta nueva doctrina de una resistencia (violenta) legítima: “ellos, quienes tienen el poder para crear a un rey, tienen el poder de *deponerlo*”, como también tienen “el poder de *juzgarlo*”⁵⁶. Este poder supremo de juzgar y derrocar gobernantes pertenece solamente al pueblo porque “las gentes no provienen de sus gobernantes [...] y, en consecuencia, las gentes no son creadas por sus gobernantes, sino que más bien los gobernantes por sus gentes”⁵⁷. Políticamente hablando, el pueblo está por sobre los monarcas⁵⁸. El derecho a desobedecer y resistir que poseen los muchos proviene de la primacía del sujeto constituyente por sobre el orden constituido. Porque el pueblo constituye a sus gobernantes, es quien tiene el derecho a resistirlos y deponerlos. De acuerdo a Beze, un pueblo no puede desobedecer y rebelarse en contra de un gobernante injusto si no lo han constituido en primer lugar. Es el poder de constituir el que confiere al pueblo el derecho soberano a resistir⁵⁹. Su principio es inequívoco: solo aquellos que constituyen tienen el derecho a desobedecer.

Cinco años más tarde, en *Vindiciae contra tyrannos*, Junio Bruto (El Celta) apeló al mismo principio al acentuar los elementos de autodeterminación y de externalidad en la soberanía popular⁶⁰. Siguiendo a Marsilio y Beze, afirmó sucintamente que “un pueblo puede existir por sí mismo, y es previo al rey en el tiempo”⁶¹. Su existencia colectiva es superior y no dependiente del Estado, porque ellos más bien dan antes que recibir⁶². De hecho, la vida del pueblo procede inmanentemente desde ellos mismos en cuanto que son capaces de vivir aparte del Estado. Al reconocer la externalidad política del pueblo respecto de las formas instituidas de gobierno, Bruto develó su autonomía, su vida extrainstitucional en la forma de la soberanía del

“*populus constituents*”⁶³, llegando a la conclusión de que:

En cuanto los reyes son *constituidos* por el pueblo, se parece seguir definitivamente que el pueblo es más fuerte que el rey. Por ello, la fuerza de la palabra: uno que es *constituido* por otro es tenido como menos, y aquel que recibe su autoridad desde otro es inferior a quien lo nombra⁶⁴.

Al igual que otros monarcómacos, Bruto trata el derecho de remover y deponer cualquier autoridad constituida, e incluso de matar a gobernantes injustos, como derivados que emanan del poder soberano del pueblo de constituir. Él también anticipó la idea de la convención constitucional, cuando reconoce la “*proviso*” excepcional, de acuerdo a la cual las reglas y procedimientos establecidos del orden normal son suspendidos, porque “la necesidad debiera alzarse, ya sea todo el pueblo, o tal vez una especie de epítome de todo el pueblo, la que sería convocada en una asamblea extraordinaria”⁶⁵. En el mismo año, George Buchanan propuso una justificación democrática del acto fundacional en su vindicación del derecho a resistir: “se debiera tomar una decisión en común en materias que afectan el bien común de todos”⁶⁶. De igual forma, el jurista calvinista Johannes Althusius, basándose en las doctrinas de los monarcómacos, dio cuenta del mismo principio de la soberanía popular como poder constituyente, proveyendo la más clara formulación hasta el momento⁶⁷. En *Politica*, publicado en 1603, defendió la resistencia activa sobre la base de que:

No se puede negar que el más alto es aquel que *constituye* al otro, y es inmortal en su fundación, y ese es el pueblo [...]. Por naturaleza y circunstancia, el pueblo es anterior a, más importante que, y superior a sus gobernantes, tal como cada *cuerpo constituyente* es anterior y superior a aquello que es *constituido* por él⁶⁸.

Para Althusius “el derecho de soberanía [...] no pertenece a miembros individuales, sino que a todos los miembros unidos y al entero cuerpo asociado del reino”⁶⁹. Entonces, el poder soberano, cuando es adecuadamente entendido como el poder de constituir, no puede ser concebido residiendo en cualquier individuo o grupo de individuos menos que todo el pueblo. Más aún, como un poder que funda/ basa a un

orden político y constitucional, este permanece irreducible y heterogéneo a tal orden. Es este derecho soberano colectivo el que justifica la remoción, deposición y derrocamiento por el pueblo de las autoridades constituidas cuando estas se vuelven injustas y tiránicas⁷⁰. El ejercicio del derecho de resistencia solo pertenece al pueblo en su capacidad soberana bajo la forma de poder constituyente. Althusius, tal como los monarcómacos, formuló una teoría democrática de la resistencia basada en la primacía del poder soberano de los muchos de constituir, es decir, de su poder de asociación autónomo “con el propósito de establecer, cultivar y conservar la vida social entre ellos”⁷¹.

3. REVOLUCIONES

Para la época de la Guerra Civil inglesa (1642-1651) y de la Revolución Gloriosa (1688), los atributos conceptuales básicos de la doctrina del poder constituyente fueron establecidos y desplegados durante los acalorados debates entre realistas, niveladores (*Levellers*) y parlamentaristas⁷². Fue durante este crítico periodo que el concepto se volvió ampliamente difundido, acentuado y adaptado a situaciones políticas muy concretas y tensas. La doctrina de la soberanía popular como el poder del pueblo de constituir era políticamente afirmada y ampliamente diseminada en numerosos panfletos revolucionarios, y teóricamente mejorada en los escritos de George Lawson, Algernon Sidney y John Locke⁷³. Emergió en la escena política ejerciendo una influencia tangible sobre las estructuras de la autoridad política y del desarrollo normativo del constitucionalismo moderno como el “poder de constituir”, es decir, el poder soberano de “abolir, alterar, reformar formas de gobierno [...] [y] de formar un Estado, donde no hay nadie, y si, posteriormente a una forma alguna vez introducida, el orden no es bueno, alterarla”⁷⁴. Desde esa época en más, la distinción entre poder constituyente y legislativo (constituido) alcanza su posición central e indispensable en el pensamiento constitucional, sentando las bases para la superioridad del derecho constitucional por sobre la legislación ordinaria. Mientras que, por un lado, el poder delegado para legislar es condicionalmente ejercido por una asamblea representativa que ha sido electa dentro de límites establecidos, por el otro, el poder de constituir, es

decir, de formar, alterar o disolver el gobierno, es absoluto, conferido a toda la comunidad y al pueblo que actúa fuera del parlamento. Como lo planteó un autor anónimo algunos años antes, estaba “más allá del poder de los *constituidos*, y solo en los *constituyentes*, el hacer tal alteración en la constitución fundamental”⁷⁵. De esta distinción, emergió la idea de una convención temporal y extraordinaria, un dispositivo político para la expresión institucional de la soberanía popular, establecido en contra de la supremacía parlamentaria. Lawson fue el primero en desarrollar una teoría sistemática de la Asamblea Constituyente, empoderada por mandatos especiales y temporales para “modelar un Estado” porque, como él estableció, “lo que podría ser hecho en casos extraordinarios es una cosa, lo que podría ser hecho de forma ordinaria, otra”⁷⁶.

De igual modo, Locke argumentó que por debajo y anterior a la “mancomunidad *constituida*” existe un poder extralegal más alto, investido en la comunidad original autoorganizada o sociedad civil, que se sitúa entre el Estado natural y político, “la cual *comienza*, y de hecho, *constituye cualquier sociedad política*”⁷⁷. Sorprendentemente, fue Hobbes quien ya, en 1642, había reconocido explícitamente que todos los fundamentos deliberados son democráticos en naturaleza, independientemente de las formas políticas que levanten, porque ellos provienen del poder constituyente del pueblo. La democracia yace debajo de todas las formas de régimen. Él plantea que existe un modo de inicio político que “se origina en la *determinación y decisión (a consilio & constitutione)* de las partes que se unen, y eso es el *origen por diseño (origo ex instituto)*”⁷⁸. Y cuando esto ocurre, y “los hombres se han encontrado para formar una mancomunidad, ellos prácticamente son, por el simple hecho de haberse encontrado, una *democracia*”⁷⁹. Diez años más tarde, Hobbes repudiaba esta posición temprana para defender en cambio la imposibilidad institucional y política de la democracia. Pero esta reaparecerá en la descripción y defensa de Locke del “pueblo como poder supremo”, con el derecho inalienable a decidir la estructura de gobierno⁸⁰. Su trabajo renueva y fortalece la clásica distinción entre poder constituyente y orden constituido, al trazar una clara línea entre la “disolución del gobierno” y la “disolución de la sociedad”: la primera no afecta a la segunda porque la sociedad existe con independencia y aparte del Estado⁸¹. Para Locke, la soberanía popular es un poder fundante, una

irregular y excepcional fuerza insurgente, un antecedente del derecho positivo y externo a cualquier forma de Estado, justificando la resistencia legítima y la revolución de parte del pueblo⁸².

En el siglo siguiente, la doctrina del poder constituyente migró a través del Atlántico y encontró suelo fértil en las colonias de Norteamérica, inspirando la guerra de independencia de Estados Unidos y la formación revolucionaria de la república federal⁸³. Una vez más, esta era evocada en el lenguaje de la soberanía popular y, como un derecho a la revuelta, suplía de recursos normativos para la guerra revolucionaria en contra del Imperio británico y la legitimidad política del nuevo gobierno republicano. Ya en abril de 1777, Thomas Young, un patriota radical de Pensilvania, en una carta abierta dirigida a los habitantes de Vermont, los insta a establecer su propio gobierno y a formular una constitución porque:

Ellos son el *supremo poder constituyente* y, por supuesto, sus representantes inmediatos son el poder supremo delegado; y tan pronto como su poder delegado se va muy lejos de las manos del poder constituyente, una tiranía es establecida en cierto grado⁸⁴.

Muy probablemente, él se inspiró en la “Declaración de Independencia” de 1776, escrita en el lenguaje del poder constituyente: los gobiernos son instituidos para asegurar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad y:

[...] donde sea que cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva a estos fines, es el derecho del pueblo *alterarlo o abolirlo*, y de instituir un nuevo gobierno, estableciendo su base sobre estos principios y organizando sus poderes en tales formas, en tanto a ellos debiese parecer más probable que afecte su seguridad y alegría⁸⁵.

Algunos años más tarde, Thomas Paine articuló la lógica democrática del poder constituyente con su ejemplar formulación: “una constitución no es el acto de un gobierno, sino de un pueblo constituyendo a un gobierno. Y un gobierno sin una constitución es poder sin derecho”⁸⁶.

Notablemente, por primera vez desde que Marsilio estableciera los fundamentos conceptuales y Lawson imaginara su forma institucional, el poder constituyente fue finalmente actualizado y dotado de forma política

en las convenciones revolucionarias establecidas fuera del marco legal colonial, cuerpos irregulares con una autoridad superior a las legislaturas ordinarias⁸⁷. Comenzando por Virginia, Carolina del Norte, Pensilvania y Massachusetts, estas brotaron a lo largo de Norteamérica con la especial tarea de redactar las nuevas constituciones. Estas formas políticas que sustituyeron a los privilegios reales, habitualmente eran elegidas por hombres libres, y dando pie en las reuniones de la ciudad para su consulta y legitimidad⁸⁸. Ellas transformaron las colonias en Estados independientes, culminando en la Gran Convención de 1787 en Filadelfia, en la que fue redactada la constitución federal, la cual sería entonces presentada a las convenciones estatales para su ratificación⁸⁹. El irritante problema de la autoautorización de la convención, su ilegalidad y arbitrariedad⁹⁰, fue resuelto por una apelación al “*poder constituyente original*” del pueblo en su capacidad soberana⁹¹. James Madison, por ejemplo, defendió la decisión de la Convención de Filadelfia de reunirse sin una autorización previa, en contra de las reglas establecidas por los artículos de la confederación, en el nombre de un poder superior a las normas positivas, que emana desde “el preciado derecho del pueblo de ‘abolir o alterar su gobierno en cuanto a ellos debiese parecer más probable que afecte su seguridad y alegría’”⁹². El principio del poder constituyente generó la legitimidad democrática que se requería para compensar el déficit legal del quiebre revolucionario. En palabras de James Wilson:

Necesariamente existe, en cada gobierno, un poder del que no hay apelación y el cual, por esa razón, podría ser llamado supremo, absoluto e incontrolable [...] tal vez algún político, que no ha considerado con suficiente precisión nuestros sistemas políticos, respondería que en nuestros gobiernos el poder supremo estaba investido en las constituciones [...]. Esta opinión se aproxima un paso más a la verdad, pero no la alcanza. La verdad es que, en nuestros gobiernos, el poder supremo, absoluto e incontrolable permanece en el pueblo. En cuanto nuestras constituciones son superiores a nuestras legislaturas, el pueblo es superior a nuestras constituciones. De hecho, la superioridad, en esta última instancia, es mucho mayor; por lo que el pueblo posee control de hecho, y también en derecho, sobre nuestra constitución. La consecuencia de esto es que el pueblo podría cambiar las constituciones cuando sea, y si es que le place. Este es un derecho del cual ninguna institución positiva podrá jamás privarlos⁹³.

La conclusión de la Revolución norteamericana vio los primeros ejemplos de codificación e integración del principio del poder constituyente como soberanía popular en una serie de documentos legales fundantes, como en los preámbulos de varias constituciones de Estado revolucionarias, y de la misma constitución federal y su disposición de enmiendas.

Esta constitución original, sin embargo, reveló algunos dilemas⁹⁴. Mientras que la recientemente fundada república reconoció la soberanía del pueblo como poder constituyente, también buscó congelarlo y neutralizarlo⁹⁵. En particular, un crítico debate se siguió sobre el tema de la revisión constitucional, esto es, de una autoalteración legalmente regulada, en donde la constitución incorporaba la lógica constituyente al inscribirla dentro de una norma jurídica⁹⁶. Fue un debate en torno a la supervivencia posrevolucionaria del poder constituyente fuera de las reglas constituidas. La pregunta central es si la soberanía popular, es decir, la democracia, puede existir solo como una forma, un régimen y una constitución, o, más bien, debe retener sus poderes informales, desobedientes, eruptivos y revolucionarios⁹⁷. Este es el dilema entre la amnesia revolucionaria y una revolución permanente. Para dar cuenta de este molesto problema, Jefferson y Paine repensaron nuevamente al poder constituyente en términos de temporalidad y de justicia intergeneracional entre los “vivos” y los “muertos”. A su vez, Madison rechazaba tales propuestas y, en cambio, defendía la estabilidad y las promesas duraderas del nuevo orden constituido⁹⁸. Y tal como Alexis de Tocqueville agudamente observó:

[...] aunque el principio de la soberanía del pueblo [...] es siempre encontrado, más o menos, en el fondo de casi toda institución humana [...] permanece ahí escondido a la vista [...] [y] si por un momento es traído a la luz, es rápidamente echado atrás a la penumbra del santuario⁹⁹.

Con el cierre de la era revolucionaria, las primeras reacciones en contra del poder constituyente fueron expresadas en oposición a la soberanía popular y su naturaleza insurreccional, sediciosa, rebelde, inestable y breve. La democracia es revolucionaria y, por tanto, deficiente en el largo plazo, debido a que “subvierte al fundamento del gobierno

civil”¹⁰⁰. Es de esta forma que el orden constituido se volvió en contra del poder constituyente. La nueva república absorbió al principio constituyente para santificar sus fundamentos, pero lo hizo a través de la representación de sus propios inicios y el objeto a la supervivencia extraconstitucional del poder de los muchos de constituir¹⁰¹.

Algunos años después, el concepto, ahora enriquecido por la experiencia de la revolución americana, resurgió en el continente europeo para dar forma al discurso y a la política de la Revolución francesa¹⁰². El marqués de La Fayette, Antoine-Nicolas de Condorcet y, por sobre todo, Emmanuel Sieyes fueron quienes propagaron ardientemente la doctrina del poder constituyente. Este redescubrimiento iniciado por La Fayette tuvo un impacto decisivo en la historia conceptual del poder constituyente y su ambiguo legado ulterior¹⁰³. En particular, es destacable el esfuerzo de Condorcet, pues buscó realizar institucionalmente el contenido democrático al defender la ratificación popular, las iniciativas de los ciudadanos, múltiples asambleas primarias, convenciones recurrentes y el derecho a la insurrección¹⁰⁴. Al hacerlo, buscó formalizar el impulso democrático de la soberanía popular¹⁰⁵. Su influencia fue decisiva en la redacción de la constitución de 1793, pero su permanente suspensión indica la desafortunada suerte de su teoría del poder constituyente¹⁰⁶.

En contraste, el intento de Sieyes de reducir el concepto a un sujeto nacional, homogéneo y orgánico, “*la Nation*”, entendida como una comunidad prepolítica que habita un Estado sin reglas de naturaleza, demostró ser más exitoso¹⁰⁷. Al hacerlo, inauguró la doctrina de la soberanía nacional. Como famosamente escribió:

El poder constituyente puede hacer todo en relación al hacer constitucional. No está subordinado a una constitución previa. La nación que ejercita el mayor y más importante de sus poderes, debe estar, mientras lleva a cabo esta función, libre de toda restricción de cualquier tipo, excepto aquella que considera mejor para adoptar¹⁰⁸.

Existe, no obstante, una tensión importante e irresoluta en la famosa definición de Sieyes. Al mezclar selectivamente elementos del pensamiento político de Rousseau y Hobbes, él alabó la naturaleza instituyente y revolucionaria del poder constituyente, aun cuando la

juridificó en una fuerza puramente legal: “Su voluntad es siempre legal, es la ley misma”¹⁰⁹. El poder constituyente se convierte en la voluntad nacional general. Así, por un lado, reconoció al poder constituyente como libre, ilimitado por las normas constituidas, la fuente extralegal de toda legalidad, mientras que, por el otro, lo trató como un concepto jurídico con una identidad definida, siempre ya mediada por la representación¹¹⁰. Esta ambivalencia terminó socavando la distinción clave constituyente / constituido que él había endosado formalmente y que políticamente acabó en la Convención Constituyente autorizada por sí mismo (1789-1791) y la popularmente electa Convención Nacional (1792-1795) con funestos resultados.

Al final, la versión de Sieyès no solo desplazó y derrotó la contribución democrática de Condorcet, sino que también hizo posible la subsecuente explotación nacional-plebiscitaria y la desfiguración populista del poder constituyente¹¹¹. Con la Revolución francesa, el concepto, atrapado en el ámbito de la representación, se enredó en intrincadas paradojas lógicas e inescrutables formulaciones legales que políticamente produjeron apropiaciones sospechosas y polémicas refutaciones. Así, en 1830, François Guizot afirmó que “este poder anterior, superior y por fuera de lo estatuido (*the Charter*), es decir, el *poder constituyente* soberano y absoluto, era como un veneno que se había mezclado con todos los bienes y todas las expectativas”¹¹². De igual forma, en 1842, él vilipendiará al poder constituyente porque:

Si pretendemos que existen, o debieran existir, dos poderes dentro de la sociedad, uno ordinario y otro extraordinario, uno constitucional y el otro constituyente; decimos algo demente, lleno de peligros y potencialmente fatal [...]. Tranquilos señores, nosotros, los tres poderes constitucionales, somos los únicos órganos legítimos y legales de la soberanía nacional. Más allá de nosotros, no hay más que usurpación y revolución¹¹³.

Durante el siglo XIX, en Norteamérica y Europa occidental, el poder constituyente fue malversado, domesticado, neutralizado o menospreciado. Su absorción gradual por el orden constituido no solo lo privó de sus atributos democráticos y revolucionarios, sino también lo degradó a una abstracta e indeterminada ideología maleable, a merced de elites gobernantes que se disputan el poder. Su impacto, sin embargo,

comenzó a sentirse en otros lugares, en los movimientos independentistas anticoloniales de Sudamérica y el Caribe, en la esquina balcánica del sur de Europa y moviéndose hacia el este, hacia el Imperio otomano¹¹⁴. Estas trayectorias espaciales sugieren que los conceptos poseen historias y geografías. La historia política del poder constituyente se volvió prácticamente global en su alcance. De hecho, la idea de que el poder final de establecer y alterar el marco de gobierno pertenece al pueblo en su capacidad soberana de erigir sus propias constituciones, sin que estas estén unidas a normas instituidas anteriormente, ha marcado profundamente la conciencia democrática, insurreccional y anticolonial de la modernidad política.

4. UN CONCEPTO DEMOCRÁTICO

Esta breve y somera historia conceptual del poder constituyente, incompleta como está, sugiere una distinción clara entre la soberanía del Estado como capacidad de comando y la soberanía popular como el poder de constituir. Sus diferencias son sustanciales en cuanto que están separadas por distintivas historias, ontologías, orientaciones normativas y objetivos políticos.

Tal como correctamente ha apuntado Martin Loughlin, “el poder constituyente como ‘poder para’ es distinto del ‘poder sobre’”¹¹⁵. De hecho, es muy distinto. En el paradigma del Estado, el énfasis está en el momento de comando (coercitivo) mientras que la versión constituyente privilegia el acto de establecer y ordenar. El primero es represivo y estático si se contrasta con la dimensión dinámica y productiva del otro. Consecuentemente, mientras el principio de comando se basa en el modelo de *gobierno*, el de la soberanía constituyente evoca un evento *fundante*. El soberano no es un gobernante, sino un legislador (*lawgiver*). Entonces, en vez de fijarse a un comando superior que mana desde *arriba* la noción del soberano constituyente, redirige la atención a las fuerzas subyacentes de la realidad instituida ubicada en la parte de *abajo*. La primera se basa en una estructura vertical, mientras que la segunda opera horizontalmente. Más aún, contrario al paradigma del comando soberano que invita a la personificación —desde el antiguo

imperatore hasta el rey y la moderna autoridad suprema (*executive*)—, el poder constituyente transmite los atributos colectivos e impersonales de la soberanía, su dimensión pública asociativa y sus inclinaciones federales. Todos estos contrastes ilustran cómo el poder constituyente ha reimaginado en los tiempos modernos la democracia en contra del paradigma real de comando¹¹⁶.

Esta yuxtaposición entre las dos versiones rivales de la soberanía hace difícil perder la regularidad del concepto del poder constituyente. Al mirar cuidadosamente cómo fue teorizado y evocado es posible bosquejar sus reglas discursivas de modo consistente. En lo que sigue, tomo en consideración algunos de los temas que se repiten con mayor frecuencia en las teorías del poder constituyente, ello con el fin de probar y definir las reglas que dan cuenta de la continuidad semántica, la consistencia analítica y la singularidad normativa del concepto. Aunque sus experiencias históricas pudieron haber sido distintas, en sus numerosas trayectorias y variaciones, en el modo de los medios de sus realizaciones respectivas, formadas por distintas influencias intelectuales, no obstante, presupone ciertos significados compartidos y una orientación común que define y organiza su inteligibilidad. Me refiero aquí a los principios de reconocimiento inmanentes del concepto. Estos principios son internos al concepto, al cual ellos construyen y ayudan a identificar¹¹⁷.

Para comenzar, el poder constituyente habla de una práctica colectiva, que envuelve a una pluralidad de actores que se reúnen a *co-instituir*, a establecer en conjunto. Dos aspectos cruciales están involucrados en la composición semántica del concepto, indicativa de sus primeros dos principios inmanentes.

Primero, existe igualdad. Un énfasis en el prefijo *co-*presenta el concepto descriptivamente: por un lado, como negación, es decir, como la imposibilidad de que uno pudiera alguna vez *co-instituir* cualquier cosa por sí mismo; por el otro, positivamente, establece que si uno quiere *co-instituir*, uno tiene que hacerlo en *co-operación* con otros. Actuar juntos, concertadamente, significa “hacer ciertos actos comunes como sociedad, los que son actos no de cierta parte, sino del todo”¹¹⁸. Estos actos apuntan a una estructura federativa y asociativa de la actividad pública que desafía la centralización, la jerarquía y el monopolio de la coerción. Son igualitaristas al punto de que el reunirse se articula en términos de igual participación. En todas las teorías del poder constituyente, las políticas

de los nuevos fundamentos son llevadas a cabo de forma conjunta y voluntaria, libres de relaciones de poder asimétricas e interferencias arbitrarias, es decir, libre de desigualdad y en verdadera co-operación. Sidney, acertadamente, comprendió esta presencia igualitaria cuando afirmó que:

Cada número de hombres, que poniéndose de acuerdo en conjunto y enmarcando una sociedad, se vuelve un cuerpo completo, que tienen todo el poder en sí mismos y sobre sí mismos, estando sujeto a ninguna ley del hombre salvo la propia. Todo aquello que compone a la sociedad, siendo igualmente libres de entrar o no, ningún hombre podría tener prerrogativas sobre otros¹¹⁹.

El significado igualitario del concepto indica cómo el acto de constituir es realizado entre pares a través de la asociación mutua.

Segundo, el concepto da cuenta de un principio generativo¹²⁰. Al destacar el segundo componente del verbo 'co-instituir', las teorías del poder constituyente vieron en la soberanía a una forma creativa de dar poder¹²¹. La soberanía popular es presentada en su capacidad institutiva, con la facultad de “instaurar” nuevos órdenes políticos, de traer a la existencia nuevas formas constitucionales, de promulgar nuevos comienzos. La soberanía establece órdenes políticos y legales, y determina las formas constitucionales¹²². En una palabra, es un poder productivo, comúnmente retratado como la fuente extralegal de toda legalidad. Este aspecto basal de la soberanía constituyente es totalmente capturado por la definición de soberanía de Schmitt como “poder fundante” (*die begründende Gewalt*)¹²³. El segundo principio inmanente del concepto de poder constituyente es positivo y generativo, una norma productiva e institutiva.

De modo correspondiente, el poder para constituir pertenece a relaciones de mutua asociación y autoconstitución. El sujeto del poder constituyente no es anterior o externo al acto de constituir. Más bien, se constituye a sí mismo en cuanto constituye para sí¹²⁴. Al enmarcar las formas políticas de su existencia colectiva también produce su propia identidad pública¹²⁵. Este proceso de autoformación es inmanente, en cuanto al grado que el poder constituyente hace, en ausencia de un antecedente, tanto del sujeto como del objeto de lo político, una

causalidad externa. Esto está capturado mejor en la definición de política constituyente de Althusius, quien la entiende como “*symbiotics*”, esto es, como una práctica horizontal de asociarse y disociarse libremente con otros, la formación de una comunalidad a través de promesas recíprocas, compromisos por el bien de “la comunicación mutua de lo que sea que es útil y necesario para el ejercicio armónico de la vida social”¹²⁶. Para el concepto, el pueblo no es una unidad natural y homogénea dotada de una individualidad orgánica y colectiva. Más bien, el pueblo constituye un cuerpo artificial y combinado, formado fuera de la mancomunalidad instituida inclusivamente y establecida en común con ciertas “cosas, actos, derechos, privilegios, intereses”¹²⁷.

El concepto, también, en una cuarta dimensión, consiste en un principio revolucionario¹²⁸. Es forjado durante situaciones extremas de crisis, conflicto y transformación, diseñado para la resistencia y la revolución, como una exhortación para rebelarse¹²⁹. Es el principio de disrupción: autorizado por sí mismo, revoltoso, en contra de la fijación y la permanencia del *nomos* estatista. Hay aquí un fuerte “deseo de alteración” (“*desire for alteration*”)¹³⁰. El concepto indica discontinuidades y rupturas en la constitución de lo político, pondera la alteridad y la otredad en contra de la clausura legal, y está atento a aceleradas temporalidades con resultados repentinos, impredecibles y contingentes. Las teorías del poder constituyente expanden los límites de lo político de modo de incluir sus propios fundamentos y orígenes. Desde la original formulación de Marsilio, el pueblo arriba en el momento de ruptura, en tiempos de excepción, escenificando una disputa de constituir nuevamente su existencia política y de renovar su identidad constitucional¹³¹. Para la reinención moderna de la democracia, la soberanía popular es revolucionaria¹³².

Sorprendente como podría sonar para algunos, este principio revolucionario coexiste con la dimensión constitucional del concepto¹³³. Las revoluciones democráticas son constitucionales, es decir, son momentos de soberanía popular y de genuino hacer constitucional. El poder constituyente es, ciertamente, uno de los principios centrales del constitucionalismo moderno y el derecho público¹³⁴. Consistentemente trata lo político en términos de política constitucional; la constitución es entendida políticamente, y lo político, a su vez, es analizado

constitucionalmente, uniendo así la revocable y políticamente sospechosa distinción entre lo político como el campo del poder facto y la constitución como el ámbito de la normatividad pura. Toda distinción con sentido y convincente entre leyes más altas y leyes ordinarias presupone, de hecho, el poder constituyente del pueblo. Esta distinción, que corresponde a uno de los principios centrales del constitucionalismo moderno, mana de la soberanía popular: el pueblo es soberano por virtud de su poder de constituir¹³⁵. El derecho constitucional fundamental, “el derecho de hacer-derecho”, disfruta de una legitimidad más alta y más amplia que la legislación normal porque es una expresión soberana del poder constituyente¹³⁶. Esta es la idea moderna de legitimidad democrática y la fundación democrática del Estado constitucional¹³⁷.

“La teoría democrática —planteaba Schmitt— conoce como una constitución legítima solo a aquella que descansa sobre el poder constituyente del pueblo”¹³⁸. Karl Marx ya había expresado esta visión en estos términos. Afirmaba que:

La democracia es el *acertijo* resuelto de todas las constituciones [porque] aquí, no meramente implícitamente y en esencia, sino que existiendo en realidad, el centro de la constitución es constantemente devuelto a su base actual, el *ser humano actual*, el *pueblo actual*, y establecido como el trabajo propio del pueblo. La constitución aparece como lo que es, una creación libre del hombre¹³⁹.

En un régimen democrático, la legitimidad depende de qué tan inclusiva, libre e igual es la participación durante la política constitucional. Precisamente, porque este concepto de soberanía nos devuelve al centro de la teoría democrática moderna, al ideal normativo de la autonomía política, este apunta a una distintiva teoría de la legitimidad política, la que se enfoca primariamente en la formación de un derecho más alto. La participación en la fundación define la experiencia moderna de la democracia. Es esta primacía de la participación por sobre la obediencia lo que demanda de los sujetos de un orden político co-instituirlo. El poder constituyente evoca el valor general de la autonomía política: ser libre es vivir bajo las leyes de uno mismo. La soberanía popular como poder constituyente reinventa el antiguo principio democrático del autogobierno. En la apta formulación de Cornelius Castoriadis, es la autoconstitución explícita y lúcida de la

sociedad¹⁴⁰.

Al mismo tiempo, la relación entre soberanía y constitucionalismo, democracia y derecho, demuestra ser dialéctica al grado de que el poder constituyente sobrepasa la universalidad constitucional de la sociedad instituida. Como insistía Marx, la “constitución ya no es un equivalente del todo” y no monopoliza lo político porque corresponde a “solo *una* faceta del pueblo”¹⁴¹. Para el concepto existe un irreducible exterior político a la organización formal del Estado. Como el poder constituyente no puede ser absorbido o consumido por orden de la constitución, lo político escapa de su constitucionalización total en su completa “objetivación” jurídica¹⁴². Permanece tanto por debajo como por el lado de los poderes constituyentes, como una fuerza de innovación, alteridad, contingencia y, más importante aún, como presencia democrática¹⁴³. La idea del poder constituyente como el exceso del constitucionalismo es un recordatorio de que lo político no puede ser reducido a una legalidad abstracta y que la democracia excede a sus formas constitucionales¹⁴⁴.

Finalmente, el poder constituyente establece una ruptura con nociones teológicas y trascendentes de poder, lo político y la subjetividad. Un principio de inmanencia está presente en el poder constituyente. Por ejemplo, este concepto de poder siempre ha sido ubicado por debajo del edificio civil y legal, no arriba ni por sobre él, sino que emanando desde el fondo, desde los muchos, aquellos que componen una colectividad genuina. Los varios nombres que la designan —“la comunidad”, “la sociedad civil”, “la multitud”, “el pobre”, “la plebe”, “los comunes”, “el *demos*”, “el pueblo”— sugieren que, en última instancia, los muchos son la fundación última de lo político, el límite absoluto de toda política que sobrevive la disolución de gobiernos, la disrupción del sistema legal y el colapso de los poderes instituidos¹⁴⁵. Esta persistente externalidad constitucional es debida a la inmanencia del poder constituyente a la vida social. Es interno a relaciones concretas de asociación mutua, formado de facto por compromisos y promesas; en intercambios, acuerdos, pactos y contactos; en corporaciones, alianzas y federaciones¹⁴⁶. El concepto es relacional y plural, y opera estrictamente en el plano de la historicidad y la inmanencia. Es profano y material, es la afirmación de los poderes de este mundo, de cambio y contingencia, de principios y finales, y el reconocimiento de que el mundo político está hecho por sus

participantes¹⁴⁷.

Aunque es cierto que, a través de su larga historia, este mundano concepto fue periódicamente contaminado por elementos de la teología política, estos permanecieron ajenos, como adiciones finales que nunca se fusionaron con el centro conceptual a convertirse en una parte constitutiva. Para el tercer cuarto del siglo XVIII, Hamilton podía proclamar en las líneas iniciales de los *Federalist Papers* que:

[...] parece haber sido preservado al pueblo de este país, por su ejemplo y conducta, decidir la importante pregunta de si las sociedades del hombre son realmente capaces, o no, de establecer un buen gobierno desde la reflexión y la elección, o de si ellos están destinados por siempre a depender de constituciones políticas sobre accidente y fuerza¹⁴⁸.

La autoridad política, los fundamentos del gobernar y el gobierno mismo no son inaccesibles más allá de juicio y lucha; en vez, estos son relativizados y descentrados, considerados como humanos, es decir, artefactos mortales sin un soporte extrasocial, carentes de banderas, de verdades o de hacedores de certezas, abiertos a cuestionamiento y, así, provisionales y revocables, condicionales y frágiles¹⁴⁹.

Intratable, como puede parecer, el concepto de poder constituyente posee su propia lógica. Sus principios discursivos inmanentes definen el contenido democrático de la soberanía popular, el cual es tanto revolucionario como constitucional. Esta reorientación de la teoría democrática moderna hacia el poder de constituir inicia un cambio desde la lógica de la determinación hacia el principio de autodeterminación, desde la inmovilidad hacia el movimiento, desde el uno hacia los muchos, desde lo trascendente hacia lo inmanente, desde la heteronomía hacia la autonomía¹⁵⁰. Es un cambio que marca el nacimiento moderno del proyecto democrático y del “imaginario social moderno de la autonomía”¹⁵¹. Con el poder constituyente, la democracia existe en el evento radical de su autoalteración¹⁵². Es una política del devenir, el movimiento de la transformación política y el cambio constitucional¹⁵³. Hannah Arendt, siguiendo a Maquiavelo, describió a esta política constituyente como la “argumentación de los fundamentos [...] esta noción de una coincidencia de fundación y una preservación en virtud de la argumentación”¹⁵⁴. El poder constituyente inaugura una exploración

fascinante y sin precedentes en la naturaleza radical de la política democrática, es decir, una política que revisa sus fundamentos y politiza sus orígenes¹⁵⁵. La democracia, en corto, comienza democráticamente¹⁵⁶.

II. PODER CONSTITUYENTE Y REPRESENTACIÓN

Miguel Vatter

1. LA PARADOJA DEL CONSTITUCIONALISMO Y EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACIÓN

Una famosa paradoja del constitucionalismo moderno, el llamado “círculo de Sieyes”, postula que sin pueblo no hay constitución, pero que sin constitución no hay pueblo¹. Sieyes inventa la idea de “poder constituyente” (*pouvoir constituant*) para tratar de resolver la paradoja, otorgando al pueblo un poder político, pero no institucional, y, al mismo tiempo, una capacidad extraconstitucional, cuya actualidad es un producto exquisitamente jurídico, es decir, una constitución. Dado que el concepto de poder constituyente es también paradójico, no es sorprendente que en la teoría política y jurídica contemporánea no exista una solución unívoca a esta paradoja y aceptada por todos². Como toda paradoja circular, si existe salida al círculo vicioso, esta se encuentra entrando en el círculo de la manera correcta. En este ensayo propongo que no se puede esperar salir de la paradoja sin reflexionar sobre un término implícito en el debate sobre el poder constituyente, pero raramente debatido de manera explícita en relación a tal poder, es decir, la idea de representación política.

Pero antes de discutir el problema de la representación, hay que tomar conciencia de que en el círculo de Sieyes se esconde un problema más profundo. Como todo constitucionalista sabe, “para el derecho, el poder no prueba nada”, según las palabras de Schmitt con las cuales Kelsen estaría igualmente conforme³. Al mismo tiempo, como todo cientista político o sociólogo sabe, la autoridad de la ley no genera poder

político alguno. Por lo tanto, se puede decir que unos de los problemas fundamentales de la constitución tiene que ver con cómo ligar el derecho al poder: si una constitución no logra hacer esto, no puede establecer un orden jurídico estable. Por ende, cada constitución tiene dos presupuestos distintos que no se pueden reducir uno al otro. Por un lado, una constitución debe manifestar la realidad de que la autoridad de la ley es otorgada por la ley misma y no por una persona que está afuera y por sobre la ley (esta es la idea fundamental del *rule of law* contra la *rule of persons*). El derecho tiene la fuente de su autoridad en sí mismo y no en el “poder” de aquellos que hacen o cambian tales leyes. Esta es la intuición que se encuentra enunciada en el pensamiento de Kelsen acerca de la *Grundnorm* a la base de toda constitución. Por otro lado, una constitución debe hacer posible la vida “política” de un pueblo, y no solamente la vida “civil” de sus miembros individuales. Esta es la intuición que se encuentra en el pensamiento de Schmitt sobre el poder constituyente. Una constitución debe hacer posible que el pueblo genere el poder para hacer leyes y no simplemente que sus partes reciban un trato igualitario frente a la ley. Como dice Kant, en una república, el pueblo es “colegislador” junto al Estado. Por eso, las constituciones establecen una forma de gobierno y un Estado a través del cual la voluntad del pueblo se pueda ejercitar, pero, al mismo tiempo, establece controles a tal gobierno (como la división de poderes y el sistema de derechos) que permiten que el pueblo se forme una opinión acerca del gobierno de manera independiente de la voluntad expresada por el Estado.

La distinción entre voluntad y opinión del pueblo es fundamental para el constitucionalismo moderno. El derecho tiene su autonomía en relación al poder del Estado porque, por un lado, es independiente de la voluntad del pueblo, pero, por otro lado, se asienta sobre la opinión del pueblo: como dice Madison, citado por Arendt, “Todo gobierno está basado en la opinión”⁴. Nadia Urbinati ha hablado recientemente de una “diarquía” fundamental para las democracias modernas entre opinión y voluntad, voz y voto⁵. Este dualismo es crucial para tratar de relacionar de manera correcta el poder constituyente del pueblo con la autoridad de la constitución.

Ahora bien, la tradición del “*droit politique*” o “*public law*” europeo da una respuesta unívoca a este problema: la solución se encuentra en la

teoría de la soberanía⁶. Según esta tradición, el poder del pueblo reside en la constitución de un Estado soberano (cuyo representante puede ser tanto un monarca como una asamblea legislativa), y es el Estado soberano (o, más correctamente, la persona pública que lo representa) quien decide qué es derecho. La persona soberana (la persona del Estado) ofrece la articulación entre poder y autoridad. Tal persona detenta todo el poder, debido a que es el representante del pueblo quien autoriza a gobernarlo.

Pero en la modernidad se encuentra también la tradición republicana, cuyo constitucionalismo articula poder y autoridad sin pasar por la persona del soberano, pues, al contrario, depende de la división y multiplicación de las fuentes del poder del pueblo, cuyo acuerdo u opinión común está en la base de la autoridad de la ley. Tal como para la tradición de la soberanía, también para el republicanismo, la clave del constitucionalismo reside en una teoría de la representación, pero esta es de signo opuesto a aquella del *ius publicum*, como trataré de mostrar a continuación.

Mi propuesta en este ensayo es que se debería juntar el debate sobre el poder constituyente y su paradoja con el debate sobre la representación política. Ahora bien, tal como con el poder constituyente, también la representación política tiene su propia paradoja. En la ciencia política se habla hoy de “paradoja de la representación”⁷, según la cual un pueblo (lo representado) debe estar “presente” para que la representación tenga un objeto que representar y, al mismo tiempo, tiene que estar “ausente”, ya que, si un pueblo estuviese políticamente presente, no sería necesaria ninguna representación. En mi opinión, esta paradoja fue ya reconocida por Schmitt y Kelsen, pero anteriormente por la mayoría de los teóricos de las revoluciones republicanas. Mi hipótesis es que las dos paradojas, aquella de la representación y esta del constitucionalismo, se presuponen y, si las pensamos de manera conjunta, nos pueden iluminar acerca de cómo hacer del círculo de Sieyes algo virtuoso. En lo que sigue voy a discutir cómo Schmitt y los republicanos dan respuestas diferentes a tal paradoja de la representación, y, por ende, ofrecen dos modelos distintos del poder constituyente.

2. PODER CONSTITUYENTE Y REPRESENTACIÓN EN SCHMITT

Hoy en día, la discusión sobre el poder constituyente está dominada por la teoría ofrecida por Schmitt en su *Verfassungslehre*⁸. La fuerza de seducción de Schmitt depende de dos tesis sobre el poder constituyente: primero, que tal poder es, sea de un pueblo, sea de un príncipe; segundo, que el poder constituyente del pueblo se encuentra en tensión con el principio de representación política: “la voluntad constituyente del pueblo no puede ser representada sin que la democracia se transforme en una aristocracia”⁹. Schmitt enfrenta la paradoja de la representación, de cierta manera, disolviéndola. Por un lado, argumenta que si un pueblo tiene una identidad política, entonces cualquier forma de representación se desvanece porque los que gobiernan y los gobernados son los mismos: “Donde el pueblo se manifiesta como sujeto del poder constituyente, la forma política del Estado se define por la idea de identidad. La nación *está allí*. No necesita y no puede ser representada”¹⁰. Para Schmitt, la democracia pura tiende a ser “directa” o plebiscitaria, su expresión es la aclamación del pueblo, pero, por otro lado, si la unidad del pueblo no está ya dada, entonces solamente la forma monárquica lo puede representar: la voluntad del pueblo se encarna mejor en la decisión del soberano: “El príncipe absoluto es el único representante de la unidad política del pueblo. Él solo representa el Estado”¹¹. La forma del Estado está dada por la figura monárquica o soberana que logra representar la unidad política del pueblo. Schmitt niega que la representación parlamentaria o liberal sea, en realidad, representación en un sentido político porque, en el concepto liberal de representación, los representantes actúan como abogados de una parte del pueblo y el consenso al cual llegan los parlamentarios no refleja la voluntad del pueblo (que se da solamente por aclamación). Los principios opuestos de identidad (lo que él llama “democracia”) y representación soberana se encuentran en todo orden constitucional¹². La *Verfassungslehre* se puede leer como un esfuerzo para dar a estos principios opuestos una articulación que podríamos llamar “populista”, en el sentido dado al término por Laclau: el pueblo se une políticamente a través de la aclamación de un soberano, quien encarna la persona del Estado y cuya decisión es constituyente y determina lo que vale como derecho.

Si esto es así, se entiende por qué la teoría constitucional de Schmitt tiene un fuerte poder de seducción tanto a la *izquierda* como a la *derecha*: por un lado, asocia el poder constituyente del pueblo con la

democracia directa; por otro lado, reduce el poder constituido del Estado a la decisión del soberano¹³. Además, la idea schmittiana de que exista una oposición fundamental entre poder constituyente (o identidad democrática) y representación política se puede rastrear en algunos teóricos del poder constituyente democrático, quienes hacen depender la legitimidad de la constitución de la “decisión” de un pueblo cuya identidad y poder no dependen de su representación política. Andreas Kalyvas, por ejemplo, sostiene que:

[la idea del poder constituyente democrático de Schmitt ofrece un] criterio normativo, la voluntad popular constituyente, con el cual se puede testear y evaluar la legitimidad de las constituciones existentes y de las estructuras básicas de la sociedad a las cuales [dicha voluntad] dio lugar... En un régimen democrático, consecuentemente, la legitimidad de las normas y valores fundamentales descansan exclusivamente en la manifestación actual de la voluntad del sujeto popular constituyente y la participación de los ciudadanos en el extraordinario y genuino proceso de elaboración constitucional¹⁴.

La cuestión es si tal “voluntad” y “participación” del pueblo no termina, al final, manifestándose en una representación soberana. En esta visión del poder constituyente existe el riesgo de perder de vista la “diarquía” entre voluntad y opinión porque no hay elaboración de una teoría de la representación alternativa a la de Schmitt¹⁵.

3. PODER CONSTITUYENTE EN EL REPUBLICANISMO REVOLUCIONARIO

En mi opinión, es necesario romper la conexión schmittiana entre poder constituyente y teoría de la representación soberana, sin por eso temer caer dentro de la concepción liberal de la representación política, la cual tiende a negar la existencia del poder constituyente como algo separado del poder legislativo constituido. Existe un consenso bastante amplio en la literatura acerca de que el uso de la representación, como una forma de destruir el poder del pueblo, debiera ser rastreado desde Hobbes¹⁶. Como explica Quentin Skinner en un importante artículo sobre los orígenes de la representación política, Hobbes hace uso del concepto de representación para argumentar que una multitud de individuos se

transforma en un pueblo solo gracias a la unidad del representante, y no por causa de la unidad del representado¹⁷. Los individuos pueden ser considerados como si fuesen “todos juntos” —como si pertenecieran a un pueblo— solo gracias a haber autorizado, cada uno por separado, a un soberano que los representa¹⁸. Por consiguiente, este representante hobbesiano no es una representación de un pueblo políticamente unido y con poder constituyente. En realidad, el soberano *carga con la persona* (“*bears the person*”) de otro sujeto colectivo, uno que reemplace al pueblo, a saber, la persona del Estado, el poder constituido, que se transforma ahora en el sujeto original de soberanía¹⁹. Skinner concluye su interpretación diciendo que, en Hobbes, el soberano “personifica” al Estado (el Leviatán), y no al cuerpo del pueblo. Podríamos decir que la teoría de la representación hobbesiana requiere la identidad fundamental entre poder constituyente y poder constituido. En el fondo, sobre tal idea de representación se basa la concepción schmittiana de la “constitución absoluta”, según la cual la constitución es fundamentalmente Estado, y no lo contrario (es decir, el Estado legítimo se basa sobre una constitución), que corresponde a la visión republicana²⁰.

En la visión republicana, una constitución existe justamente porque no hay y no debe haber *identidad* entre gobernados y gobernantes, pueblo y Estado, poder constituyente y poder constituido. El pueblo debe estar en condición de controlar y guiar al Estado para que este Estado persiga el bien del pueblo, y no los intereses de sus representantes. Ahora, una constitución republicana establece dispositivos de representación para tales fines. Tal representación necesita de la diferencia entre gobernados y gobernantes. Según la genealogía de Skinner, tal concepción antihobbesiana fue utilizada originalmente por parlamentarios críticos de la monarquía inglesa. Para ellos, “lo que existe en la naturaleza no es gobierno, sino la mera capacidad de instaurarlo, por lo que el pueblo debe participar como los autores de cualquier autoridad que esté emplazada subsecuentemente sobre ellos”²¹. Históricamente, el concepto de representación política tiene como condición de posibilidad la idea de un poder constituyente no soberano, aunque creo que tal idea de representación política precede al parlamentarismo inglés, como indico abajo. Para estos primeros teóricos ingleses del gobierno representativo, el “estado de naturaleza” —esto es, la condición que precede al establecimiento de la asociación civil y, de

esta manera, también al Estado y a la ley positiva— se caracteriza por un poder constituyente de los pueblos, y no por un estado de guerra anárquico de todos contra todos. Al contrario que para Hobbes, el pueblo existe antes que el contrato que establece al gobierno o forma política. Esto no significa que la unidad política del pueblo esté dada “por naturaleza”: tal unidad es esencialmente el producto de “federaciones” a través las cuales el pueblo genera su poder constituyente. Por eso, la teoría de los monarcómacos postula dos contratos, uno que forma el pueblo con poder constituyente, el otro que establece el poder (constituido) del soberano.

La genealogía de Skinner nos muestra que el concepto republicano de representación es ideado en vista de otorgar al pueblo un recurso en contra del poder soberano, una resistencia a este poder, que a su vez no disuelve el gobierno por completo. La representación en la teoría republicana nunca fue ideada con el propósito de lograr que el pueblo tomara el lugar del soberano, que el pueblo gobernase (aunque de manera “indirecta”), sino para controlar el poder de mando del soberano, de tal manera que, usando la terminología de Lefort, dejara abierto el espacio hueco de la soberanía. Para los revolucionarios norteamericanos y franceses la diferencia entre el pueblo y el Estado establecida mediante dispositivos representativos o constitucionales debe ir en beneficio de la mantención de la prioridad del poder constituyente del pueblo, el cual, de lo contrario, sería subsumido por los poderes constituidos del Estado y no podría más controlar este último. Para los revolucionarios norteamericanos y franceses estaba claro, en efecto, que el pueblo no debía identificarse nunca con su gobierno, puesto que el poder constituyente del pueblo precede y hace posible todo gobierno²². Es en nombre de retener su poder para juzgar o, en jerga actual, para “monitorear” (Keane) o “impugnar” (“*contes*”) (Pettit), al gobierno, que los ciudadanos demandan que todo gobernante debe de ser un *mero* representante.

Vemos cómo tal concepción republicana de la representación entiende la paradoja de la representación de manera diferente. El pueblo debe de estar “presente” antes del Estado porque tal Estado es su construcción: por lo tanto, la representación política se debe de entender en función de proteger la prioridad del poder constituyente sobre el poder constituido. Por otro lado, el pueblo no debe de estar “presente” en

cuanto Estado, en cuanto forma de gobierno, porque, si no, no podría ejercer su opinión y juicio sobre el Estado. Por lo tanto, la representación política debe hacer posible que, justamente, el pueblo esté en una posición de no-gobierno (Arendt se refiere a la idea de “no-rule”), y, desde esa posición, las personas elegidas para gobernar al pueblo son sus “meros” representantes, quienes pueden ser cambiados a voluntad.

4. REPRESENTACIÓN COMO IMPERSONALIDAD, Y, POR LO TANTO, IMPARCIALIDAD

Pero ¿qué idea de representación es esta? La representación republicana tiene dos características que le permiten su función como control del gobierno (o dicho de otro modo, su capacidad de preservar la libertad e igualdad de los ciudadanos ante el Estado). La primera característica es la impersonalidad, o la separación de la persona y del procedimiento, que está en la base de la idea de un gobierno de leyes y no de personas. La segunda es su carácter imaginativo, es decir, el componente que requiere que el Estado se modele al pueblo y no inversamente (como, en vez, reclama Hobbes).

Para explicar la primera característica, Skinner sigue a Pitkin cuando traza la genealogía desde la idea no soberana de la representación hasta la concepción de “persona” que da Cicerón en *De oratore*²³. Según esta concepción, cuando alguien me representa, me está “personificando”, es decir, carga con mi persona, tal como lo hace un abogado cuando habla por su cliente en una corte de justicia. Es en este contexto donde Skinner destaca cómo Cicerón da una ilustración de la idea de persona diciendo que el representante (que carga con la persona o la máscara de su cliente) intenta “de la manera más imparcial posible, jugar la parte de cada una de las tres personas involucradas, vale decir, mi persona, la persona de mi adversario y la persona del juez”²⁴. Esta idea de Cicerón acerca de la relación entre persona y representante es notable dado que, una vez que el abogado asume el rol (o la máscara o persona) de su cliente, en virtud de la misma situación antagónica en la que el abogado se encuentra jugando su papel o rol, obliga al representante a asumir *también* las máscaras o personas de los otros representantes, y esto solamente motivado por el deseo de construir la mejor defensa posible para su

cliente. Esto significa que la representación republicana presupone no una identidad “natural” del pueblo, como argumenta Schmitt, sino una pluralidad conflictual, a la cual corresponde una forma mixta de constitución.

Mi hipótesis es que el fundamento de la relación entre justicia, imparcialidad y representación se debe encontrar en este fenómeno. Si tengo razón, esto explicaría también por qué Rawls piensa que el rol del ciudadano en la posición original debe ser jugado por su representante y no por el ciudadano mismo. Tal como Rawls afirma: “un juicio criminal es un caso de justicia procedimental imperfecta”²⁶. En este tipo de juicio, cada parte tiene sus propios intereses, además de los defensores propios de estos intereses, pero, a través de la forma de cooperación antagónica o “adversarial” establecidas por los procedimientos de un juicio criminal, todas estas partes actúan como si estuvieran buscando el resultado justo como su interés de más-alto-orden. En tal juicio criminal, la representación hace posible la búsqueda de la imparcialidad, sin el sacrificio de los propios intereses. El ejemplo del abogado ciceroniano demuestra que la imparcialidad no puede ser previa a la representación, sino que, por el contrario, la representación es la condición de posibilidad de la imparcialidad.

La idea de justicia procedimental implica que la justicia no puede ser un resultado que sea decidido por una de las partes en el procedimiento. La justicia, de esta manera, no puede ser encarnada por ninguna persona. Esta es la razón por la que la justicia procedimental requiere que cada individuo, cuyo interés de más-alto-orden reposa en un resultado justo, disponga de ellos la representación de su propia persona en tales procedimientos. Esta separación entre la persona y el procedimiento, es decir, el hecho de que la persona se deje ser representada, es la condición de posibilidad para que el procedimiento genere un resultado imparcial.

La segunda característica de la representación republicana es aquella que justifica la idea de que los representantes, si deben controlar al soberano, no pueden traicionar al pueblo una vez que hayan formado parte del poder constituido. ¿Qué nos asegura la fidelidad de los representantes al pueblo? Para responder a esta pregunta, Skinner argumenta que, al cargar con la persona de otro, el representante no solo debe hablar y actuar por aquel (cómo hace el abogado), sino que también debe ser una imagen, un retrato del representado: el representado debe

poder “imaginarse” en el representante²⁷. Los tres elementos básicos de la democracia representativa, vale decir, la elección de los representantes, la proporcionalidad de la representación y, por último, el carácter virtuoso de los representantes, todos estos elementos dependen del carácter imaginativo de la representación, esto es, de la habilidad de los representantes de imaginar al pueblo.

Vemos tal necesidad de la imaginación en juego en la concepción constitucionalista de Rawls, cuando esboza su secuencia de cuatro etapas, que es simplemente un modelo que posee cuatro dispositivos de representación que se establecen como la forma en la que los ciudadanos pueden aplicar los principios de la justicia en la asociación civil. En la primera etapa, Rawls utiliza exactamente la misma idea de la representación como la fabricación de un retrato entre el pueblo y sus representantes. En la segunda etapa, correspondiente a una asamblea o convención constituyente, por ejemplo, es cuestión de “vernós a nosotros mismos como delegados —debemos trazar los principios y reglas de una constitución bajo la luz de los principios de la justicia trazados con anterioridad”²⁸. En la tercera etapa, correspondiente a un poder legislativo, “devenimos, por así decirlo, legisladores que promulgan leyes como la constitución lo permite”. En la cuarta etapa, correspondiente al poder judicial, “asumimos el rol de los jueces, interpretando la constitución y las leyes, como miembros del poder judicial”²⁹. Cabe destacar que todas las expresiones aquí empleadas por Rawls (tales como: “vernós a nosotros mismos como delegados”, “actúan, por así decirlo, como legisladores”, “asumimos el rol de los jueces”) refieren al sentido de representación como la creación de un retrato o un parecido, es decir, la representación como un acto de la imaginación, que está en la base de la concepción de Skinner de la representación republicana.

En otras palabras, los dispositivos republicanos de representación son los únicos que permiten confeccionar la identidad entre gobernantes y gobernados, que es el distintivo de la democracia, dentro de una teoría de la justicia. Por supuesto, es posible confeccionar una identidad entre gobernantes y gobernados que evite la representación, como ocurre en la concepción schmittiana de la democracia directa, pero lo que sostiene Rawls es precisamente que, en una democracia directa, la identidad de gobernantes y gobernados no es una consecuencia de la aplicación de los principios de justicia, sino, por así decirlo, una presuposición sustantiva o

natural de la justicia. Tal como argumenta Schmitt, en la democracia directa, una condición para tratar con justicia a los ciudadanos es la identificación previa sustantiva de los mismos como un grupo homogéneo. Entonces, lo que el republicanismo moderno opone a la democracia directa no es la eliminación de la democracia, sino un procedimiento generador de un pueblo que no trae consigo ningún tipo de referencia a identificaciones o rasgos sustanciales o naturales. Esta es la razón más fundamental del velo de la ignorancia en la posición original: permite la construcción de un pueblo que no está sustentado en rasgos sustanciales comunes o naturales de las personas (ya que estas bases para la identificación se encuentran todas detrás del velo), sino solo sobre la base de su *estatus* como seres iguales y libres, vale decir, como *sui iuris*.

Hay otros dos elementos que son absolutamente esenciales en la secuencia de cuatro etapas de Rawls, y estos son los elementos de los que carece la reconstrucción de los principios parlamentarios de Skinner. El primer elemento es que, antes de que los ciudadanos puedan “verse a sí mismos como” *delegados* para una convención constitucional, deben haberse “visto a sí mismos como” *un pueblo* con poder constituyente. Necesariamente, tal “visión” de cada ciudadano como un miembro igual y libre de un pueblo puede solo ser la función del dispositivo más primordial de la representación, a saber, el dispositivo de la posición original.

El segundo elemento puede distinguirse claramente en los escritos de Rawls, y afirma que la identidad entre gobernantes y gobernados, posibilitada por los dispositivos de representación, tiene siempre el carácter de un juicio reflexivo: la identidad alcanzada por el dispositivo de representación es una identidad “como si”. Esto significa que, en una sociedad civil bien estructurada, los ciudadanos son idénticos a los gobernantes o, como establece Kant, los ciudadanos pueden ser colegisladores, solo bajo el uso de su juicio (u opinión), no bajo el de su voluntad. Desde una perspectiva republicana, la ley coercitiva tendrá siempre dos caras: la ley en cuanto “voluntad” del poder constituido (del Estado) y la ley en cuanto “opinión” de un pueblo libre porque detenta poder constituyente. Bajo esta segunda comprensión, la ley aparece como si su fuente fuera la idea de una constitución, una idea que se emplea como un principio para el uso reflexivo del juicio de los ciudadanos, en la

actividad de enjuiciar y criticar la legitimidad de las leyes por medio de los criterios de la justicia política.

5. REPRESENTACIÓN RESPONSIVA VS. INDICATIVA

Para entender estas dos últimas características de la representación republicana es preciso ahondar algo más en el debate actual sobre la representación. En la concepción republicana de la representación se da un tercer concepto de representación que desborda la clásica distinción establecida por Hanna Pitkin entre el representante como alguien que “toma el lugar de” o simboliza al representado (“*standing-for*”), es decir, lo que Schmitt llama la “representación monárquica”, y el representante como alguien que “actúa a favor de” [e]l representado (“*acting-for*”), es decir, la representación liberal y parlamentaria (defendida, por ejemplo, por Urbinati)³⁰. La tercera posibilidad, recientemente llamada por Philip Pettit una “representación indicativa o pictórica” se da cuando el representante “está por” (“*standing-in*”) o es “muestral” en relación al representado³¹. Este tercer tipo de representación, según mi hipótesis, tiene una historia más larga que su origen en el parlamentarismo inglés. Hasso Hofmann la identifica con la *representatio identitatis* de las ciudades-estado medievales, donde las asambleas populares “representan” al pueblo porque “son lo mismo” que el pueblo, y esto es debido a que no hay una elección por votación, sino por sorteo³². Pero ¿qué tipo de “identidad representativa” está en juego aquí?

Mientras que el representante parlamentario es de tipo “responsivo”, en el sentido de que debe “rastrear” el parecer de sus electores y responder a los mismos —si no, corre el riesgo de perder a las siguientes elecciones—, los representantes de tipo “indicativo” sirven como “indicadores” o *proxies* de la opinión común que un pueblo, considerado como un todo, podría llegar a tener si pudiera deliberar por sí mismo. El representante indicativo no es solamente el delegado de cada votante representado; por eso mismo, el representante indicativo debe ser seleccionado de manera aleatoria, y no electoral.

La teoría de la representación indicativa no ha sido todavía formulada de manera completa. Yo quisiera mencionar dos elementos importantes en este contexto. Primero, estos representantes deben ser a

imagen del pueblo o deben poder formar una imagen del pueblo. Como toda representación, también la representación indicativa es una máscara, pero debería ser la máscara que le representa al pueblo su “mejor cara” o, dicho en lenguaje jurídico, es la máscara que corresponde a la “real” personalidad del pueblo y no a su *persona ficta*, que es la máscara con las cuales deben cargar los representantes de los poderes constituidos del Estado. Lo contrario pasa con la elección de los representantes para que ocupen un cargo de poder en el Estado: allí queremos que los representantes no sean como nosotros, tal como alguien acusado de cometer un crimen desea que lo represente no alguien similar, sino el mejor abogado, para ganar la causa. Pero no diríamos que los abogados (o los parlamentarios) presentan la “mejor cara” del pueblo (por eso, la opinión difusa de que un pueblo merece los representantes que tiene es claramente falsa). La diferencia entre representación “responsiva” y representación “indicativa” es que la primera representa la unidad política del pueblo en cuanto corporación, en cuanto poder constituido, mientras que la segunda lo representa en cuanto “común”, en cuanto poder constituyente.

La representación parlamentaria, según Skinner, tiene tres elementos. Primero, los representantes deben “actuar por” los representados. Segundo, la representación debe ser proporcional, en el sentido de que todas las partes del cuerpo del pueblo deben ser representadas. Tercero, los representantes deben dar al pueblo la “mejor imagen” de sí. ¿Acaso estas tres funciones pueden ser igualmente recogidas por un parlamento y su forma de representación “responsiva”? ¿O no debemos admitir que a estas diferentes formas de representar les corresponde una pluralidad irreductible de dispositivos representativos? Más aún: ¿por qué no asociar el primer requisito de la representación republicana con el poder constituido y el segundo y el tercero con el poder constituyente? ¿Puede realmente un parlamento otorgar una representación “proporcional”, si es verdad que, en su versión constituyente, no existe “un” pueblo con su “identidad” ya “dada”, pero tal pueblo está siempre cambiando debido a su inherente pluralismo y apertura a la alteridad? Por lo mismo, ¿puede este mismo parlamento “responsivo” imaginar por sí solo al pueblo en su mejor faceta, en su cara más “empoderada”?

La hipótesis que me gustaría avanzar en conclusión es que tal

imaginación representativa del pueblo debe ser, por así decir, constitutiva de un pueblo con poder constituyente: debe presentar al pueblo una imagen de sí mismo, una vez investido, con la capacidad de formar, reformar y desformar la constitución, acorde a la mejor imagen de sí mismo producida a través de asambleas ciudadanas que tengan la función “indicativa” de representar la razón pública del pueblo constituyente.

Estas asambleas ciudadanas y su concepción del representante no calzan con el dualismo de Pitkin debido a que los representantes indicativos ya no “toman el lugar” del pueblo, apropiándose para sí mismos del poder popular, como lo hace el representante “simbólico” que Schmitt asocia a la función monárquica o al líder populista, sino que ahora, por el contrario, ellos hacen posible la existencia política y constituyente, es decir, colegisladora del pueblo. Por otra parte, los representantes ya no “actúan por” quienes los eligieron, no son simples defensores de los distintos intereses de los grupos e individuos que componen a un pueblo, ya que su actividad representativa tiene por finalidad la unificación y el empoderamiento de un pueblo por sobre y contra el Estado soberano y sus poderes constituidos.

Este tercer tipo de representación ha asumido en tiempos recientes en Canadá, Australia, Islandia e Irlanda la forma de “asambleas ciudadanas” elegidas de manera aleatoria y puestas en posición de poder deliberar en plena libertad e información, empoderadas para proponer contenidos jurídicos que se puedan refrendar. El poder constituyente del pueblo debería poder asumir estas nuevas (o muy antiguas) formas representativas. De esta manera, se podría decir que el pueblo es realmente un “colegislador” presente al lado y en tensión productiva con el poder legislativo constituido o derivado.

III. PODER CONSTITUYENTE: ¿UN MITO CATÓLICO VERSUS UN SÍMBOLO PROTESTANTE?

Gonzalo Bustamante

EN LOS últimos años, tanto en la vida político-social como en la reflexión académica, el tema de la vigencia de la forma constitucional y de los conceptos que la articulan, tales como soberanía, pueblo, poder constituyente y poder constituido, han sido un tema recurrente. Lo anterior no se explica por simples particularismos de procesos políticos, como podrían ser los casos de Chile, Bolivia o Ecuador, sino que más bien responden a un agotamiento de la soberanía estatal vertical moderna y a la forma constitucional que la ha validado. Lo anterior se expresa en parte de los trabajos recogidos en esta obra, como los de Vatter, Duso, Chignola, Mascareño o Kalyvas, entre otros.

La pregunta que subyace es sobre las razones de la crisis de ese sistema político y las posibles respuestas. Mientras algunos verán en la causa el surgimiento de formas constitucionales que no requieren ya ni un “Estado” ni un “pueblo” (Mascareño, Kjaer) y que, simplemente, por la vía de sistemas de derechos en forma de garantías se puede generar un constitucionalismo legitimado transnacionalmente (Thornhill); otros pondrán el acento sobre el agotamiento de las formas clásicas de entender la representación (al menos, como las expuso Pitkin) y, por ende, en la necesidad de buscar otras estructuras representativas, ya no liberales sino de corte republicanas (Vatter, Pettit); finalmente, otros sostendrán que toda forma representativa, necesariamente, rapta para sí el nombre de la “democracia”, vaciándola de su significación originaria (Kalyvas). En ese sentido, por ejemplo, para el filósofo griego, la disputa entre republicanos y liberales no posee la posibilidad de recuperar la

democracia como tal desde el momento en que ambas posiciones sostienen formas contrarias a una democracia entendida como el “gobierno de los pobres y de quienes carecen de poder”, basada en una comprensión noaristocratizante de la prudencia como racionalidad práctica.

De modo aún más radical, autores como Duso y Chignola defenderán que la solución a la crisis política actual implicaría tener que pensar la política desde otras formas y categorías. Estaría en los mismos conceptos modernos, en cuanto dispositivos al decir de Foucault, el que la democracia pos Revolución francesa (ya sea en su modalidad representativa o directa) conlleve la imposibilidad de la pluralidad. Lo anterior, debido a que su fundamento sería una antropología homogeneizadora e individualista que informaría conceptos como “pueblo” y la “soberanía estatal”. Para ambos autores italianos, la crisis política actual es producto de los mismos conceptos que configuraron patológicamente la estructura del sistema político moderno.

Si bien esta última hipótesis mencionada es plausible y permite abrir nuevas posibilidades para pensar la política, en el presente trabajo me centraré básicamente en las condiciones de falta de representación que afectarían al Estado liberal (lo que al final del día es el “Estado moderno”) desde su misma lógica operativa¹.

Si se atiende a sus cimientos político-normativos, se puede constatar que, tanto en la baja participación electoral como en el descrédito de los partidos políticos como vehículos válidos de representación, subyace la idea de una falta de involucramiento de los ciudadanos como agentes legitimadores. Lo anterior ha ayudado a configurar un cuadro donde han surgido competidores al Estado y los partidos políticos, como encarnación y vehículos de la voluntad general. Lucien Jaume² ha descrito este fenómeno como el surgimiento de una “alterlegitimidad”, que se encarnaría en movimientos sociales y ONG que reflejarían nuevas sensibilidades no procesadas por la estructuras del Estado y la política tradicional. Es así como se presenciaría un aumento permanente de movimientos sociales que abogarían por nuevos ordenamientos en torno a temas como los ecológicos, el matrimonio igualitario, la reformulación de la comprensión de los géneros, un nuevo trato social o una reconstrucción y reconocimiento de pueblos marginados por el eurocentrismo, entre otros.

Esa alterlegitimidad descrita por Jaume sería la expresión de una sociedad civil que se apropia para sí la soberanía y la autorrepresentación, ejerciéndola de modo no-convencional, en contra de la potestad tradicional del Leviatán hobbesiano. Es así como, vía competencia, estaríamos presenciando una fragmentación y pluralización de la política entre el Estado y su constitución, por un lado, y la legitimidad que reclamaría para sí la alterlegitimidad, por otro.

La tensión entre ambas formas de representación (la estatal clásica y la *alter*) se produciría desde el momento en que la alterlegitimidad tomase la forma, obligatoriamente, de una resistencia hacia la forma de soberanía estatal. Asume que el Estado no es la *persona ficta* hobbesiana que actúa en nombre de todos, cuestiona de este modo la legitimidad procedimental vía elecciones y, como conclusión de los puntos anteriores, interpreta la política como una contraposición entre el Estado y su forma jurídica versus la sociedad civil. Esta última poseería una comprensión de la política como un *modus vivendi*, en el cual la acción como desobediencia civil —expresada de formas tan variadas como redes sociales, marchas, paros, etc.— es la que validaría su propio actuar.

La alterlegitimidad, contra lo que supone Jaume, posee un mito fundante, al igual que la soberanía estatal. El de esta última es la idea de un contrato originario entre individuos iguales. No es casual el uso de figuras bíblicas en Hobbes, tanto para criticar como para legitimar y defender posiciones políticas. En el autor inglés existe una comprensión de la fuerza de las imágenes y su efecto, que lo anticipan a épocas posteriores. Por su parte, la “participación ciudadana” se articula sobre la idea del poder constituyente y el mito del *new beginning*. Si bien esto último ha estado ligado desde autores como Sieyes a la legitimización del poder constituido por uno constituyente en cuanto comitente, la alterlegitimidad hará uso de ellos (poder constituyente y *new beginning*) como un elemento “vivo”, que mantiene su accionar de forma permanente y, por ende, que desafía, constantemente, al poder ya constituido. De esta forma, la alterlegitimidad reclama para sí el verdadero uso del concepto *democracia*.

En este trabajo expondré, brevemente, aspectos centrales de la disputa entre la comprensión poshobbesiana de la democracia representativa y la idea alterlegitimizadora que calificará a esta como un oxímoron. Luego, referiré el caso particular del debate constituyente en

Chile y como este no puede ser dissociado, al menos no del todo, de esta misma discusión.

1. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: ¿UN OXÍMORON?

De modo global, se percibe un descontento hacia el sistema representativo que se ve reflejado en altas tasas de abstención, manifestaciones de movimientos sociales y surgimiento de partidos de protesta de todo tipo.

¿Qué explica este fenómeno? Una hipótesis posible es que se esté padeciendo lo que Thomas Jefferson señaló³, esto es, que la derrota del sistema democrático podría ocurrir, más que por una fuerza armada, por un aumento descontrolado de lo que él consideraba una “aristocracia financiera y bancaria”⁴. Según el propio Jefferson, a la pérdida del sentido del valor de la vida cívica podría seguir el afianzamiento “del poder del dinero” sobre la política.

La idea de Jefferson no tiene nada de excéntrica: es la forma en que se ha entendido el sistema democrático desde sus orígenes en el republicanismo. La democracia no es solo votar, sino dispersar institucionalmente el poder en la sociedad.

En el Estados Unidos actual poco queda del espíritu de Jefferson; su sistema político se encuentra influido por grandes corporaciones, al nivel de ser una suerte de *berlusconismo* sin Berlusconi⁵. Como lo ha explicado el filósofo italiano Maurizio Viroli⁶, no se requiere un líder como “*Il Cavaliere*” para que una democracia colapse y termine transformada en un caso de *berlusconización*: es suficiente con la pérdida del sentido cívico, reemplazar el debate público de ideas por imágenes y un paulatino deterioro de la diseminación del poder.

Ese *berlusconismo*, como lo ha indicado Viroli, es un sistema político sin precedentes en las democracias contemporáneas desarrolladas. Quizás su antecedente se encuentre en los gobiernos de los Medici en Florencia. La “*Famiglia*”, gracias a su poder, logró instaurar un régimen que, sin ser una dictadura, era una tiranía velada a favor de sus intereses. De igual forma, lo logró “*Il Cavaliere*”. Berlusconi apoyado no solo en su fortuna, sino además en un imperio comunicacional gigantesco, logró llenar el vacío político que significó el término del ciclo de gobiernos de

coalición entre demócrata-cristianos, socialistas y liberales, los cuales dieron estabilidad política a la península italiana en la posguerra. Por otras causas, a nivel global, parecen repetirse fenómenos similares.

Por lo excepcional, el *berlusconismo* es un caso que amerita ser considerado⁷. ¿Qué permitió su generación? El desmoronamiento de los partidos tradicionales, el clientelismo político, una población ampliamente impresionable por los medios de comunicación, un hombre que supo aprovechar su carisma, poder económico y comunicacional, no solo para conquistar a las masas, sino además para corromper al cuerpo político general de la nación. Pudo crear lo más parecido posible a un sistema no-democrático manteniendo la democracia formal. En ese sentido, el de Berlusconi no fue el gobierno de “una persona”, sino de un sistema.

Ya Maquiavelo vio con máxima claridad la posible corrupción del sistema político. La combinación de la ambición de unos pocos con la desidia ciudadana de una mayoría podía significar la pérdida de la libertad. Lo anterior puede ser de una forma no-violenta, como en la Florencia de los Medici: un sistema político que estaba al servicio de una familia. Los candidatos a “*Medici*” toman distintas formas en el mundo contemporáneo: corporaciones financieras, farmacias, medios de comunicación, empresas energéticas y un largo etc.

Como el *berlusconismo* es una enfermedad que afecta no solo a la tierra de Dante, sino que se expande a nivel global, cabe interrogarse si en el propio sistema democrático-representativo no existe una tendencia natural hacia él o, al menos, a ser afectado por este fenómeno.

Desde una perspectiva histórica, un régimen es democrático, si y solo si, quien legisla es el *demos* o los múltiples *demos*; lo anterior, solo puede ocurrir de dos formas: por acción directa de estos *demos* o por representación encarnada en un “retrato-abogado”. Autores como Jacques Ranciere sostendrán que lo segundo nunca ocurriría, por lo cual, el sistema representativo sería por esencia antidemocrático. La representación raptaría la categoría de sujetos *sui iuris* (ser los legisladores) a los “representados” (los ciudadanos) para transformar la “representación” en un momento básicamente hobbesiano, *auctoritas non veritas facit legem*: es la autoridad la que posee legitimidad (*legitimitat*) y quien otorga validez a las normas legales. Esa idea se encuentra en la base del concepto de validez (*geltung*) y del

dezisionismus del mismo Schmitt.

Por eso, desde Maquiavelo, se ha entendido la instauración de una república de ciudadanos libres como un momento revolucionario, de reflexión directa de quienes son los representados, dando especial voz a los que en la tradición retórica clásica, desde Córax y Tisias⁸, serán comprendidos como poseedores “de razonabilidad débil” en oposición a la “razonabilidad erudita o elitista” de unos pocos. Por ejemplo, Arendt rescatará en su obra *On Revolution* la idea de lo político como la capacidad de actuar en conjunto por un grupo de ciudadanos. Será esa capacidad lo que se expresaría en la tradición clásica bajo el concepto de *zoon politikon*. Precisamente, sería en ese acontecimiento público de la interacción colectiva donde se materializaría la libertad política de la ciudadanía. Desde esa mirada es posible apreciar el carácter fundante que posee cada momento revolucionario y evaluar hasta dónde implica un principio de posibilidad de la democracia como soberanía ciudadana.

Puesto en perspectiva con la tradición democrática, la fortaleza del sistema representativo no ha estado en su carácter “democrático”, sino en la generación de sus cualidades, primero hobbesianas y luego profundizadas por autores como Guizot, von Mohl o von Stein: producir orden y paz a través de la capacidad de procesar sistémicamente de modo menos traumático distintas formas de disenso social y crear bienestar social equitativo, esto último influye directamente sobre las posibilidades de “orden y paz”, así como la anulación de las diferencias de “*demos*” en la sociedad, para pasar a distribuir y garantizar derechos iguales para todos. Lo anterior sería lo que explicaría su carácter despolitizador. Lo que estaríamos presenciando es la percepción de que esa renuncia colectiva para la formación de la comunidad política es deficitaria respecto de uno de los atributos esenciales del sistema representativo, como es la administración de equidad, vale decir, producto de las profundas desigualdades se deslegitimizaría el sistema, lo que a su vez produciría en muchos la sensación de que la causa es de la estructura constitucional como ordenadora de la forma política.

En el sistema representativo se generaría el imaginario de que quien ordena realmente es el sujeto soberano o, si se quiere, que el pueblo manda; sería una ilusión compensatoria de exactamente la falta de eso. Cuando no existe la debida sensación de justicia social, esa “ilusión compensatoria” perdería su efectividad. Por eso, la desafección hacia los

llamados sistemas políticos democráticos ocurriría tanto por una incapacidad de satisfacer las expectativas de protección social como por un reclamo de si detrás de esa representación existe una “real democracia de un *demos* que posee la condición *sui iuris*”. La desigualdad socioeconómica, creciente con la globalización, produciría la impresión en los menos favorecidos de que la igualdad política moderna no existe en nuestra sociedad, sería solo nominal, algo que afectaría a la imagen de legitimidad tanto de lo que Weber entendió por una democracia social como por una política. Volveré más adelante sobre esta idea weberiana.

Lo que quedaría por ver es si acaso ambas formas, la “social” y la “política”, no son antitéticas. Por eso, parece pertinente analizar el contrapunto con respecto a esto por parte de dos autores clásicos que sintetizaron en su diferencias la forma “americana” y “europea” de entender el posible oxímoron *democracia representativa*: Tocqueville y Guizot.

2. LA DEMOCRACIA AMERICANA DE TOCQUEVILLE Y EL ESTADO ADMINISTRATIVO DE GUIZOT

Tocqueville comprenderá la democracia no como una forma de gobierno, sino como una tendencia, revolucionaria, que expresaría una condición moderna fundamental: la búsqueda de la igualdad. Por su parte, Guizot considera que la idea de la “democracia a la americana”, así entendida, no es un modelo que garantice estabilidad y gobernabilidad en el mundo moderno; solo lo sería un Estado social construido desde una soberanía que se exprese en un poder centralizado. Para Guizot solo el absolutismo y su fuerza central administrativa podrían originar una nación y una civilización, y solo ellos serán posibles promotores de la burguesía y de una nueva aristocracia que permita dar sustentabilidad a ese Estado social.

En una interpretación provocadora, Sandro Chignola reconstruye foucaultianamente a Tocqueville y destaca que si, en este, la democracia es una tendencia, lo que la caracterizaría es, básicamente, su carácter disociador. Esto significa que, para Chignola, la democracia disolvería las estructuras sociales y diferenciadoras existentes para dar paso a las condiciones de un individuo, ahora presocial y en la base de la democracia, lo que permite producir una función subjetiva serial y, desde

ella, la anulación de la diferencia. Es por eso que “sociedad” (como agregación de individuos) e “individuo” serían nombres colectivos. De lo anterior, se sigue que la democracia para Tocqueville (en palabras de Chignola) sería una instancia de desanidación y desestabilidad. Por eso, sería intrínseco a ella el problema de “su gobernabilidad”: ¿es posible el gobierno de la democracia? En términos generales, el problema del gobierno se podría resolver, siguiendo a Tocqueville y a Guizot, desde una división binaria: desde sociedades donde una fuerza externa a ella organizara los procesos sociales (Guizot), versus otras, como la americana, donde es la sociedad la que actuaría sobre sí misma (Tocqueville). Eso permitió a Tocqueville exclamar sobre ella: “El pueblo reina sobre el mundo político americano como Dios sobre el Universo. Sería inicio y fin de cualquier cosa”⁹. Esa particularidad americana estaría dada por las características únicas de su origen. Sobre esto último, parece relevante destacar que, en Tocqueville, las colonias de Nueva Inglaterra serían herederas de algo que se perdería en la Europa continental (al menos, en Francia), esto es: la libertad feudal. Esa pérdida, por un lado, será lamentada por Tocqueville, mientras que, por el otro lado y de modo contrario, será considerada por Guizot como un paso necesario para el surgimiento de la nación.

Por último, la “democracia americana”, a diferencia de la experiencia revolucionaria francesa, implicaría un rechazo al sistema representativo, al menos, en todo aquello concerniente al interés común y a la defensa de la libertad. Cuando las categorías de “individuo” y “sociedad” no están dadas desde el comienzo, la soberanía propia de la representación es una fuerza externa, es la encargada de someter de modo absoluto a las instituciones diferenciadoras existentes hasta despolitizar la *societas civilis* y poder dar paso a un “proceso de igualdad”. Ese proceso “modernizador absolutista” suscitaría un nuevo sometimiento, no ya “clasista”, sino la del sujeto de derecho moderno en favor de una forma abstracta de obligación institucionalizada. Esa igualdad homogeneizadora permitiría la concreción en el *rule of law* de lo que Sieyes describió como el “derecho como un círculo donde todos los puntos están equidistantes de su centro”¹⁰. Tanto para el ya citado Chignola como para Foucault en *Defender la sociedad*, la representación europea y el proceso de igualación que le acompaña serían una continuidad más del absolutismo. Lo anterior, tanto desde la perspectiva

de “todos poseen un señor”, como desde la integración despolitizada en una sociedad desdiferenciada de individuos libres e iguales. Por cierto, la libertad privada no sería más que la compensación que recibe el individuo en cuanto sujeto del derecho moderno frente a la pérdida que implica la sumisión frente al poder soberano. En ese sentido, la patogénesis del sujeto de derecho europeo poseería su origen en un “resentimiento antiaristocrático”. Arendtianamente se podría indicar que la pérdida del carácter político de los ciudadanos está dada por un incremento de lo “social”¹¹. Así, siguiendo tanto a Chignola como a la lectura que hace Foucault de la guerra interna como origen de la destrucción del orden feudal que permitió el surgimiento de la soberanía moderna, la existencia del proletariado no sería más que la constatación de que, en el fundamento de la “democracia europea como Estado social”, se encontraría la envidia que habría producido patologías como el mismo proletariado, cuyo surgimiento se explicaría por una “ortopedia social” necesaria para sostener una nueva forma de socialización política de tipo artificial.

En síntesis, la “democracia americana” se confirmó como un proceso de “gobernarse a sí mismo” mientras que su “versión europea-francesa”, por un aumento de un aparato central administrativo. El derecho administrativo sería reflejo de la utilidad pública y la razón pública.

Desde esa reconstrucción genealógica es posible establecer, al menos, cuatro objetivos a considerar críticamente:

a) La idea de soberanía construida desde una base que origina un poder que, como dirá Sieyes, es comitente y que garantiza cualquier derecho gracias a esa fuerza irresistible. Lo anterior supone una sociedad *sine imperio*. De tal modo, el sistema representativo sería hijo del absolutismo y toda forma política centralizada de tipo socialdemócrata (en un sentido amplio, incluyendo versiones como el conservadurismo gaullista, su versión socialdemócrata escandinava o el *Old y New Labour*) también serían representantes contemporáneos del mismo. Lo mismo aplicaría para toda forma de liberalismo ingenieril.

b) El burgués como un *free-rider* de la libertad y la forma negativa de esa misma libertad. Vista así, la figura del burgués sería lo opuesto a la libertad feudal del colono de Nueva Inglaterra que nos describe Tocqueville. ¿Cuál es la relevancia de esto? Para responderlo parece necesario determinar cuál es la naturaleza del juicio político y, desde ese

punto de partida, analizar las implicancias de la formulación negativa de libertad tradicional del liberalismo. La política, como bien indica Maquiavelo, se centra en el binomio gobernantes/ gobernados, vale decir, unos son los que ejercen el poder y otros los que lo padecen por medio de su aplicación. Por tanto, la distinción básica de la política será la de definir si la estructuración del sistema político será desde la mirada de quienes gobiernan buscando su legitimización o desde la de quienes son los gobernados, caso en el cual el eje sería la protección de los ciudadanos respecto de quienes poseen el poder.

c) El derecho natural moderno como una compensación del despotismo inherente al Estado moderno administrativo.

d) El sistema representativo implicaría la aporía de un proceso de estatización (el Estado y su *rule of law* es el soberano) y, a la vez, habría implicado la paradoja de ser quien consolida una despolitización y atomización de los individuos. Justamente, esto último se refiere a la génesis de lo que se entiende como la gobernanza de lo que, genéricamente, se designa como “neoliberalismo”.

Los centrales, me arriesgo a aventurar, serían a) y d), ya que b) y c) son solo condiciones de posibilidad de los otros dos, mientras que los primeros apuntan a la actualidad y a la manifestación del problema.

Si es así, parece pertinente preguntarse: 1. ¿Cuándo experimentaríamos la democracia? Si la idea de la libertad en Tocqueville es fuertemente antiburguesa y asumiría la forma de una “libertad medieval”, surge un segundo punto: 2. ¿Qué validez poseería esa libertad para un ciudadano que es (de modo creciente) un *free-rider* de una libertad no-política?

Aventuraré dos posibles respuestas:

Una posibilidad a la primera cuestión es que, si es una tendencia y no una forma de gobierno, solo existiría en espacios donde el acontecimiento (evento) que surge de la misma acción de los ciudadanos transforma una forma política o, al menos, la desafía. Por tanto, asambleas deliberativas directas, movimientos sociales o instancias locales participativas serían parte de la única posibilidad de vivir una experiencia democrática. Es el espacio de la alterlegitimidad.

Sobre lo segundo queda abierto el tema de si ese momento histórico que describe Tocqueville no se encuentra absolutamente superado, partiendo por EE.UU. Como ya verá el mismo Tocqueville, el triunfo de

Andrew Jackson marcaría un inicio de quiebre con lo que él mismo había visto en Estados Unidos. En este sentido, es plausible considerar el *New Deal* de Roosevelt como heredero de esa misma tradición jacksoniana. Luego lo será la Gran Sociedad de Johnson. Y, finalmente, desde otra vereda, pero igual de alejada de la libertad de pequeñas comunidades descrita por Tocqueville, el neoconservadurismo de los Reagan-Bush, así como la gobernanza de los *New Democrats* de Bill Clinton; todos serían negaciones a la democracia americana descrita por Tocqueville. Si es así, el único espacio para esa forma de libertad desaparecida sería la de la nostalgia conservadora (algo hay de eso en Strauss) o la de un horizonte normativo que permitiera una actividad crítica sobre el presente.

A este respecto, parece esencial volver sobre dos elementos centrales en la misma caracterización de Tocqueville de la democracia, no expuestos hasta ahora: la generación de una nueva religión y la tendencia a la satisfacción del bienestar material.

Sobre lo primero. La “nueva religión” poseería la característica de toda religión: una invención seguida por sus propios creadores. Sería la opinión pública; su profeta, “el público”. Si todos somos iguales y nadie posee una diferenciación que haga razonable el someter mi opinión a la de otros, se produce una nueva entidad, la cual sintetizaría la voluntad democrática: la opinión pública.

Respecto de lo segundo. El placer, como producto de la satisfacción material, sería un elemento central de la cultura democrática.

Guizot, la contracara de Tocqueville, nunca negó estas condiciones como propias de la modernidad. Es así como considerará clave para el orden político la posesión de una prensa que promueva la fidelidad hacia el Estado y la nación. Y, de igual forma, aplaudirá el talante emprendedor del burgués y su deseo de satisfacción material.

La democracia, como un “adolescente inquieto” que debe ser corregido y disciplinado, habría sido quizás superada (derrotada) por el hombre burgués y el Estado administrativo que, haciendo uso de lo que Chignola designa como una “ortopedia social”, logró ocasionar un bienestar suficiente como para legitimarse a sí mismo.

Hoy, lo paradójico, estaría en que si la democracia es una tendencia y si, efectivamente, solo se la vive y experimenta en circunstancias como las defendidas por la alterlegitimidad —esto es, por medio de movimientos sociales y asambleas deliberativas a nivel local—, su renacer en el

presente estaría vinculado (en no pocos casos) a la nostalgia por aquel Estado-social que la sepultó: ¿No es acaso en su nombre y la melancolía que produce la razón por la que en muchas ocasiones se marcha? Un estado social que, a su vez, habría sido muerto por la expansión de fuerzas que él mismo desató: el neoliberalismo. La democracia (ese Dios de Tocqueville) habría sucumbido históricamente frente al Estado-social administrativo, y este —producto del mismo tipo de individuo que fomentó—, frente al neoliberalismo. Si es así, quizás, como pocas veces, se pueda decir que “el que mató a Dios, ha muerto”.

3. EL PROBLEMA CONSTITUYENTE COMO MITO FUNDANTE

En lo que sigue, intentaré mostrar de modo general que la actual crisis político-institucional¹² está vinculada en su discusión a cuatro momentos que, por su parte, se relacionan con la contraposición entre legitimidad de la soberanía estatal por medio del *rule of law* y el *new beginning* defendido por la alterlegitimidad.

Se puede señalar que el problema constitucional actual es eucarístico¹³. ¿En qué sentido? John Milton distinguirá en el sacramento de la eucaristía dos opciones: aquella que lo asume como un acto recordatorio y simbólico, desde el cual se asigna un sentido, y quienes, por el contrario, confundiendo la realidad y alienados con un carácter racional, ven en este acto un momento real. Por tanto, en unos, su “comunión” es simbólica, mientras que, en otros, un estado mental alterado que, a juicio de Milton, les hace creer que lo simbolizado existe. O, si se desea, no se percibiría —como dice Hobbes— que los dioses paganos cobran vida solo a través de los sacerdotes que los ritualizan. El error para Milton estaría en dar una categoría de realidad ontológica a lo que es un ritual.

De modo similar, el momento originario de un “poder constituyente” puede ser leído como un símbolo hacia el cual se remite o, a la inversa, como una realidad que crea una “comunión” entre un momento presente y su capacidad de ser revivido. A la primera, de modo analógico, la podríamos considerar una interpretación “protestante” del “poder constituyente”, entendiéndolo como un símbolo dador de sentido; a la segunda, una interpretación “católica apostólica romana” (lo sintetizaré

en católica), en la cual el poder constituyente tendría la capacidad de detener el tiempo político cotidiano para dar paso a un momento extraordinario.

Para entender cómo, y en qué sentido, se da esta distinción en el debate, cuando existen defensores de una y otra posición, se requiere un rodeo previo, de cuatro momentos, antes de ir al tema en sí.

¿Cuáles son los cuatro momentos a ser considerados?

El primero es la democracia en cuanto a su sentido original. En uno de sus últimos trabajos conjunto de los historiadores Johann Arnason, Kurt Raaflaub y el sociólogo Peter Wagner se aborda lo que ellos califican una “invención” —en cuanto “producto cultural”— de la “democracia” en Grecia¹⁴. En esa obra colectiva, se muestran los elementos esenciales de esa “innovación cultural”, los cuales pareciera, como diría Hegel, que “reaparecen en todos los tiempos” y, por tanto, siguen presentes en el debate actual sobre la forma del sistema democrático. Partiré, en un primer momento, por abordar la pregunta: ¿Qué caracterizaba a esa idea de democracia?; y luego, en un segundo momento: ¿Cómo, con el contractualismo y el nuevo sistema representativo *a la* Hobbes, se rompe con esa tradición política anterior? Proseguiré, como parte de un tercer momento, con el intento de superación de la denominada “crisis de la democracia”, elaborada en el famoso reporte de 1975 de Crozier, Huntington y Watanuki, que realizaron para la Comisión Trilateral. Un elemento central en esa tesis será, respecto de “la crisis”, determinar: ¿A qué refiere? ¿Cuál sería el sujeto que la padece? ¿Lo sería (la crisis) tanto de la forma democrática original griega como del sistema representativo hobbesiano? Finalmente, como cuarto momento y final, cabe tratar de resolver si la extendida idea de *governance*, y la “eficiencia que le acompaña”, es la solución a la cual apuntaban en su reporte los ya mencionados Crozier, Huntington y Watanuki.

Para la comprensión de esos cuatro momentos y su posterior análisis sobre su relevancia con el debate constituyente propondré como piedra de toque de la discusión las ideas de “pueblo” y “ciudadanía”, las que mutarán y marcarán las diferencias. Ese punto de inicio de análisis no es arbitrario. Tanto los historiadores anteriormente mencionados, así como Josiah Ober (entre muchos), indicarán que la comprensión sustancial en Grecia del concepto de *demokratia* estaría dado por el uso del sufijo *kratos*-; mientras que, en sus formas opuestas, en la *monarchia* y la

oligarchia, la esencia definitoria sería la del sufijo *arché*-. De esta forma, el tema definitorio de la democracia pasará por la condición que *kratos*-aporta a *demos*. *Kratos* indicaría un poder (en el sentido webberiano de *Herrschaft*), una capacidad de actuar, y nunca, como erróneamente a veces se señala, el “número de algo”. De esa forma, *Demokratia* sería el poder del *demos*, de un colectivo.

Por el contrario, y siguiendo en esto también a Ober, el concepto de *arché* (determinante de los opuestos a *demokratia*) conllevaría tanto “número”, como el control de un aparato oficial previamente existente. Desde un punto de vista semántico implica tanto un “principio”, como un “imperio” (el dominio de un Estado más allá de sus límites), así también como una oficina (magistratura). Es así como *arché*- determinará, en un inicio, “principios de extensión numérica” (uno, pocos), de dominio de oficinas y magistraturas oficiales, hasta mutar en el tiempo para tomar la forma de “poder legítimo”. ¿Qué es lo relevante de estas distinciones? El punto es que por medio de los sufijos griegos de *arché*- y *kratos*- se marcarían tipos de gobierno opuestos desde su concepción más básica¹⁵. La importancia de esto está dada por lo que Cynthia Farrar —siguiendo a los autores ya indicados— sintetizará respecto del concepto original de democracia, el cual habría sido construido desde (1) la conciencia de la gente de su propio poder potencial, (2) la creación de instituciones que les permitieron darse cuenta de ese potencial y (3) la redefinición del status y el poder como realidades políticas y no como atributos sociales.

Por tanto, en nuestro primer momento, tenemos que: el concepto original de *demokratia* no implicaba una condición “numérica” sobre cuántos ejercían la función de dirigir las instituciones políticas. Por ende, la democracia griega de los siglos IV y V no era un gobierno de “los muchos” en contraposición tanto a la *monarchia* (el gobierno de uno solo) como a la *oligarchia* (el gobierno de unos pocos), sino simplemente la posesión por parte de un colectivo (*demos*) de un poder (capacidad) que no es institucional y que se designa bajo el concepto de *kratos*. Ese *kratos*, básicamente, se refleja en la capacidad de generar un juicio racional colectivo y de expresarlo retóricamente, por cierto, siempre en contraposición a los que poseen *arché*¹⁶.

El segundo momento es “la representación hobbesiana en el Estado-nación”. Hobbes marcará de modo decisivo no solo la idea de un régimen legítimo en cuanto reflejo de un sistema contractual representativo, sino

que, además, en cuanto a su conceptualización básica, al mismo liberalismo. En esta conceptualización, los ciudadanos serán entendidos como individuos atómicos que buscan satisfacer aspiraciones personales, no sociales. El derecho natural implicará su propio abandono para dar paso a una ley natural, la que tendrá como efecto más que la protección de los individuos, el legitimar la acción del Estado y la inviolabilidad del *rule of law* en vista a la seguridad, el orden y la paz. La libertad natural hobbesiana será una que, finalmente, no será sostenible ni valdrá la pena ser vivida en el estado de naturaleza. Lo que quedará de ella será la posibilidad de vivirla en todo aquello que implique “ausencia o silencio de ley”, esto es, en el espacio no-político de la vida social: los negocios, los placeres y la vida íntima de la familia. La organización de la estructura del Estado, su legitimización bajo el *rule of law* y el diseño del espacio “con ausencia de ley” para disfrutar de la libertad supondrán el desarrollo de una tecnología política de tipo ingenieril que operará desde la construcción institucional hasta la distribución de la libertad y su intercambio bajo la forma de una *comodity* frágil. Esta última tomará la forma de derechos naturales que aseguren igual libertad para todos. Es así, como ya desde ese momento se elimina la idea de ciudadano como la de un “sujeto con capacidad de actuar colectivamente” y se la reemplaza por la del burgués. La ideología burguesa hobbesiana permitirá la evolución tanto del liberalismo como de la idea del sistema representativo, configurándose (ambos) bajo una idea del Estado y el derecho. Se les entenderá a ambos como una economía de la injerencia gubernamental, cuyo accionar tendrá como paciente, lo que Chignola ha definido, un *free-rider* despolitizado que es depositario de derechos.

¿Qué explica el éxito de la forma estatal liberal moderna? Dos elementos ya indicados, estos son: la capacidad del sistema representativo *a la* Hobbes, en su origen y evolución, de producir orden y paz a través de procesar, sistémicamente, de modo menos traumático, distintas formas de disenso social y, de este modo, originar bienestar social equitativo. Sumado a lo anterior, la aportación “alemana” a la comprensión del Estado hobbesiano desde los ya mencionados von Mohl y von Stein (entre otros) serán cruciales para que este sea comprendido como un “procreador de bienestar social equitativo”.

Tercer momento: la denuncia de crisis y el surgimiento del ¹⁷. La crisis “revelada” en el texto que mencioné, el informe de Crozier,

Huntington y Watanuki de 1975, apuntaría a que la estructura vertical del sistema estatal moderno habría colapsado (en esa época, “estaría colapsando”) como producto de un incremento de las demandas sociales y la incapacidad del Estado por satisfacerlas. Esa incapacidad de respuesta estatal democrática estaría dada, a juicio del informe a la comisión trilateral, por un contexto global externo que ocasiona presiones hacia los Estados-nación, a los que se suman movimientos sociales internos que producen nuevos valores y sensibilidades, particularmente entre jóvenes e intelectuales, transformándoles en una nueva clase contestataria, y, por último, lo que a juicio de los redactores sería lo principal: las propias operaciones democráticas “habrían producido un quiebre de los significados tradicionales del control social, una deslegitimación de la política y otras formas de autoridad, y una *sobrecarga (overload)* de demandas sobre el gobierno que excede su capacidad para responder”¹⁸.

Lo crucial es la vinculación que efectúan entre “gobernabilidad” y “democracia”: sin la primera no sería posible la segunda. El debilitamiento de la “gobernabilidad” estaría dado por el resultado de los tres factores ya mencionados, los que, a su vez, tendrían como resultado el involucramiento en la actividad política de una proporción cada vez mayor de la población. Esto se vería reflejado en:

a) El surgimiento de nuevos grupos y alteraciones de la conciencia antigua de otros. Por ejemplo: minorías étnicas, sexuales, regionalismos, jóvenes, etc.

b) La aparición de nuevas estrategias de presión por parte de estos grupos.

c) El aumento en estas nuevas realidades sociales de la idea de que el gobierno tendría la obligación de satisfacer sus demandas y, a la vez, un aumento de las mismas y de las expectativas que crean¹⁹.

El resultado de lo anterior sería una saturación en “el gobierno” y la expansión de su papel en la economía y la sociedad, quedando afectada la misma gobernabilidad²⁰. En cierta forma, existe en el informe un reconocimiento a que la forma estatal moderna clásica no sería capaz de lidiar y responder a lo que hemos identificado como una pretensión de alterlegitimidad.

Hasta ahí el tercer momento.

El cuarto, y último momento: la solución de esa crisis pasaría por

reemplazar el Estado contractual de tipo vertical por una *governance* que se mida por su línea de resultados, por tanto, olvidarse de la “democracia de la representación” para dar paso a la “democracia de los resultados o eficiencia”²¹. Como indica al respecto Chignola²², esto implicará un paulatino disminuir del Estado y una creciente desregulación para así ganar en gobernabilidad y descomprimir a un Estado agobiado. Cabe recordar, y no olvidar, que se estableció la gobernabilidad como posibilidad de la democracia, por tanto, si del proceso de desregulación y jibarización estatal se recupera gobernabilidad, necesariamente, gana factibilidad la democracia. Por eso, es un proceso de “gobernanza sin gobierno” (*“governance without government”*). Esto implica reconceptualizar, obligatoriamente, la espacialidad de lo político, disminuyendo su rango de acción. Básicamente, las formas de *governance* buscan responder eficientemente a demandas que van más allá de las formas políticas clásicas de representación, por eso, *governance* conlleva una forma de autorregulación que posee un solo principio normativo: los mecanismos propios del mercado.

Tanto los momentos dos, tres y cuatro asumen la necesidad, ya sea para resguardar la paz y el orden, o para garantizar la gobernabilidad y, por ende, tener una democracia “factible” de un ciudadano *free-rider*, esto es, “uno que es receptor de espacios de libertad, pero no constructor de los mismos”. Como ya se ha señalado, el sujeto *free-rider* es el opuesto al de la tradición democrática griega y posteriormente republicana, donde se entiende al ciudadano como eminentemente político, donde esa condición está dada por la capacidad de actuar con dominio. Por el contrario, en la forma hobbesiana, la única opción *sui iuris* (ser su propio legislador) lo es de la *persona ficta* del Estado. Mientras que en la *governance* lo es, finalmente, una realidad entendida como anterior al Estado mismo: el Mercado. Es desde esa realidad, transformado en principio rector, desde la que se dará cuenta de la libertad como una adjudicación a un *free-rider* y que se materializa en la forma de múltiples emprendimientos privados. En cierta forma en la comprensión del *governance*, la legitimidad no está dada por un “pueblo que es representado”, sino por la eficiencia medida de acuerdo a la capacidad de mantener y acrecentar el mercado y adjudicar sus beneficios a los *free-riders*.

4. COMENTARIOS FINALES

Desde estos cuatro momentos se puede señalar que la discusión actual sobre la naturaleza de un orden constitucional y, desde ahí, de los mecanismos más apropiados para su legítima generación descansa, básicamente, sobre una comprensión previa de los ciudadanos y a partir de la cual se entienden otros conceptos tales como democracia, gobernabilidad, poder constituyente y poder constituido²³.

Solo así se puede entender la constitución como un acto fundante original de un pueblo que posee, como dirían los griegos, un *kratos* para darse su propio ordenamiento. Esa estructura argumentativa se encuentra en la base de quienes defienden procesos constituyentes del tipo de “asambleas constituyentes sustantivas” y no solo formales, donde efectivamente el “pueblo” delibere.

Por su parte, quienes se oponen a mecanismos como una asamblea constituyente, en cierta forma, asumen que la idea de un “colectivo como el pueblo con la capacidad de generar un juicio racional colectivo y expresarlo en una decisión” es una quimera que toma una forma ideológica y que, como veían los autores mencionados de la “crisis de la democracia”, conlleva una politización de una ciudadanía que se arriesga así a producir una crisis de gobernabilidad. Por tanto, la ciudadanía no puede tener un *kratos*- ni ser su propio legislador, sino que por el contrario, solo individuos *free-rider*, moldeados por una naturaleza performativa de la actividad política y que vía simbólica (votación) validan un sistema. Desde esa mirada, lo mejor que se podría decir sobre la opción “católica del poder constituyente” es lo que indicaba el bando aristocrático en la Grecia clásica sobre la idea de un *demos* que posee un *kratos*:- es simplemente el gobierno de los muchos por sobre los “pocos que saben”²⁴.

En la comprensión de los procesos de legitimidad en la modernidad, ocurre lo que un autor como Menke describe como la expansión de una semántica de igualdad en la forma de la extensión de derechos subjetivos, tanto políticos como sociales. Dentro de ese proceso se entenderán como normativamente justificados solo aquellos sistemas que poseen un fundamento democrático. Visto de este modo, dictaduras como la de Stalin, Franco o Pinochet, independientemente de la eficacia mostrada por los sistemas político-jurídicos que las ampararon, carecen de

reconocimiento normativo.

Por eso mismo, no sería comparable el origen cuestionable (no-democrático) de una constitución originada pos Segunda Guerra Mundial, de otros casos anteriores donde esa “conciencia normativa” se encontraba menos asentada y generalizada. Por ejemplo, si bien la Constitución estadounidense y su posterior Carta de Derechos están pensadas originalmente solo para “blancos poseedores de propiedades” y, luego, por evolución jurídica, se fue produciendo la inclusión de toda la sociedad americana, logrando así su validación, lo cierto es que ese origen, históricamente, responde a un período donde la “revolución de la subjetividad” propia de la modernidad se encontraba menos extendida. Es más, tanto las estructuras institucionales posteriores a 1945, así como los discursos políticos, no son comparables con situaciones anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Posterior a ella, y de modo creciente, se extenderá la conciencia de la igualdad, los derechos y la participación a niveles sin precedentes. Por eso, la constitución del *apartheid*, por su origen, y aunque hubiese sido reformada, era imposible su mantención por lo que simbólicamente representaba para una nueva sociedad democrática y no-racial en Sudáfrica ²⁵.

El segundo punto se relaciona con un factor diferente: el que la democracia no estaría satisfaciendo las expectativas de la población. ¿Cuál es la naturaleza de esas expectativas?

En el mundo moderno, el sujeto económico y el de derecho se constituyen de modo distinto. Como indica Maurizio Lazzarato, el hombre económico y el sujeto de derechos dan lugar a dos procesos de constitución absolutamente heterogéneos: el sujeto de derechos se integra al conjunto de sujetos de derechos mediante una dialéctica de la renunciación²⁶. La constitución política supone, en efecto, que el sujeto jurídico renuncie a sus derechos, que los transfiera a alguien más. El hombre económico, por su parte, se integra al conjunto de sujetos económicos (constitución económica), no mediante una transferencia de derechos, sino mediante una multiplicación espontánea de intereses. Uno no renuncia a su interés. Lo relevante respecto de lo nuestro es que la constitución diferenciada del sujeto económico y el de derecho suscitará una bifurcación en el sistema político, que es lo que Weber describe como democracia social y democracia política; como señala José Luis Villacañas, reconstruyendo el argumento weberiano:

La democracia social aludía a la estructura igualitaria y liberal que disolvía los férreos condicionantes estamentales y se apresuraba a diferenciar a los seres humanos por su condición de consumidores y por su localización en la estructura del trabajo y del mercado. La democracia política, por el contrario, incorporaba elementos de virtud y responsabilidad específicamente políticos, que tendían a disminuir tanto como fuera posible el poder del ser humano de imponer su voluntad a sus semejantes. La democracia social funcionaba mediante la masiva incorporación de los seres humanos al proceso productivo, la tecnificación de los saberes, la profesionalización de la vida y la movilidad social, que implicaba la disolución incluso del último intento de representar y estabilizar la estructura social en términos de sociedad de clases. La democracia política, por el contrario, reclamaba compromisos prácticos y epistemológicos de envergadura, todos ellos dirigidos a formar un poder funcional y limitado, a controlar a los representantes políticos, a exigir como única forma de mando la delegada por ordenamientos jurídicos, racionales y flexibles, capaces de prestar atención a los intereses de las mismas masas. La primera se basaba en la libertad como independencia y la segunda en la libertad como obligación autoimpuesta. La primera aspiraba a ofrecer en el mercado suficientes bienes como para cubrir las necesidades; la segunda debía asegurar una distribución más o menos equitativa de esos bienes. A esta función, que aportaba el contenido material de la democracia política, Weber la llamó “socialización”²⁷.

Podemos contestar entonces a la pregunta por la naturaleza de las expectativas de la población: las expectativas que se buscan cubrir son las de un déficit de democracia social y política *a la* Weber. Como ya se señaló, en el sistema representativo se engendra el imaginario de que quien ordena realmente es el sujeto soberano o, si se quiere, que el pueblo manda; es una ilusión compensatoria de, exactamente, la falta de eso. Cuando no existe la debida sensación de justicia social, esa “ilusión compensatoria” pierde su efectividad.

Maquiavelo, entre sus múltiples legados, nos dejó que la política es básicamente contingencia, es decir, que no existe ningún factor que la condicione. Su lógica está dada por una mayoría que no desea gobernar ni ser gobernada y una minoría que desea gobernar pero tampoco desea ser gobernada. En este escenario, lo que las instituciones hacen es mediar entre ambos grupos, estableciendo balances y, de esa forma, procesan esa contingencia intrínseca al sistema político, pero siempre estando latente aquella opción fundacional de un nuevo orden, como es una revolución. Esa tarea mediadora de la contingencia que ve Maquiavelo solo podría

ser cumplida si se le asigna a los procesos constituyentes, incluyendo a las distintas opciones de “asamblea constituyente”, las dimensiones que realmente posee: un cambio dentro de un sistema representativo, sean esos “representantes” obtenidos por elección, sorteo o designación, con la carga de elitismo (por la inevitable exclusión inherente a la separación categorial representantes/ representados) que un proceso así genera.

Para finalizar, y a modo de síntesis, las posiciones enfrentadas respecto del nuevo ordenamiento constitucional que el país requiere implican, de modo fundamental, una idea sobre la ciudadanía y, desde ella, se determinan las respectivas visiones que desde cada una se tienen sobre el Estado, la sociedad y sistemas tales como el económico. De los cuatro momentos recién descritos, se desprende una visión de los ciudadanos radicalmente opuesta: desde la idea original griega de una comunidad con la capacidad de ejecutar juicios racionales colectivos (rescatada por la alterlegitimidad como *modus vivendi*), pasando por la de unos *free-rider* que por medio de una abstracción identitaria han autorizado a unos representantes a actuar por ellos, hasta, por último, el *governance* que buscaría superar la crisis en la que habría caído el Estado representativo por medio de la racionalización de los espacios político-estatales y su reemplazo por espacios racionalizados autónomamente por medio de la lógica del mercado, lo que a su vez sería el reflejo de la misma libertad que vive el *free-rider* en forma de “consumo”.

La forma política del Estado es una discusión sobre la articulación de la soberanía, la representación y el concepto de libertad que hace de bisagra entre ambos. En el momento en que la simple racionalidad de las instituciones y de la economía no pueden dar respuesta cabal a las aspiraciones de equidad y participación democrática de los ciudadanos, necesariamente se vuelve sobre un debate estrictamente político, como bien lo ha indicado Chantal Mouffe. En la descripción de la autora belga, lo político implica un sentido de diferencia y disputa. A lo que asistiremos, paulatinamente, será a una confrontación entre quienes defenderán (en la izquierda y derecha) un camino reformista de tipo institucional versus quienes (en la derecha e izquierda) sostendrán alguna forma de participación popular alterlegítima. Y, más aún, en ambos lados de la confrontación podrá haber un sentido político o la negación del mismo por medio de la anulación de la deliberación.

Si, por un lado, se entiende al Estado solo como un centro

administrativo-técnico, la institucionalidad-democrática solo como desarrollo de políticas públicas; y, por el otro, se usan conceptos como “popular”, “ciudadano”, “la gente” (entre varios más) como *marketing-imagen* o una oferta demagógica, estamos en ambos casos frente a formas no-políticas. Una mirada institucional-democrática, por el contrario, requiere de una defensa permanente en el plano de las ideas, de ir repensando su comprensión de elementos tales como la representación y la expansión de ámbitos de no-dominación ciudadana, así como las posibilidades de real participación y legitimización de tipo *alter-*, que no parte de una idea de “líder” o de “satisfacción de la masa”, sino de una idea de “ciudadanía”, a partir de la cual se construye una idea de democracia participativa; ambas son formas políticas y no necesariamente excluyentes.

En resumen, si el poder constituyente es la forma eucarística que legitima el poder político, debemos volver al inicio: Milton indicará que la forma eucarística es siempre metafórica, solo la irracionalidad católica podría creer lo contrario. De igual forma, señala —expresamente contra Hobbes— que es una metáfora el que por un contrato el pueblo ceda su soberanía, esta siempre permanece junto a él, junto al pueblo. Por su parte, Hobbes, denunciará también el uso de los católicos de la eucaristía, pero con un matiz distinto. El autor del *Leviatán* indicará que por medio de una metáfora, y aprovechándose de la credulidad de sus fieles, los hacen creer que en ese pacto, en esa comunión, ellos siguen presentes.

IV. ÓRDENES NORMATIVOS TRANSNACIONALES: EL CONSTITUCIONALISMO DEL DERECHO INTRA Y TRANSNORMATIVO

Poul F. Kjaer

1. INTRODUCCIÓN

La función central del derecho del Estado-nación es la mantención de expectativas normativas¹. En contraste, el derecho transnacional se orienta primariamente hacia el establecimiento de marcos de transferencia y adaptación mutua². Esta función, sin embargo, no se despliega exclusivamente dentro de marcos interestaduales. En lugar del derecho transnacional, ha emergido una categoría de derecho más extensa, que trata transferencias y adaptaciones entre órdenes normativos como tal. Este tipo de derecho, en cuanto es caracterizado por una relativa supremacía estructural de estructuras de expectativas cognitivas antes que normativas, puede ser también entendido como una forma específica de derecho transnормativo, debido a su orientación primaria hacia el establecimiento de una adaptabilidad incremental mutua entre órdenes normativos.

Las perspectivas actuales tienden a entender la relación entre las dimensiones normativa y cognitiva del derecho sobre la base de una perspectiva de suma cero, en la que más de una implica menos de la otra. La distinción entre las dimensiones normativas y cognitivas del derecho es, sin embargo, condicionada de forma lógica por la relevancia continua de ambas dimensiones. Desde un punto de vista sociológico, la relación entre las dimensiones normativas y cognitivas del derecho son, además, caracterizadas por una relación de incremento mutuo, donde más de una implica más de la otra. En vez de experimentar marginalización, la comunicación legal de base normativa ha sufrido una reconfiguración, la

cual transforma incrementalmente la dimensión normativa en un componente estratégico, más que táctico. Esto, nuevamente, es la razón central de la emergencia de semánticas constitucionales más allá del Estado en las décadas recientes, en la medida en que estructuras constitucionales son el marco a través del cual es alcanzada una estabilización normativa de segundo orden respecto de los procesos legales orientados, primariamente, de modo cognitivo.

El área de mayor avance de este desarrollo ha estado en relación a los procesos sociales caracterizados por una primacía de la diferenciación funcional y una reducida dependencia en formas de diferenciación estratificadoras y territoriales como formas de estabilización interna. En estos arreglos, han emergido marcos de tres dimensiones que descansan en los conceptos de constituciones, constitucionalización y constitucionalismo, y que sirven como formas legales de las dimensiones de autorreflexión, prestación (*Leistung*) y producción de la función de procesos sociales. Las constituciones se entienden aquí como formas internas de ordenamiento orientadas al establecimiento de una jerarquía de normas; la constitucionalización, como el proceso a través del cual intercambios y transferencias entre entidades sociales y sus entornos son estabilizadas legalmente; y el constitucionalismo, como la forma legal específica a través de la que la unidad del pasado y el futuro son fijadas. El marco transnacional para la denominación de comercio justo ilustra estas ideas.

2. LA EXPANSIÓN DE UNA ESTATALIDAD LIMITADA

La mayoría de las perspectivas sobre el constitucionalismo en el ámbito global, explícita o implícitamente, parten del supuesto de que se puede observar un debilitamiento de la estatalidad y de que, tal desarrollo, es uno de los cursos primarios para la emergencia de un constitucionalismo más allá del Estado³. De diversas formas, esta perspectiva refleja una comprensión cruda y simplificada de la estatalidad. Desde un plano puramente numérico, el número de Estados ha continuado expandiéndose rápidamente a lo largo de los últimos dos siglos, en especial durante los últimos 50 años. Más aún, en términos de alcance, solo recientemente el fenómeno de la estatalidad ha adquirido un estatus global, a saber, como resultado de los procesos de descolonización de

mediados del siglo xx⁴. Así, observado desde una perspectiva histórica de largo alcance, podemos afirmar que una expansión cuantitativa y sin precedentes en la estatalidad ha tenido lugar en la historia reciente. Sin embargo, la estatalidad ha continuado expandiéndose también cualitativamente. Si uno caracteriza a un “Estado fuerte” sobre la base de una distinción formal y operativa entre el Estado y otros segmentos de la sociedad, en un arreglo institucional de carácter estable y una amplia capacidad, aunque no necesariamente exclusiva, de desplegar el poder político de modo generalizado a lo largo de su territorio, entonces es posible argumentar que hoy en día, y antes que en cualquier período histórico previo⁵, una mayor parte del planeta se caracteriza por una estatalidad fuerte.

Pero la expansión de la estatalidad no implica que la sociedad centrada en el Estado, a la cual se refieren académicos como Dieter Grimm⁶ y Martin Loughlin⁷, se encuentre viva y en buen estado. Una sobria perspectiva histórico-sociológica muestra que una sociedad centrada en el Estado —en la cual todas las operaciones sociales dentro de un territorio dado están limitadas por la supremacía del Estado, mientras que, al mismo tiempo, esta sociedad basada en el Estado permanece claramente demarcada de otras sociedades—, de hecho, no ha existido nunca. El Estado, entendido como una distintiva entidad política, siempre ha estado enfrentado a la competencia de extensivas formas de ordenamiento fuera del Estado. Por ejemplo, como Chris Thornhill plantea, el Estado alemán fue incapaz de desplegar su poder político de modo incuestionable a lo largo de su territorio hasta cierto momento dentro del siglo xx, luego de que formas de ordenamiento privado, basadas en la nobleza, colapsaran finalmente a raíz del nacionalsocialismo y la Segunda Guerra Mundial⁸. De modo similar, se podría argumentar que el gobierno federal de Estados Unidos no ganó autoridad incuestionable en los Estados Unidos del sur hasta algún momento durante la mitad del siglo xx, porque hasta ese entonces el poder federal era continuamente rebatido por contramovimientos localistas. Más aún, en lugares como el sur de Italia, el sudeste de Turquía y el País Vasco, contramovimientos similares continúan en boga en la actualidad, así como la fuerte presencia de estructuras de poder localistas siguen siendo la norma en la mayor parte de África, Asia y América

Latina, creando así una base para el pluralismo legal⁹. De tal modo, la mayor parte del mundo no ha sido aún sujeta a una efectiva codificación hegeliana de la sociedad constituida en su totalidad por el Estado. En su lugar, el Estado actúa solamente como un delgado barniz que cubre formas muy persistentes de ordenamiento social privado y local que operan bajo su juicio.

Sin embargo, más importante que esta visión legal pluralista es el hecho de que la estatalidad moderna ha estado siempre unida a la reproducción de un número bastante específico de funciones sociales. Así, a pesar de que una gran parte del mundo se caracteriza gradualmente por un tipo de estatalidad moderna en el cual una limitada, pero generalizada, forma de poder político es desplegada a lo largo de su campo territorial, ello no significa que todas las operaciones sociales dentro del territorio en cuestión se circunscriban automáticamente al poder político. Este, fundamentalmente, permanece incapaz de definir o controlar, por ejemplo, las creencias religiosas, la belleza del arte, la valoración de las noticias o las verdades científicas. La supremacía política existe solamente en relación a las funciones sociales específicas, aunque sumamente fundamentales, del poder político, tales como el ejercicio legítimo de la violencia física¹⁰. Una consecuencia de esto, como ha observado Gunther Teubner, es que incluso los regímenes totalitarios del siglo xx no fueron capaces de erradicar la existencia de fuentes de sentido (*Sinn*) independientes dentro de espacios como el arte, la ciencia, la religión y la economía. Estos regímenes, más bien, simplemente suprimieron estas esferas de la sociedad, forzándolas a una existencia subterránea¹¹. Otra consecuencia de la limitación estructural inherente al poder político moderno es que la idea de “democracia radical” permanece como *fata morgana*, en cuanto que el tipo de toma de decisiones democrática que ha emergido en los Estados-nación es una forma institucional relacionada directamente a las particularidades del medio del poder político¹².

3. LAS MÚLTIPLES CAPAS DE LA SOCIEDAD MUNDIAL

Cuando el diagnóstico de la estatalidad, en la forma de un ordenamiento político que se expande pero que, no obstante, es limitada, está conectado

al tema de la globalización, se vuelve evidente que uno no puede, y no debe, ver la estatalidad y la existencia de formas extensivas de ordenamiento social transnacional relacionadas entre sí en la base de un juego de suma cero. Por el contrario, ambas dimensiones de la sociedad mundial se encuentran engranadas en una relación de incremento mutuo. Mientras que el discurso de la globalización se basa en el supuesto de un incremento radical en la importancia y centralidad de formas de ordenamiento social transnacional¹³, una perspectiva histórica revela que las formas de ordenamiento nacional y transnacional emergieron en conjunto¹⁴. Las primeras organizaciones internacionales modernas, públicas y privadas, aparecieron a principios del siglo XIX, un periodo en que, cubriendo una parte extremadamente limitada del territorio global, solo existía un puñado de Estados modernos. De tal modo, la expansión radical en la densidad de las formas de ordenamiento transnacional moderno en los últimos 200 años se desplegó de la mano de la igualmente radical expansión de la estatalidad. En ambos casos, las ulteriores expansiones, más intensas, tuvieron lugar en los últimos 50 años, subrayando así aún más la constitutividad (*constitutiveness*) mutua de las dos formas de ordenamiento. De tal modo, no existe una contradicción inherente entre la estatalidad y el ordenamiento transnacional. Al contrario, los dos fenómenos emergieron en un movimiento doble que implicó tanto una globalización gradual de la estatalidad como un reemplazo gradual de la forma colonialista de transnacionalidad, caracterizada por una fuerte dependencia en la diferenciación de centro/ periferia, con el tipo de regímenes funcionalmente diferenciados que constituyen la forma central del ordenamiento transnacional en la actualidad¹⁵. En resumen, las formas de ordenamiento nacional y transnacional han continuado expandiendo su alcance de modo mutuamente constitutivo, tal como, al mismo tiempo, la más profunda de sus expansiones permanece mucho más limitada de lo que se asume normalmente debido a la existencia continua y vital de formas de ordenamiento social-localista, que operan debajo de ordenamientos basados en el Estado y en espacios transnacionales.

De esto se sigue que el concepto sistémico de sociedad mundial —que presenta la idea de que solo existe una sociedad, la cual se caracteriza, principalmente, por relaciones horizontales entre sistemas funcionales como la política, el derecho, la religión, la economía y el arte— es

inadecuado. Es inadecuado en cuanto no reconoce suficientemente el valor independiente de la dimensión vertical de la formación de estructuras en la sociedad mundial, como se refleja, fundamentalmente, en los distintos principios organizacionales y en las lógicas que caracterizan las formas locales, nacionales y transnacionales de ordenamiento social en el ámbito global. Una perspectiva sistemática de dos dimensiones, que tome en cuenta tanto las estructuras verticales como las horizontales, implica, sin embargo, que las estructuras transnacionales y las nacionales no pueden ser consideradas equivalentes funcionales, es decir, que poseen una cualidad que las vuelve mutuamente sustituibles¹⁶. Más que una globalización de regímenes societales ya existentes, que hasta entonces habían estado incorporados en los contextos nacionales, los regímenes transnacionales constituyen un tipo diferente de regímenes que cumplen funciones sociales bastante distintas. Esto también se refleja en sus diversos orígenes. Los complejos conglomerados constitucionales, que en el lenguaje diario son descritos como Estados-nación, crecieron gradualmente, a través de una metamorfosis, desde los órdenes feudales existentes¹⁷. Los regímenes transnacionales de hoy en día, por su parte, emergieron primariamente desde dentro de la forma colonial de ordenamiento transnacional¹⁸, a través de la reconfiguración de procesos de formación de estructuras transnacionales, lejos de la de la dependencia de diferenciaciones de centro/ periferia, y hacia una dependencia incrementada de la diferenciación funcional como su principio de organización central.

4. EL DERECHO INTERNO Y EXTERNO DE LOS ÓRDENES NORMATIVOS: CONDENSACIÓN Y TRANSFERENCIA

El término 'transnacional', sin embargo, es problemático, ya que refleja el prejuicio de nuestro aparato conceptual centrado en el Estado. Es un término definido de modo puramente negativo, lo cual simplemente refiere a una estructura “no-estatal” que posee un alcance espacial que se extiende más allá de los bordes del Estado¹⁹. En la práctica, por tanto, el término implica que el concepto de Estados(-nación) sea defendido como el objeto central del análisis. Esto ha llevado a autores del derecho transnacional a argumentar que la sociedad, y no el Estado, debería ser

considerada la fuente central de la creación del derecho ²⁰. Aunque en principio cierto, el concepto de sociedad, sin embargo, permanece muy amplio e indeterminado para servir como la unidad de análisis principal. Es por ello que los órdenes normativos son un objeto de análisis más adecuado. Los órdenes normativos —como tribus, clanes, Estados, organizaciones, regímenes y redes— se localizan dentro de cada una de las tres capas de la sociedad mundial y comparten la habilidad de generar fuentes de sentido (*Sinn*) independientes, a través de la reproducción de límites externos en la base de mecanismos de inclusión/ exclusión. Internamente, los órdenes normativos son caracterizados, más aún, por un esfuerzo hacia el establecimiento de un arreglo coherente de reglas, reflejado en estructuras de expectativas (*Erwartungsstrukturen*)²¹ específicas que se conectan con el desarrollo de sanciones legales como medios para establecer conformidad con estas. O, puesto de forma distinta, para una estructura social, la condición para convertirse en un orden normativo es adquirir una forma legal generalizada.

Antes de las demasiado estrechas categorías de derecho nacional y transnacional (siendo este último descrito a veces como derecho internacional, global o mundial), resulta fructífero introducir una distinción entre las dimensiones internas y externas del derecho de los órdenes normativos. En el discurso del derecho transnacional, global y mundial, aún en proceso de maduración, estas formas de derecho se consideran a menudo equivalentes funcionales del derecho del Estado-nación, en el sentido de que las dos formas de derecho cumplen funciones societales idénticas y, por tanto, son mutuamente sustituibles²². La distinción entre el derecho interno y externo de los órdenes normativos, no obstante, provee de una base para una visión distinta²³. De hecho, ambas dimensiones del derecho refieren al mismo signo de validez (*Geltungssymbol*) interno —a saber, el código derecho/ no-derecho—, el cual sirve como el impulsor central de reflexividad por medio del cual la autopreservación del derecho está asegurada. De modo similar, la prestación (*Leistung*) que las dimensiones internas y externas del derecho de los órdenes normativos producen en relación a otros segmentos parciales de la sociedad mundial permanece inalterable, en cuanto que ambas dimensiones se orientan hacia el manejo de conflictos sociales que ocurren en otros segmentos parciales de la sociedad. La diferencia fundamental, y sumamente decisiva, entre el derecho interno y

externo de los órdenes normativos puede encontrarse en relación a sus respectivas funciones respecto de la sociedad mundial en su totalidad. La función primaria de la dimensión interna es asegurar la condensación positiva, llevada a cabo a través de la reiteración²⁴ del orden normativo en cuestión, por medio del establecimiento de una convergencia general de las estructuras de tiempo reproducidas por ese orden (*Gesamtgesellschaftlicher Zeitausgleich*)²⁵. Relativizando en cierto modo la tesis luhmanniana de la sociedad mundial, esto significa que los órdenes normativos en su configuración interna pueden entenderse como sociedades en cuanto que “la función más general de una comunidad social es articular un sistema de normas a una organización colectiva que posee unidad y cohesividad”²⁶.

La función externa del derecho de los órdenes normativos es el opuesto directo. En vez de condensación, su función es facilitar la transferencia entre distintos órdenes normativos legalmente condensados de componentes sociales compactados (*Sinnkomponente*), tales como productos económicos y capital, conocimiento científico, creencias religiosas, decisiones políticas y competencias educativas. Como es aparente también dentro del contexto jurídico de la Unión Europea en el enfoque de las leyes de conflicto de Christian Joerges²⁷ y en la teoría del derecho mundial de Marc Amstutz, usando como ejemplo el derecho privado de la responsabilidad social corporativa²⁸, el derecho externo de los órdenes normativos está esencialmente orientado hacia el establecimiento de compatibilidades entre distintos órdenes normativos legamente condensados. Expresado de modo distinto, aunque tanto las dimensiones internas como las externas del derecho de órdenes normativos producen elementos de integración positiva y negativa, ambas formas se caracterizan por una asimetría estructural fundamental en cuanto que el derecho interno de los órdenes normativos posee un sesgo, construido internamente, en favor de la integración positiva a través de la condensación, y el derecho externo, un sesgo a favor de la integración negativa por la vía de la facilitación de transferencia²⁹.

No es sorprendente que, dentro del actual debate académico sobre la globalización del derecho y el ordenamiento constitucional, participantes inclinados ideológicamente tiendan a analizar las implicaciones de la distinción entre dimensiones internas y externas de los órdenes normativos como una diferencia entre perspectivas republicanas y

liberales³⁰. Yendo más allá de estas indulgencias semánticas que solamente logran arañar la superficie de lo social, las funciones fundamentalmente diferentes de las dimensiones internas y externas del derecho de los órdenes normativos entregan una explicación de la constitutividad mutua entre formas nacionales y transnacionales de ordenamiento en la sociedad mundial. La incrementada condensación interna de un orden normativo implica la fortificación de sus límites a través de la activación de mecanismos de exclusión³¹. Pero resulta aún más decisivo el hecho de que la mantención efectiva de límites presupone siempre una adaptación al entorno en el cual estos límites son creados. Es, por tanto, un postulado central de la teoría de sistemas que la clausura incrementada de una entidad social es la condición para una apertura incremental y viceversa³². O expresado de otro modo, la condensación aumentada está condicionada por una posibilidad de transferencia incrementada. Por ejemplo, la transformación de Inglaterra y Países Bajos en los primeros Estados modernos en la modernidad temprana estuvo fuertemente unida al hecho de que, comparativamente, eran economías abiertas, a la vez que el fortalecimiento gradual de estos Estados estaba estructuralmente relacionado a su arraigo a extensivas formas de ordenamiento transnacional, basadas en el derecho privado a través del colonialismo³³. De la misma manera, los Estados más modernos de la actualidad, como aquellos ubicados en América del Norte y el nororiente de Europa, permanecen como los Estados con las economías más abiertas y con los mayores niveles de arraigo en los marcos transnacionales, como el sistema de alianza cuasi imperial de Estados Unidos y la Unión Europea. Más aún —y de forma contraintuitiva—, una fuerte correlación parece existir entre la apertura (económica) del Estado y el tamaño de su sector público. Mientras más abierta es la economía, más grande tiende a ser el sector público, ya que la apertura incrementada significa volatilidad, de modo que se crea una necesidad funcional para la introducción de mecanismos de estabilización³⁴.

5. LA RECONFIGURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE EXPECTATIVAS COGNITIVAS Y NORMATIVAS

Las funciones fundamentalmente distintas del derecho interno y externo de los órdenes normativos, como se expresa en sus respectivas orientaciones hacia la condensación y transferencia, están también reflejadas en la estructura de expectativas sobre las que se basan las dos formas de derecho. Como dijimos antes, la teoría de sistemas propone la idea de que existe solo una sociedad, esta es, la sociedad mundial³⁵. Además, las estructuras de la sociedad mundial, incrementalmente globalizadas, se caracterizan por una aumentada dependencia en las estructuras de expectativas cognitivamente fundadas, entendidas como expectativas sujetas a revisión en caso de decepción, y por una disminuida dependencia en estructuras de expectativas fundadas normativamente, entendidas como expectativas mantenidas a pesar de su decepción³⁶. Esta dislocación es vista en conexión a un incremento relativo en la centralidad de procesos sociales con un fuerte componente cognitivo, como aquellos relacionados a la ciencia, la tecnología y la economía, y a la concordante disminución relativa de la relevancia de procesos sociales con un fuerte componente normativo, como aquellos relacionados a la política, la moral, la religión y el derecho en el plano global³⁷.

Sin embargo, esta perspectiva, al mismo tiempo, queda corta y va demasiado lejos. Queda corta porque, como se ha reflejado a nivel transnacional en la emergencia del gerencialismo (*managerialism*)³⁸, es difícil argumentar que se puede observar un relativo declive en la relevancia de las formas de comunicación política y legal. Es posible, más bien, observar una transformación mucho más profunda en la naturaleza misma de aquellas formas de comunicación que previamente tenían una base normativa. Desde el Método Abierto de Coordinación hasta medidas de responsabilidad social corporativa y la regulación de riesgos basada en la ciencia, es posible observar la emergencia de nuevas formas de regulación política y legal con un fuerte componente cognitivo en el nivel transnacional. Por supuesto, este desarrollo no está limitado a la esfera transnacional, es más bien un desarrollo mucho más profundo que puede también observarse dentro del nivel del Estado-nación de la sociedad mundial³⁹. Pero debido a la fuerte dependencia en la diferenciación funcional a nivel transnacional de la sociedad mundial, más que el tipo de diferenciación territorial que permanece como un rasgo fuerte a nivel del Estado-nación, se despliegan procesos de inclusión/ exclusión de modo

mucho más dinámico, lo que conduce a la incertidumbre sistémica respecto de quién es incluido y quién excluido. Así, puede observarse una presión estructural dentro de las estructuras transnacionales por marcos mucho más flexibles y, de este modo, por un movimiento hacia una incrementada dependencia en marcos de base cognitiva.

A pesar del profundo arraigo de la transformación del tejido básico del derecho y la política a través de una cognitivización incrementada, la perspectiva de la teoría de sistemas sobre la relación entre expectativas cognitivas y normativas resulta, sin embargo, problemática. Lo es porque enmarca la relación como un juego de suma cero. No solo está lógicamente condicionada la existencia de una por la existencia de la otra⁴⁰, sino que los dos lados de la distinción son *mutuamente constitutivos* en el sentido de que son el producto de desarrollos coevolutivos, en los que la incrementada vitalidad de una dimensión está condicionada por una vitalidad incrementada de la otra. Más que una reducción en la comunicación de base normativa, se puede observar una reconfiguración, la que implica una cognitivización incrementada en el nivel operativo —eso es, a nivel de las tácticas más que de las estrategias, a nivel del método más que el de la teoría y a nivel de los principios políticos (*policy*) más que en la política misma— mientras que la comunicación de base normativa incrementalmente adopta un rol estratégico. Por ejemplo, el fenómeno social de la moralidad —uno de los buenos ejemplos de comunicación de base normativa— ha experimentado una enorme transformación a raíz de la incrementada diferenciación funcional. Ha retirado y cedido su rol como la iniciadora y el medio del “terror comunitario de la vida pueblerina” (“*Gemeinschaftsterror des dorflichen Zusammenlebens*”)⁴¹, y se ha vuelto una forma de comunicación mucho más reflexiva. En su forma más moderna, la moralidad simplemente cumple una función de alarma, reproducida a lo largo de los límites de los sistemas sociales que son activados en dos instancias⁴². La primera instancia se relaciona con la preservación de integridad: cuando un sistema social se ve a sí mismo como la víctima de asimetrías, de efectos de desplazamiento y de tendencias colonizantes que emergen desde su entorno en la forma de, por ejemplo, *doping*, corrupción, prostitución o polución, que amenazan la coherencia del sistema. En tales casos, las formas modernas de la comunicación moral cumplen la función de aumentar la consciencia cuando las crisis sociales

emergen a través de procesos de fusión y de disolución de límites⁴³. La segunda instancia es específica a los sistemas funcionales y expansionista en naturaleza. Dentro de los sistemas funcionales, en contraste con los sistemas organizacionales y de interacción, pueden observarse unas lógicas de “inclusión total” (*Vollinklusion*) a través un acoplamiento de todos los seres humanos con roles sociales específicos (roles de producción o de audiencia) que corresponden al sistema en cuestión⁴⁴. Las religiones misionarias buscan convertir a todos los seres humanos alrededor del mundo en creyentes, la economía capitalista busca transformar a todos los humanos en productores y consumidores, y la agenda de los derechos humanos se orienta hacia una inclusión formal y factual de todos los seres humanos bajo el paraguas de los derechos humanos. Pero en la medida de que tal esfuerzo permanece contrafáctico más que de facto, a través de la exclusión de un número significativo de individuos, la comunicación moral tiende a emerger⁴. La comunicación moral en esta instancia cumple la función de apuntar a un “potencial no explotado”, el cual puede ser fuente para ulteriores expansiones del sistema en cuestión.

De modo similar, el retroceso de la política desde el control manual sobre grandes segmentos de la sociedad en las décadas recientes implica una reconfiguración de lo político, más que un impacto disminuido de formas políticas de comunicación. Como nos enseñan los foucaultianos, a través una nueva gestión pública y por la vía de formas cognitivas en la formulación de políticas, la emergencia de modos de ejercer el poder más refinados, indirectos y, de ese modo, en su abstracción, menos visibles, refuerza el ámbito del ejercicio del poder. Continúa siendo imposible, por tanto, afirmar que procesos regulatorios fuertemente cognitivos, por ejemplo, en áreas tan distintas como el comercio, la salud, la seguridad de los alimentos o Internet se van despolitizando incrementalmente, en la medida que todos ellos están unidos sobre la realización de normativas internamente definidas y visiones esencialmente políticas respecto al establecimiento de un comercio libre nodiscriminatorio, el acceso a la salud, niveles apropiados en la seguridad de los alimentos y acceso a comunicaciones basadas en Internet a nivel de todo el mundo.

Sigue de lo anterior que la distinción constitutiva de los órdenes normativos es la realidad doble (*Realitätsverdopplung*) entre facticidad y normatividad, tal como se expresa en la distinción entre el orden factual

existente y la idea, internamente reproducida e igualmente real, concerniente al cómo debe lucir el orden en cuestión. En la medida en que todos los fenómenos sociales están basados en procesos, esta distinción es, sin embargo, de naturaleza dinámica. Las visiones normativas también cambian en el tiempo; solo que ellas lo hacen a paso más lento que el despliegue actual, e incrementalmente cognitivizado, de las operaciones sociales de un orden dado. Existe una brecha de tiempo entre las dos dimensiones, y en unir esta brecha consiste la función central del derecho, tanto en sus variantes internas como en las externas. El mantenimiento de expectativas normativas a través de la condensación, dominante a nivel del Estado-nación, tanto como la posibilidad incremental de transferir por medio del inicio de procesos de aprendizaje cognitivamente basados, especialmente observables en el nivel transnacional de la sociedad mundial, solo permanecen como dos estrategias distintas para cumplir esta función. Tal como discutiremos más adelante, establecer la unidad entre las dos dimensiones es, además, la función central del constitucionalismo.

6. LA DOBLE REFLEXIVIDAD DE LAS CONSTITUCIONES INTERNAS

Como también se expresó en las semánticas del cuerpo político durante la temprana modernidad, las constituciones son comúnmente entendidas como marcos con un carácter cuasi trascendental⁴⁶. Se podría mantener esta visión si las constituciones cumplieran la función de enmarcar a los órdenes normativos en su totalidad. No obstante, este no es el caso, ya que a lo largo de la historia moderna el objeto constitucional ha sido las organizaciones formales de los órdenes normativos antes que los órdenes normativos mismos. Esta distinción fundamental ha sido desestimada habitualmente dentro de la discusión académica constitucional. Por ejemplo, aquellos autores que mantienen que el Estado es el único objeto constitucional apropiado, descansan en una simplificada comprensión de la estatalidad, en la cual el Estado es igualado en su totalidad a un orden normativo dado o a la sociedad. Como ha estado claro desde que Hegel introdujera su distinción Estado/ sociedad, un Estado es, sin embargo, una forma de organización formal particular entre otras, o, mejor dicho, un conglomerado sueltamente acoplado de varias organizaciones que existe solo en cuanto se encuentra formal y operacionalmente separado

de los otros segmentos de la sociedad⁴⁷. La constitución del Estado no es, por tanto, la constitución de un orden normativo en su totalidad, sino de un conglomerado organizacional específico.

Una consecuencia que se deriva de la idea de que el objeto constitucional no es el Estado, sino más bien las organizaciones formales, es que el rango de objetos constitucionales es mucho más amplio de lo que normalmente se asume. Lo cual también subraya la evolución histórica de las formas modernas de organización formal, en cuanto que los rasgos organizacionales básicos de los Estados fueron desarrollados originalmente en el contexto de la Iglesia católica y solo adoptados posteriormente por los emergentes Estados modernos⁴⁸. De modo similar, las empresas privadas y otras organizaciones de carácter privado vieron en el Estado moderno un modelo a seguir, a partir del cual adoptaron sus características básicas⁴⁹, abriendo así un horizonte conceptual que hace posible imaginar una expansión bastante radical en el tipo de organizaciones que pueden observarse a través de los anteojos constitucionales.

Una tercera implicación es que la versión culturalista del pluralismo legal yerra en un punto fundamental cuando deja fuera la perspectiva organizacional. Mientras que el argumento del Estado central queda corto en cuanto a la especificidad de las constituciones de los Estados modernos, su idea respecto del carácter específicamente moderno de las constituciones es fundamentalmente cierta, en cuanto que se expresa también en el vínculo intrínseco entre las organizaciones formales modernas y la emergencia de las constituciones. Así, mientras la estatalidad moderna y las formas transnacionales de ordenamiento son fenómenos coevolutivos —porque los dos se basan en la misma forma de organización formal moderna—, ambas se encuentran acopladas en una relación de suma cero respecto a tipos de entidades “premodernas” y “culturalistas” como tribus, clanes y redes de nobleza, las que operan bajo tanto desde el Estado como desde los órdenes transnacionales, y que están siendo gradualmente marginadas como resultado de la conversión de la sociedad en una moderna “sociedad organizacional” (*Organisationsgesellschaft*).

Siguiendo a Hegel⁵⁰ y Weber⁵¹, pueden apuntarse una serie de rasgos centrales de las organizaciones:

a) Los mecanismos de exclusión e inclusión se formalizan en base a

la membresía, lo cual permite el establecimiento de límites entre la organización y su entorno. Esta membresía se divide, a su vez, entre roles primarios (*Leistungsrollen*) y secundarios (*Publikumsrollen*).

b) Existe una formalización de competencias y procedimientos de toma de decisiones que permiten una producción continua de estas, que se aplican a todos los miembros, con decisiones que emergen recursivamente de decisiones anteriores.

c) Existe una dependencia dual en jerarquías organizacionales y legales como la forma a través de la que las decisiones son tomadas y traspasadas a los miembros.

d) La existencia de un *locus* de autoridad formalizado que actúa como un vehículo para la generación de aceptación de las decisiones producidas.

En la medida en que todos estos rasgos se encuentran, se hace posible hablar de organizaciones como formas específicas de ordenamiento autónomo, en el sentido de que estas se transforman en estructuras autocontenidas que producen decisiones de manera recursiva, donde una decisión refiere a decisiones previas a través de la referencia a una fuente de autoridad interna. Como tal, las organizaciones existen inicialmente en forma madura cuando se vuelven autorreflexivas, en el sentido de que la producción de decisiones se convierte en un proceso interno que se despliega a lo largo del tiempo.

Permanece como condición, sin embargo, un vínculo a una dimensión externa, en cuanto que es posible hablar de las organizaciones como organizaciones *formales* solo si estas se estructuran legalmente. Las organizaciones solo se convierten en organizaciones formales por medio de un vínculo con un marco legal, ya que la concordancia con un marco legal coherente es la forma a través de la que las cuatro dimensiones mencionadas más arriba se vinculan estructuralmente y, así, se establece la coherencia. Como propone Teubner, la organización formal implica una forma específica de *doble reflexividad* en el sentido de que la perspectiva de la organización en cuestión y una perspectiva legal se acopla la una a la otra⁵². Así, el proceso social reproducido por una organización dada está siendo *simultáneamente* reflejado en una perspectiva legal concordante. O, si lo expresamos de modo distinto: la jerarquía organizacional se refleja en una correspondiente jerarquía de normas legales.

Sin embargo, la condición estructural para la emergencia de la doble reflexividad, como se indicó anteriormente en los puntos tres y cuatro, es la existencia interna de una jerarquía y de fuentes de autoridad que pueden servir como base para la toma de decisiones colectivamente vinculantes. De tal forma, sin la existencia de una infraestructura política dentro de una estructura social dada, no hay base para una institucionalización estable de la doble reflexividad. La Corte de Arbitraje Deportivo solo puede relacionarse en un modo de doble reflexividad en la medida en que existe una contraparte política en forma de Comité Olímpico Internacional. De igual manera, el panel y los cuerpos apelativos de Organización Mundial del Comercio (OMC) solo pueden establecer vínculos que posean la cualidad de la doble reflexividad por la vía de una vinculación a la dimensión política de la OMC en forma de Conferencia Ministerial, el Consejo General, y así. Como lo ha hecho Moritz Renner, esta forma de doble reflexividad puede ser entendida como un acoplamiento estructural triangular entre el sistema jurídico, el sistema político y procesos sociales focales dados⁵³. Esta visión significa un quiebre de entrada con la ortodoxia de la teoría de sistemas, en cuanto esta, en su formato actual, solo puede operar con relaciones binarias. Un quiebre con la perspectiva binaria no solo significa un diagnóstico social substancialmente distinto del que ha sido presentado por la ortodoxia sistémica, sino también implica que uno tiene que buscar una remodelación radical de la teoría en su totalidad. Una alternativa a la perspectiva triangular aparece a través de la distinción entre formas primarias y secundarias del sistema político⁵⁴. La distinción es, por un lado, entre acoplamientos del derecho y procesos que son primariamente políticos, como aquellos desplegados dentro de los Estados y cuerpos públicos transnacionales como la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio, y, por el otro, acoplamientos entre el sistema jurídico y procesos sociales privados en los que las estructuras de toma de decisiones políticas han emergido internamente⁵⁵. Esta última forma puede observarse al interior de entidades privadas como las asociaciones de comercio, cuerpos reguladores de carácter privado y las ONG, y puede ser descrita como una forma de “política secundaria” (*secondary politics*). La política secundaria describe a estas estructuras porque, principalmente, estas se consideran a sí mismas relacionadas con la función substancial que ejercen —por ejemplo, la economía, los

deportes, la salud o la religión— al mismo tiempo que sus esfuerzos hacia una estabilización de tales procesos les da una dimensión política adicional.

En suma, las constituciones pueden ser entendidas como instituciones que, en su función política, enmarcan el cuerpo de reglas y normas que establecen la estructura formal, las competencias decisionales y un locus de base jerárquica de la autoridad dentro de una estructura organizacional; al mismo tiempo, en su función legal, estas establecen principios para la estructuración de conflictos entre las normas dentro de esta entidad. En este sentido, las constituciones sientan las reglas habilitantes y limitativas que guían a las organizaciones formales. Así, en principio, es posible afirmar que las constituciones existen en todos los casos donde tanto una estructura social legal como una no-legal se unen entre sí dentro del marco de una organización formal, estableciendo de tal modo una forma específica de autoconstitución doble que asegura una concordancia entre una perspectiva legal y otra no-legal. No solo los Estados, pero en principio todas las organizaciones formales, incluyendo aquellas que operan en la esfera transnacional, pueden ser objeto de una constitución⁵⁶.

7. LA DOBLE PRESTACIÓN DE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN EXTERNA

En la sección anterior, las constituciones se tratan como un rasgo interno de las organizaciones formales, en el sentido de que un vínculo con el derecho permite una condensación de la autoridad a través del establecimiento de una jerarquía legal y organizacional. Pero como todos los otros tipos de sistemas sociales, las organizaciones solo existen por la vía de una demarcación y mantención de límites respecto de sus respectivos entornos sociales⁵⁷. El establecimiento de coherencia a través del desarrollo de un set consistente de normas internas está condicionado por la mantención de estos límites. Al mismo tiempo, y como todos los otros tipos de sistemas sociales, las organizaciones se intersectan con otras estructuras sociales en sus entornos. Además de controlar la necesidad funcional de la preservación interna de la coherencia, como se esbozó en la sección previa, el establecimiento de una conectividad externa es la función más central de las constituciones. Las

constituciones, en su dimensión externa, delinear el segmento de sus entornos sociales que tienen en cuenta las organizaciones, o los conglomerados de organizaciones. Las constituciones establecen “entornos internos”, en el sentido de que construyen internamente un medio abstracto que cumple un rol dual: primero, la transposición de componentes sociales compactados, como las decisiones políticas, los capitales y productos económicos, el conocimiento científico y las promesas religiosas de salvación que una organización dada produce a lo ancho de la sociedad. Segundo, la canalización e incorporación de los componentes sociales compactados, producidos en alguna otra parte de la sociedad, al interior de una organización dada. La práctica del cumplimiento de esta función dual es lo que describe el término ‘constitucionalización’⁵⁸, en la medida en que el término denota el proceso en que se establecen los intercambios entre una organización formal dada y el resto de la sociedad. Así, volviendo al clásico vocabulario constitucional, la constitucionalización puede ser entendida como el proceso *interno* a través del que una organización formal delinea un sujeto constitucional⁵⁹. Un sujeto que no solo provee una imagen que es reflejo del entorno social de la organización, sino que también sirve como médium para la trasposición de componentes sociales compactados hacia y desde el entorno social de una organización dada.

El ejemplo clásico de un entorno interno es la *legalmente construida* “nación” o “pueblo”, que emerge dentro del sistema político en forma de Estado. La construcción de una nación —entendida como una forma abstracta y generalizada en contraposición a la suma de individuos dentro de un territorio dado— se hace para delinear el segmento de su entorno social del cual un sistema político dado observa y toma en cuenta en su toma de decisiones. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos solo está obligado a considerar los efectos que su toma de decisiones tiene sobre la nación estadounidense, pero no los efectos sobre las naciones de Canadá o México. Más concretamente, el concepto de nación sirve como un médium a través del cual las decisiones son traspuestas en la sociedad en general. Por otro lado, la nación es también una forma a través de la cual las perspectivas que emergen desde el entorno se transfieren al sistema político. Para que esto suceda, es necesaria una operacionalización de la nación por la vía de la construcción de roles sociales y estructuras de expectativas específicas. Lo cual toma dos

formas distintas. Primero, una operacionalización ocurre a través de una estabilización y formalización de relaciones hacia otras estructuras organizacionales en cuanto que las relaciones son formalizadas de sistemas de negociación institucionalizados (*Verhandlungssysteme*) en la forma de consejos asesores, redes, comisiones y otras plataformas de transferencia que se establecen entre el sistema político y organizaciones diversas (por ejemplo, organizaciones económicas, religiosas y científicas). Segundo, la operacionalización ocurre a través del establecimiento de roles primarios y secundarios al introducir una distinción entre quienes gobiernan y quienes son gobernados (*Regierende und Regierte*)⁶⁰, esto es, entre aquellos que son internamente ubicados en el sistema político y aquellos que se encuentran en el entorno interno. En los Estados democráticos, se introduce también una distinción más entre los ciudadanos y el votante en el entorno. La primera cumple un rol pasivo como “audiencia” y la segunda un rol activo en el sentido de que, a través de la votación, la transferencia actual desde el entorno hacia el sistema político tiene lugar.

En el nivel transnacional de la sociedad mundial, el giro hacia formas de gobierno basadas en redes (*network-based governance*) respecto de organizaciones que operan dentro de órdenes normativos funcionalmente delineados cumple un rol similar. En el caso de la Unión Europea, estructuras de gobierno como el *Comitology* y el Método Abierto de Coordinación y Agencias (Regulatorias) desempeñan el rol de marcos heterárquicos, a través de los que se enmarca la transferencia de componentes sociales compactados entre el orden legal de la Unión Europea y su entorno (incluyendo los órdenes legales de los Estados miembros)⁶¹. Estructuras comparables, aunque mucho más embrionarias, han emergido también en torno a organizaciones públicas y privadas, tales como ONG de gran escala, compañías multinacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas organizaciones comparten la característica de encontrarse enfrentadas al reto de delinear sus respectivos entornos sin recurrir al concepto de nación, en cuanto no se encuentran internamente estabilizadas a través de una referencia a demarcaciones territoriales. Frente a ello, estas gatillan la emergencia del concepto de “*stakeholders*” como un equivalente funcional del concepto de nación. La forma del *stakeholder* se caracteriza por un componente

cognitivo mucho más fuerte en comparación a la forma de la nación, en cuanto que posee un fuerte elemento de intercambiabilidad sobre la base de un criterio de funcionalidad⁶². Aunque las naciones rara vez han sido las unidades estables que la teoría nacionalista y las teorías políticas legales más normativas las hacen ser, las lógicas de inclusión y exclusión poseen, no obstante, un carácter temporal mucho más fuerte dentro de las configuraciones de los *stakeholders*⁶³.

El incrementado nivel de temporalidad, y así de contingencia, es la explicación probable para la fuerte dependencia en los derechos dentro de escenarios transnacionales. Los derechos son la forma legal que toma la constitucionalización. Mientras Thornhill parece reducir los derechos a la única forma por la que los procesos de inclusión/ exclusión se manejan⁶⁴, la capacidad estructural de las organizaciones formales nacionales y transnacionales de desarrollar regímenes de derechos parece estar condicionada por sus apegos a medios generalizados, no-legales, que representan una versión destilada del material sociocultural existente, tal como se expresa en los fenómenos de la nación y del *stakeholder*. Aun cuando los regímenes de derecho tienden a emerger desde el interior de los procesos sociales a los que están atraídos —antes que ser impuestos externamente—, estos se vuelven inidentificables y operativos solo cuando se establece una distinción entre las dimensiones legal y no-legal, lo que conduce a la emergencia de una forma específica de doble prestación. Tradicionalmente, el registro de derechos se entiende como el marco a través del que, en la misma operación, se aseguran las libertades e imponen las obligaciones sobre los sujetos legales⁶⁵. La prestación (*Leistung*) social central de los derechos, sin embargo, es la de proveer componentes sociales compactados con una forma legal, la que permite sus transferencias en un modo que no desestabiliza la integridad operativa tanto de la entidad donante como de la que recibe⁶⁶.

Se sigue de lo anterior que la constitucionalización no implica solamente un incremento en la autorreflexividad de una organización formal dada. La constitucionalización no es solo un ejercicio en autovinculación negativa que las organizaciones persiguen para reducir el riesgo de autodestrucción por la vía de un sobreesfuerzo sistémico⁶⁷. Esta visión, que se puede remontar a la estratégica, aunque esencialmente contingente, elección de Luhmann de enfatizar la autorreflexividad de los

sistemas sociales mientras que minimiza sistemáticamente las dimensiones de prestación y función de los mismos, conduce a una descripción de la sociedad empíricamente implausible⁶⁸. Los procesos de constitucionalización, más bien, proveen de una contribución mucho más positiva hacia los otros segmentos de la sociedad, en la medida en que buscan reducir externalidades negativas, tendencias colonizantes, y efectos de exclusión respecto de los entornos de los órdenes constitucionales correspondientes. Esto también se confirma por los escenarios contextuales dentro de los que emergen las constituciones. Las constituciones nunca están solas, sino que siempre emergen en escenarios coevolutivos, donde varios órdenes emergen simultáneamente. Los Estados-nación, por ejemplo, no son estructuras unitarias, sino que más bien toman la forma de conglomerados constitucionales en las que se reúnen las constituciones del Estado, las constituciones de la Iglesia y las constituciones del trabajo. Esto nuevamente vuelve a las múltiples intersecciones entre las constituciones en los campos de batalla donde los órdenes constitucionales son delineados y donde emergen narrativas de justificación respecto de la prestación que órdenes constitucionales específicos producen en relación a otros segmentos de la sociedad. La emergencia de las constituciones está estructuralmente condicionada por procesos de constitucionalización capaces de garantizar el despliegue de procesos coevolutivos que se refuerzan mutuamente. La emergencia de un orden constitucional autónomo dentro de la Unión Europea es un ejemplo perfecto de esto, en cuanto que el establecimiento interno de jerarquías legales y organizacionales fue condicionado sobre la emergencia coevolutiva de marcos legales y organizacionales heterárquicos, en la forma de estructuras de gobierno, como las agencias, la *Comitology* y el Método Abierto de Coordinación, los que aseguraron la concordancia entre el orden constitucional de la Unión Europea y su entorno, especialmente de los órdenes legales de los Estados miembros.

8. LA DOBLE FUNCIÓN DEL CONSTITUCIONALISMO ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO

La distinción entre ordenamiento interno y heterárquica externa, como se expresa en la distinción entre constituciones y constitucionalización,

constituye una tensión paradójica. Esta tensión también puede ser descrita utilizando la distinción entre procesos jerárquicamente organizados y procesos heterárquicamente espontáneos⁶⁹. En primer lugar, un orden normativo existe cuando se establece una unidad entre estas dos dimensiones, y para establecer esta unidad necesita recurrir al tiempo. Del mismo modo, tal como la teoría constitucional normativa busca disolver la tensión entre la política republicana y los derechos liberales a través de procesos de aprendizaje social desplegados en el tiempo⁷⁰, también es posible observar desde un punto de vista sociológico que los arreglos constitucionales no solo reflejan estructuras existentes, sino que expresan, más bien, una visión específica del futuro sobre la base de un entendimiento específico del pasado⁷¹. Estas visiones también pueden ser descritas representando una forma de “consciencia constitucional” capaz de proveer de una base para una demanda contrafáctica respecto de un posible enmarcamiento constitucional de un orden normativo en su totalidad. Es el establecimiento de esta consciencia constitucional la que es descrita con el término 'constitucionalismo'.

Como se indicó anteriormente, el derecho opera con proposiciones contrafácticas que se orientan hacia el futuro. El constitucionalismo, sin embargo, implica orientación hacia un tipo específico de proposición contrafáctica que puede ser descrita con el término de doble función. El constitucionalismo implica que, tanto desde una perspectiva focal — incluyendo la económica, la política y la del entorno— como desde una perspectiva legal, se desarrolla una visión de “inclusión completa”. Esto implica que, en principio, todos los humanos pueden ser sujetos dignos de inclusión dentro del orden normativo en cuestión. Desarrollado originalmente dentro de la Iglesia de Roma, el esfuerzo contrafáctico por la inclusión completa se ha vuelto generalizado: en este caso, por la vía de la transformación de todos los individuos en miembros de la Iglesia católica y la subordinación de todos los poderes mundanos en subordinados de Roma. Por ejemplo, la República francesa, el modelo histórico a seguir para la mayoría de los Estados continentales, ha dependido tradicionalmente de un autoentendimiento que está fuertemente vinculado a la idea contrafáctica de la realización de los ideales de la Revolución francesa a lo largo del mundo. Desarrollos similares se pueden observar dentro de regímenes sectoriales

consistentes en organizaciones formales y sus redes constitucionalizadas circundantes, tales como el régimen de la OMC, el régimen de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés), el régimen de la OMS y el régimen, aún emergente, de los derechos humanos globales⁷². Los objetivos contrafácticos son universales en naturaleza, como el esfuerzo hacia la realización del comercio libre no discriminatorio, acceso global libre y sin censura a Internet, acceso básico a la salud en todo el mundo, y no solo una inclusión formal de todos los humanos bajo el paraguas de los derechos humanos, sino que también una inclusión de facto. En otras palabras, el constitucionalismo implica la institucionalización de teleologías normativas y una relación jerárquica entre los procesos de juridificación de la teología y procesos de juridificación incrementalmente cognitivizados. Una vez que estas lógicas están en lugar, es posible hablar de constitucionalismo en un sentido profundo y maduro. El ordenamiento constitucional, por tanto, no versa solo sobre reglas limitantes y facilitantes, sino que también refleja un movimiento hacia la autotranscendencia a través del despliegue de una aspiración universalista.

9. CONCLUSIONES

A partir del marco teórico bosquejado anteriormente, pueden deducirse tres dimensiones centrales de un orden constitucionalista maduro, que respectivamente pueden ser descritas con los términos 'constitución', 'constitucionalización' y 'constitucionalismo'. En primer lugar, un orden constitucional está caracterizado por la doble reflexividad, en la medida en que un acoplamiento está establecido entre el objeto constitucional, en la forma de una organización jerárquica que se basa en y reproduce una fuente de autoridad autónoma, y un marco jurídico concordante. En segundo lugar, la constitucionalización a través de la doble prestación implica un acoplamiento entre, por un lado, una reconstrucción interna de un sujeto constitucional externo y, por el otro, un registro de derechos legales, estableciendo un marco para los intercambios entre el objeto constitucional y el resto del mundo, como es internamente representado por el sujeto constitucional. Tercero, podemos hablar de

constitucionalismo a través de la institucionalización de una función doble, cuando una constitución basada en principios y legalmente fortificada, que se esfuerza hacia una inclusión universal, provee un sentido de dirección en el tiempo a través de una forma de consciencia constitucional articulada. En pocas palabras, la tensión entre una constitución endógena y una constitucionalización exógena está externalizada, pero no disuelta, mediante el recurso al tiempo, en el sentido de que la tensión es empujada en el futuro sobre la base de una promesa de reconciliación futura.

Esta disposición es, en principio, válida para formas de ordenamiento constitucional tanto basadas en el Estado como aquellas que no. Por otra parte, establece todo un rango de diferentes órdenes normativos con base constitucional que existen en la sociedad mundial en la forma de regímenes privados, públicos e híbridos, orientados hacia problemas tan distintos como el comercio justo, la seguridad alimentaria, Internet, deportes, comercio e inversiones y religión. En distintas partes del mundo y en diferentes épocas, distintos regímenes emergerán en el primer plano, mientras que se observan constantemente continuos conflictos e intentos de adaptación mutua.

SEGUNDA PARTE
DEBATE CONSTITUYENTE
EN EL MUNDO

V. ESTADO, CONSTITUCIÓN. UNA LECCIÓN

Sandro Chignola

A COMIENZOS de los años ochenta tuvo lugar un debate —representado, en parte, por el importante ensayo de Theda Skocpol *Bringing the State Back in*¹ y otros sobre el tema— respecto al problema de trasladar el Estado al centro de la discusión. Por un largo periodo de tiempo, entre los años sesenta y setenta, el análisis marxista en Italia seguía la pregunta retórica de Bobbio: “¿existe una teoría marxista del Estado?”². Para Bobbio, la respuesta a esta pregunta resultaba obvia: no existía tal teoría y los marxistas no tenían nada que decir sobre el Estado. En base a esta hipótesis, a fines de los setenta se resolvían las tesis que valorizaban la autonomía de lo político como uno de los ingredientes de la política del compromiso histórico. Y es que en tanto los marxistas no contaban con una teoría del Estado, lo único que se podía hacer era recorrer un largo camino a través de las instituciones para buscar articular síntesis políticas y constitucionales que de algún modo explotasen, en un sentido dinámico y progresivo, al aparato político e institucional de la democracia. Esta era la hipótesis del Partido Comunista Italiano (PCI) y de sus intelectuales.

A lo largo del presente ensayo, intento mostrar lo contrario: había otro pensamiento comunista y subversivo que tenía una idea precisa del Estado y de la constitución, pensamiento que además marca el trazo desde el cual aún hoy en día algunos nos esforzamos en pensar. En ese sentido, el problema ni siquiera era el de *Bringing the State Back in*, puesto que el Estado siempre había sido (y para algunos de nosotros aún lo es) el terreno privilegiado para el contraste tanto de lo teórico como de lo político. El Estado moderno, entendido como una síntesis de factores sociales y de territorialización de un mercado nacional que opera tanto en el plano interno como en el de las relaciones internacionales, tiene una

génesis precisa. Esta se encuentra como dispositivo lógico-conceptual, desde mi punto de vista, en el *Leviatán* de Hobbes³. Conviene recordar, en este sentido, el ensayo que Carl Schmitt dedica al Leviatán⁴, en el cual reconstruye la simbología política del concepto: no se sabe bien qué representa, pero de todos modos es un animal grande porque así está dicho en el libro de Job. El Leviatán es evocado como la potencia más grande sobre la tierra para hacer cesar la guerra de todos contra todos, la cual constituye para Hobbes el estado de naturaleza. Carl Schmitt decía, justamente por el hecho de que gran Leviatán es evocado para contener y neutralizar el conflicto, y debido a que su evocación del conflicto continúa alimentándose, que, en el acto de su nacimiento, “ya se ve amanecer el día en el que el gran Leviatán terminará siendo asesinado”⁵.

También podemos pensar el tema del Estado desde la figura de una muerte no simplemente biológica o por decadencia interna y agotamiento: asesinemos al Estado. ¿Por qué no? Como intentaré mostrar en la parte final de este trabajo, estoy convencido de que una serie de procesos ya han —de hecho— asesinado al Estado. Este está refuncionalizado por políticas globales, por la crisis financiera y, además, sus funciones son rearticuladas en otros lugares y de otro modo. Es más, todo esto señala el perímetro de un nuevo territorio, de espacios de conflictos diferentes e inéditos, para los cuales no tengo demasiadas palabras, porque aquí se abre todo un espacio de investigación teórica y de inversión política —de aquello que está frente a nosotros— y que representa también un problema para nosotros, quienes jamás hemos tenido la dificultad de reconducir el Estado al interior del debate. Problema del que hemos discutido mucho y, sobre todo, seguimos discutiendo.

Sitúo mi argumentación en un eje entre dos polos, en los cuales están encerrados los extremos del discurso de “izquierda” sobre el Estado y la constitución, tanto la italiana como la de otros Estados. Tenemos, por un lado, un fetichismo por la constitución muy difundido en Italia. Quien intente actualizar sus propios instrumentos teóricos y políticos, afilándolos en la punta más incandescente de esta tendencia, se encuentra con este fetichismo por la constitución, con la defensa de un pacto republicano, con una batalla de retaguardia. Hasta no hace demasiado tiempo, al menos hasta el gobierno de Berlusconi, podíamos encontrar a quienes agitaban la bandera de la constitución, los que

agitaban la retórica de lo público y su apología. Y lo hacían tanto en las batallas contra las reformas universitarias como en las batallas contra el poder plebiscitario y personal de Berlusconi. Esto es, lo hacían como si la constitución representase y definiese el último bastión de los poderes democráticos y de la división de poderes; como si, justamente, se pudiese hacer de la constitución un fetiche para las retóricas políticas que conducían las batallas contra la “privatización” de la cosa pública.

Resulta inútil poner en evidencia el hecho de que el modo en que se involucran y multiplican los mecanismos de la crisis financiera nos dejan entender que desde hace ya un tiempo el fetichismo de la constitución no puede resultar en nada más. Una batalla por la defensa de la constitución es un terreno atrasado para cualquiera, el cual debe abandonarse. Desde el gobierno de Monti, hemos entrado en una fase en la que el poder de los “técnicos” se carga de dimensiones directamente constituyentes, las que convocan aquello que Carl Schmitt llamó las “instituciones comisarias de la dictadura”⁶. Me parece que esto es de lo que se trata fundamentalmente el problema del fetichismo por la constitución, tanto en lo que respecta al comisariado de Grecia como en lo concerniente a los otros con déficit en la balanza de pagos⁷. Hablar de constitución —es decir, de un acuerdo general que funciona como marco para un ajuste, el cual engloba, a su vez, una democrática distribución de los poderes nacionales— solo nos indica un retraso respecto de lo que debemos contrastar, o de aquello que de todos modos tenemos delante de nosotros, lo que como terreno de conflicto nos convoca.

Por el otro lado, para hallar el otro extremo del discurso de la izquierda es necesario hacer algo de arqueología y retrotraernos a fines de los años setenta. En *Macchina Tempo*⁸, Toni Negri nos narra cómo, a pesar de las otras variadas acusaciones de las que fue objeto en esos años, se le invitó a redactar una entrada para la *Enciclopedia Fischer Feltrinelli*⁹. Quienes somos más viejos recordamos esta cuestión, una enciclopedia de ciencias políticas en la que la voz “Estado” era definida del siguiente modo: “simple objeto de odio”. Aquí encontramos el otro polo de nuestro eje de la discusión: el fetichismo de la constitución, por un lado, y el Estado como un “simple objeto de odio”, por el otro. Cuando Negri fue arrestado, muchos recordaron esta referencia y lo acusaron de haber dado una suerte de confesión pública de aquello que había sido su comportamiento subversivo y el de una generación completa. En la

introducción de *Macchina Tempo*, Negri reivindicaba el hecho de que antes de haber podido definir al Estado como un “simple objeto de odio”, había dedicado profesionalmente más de 1.000 páginas en intervenciones y trabajos de investigación en los que analizaba qué era el Estado. En estos análisis, había desagregado del Estado a las tecnologías y los poderes, perseguido las racionalidades y los niveles de ejercicio, e incluido en sus análisis a los procesos jurídicos y políticos. En este sentido, este es el juego que debemos tener presente desde el punto de vista metodológico y ético: el hecho de que el odio es una pasión noble que requiere paciencia. Que, al menos, requiere de más de 1.000 páginas para preguntarnos qué es eso que odiamos.

Cuando Manifesto Libri publicó nuevamente el bellissimo texto de Negri sobre Lenin, las *33 lezioni su Lenin*¹⁰, un editor caritativo intercambió, en todos los lugares que debía hacerlo, el término 'odio' por 'aversión'. Contrario al editor, yo creo que el odio existe. No olvidemos el gran debate filosófico-político que ha habido, y aún existe, sobre las pasiones de la política (una pasión que, creo, debe revalorizarse). Dentro de esta dimensión, el Estado no me gusta, ni siquiera la constitución y el fetichismo que la recubre como forma de pacificación nacional. A pesar de esto, debemos tener siempre presente el hecho de que una definición del Estado como objeto de odio implica un posicionamiento y una ética que, antes que todo, supone un método y una disciplina de investigación. “Conoce verdaderamente, quien verdaderamente te odia”, escribía otro viejo maestro. En este sentido, un método nos obliga a confrontar, sin atajos y aceptando el cansancio, al conjunto espeso y complejo de los dispositivos y de los nudos conceptuales, categoriales, políticos e institucionales del Estado y de la constitución como fórmulas organizadoras, e históricamente diferenciadas de mando.

Me ubico, entonces, dentro de este arco de oscilación para hablar del Estado y de la constitución, y para también intentar hablar de la serie de pasajes que nos obligan a dinamizar continuamente ambas definiciones, en dependencia de los equilibrios que los marcan y a los que, de vez en cuando, les corresponden. Equilibrios que expresan síntesis evolutivas, pero también que desencadenan mecanismos de neutralización del conflicto y que hace disparar instrumentos de captura respecto de los dispositivos de subjetivación que los arrastran. Parto, por lo tanto, como también hacía Negri en aquella enciclopedia, desde algunas banales

definiciones de doctrina del Estado.

Entonces, desde este punto de vista, ¿qué es la constitución? Es posible intuir ya, desde mi premisa en contra del fetichismo de la constitución, que me encuentro fuera de la definición de la constitución como un “bien común”. Me parece detestable este léxico de los bienes comunes que circula continuamente en sectores del movimiento. Bersani decía hace poco, en una entrevista para *la Repubblica*, que el próximo eslogan para los políticos será “Italia, bien común”. Un obsequio al fetichismo generalizado de la constitución. Frente a esto pensaba: ¡Ustedes defiendan este “bien común”!, yo no. Preguntémonos entonces ¿qué es la constitución desde este punto de vista? Antes que todo, en el concepto de constitución está implícito un estrato muy antiguo, podríamos decir una dimensión primaria, la cual trata a esta como una fórmula de garantía, sea esta coincidente o no con una constitución. Esta fórmula corresponde al estrato semántico más antiguo del concepto: una suerte de pacto tácito dentro del cual es transcrito un sistema de garantías políticas, de libertades o *immunitates*, de pactos. A este respecto, hay un hecho que resulta interesante discutir. En la historiografía constitucional, habitualmente se recurre a una figura que fue reactualizada por el último Foucault, la cual resulta útil para este caso, a saber, la figura de la elipse. Cuando se habla de la constitución en un sentido muy antiguo, por medio de la noción de “pacto”, existen dos poderes que se enfrentan y que no se absorben mutuamente, en una relación en la que se afirma la resistencia. Vista así, la constitución es el sistema de garantías que recepciona y transcribe en la forma del pacto el éxito de un enfrentamiento entre un señor legítimo —de un rey— y un sistema de poderes —nobiliarios, corporativos, comunales— que le resisten, obligándolo, por medio de esto, a reconocer y codificar un sistema de garantías y libertades que opera como límite para el ejercicio de su poder. Hay una parte de la *Verfassungsgeschichte* —la historiografía constitucional alemana— que entiende a los mecanismos de estatización de los poderes dentro de la constitución como una iniciativa de la que se hace cargo el soberano. Sea este en ocasiones el rey, la voluntad general constituyente o el sistema de los poderes públicos. En todos estos casos, el Estado se autolimita. Para ello, vincula las propias prerrogativas soberanas a la sociedad sobre la que se circunscribe, que hace posible, y a los sujetos incluidos en ella. Podemos entonces ver que

existe una historiografía constitucional que hace referencia a este sistema de garantías, al cual en cierta medida entiende como “contrato”. Como el fin de un conflicto o de una lucha por el derecho que tiene lugar entre dos poderes, los que, exactamente como lo muestra la idea de la elipse, representan los dos fuegos de un proceso que no puede no ser reabsorbido solamente en uno de ellos.

Cuando hablo de gobierno o de gubernamentalidad en un sentido foucaultiano, siempre tiendo a reactualizar esta figura de la elipse en cuanto es la elipse de la tensión y la resistencia. Es un esquema de composición de fuerzas, en otras palabras, una dinámica. Así, cuando hable sobre qué son hoy en día el Estado y la Constitución, sobre los procesos de gubernamentalización (o de *governance*) que signan la estatalidad contemporánea y que marcan la forma residual de la existencia del Estado en los procesos que lo redefinen y rearticulan, me parece que es necesario tener presente y reclamar la figura de la elipse. En sus últimos cursos en el *Collège de France*, Foucault decía: “hemos entrado en la época de los gobernados”¹¹. Esta es justamente la idea: existe una polaridad no reabsorbida entre una instancia de gobierno y aquello que debe ser gobernado, pero que se resiste al gobierno. Resistencia que se ejerce desde fuera del sistema de poderes disciplinarios y representativos. Una resistencia que no se deja domesticar o “traducir”, y que proviene de un sujeto material, que se encuentra profundamente atravesado por las necesidades y los intereses que subjetivan su posición. Sobre este punto, podemos hacer particular referencia, dentro de la historiografía constitucional alemana, a un viejo ensayo del historiador suizo Werner Näf. El ensayo fue publicado en la primera mitad de los años cincuenta en la *Historische Zeitschrift* bajo el nombre de “Formas tempranas del Estado Moderno en la baja Edad Media”¹². En este, Näf habla de la figura de la elipse, mostrando que dentro de este esquema —correspondiente al estrato más antiguo y al que nos referíamos por medio de la idea de la constitución como garantía— el sujeto conductor es el que pide, desde la resistencia y el conflicto entre poderes, que le sea reconocido el derecho. Es decir, es el gobernado el que impone la constitución. Y, consecuentemente, esto significa que Foucault está en lo cierto en sus cursos del *Collège de France*: hemos entrado en una época posdemocrática y pos-soberana, la cual puede ser definida como “la época de los gobernados”. Este genitivo debe ser entendido en

orden subjetivo: son los gobernados quienes obligan a alguien a enfrentarse a ellos, y dentro de esa dinámica a pactar esquemas normativos, formas y garantías. A empujar el proceso de judicialización más allá de la clásica distinción planteada por la constitución entre lo público y lo privado; a llevarlo, por ejemplo, al terreno de lo común. Es en este sentido en que entendemos la primera fase, la de la constitución como garantías.

En una segunda fase, el concepto de constitución asume una función directamente constituyente. Este lo hace, al menos, en tres sentidos: a) como estabilización de un determinado orden de poder dentro del cual la constitución reconoce e identifica a un titular de soberanía; b) como esquema de racionalización del poder de quien ostenta la soberanía, en cuanto que esta garantiza y fija un orden de distribución y de equilibrio entre los poderes (versión que, en relación al concepto de constitución, resulta más moderna que las otras); y c) como legitimación de un único titular del poder político. Podemos entonces resumir estos tres sentidos como *estabilización*, *racionalización* y *legitimación*. Desde este punto, comienza el acontecimiento del Estado moderno, en cuanto que lo entendemos como un soberano (antes el monarca y, con posterioridad a la Revolución francesa, el pueblo y su voluntad general) que constituye al sistema de relaciones que lo reconoce como soberano.

Si volvemos a la referencia que hicimos al *Leviatán* de Hobbes al principio de este artículo, podemos ver que, en esta obra, aparece con claridad la idea de que es el representante el que hace al pueblo y no viceversa¹³. El representante hace al pueblo en el sentido de que un orden de poderes que, al mismo tiempo, define al soberano y al sistema de poderes y su racionalización, es también aquello que identifica a la “constitución” —aquí entendida bajo la forma de modo de existencia— de la unidad política del pueblo que se refiere a aquel Estado y a aquella constitución. Es el acontecimiento que hace del Estado moderno y de la constitución un pasaje clásico de la historia constitucional occidental. Es el acontecimiento que otro reaccionario, Alexis de Tocqueville, nos mostrará como el arco que une las lógicas políticas y jurídicas del absolutismo monárquico y de la Revolución francesa. Esta noción de constitución, dentro del esquema de la constitución *von oben* —desde arriba, como lo expresaría la historiografía constitucional alemana— de la unidad política de un pueblo entendido como pueblo constituido en el

marco de una constitución.

En la época revolucionaria, sin embargo, se produce un pasaje ulterior, donde existe una novedad. Esta corresponde a la historia más moderna y es el último estrato de los tres que pretendo recorrer. El primer estrato coincide, como hemos visto, con la función de garantía de la constitución. El segundo, con la función constituyente-constitutiva relativa a la fijación y distribución de los poderes internos a un Estado soberano. Con la época de las revoluciones, y de modo muy claro con la Revolución francesa, esta tercera función es delineada: la constitución como el lugar de educación política y como instancia disciplinaria. En este estrato, la evocación retórico-revolucionaria de la constitución sirve para construir y para reconducir a su forma la complejidad de los procesos de socialización política que hacen de un hombre un ciudadano, y del ciudadano el producto de un proceso disciplinario y de nacionalización. Es el proceso que lo hace identificarse políticamente con la constitución a la que debe “fidelidad”. Todo esto se encuentra referido en la doctrina de un concepto formal de constitución. Pero ya la última función, la disciplinaria, alude a alguna forma de proceso. A saber, al proceso de socialización política de los individuos. Por ejemplo, desde el punto de vista histórico, se trata de aquella parte de la historia del discurso constitucional que podríamos ubicar entre el periodo de la Revolución francesa y el de los procesos de unificación nacional del siglo XIX. Es aquella sección del proceso constitucional en cuyo interior se afirman la proyección y el montaje de instituciones escolares, la instrucción elemental, obligatoria y gratuita entendida como una obligación del Estado, la nacionalización de las masas, la selección, la estabilización, y, por tanto, la “construcción” de una lengua y una literatura de carácter nacional. Nos referimos, por medio de esto, a procesos de implantación de la nación, de un auténtico *nation building*. Ya dentro de esta dimensión aludimos a una dimensión dinámica que resulta pertinente al concepto de constitución. A aquella función que otro quisiera nostálgicamente evocar para compensar el exceso y frío tecnicismo que se pone en evidencia dentro del proceso constituyente europeo. Por ejemplo, en la idea de una Europa entendida como una nación sin pueblo.

Dentro del concepto de constitución, la doctrina distingue una noción formal —la que se encuentra comprendida dentro de estas tres

funciones del concepto— de la noción de constitución entendida como fotografía del *status quo* —como congelamiento de una dinámica, como “bloqueo” de una situación. Sería interesante, en este sentido, reflexionar sobre la contemporaneidad del nacimiento de la fotografía y de la sociología política en el siglo XIX francés, aunque esto excede el objeto del presente trabajo. Este concepto de constitución, al cual se hace referencia en el debate, al cual remiten todos los fetichismos de la constitución que tratamos inicialmente, parte del presupuesto de que la constitución “fotografía”, esto es, legítima, autoriza y representa una distribución particular y específica de los sujetos y de los poderes. Evoca así un estado de las cosas y cristaliza una situación. Pero aun así, el concepto de constitución dentro de la doctrina no se refiere, solamente, a este aspecto puramente formal, icónico o, como hemos dicho, “fotográfico”. Según otra acepción, la constitución es entendida en un sentido material. No como el *status quo*, la fotografía o la imagen, sino como un concepto de constitución entendido como proceso, como síntesis dinámica. La constitución entendida en su sentido material, despliega al concepto como desarrollo —como reconocimiento, inclusión, un alargamiento del propio perímetro— de los factores sociales en el interior de un marco formal. Es una noción de constitución que paradójicamente remite, aunque no del todo, a otra semántica muy antigua del concepto de *constitutio*, en la que se hace referencia a la *constitutio corporis*, a la complexión física de un cuerpo viviente. Desde este punto de vista, la constitución se entenderá como un proceso viviente. Esto, particularmente, dentro de la doctrina de los años treinta, en donde todos los límites de la noción formal de constitución, acompañadas por las crisis entre las dos guerras, llegaba a esta evidencia. Veremos, entonces, como una serie de juristas antiformalistas (desde Heller a Smend, Schmitt o Hauriou y hasta el institucionalismo francés de la época) se inclinarán a pensar la inmanencia de las dinámicas constituyentes dentro de esta erosión de prerrogativas exclusivamente formales de la constitución: a un concepto material de constitución. Es decir, a un concepto que permita pensar la constitución como un proceso evolutivo de constitución y adecuación entre el sistema de los poderes y la sumatoria de los factores sociales que lo rodean.

Para ocuparnos del discurso que nos interesa es necesario partir por esta idea material de constitución, ya que es desde ahí donde la

constitución es pensada por fuera del fetichismo de la forma, y por donde comienza a pensarse como un sistema sintético-evolutivo en tensión, entre procesos sociales y cuadros institucionales, entre conflicto y dispositivo normativo. Es desde donde podemos empezar a pensar contemporáneamente en qué forma se produce (o se puede empezar a producir) el intercambio y el enfrentamiento entre los movimientos sociales y las instituciones. Ya, en la segunda mitad del siglo XIX, Ludwig August Rochau advertía que la constitución debe ser una síntesis vital y no una simple cristalización de hecho: “la sustancia de la política constitucional no es solo algo dado, sino también algo vivo”¹⁴, para retomar los términos de la distinción entre constitución en un sentido formal y material. Lo que está en juego aquí es la decisión de dinamizar el cuadro, de intentar pensar la relación entre constitución y conflicto más allá del juego de miradas en retrospectiva, las que, para redimir el presente, no saben hacer otra cosa que mirar al pasado. Piensan el presente como potencial de reverberación, pero un potencial “virtuoso” del pacto establecido en 1947. Por el otro lado, si observamos lo que planteaban los padres de la constitución estadounidense, podemos ver presente la idea de que cada generación debiera tener el derecho de hacer su propia constitución. Muy poco de esto se reafirma en nuestro presente, y más bien aquello corresponde a lo que la constitución republicana imaginaba y fijaba al sistema de sus propias referencias fundamentales.

Para una buena parte del pensamiento filosófico, esta relación entre la constitución formal y material presupone una separación clara entre Estado y sociedad, distinción sobre la cual se asienta esta relación. Si nos remontamos de forma banal no a Hegel —quien, a pesar de proponer la distinción entre los dos términos y los dos circuitos diferentes de integración del Estado y la sociedad civil, no pensaba de este modo—, sino al modo en que pensaba buena parte del pensamiento liberal, es posible encontrar la misma lógica. Identifiquemos a un titular del poder, racionalicemos los poderes, distribuyamos estos últimos entre los segmentos organizadores de la sociedad y de las instituciones, y luego pongámoslos en relación con los procesos sociales que no son inmediatamente políticos o que no son tomados directamente por la constitución. Intentar pensar de manera sintética y viviente este intercambio entre procesos sociales y el Estado, sean estos de carácter progresivo, conflictual o no, significa, por el contrario, tener que

reinterpretar y rearticular esta escisión frontal entre Estado y sociedad. ¿Cómo puede pensarse esto? Los autores citados previamente —Heller, Smend y el debate weimariano de los años treinta— tienden a pensar este proceso como uno de carácter lineal e inmanente. Como una suerte de revivificación permanente de las estructuras institucionales a través del registro de los factores sociales más vivos y progresivos. Desde este punto de vista, es posible sostener que algunas de las posiciones más vivas dentro del debate actual de la izquierda tienden todavía a pensar esta relación en términos virtuosos. Sin embargo, desde mi punto de vista no resulta posible pensarlo de este modo. Pensemos, por ejemplo, en Étienne Balibar, uno de los pensadores más agudos de la izquierda contemporánea, quien rechaza la autonomía de lo político de la que hablábamos al comienzo. Balibar rechaza la idea de que solo exista Estado y que solamente, a través de la propia indexación a este, por medio del filtro de la representación política, puedan encontrar expresión política una serie de procesos específicos. Lo que él intenta es pensar en términos dinámicos y efectivos esta síntesis entre procesos sociales e instituciones. Trata, por tanto, de revivificar un proceso constituyente continuo, el cual, desde el punto de vista del esquema que hemos desarrollado hasta ahora, puede caracterizarse como la versión de “izquierda” del antiformalismo jurídico de los años treinta. El discurso de Balibar sobre la república tumultuosa —es decir, sobre la posibilidad de engranar en términos “virtuosos” la relación constituyente entre los conflictos sociales, la institucionalización de estos a través de fórmulas dinámicas y síntesis progresivas, la continua renovación de los cuadros políticos e institucionales, valorizando así en un sentido maquiavélico y republicano la dinámica entre tumulto y constitución— es un discurso que ha sido desarrollado por el autor en una serie de contribuciones sobre Europa y sobre la constitución, y no en sus últimos trabajos referidos a la genealogía y la antropología de la ciudadanía que han sido publicados en Francia en el último tiempo.

Balibar posee un discurso específico sobre la izquierda. Si, en particular, nos remitimos a su libro publicado en los ochenta y titulado *A che cosa serve il Partito Comunista Francese?*, podemos encontrar lo siguiente: el Partido Comunista sirve para imponer e institucionalizar las instancias sociales a través de una suerte de constitucionalización del tribunado de la plebe. Lo mismo que Maquiavelo pensó al releer a Tito

Livio, es decir, una constitución en su sentido material es una constitución que se renueva. En la síntesis de izquierda de este pensamiento —como el llevado a cabo por Balibar—, esta se renueva continuamente, institucionalizando, reconociendo y constitucionalizando representaciones que se radican en y se vinculan con la conflictividad social, proceso en el que operan lazos de transmisión con la constitución. Desde el punto de vista de Balibar, esto no significa un reconocimiento que emerge desde lo alto, en el sentido de una suerte de cooptación de las instancias sociales que se determinan a partir de una vocación progresista del poder. La idea de Balibar, que es una idea de izquierda, es la de una constitucionalización constante del conflicto y de las instancias que a través de este se expresan, se subjetivan y que obligan a las instituciones, también a través del reconocimiento de los procesos dotados de un cierto grado de autonomía, a registrar nuevos equilibrios.

Creo que esta idea tiene límites, y esto es lo que intento demostrar en la segunda parte de este artículo. Posee límites en cuanto que es una idea que resulta incluso perdedora en términos políticos, en referencia al tipo de situación política que tenemos por delante. Y ese es el resultado del análisis que debemos llevar a cabo: enderezar las instancias de subjetivación política a la constitución, la cual está todavía totalmente atravesada y excedida por los procesos que ya no está en condiciones de alojar en su propio interior. Por el momento basta pensar en cómo la desarticulación contemporánea del Estado¹⁵ vuelve imposible valorizar en un sentido positivo, “virtuoso” si se quiere, la distinción entre Estado y sociedad civil, y lo que de esta se sigue: la distinción entre lo público y lo privado, entre cuadros formales y cuadros materiales de la constitución, entre lo interno y lo externo del derecho. Vista de este modo, la posición de Balibar (del mismo modo que otras dentro de la izquierda) resulta profundamente nostálgica de algo que, para bien o para mal, ya no existe más. No resulta siquiera posible pensar la constitución en este sentido, como el terreno sobre el que redefinir un bien político común. Tampoco para, a través de ella, defender los equilibrios, aunque progresivos y dinámicos, en el interior de un marco de referencia que sigue siendo el de la estatalidad clásica, el cual ha sido en gran parte superado y privado de los procesos que lo exceden. Una realidad que ya no existe más, y que, la parte que aún sobrevive, resulta funcional a las políticas de reorganización macrosistémica en los espacios posnacionales de la Unión

Europea, o de la *governance* global¹⁶.

Volvamos al cuadro de la dinamización de la constitución y la doctrina. En tanto se entiende que el motivo por el que la constitución puede ser pensada de manera fetichista como “bien común” reside en que, en esta, son recepcionados e inscritos los derechos. Una obra como *Ciudadanía y clase social* de Thomas H. Marshall resulta un clásico *paradigmático* desde este punto de vista. Da cuenta de una constitución formal hacia la que se dirigen las reivindicaciones de los movimientos sociales y dentro de la cual están registradas las olas sucesivas de derechos. Encontramos nuevamente la dinámica y la tensión entre constitución formal y material, planteada ahora como el terreno en el que maduran los procesos que participan de modo progresivo en la síntesis constitucional, produciendo, de este modo, equilibrios siempre progresivos.

Si analizamos esto en mayor detalle, podemos partir por la idea de que en las constituciones están inscritos los derechos fundamentales. Volvamos entonces a la tradición constitucional de los siglos XVII y XVIII. La primera oleada de derechos que son registrados en las constituciones son los derechos civiles: la libertad de expresión, la propiedad privada, el *habeas corpus*, y así sucesivamente. Luego, es el dinamismo de la sociedad el que progresivamente impondrá otra serie de derechos que correspondientemente se inscriben en la constitución para ser recibidos. La segunda oleada, en la que se incluye Marshall, es la de los derechos políticos, con todo aquello que contradictoriamente remite al reconocimiento de los derechos de participación. Esto, en la medida en que el esquema concéntrico de Marshall no se refiere a oleadas que de forma no contradictoria se ensamblan unas con otras, como círculos del tronco de un árbol que crece, como secuencias de justificación de derechos cada vez más abarcadoras y extendidas. Si prestamos atención a esta segunda oleada de los derechos de participación que son constitucionalizados como derechos políticos, *por medio* de cualquier manual de historia contemporánea podemos saber que esta constitucionalización se produce en términos contradictorios y difíciles: es una historia que comienza con los primeros debates del sufragio limitado de las clases burguesas en la Francia de la Restauración, y que se *concreta* de modo bastante contradictorio en Europa, en relación a las declaraciones universales de los derechos del hombre y del ciudadano,

con la concesión del voto a las mujeres entre 1944 y 1946. La tercera generación de derechos se refiere a los derechos sociales. Las mujeres votan en Francia desde 1944 como resultado de la constitucionalización de la segunda oleada de derechos, pero los debates sobre los derechos sociales comienzan antes. La historia nos indica que ya se planteaban como problema en la época de Bismarck en Alemania. Los derechos sociales son reconocidos en un proceso que concierne la genealogía de la “gubernamentalidad” que Foucault reconstruye en su curso de 1978 en el *Collège de France*. Por medio del concepto, se da cuenta de un intervencionismo del Estado a través de tecnologías jurídicas que implican la progresiva superación de la distinción entre Estado y sociedad, entre sujeto de derecho y las biopolíticas de la población. Intervencionismo que resulta observable en la distribución de la desocupación, en las pensiones de invalidez, en las políticas de asistencia o sobre la maternidad y similares. En este sentido, esta tercera fase nos permite ver cómo la estratigrafía de la constitución es compleja. Y, por tanto, que no debemos entender a Marshall como si nos relatara una tendencial extensión de los derechos, como una línea inercial y progresiva de la historia constitucional occidental, evitando que esta historia sea restituida como contradictoria, difícil o conflictual. Como una historia también conformada por aquello que el historiador alemán Reinhart Koselleck llama, retomando la expresión de Ernst Bloch, la “contemporaneidad de lo contemporáneo”, es decir, una historia de agregaciones superpuestas, de choques de tiempos, de reivindicaciones; en resumen, de formas de reconocimiento parcial, aporéticas y difíciles. Todas formas, es necesario remarcarlo, arrastradas desde las luchas.

El problema de la superación de la distinción entre Estado y sociedad civil, que pone en crisis la repartición clásica entre derecho público y derecho privado, comienza alrededor de 1848. En ese sentido, las insurrecciones de ese año se afrontan desde la ciencia jurídica y política alemana durante la década siguiente. Lorenz Von Stein se encuentra entre los primeros en comenzar a preocuparse por las funciones de profilaxis, lo que nos remite, ya en ese momento, a la biopolítica. En un libro de Francois Ewald sobre la genealogía del Estado de bienestar¹⁸, se pone en evidencia cómo el descubrimiento de Pasteur sobre la contaminación viral es sucesivamente funcionalizada en un sentido político: es un descubrimiento que permite determinar la posibilidad de

una intervención social del Estado y los instrumentos para esta. Es decir, busca reconocer los derechos sociales como marco para disciplinar las salvajes insurgencias proletarias. Sirve así, fundamentalmente, para vacunar a la sociedad en sus clases más pobres contra el contagio del virus comunista. Este es el problema que orienta la potente innovación en el campo de las ciencias jurídicas y del Estado en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando hablamos de biopolítica en el sentido de una función inmunitaria de los marcos legales, a este tipo de problemas nos referimos. Es por estos motivos que hemos discutido a Marshall, porque desde el punto de vista del marxismo que se proponía a fines de los sesenta¹⁹ es precisamente el problema de esta relación lo que está en juego. A saber, de cuál es la funcionalidad que el Estado y la constitución tienen relación con las dinámicas sociales: ¿Qué es lo que estas significan en una sociedad que se encuentra estructurada por el dualismo de clases? ¿Cuáles son los equilibrios que la constitución intenta conservar y preservar? ¿Cuáles son los tipos de relaciones que la constitución, entendida en un sentido material, intenta no tutelar, sino más bien capturar para poder inmunizarlos respecto de su virulencia revolucionaria? Estas son las preguntas sobre las que el fetichismo de la constitución irónicamente sobrevuela. Porque la historia de las instituciones —en una lectura que, más que marxista, resulta foucaultiana— está hecha del modo en el que las resistencias/ insurgencias son capturadas y comprendidas por los poderes y las instituciones.

Entonces, ¿qué es la constitución desde el punto de vista marxista o desde la posición de un marxista herético, como era cualquier operador en los años sesenta o setenta, cuando, justamente, se comenzaba a analizar esta forma de compromiso sintético entre los equilibrios materiales por un lado y la constitución formal, por el otro, y a denunciar los límites de esta relación en términos de crítica política? Como preludio a la parte final de este análisis, debemos asumir como eslogan de ahora en adelante más la vieja idea de Negri, según la cual la crítica a la economía política debe ser la crítica de la administración, del Estado y de la constitución. Este es el tipo de trabajo que orienta las conclusiones que siguen y que, por lo tanto, las vuelve aún imposibles: no llegaré a cerrar este razonamiento ofreciendo una fórmula, porque la crítica material de la economía política coincide con los procesos de subjetivación, con las formas materiales de conflicto. Y, en este sentido, la crítica a la economía

política aplicada a la administración, al Estado y a la constitución implica una tarea que no puede ser solo teórica. Esta no puede alcanzar un resultado definitivo para el presente análisis porque los procesos de subjetivación y los conflictos entre libertad y poder, entre autonomía individual y sistema normativo, no terminan jamás. Solo las luchas, entendidas como el continuo relanzamiento de la tensión entre subjetivación política y captura institucional, pueden aclarar, de vez en cuando, de qué trata el problema.

Este último discurso relacionado con los derechos sociales nos conduce al discurso sobre la constitución italiana hecho por Toni Negri y algunos colegas que trabajaban con él a fines de los sesenta y comienzos de los setenta. En esta alocución, se preguntaban qué es la constitución de la Italia republicana. Y respondían: la Constitución del 48, fundamentalmente, es un acto represivo. Si esta es celebrada, cuasi santificada, como el momento en el que por primera vez —como diría Bersani, y también Ugo Mattei— la nación se constituye y se reconoce como bien común de los italianos dentro de un gran compromiso político e institucional que recibe y enuncia como derechos fundamentales el derecho al trabajo, a la paz, a la seguridad, desde el punto de vista operista, esta es también el instrumento a través del cual se realiza la operación que cierra las dinámicas insurreccionales que habían atravesado la resistencia y que permanecían luego de ella. ¿Cómo se logra llevar a buen puerto esta operación? El artículo 1 dice que Italia es “una república democrática fundada en el trabajo”, y califica al trabajo abstracto y general. El análisis operista, entonces, comenzará a poner en crisis justamente esta noción abstracta de trabajo, buscando relacionar la crítica a la economía política con la crítica al Estado. Si analizamos la nueva composición social y política de clases que se expresaba políticamente en las luchas de los años sesenta y setenta, esta composición estaba integralmente mistificada en el cuadro político sancionado en el compromiso constitucional. Cuando Gigi Roggero dice que “los jóvenes deben hacer la encuesta”, quiere decir lo siguiente: cómo hacemos, si no es de este modo, para trazar el plano en el interior del cual la crítica de la economía y la crítica de las instituciones convergen para hacer emerger la actual composición de clase del trabajo vivo, para poder posicionar objetivos y estrategias de lucha respecto de esta última.

Luego vienen los años sesenta. Son los años del ordenamiento del

gran compromiso fordista en Italia. Los años en los que las instituciones del Estado, los partidos y los sindicatos que se reconocen en el Parlamento y en la constitución resultan ser el nudo en el que se realiza, sobre todo gracias al Partido Comunista italiano, la progresiva “cooptación de la clase, a través de sus representantes, para gestionar la propia explotación”²⁰. ¿De qué se trata, entonces, el compromiso fordista que se resuelve en esos años? Observemos cómo funciona la síntesis dinámica de una constitución que sabe que es un cuadro formal, pero también una constitución material. Esto quiere decir, una constitución que produce equilibrios más avanzados. Sin embargo, desde el punto de vista de la conflictividad creciente de los años sesenta, esto significa la construcción de los equilibrios que, incrementando ritmos y explotaciones, permiten el *boom* económico. Lo cual, por lo demás acaece a través de la cooptación de aquellas posibilidades que en Balibar aún parecen posibilidades para un tribunado de la plebe, es decir, a través de la cooptación de los sindicatos y de las representaciones de la izquierda. Fundamentalmente, esto significa más productividad y más salario; expresa más salario para poder comprar aquellos bienes que son producidos por la gran fábrica fordista. Esto significa unificar Italia como bien común a través del hecho de que se venda una lavadora en cada casa, y, por ese motivo, los operarios y los trabajadores deben ganar algo más de lo que ganarían o habrían ganado si se los retrotraía a las condiciones de un país atrasado y semicampesino como era Italia en los años cincuenta. No hay que dejar de tener en cuenta que el precio de todo se ve reflejado en un incremento y una centralización del mando, en la expropiación de la cooperación productiva y su reglamentación bajo las jerarquías de la empresa, en la soberanía absoluta del cronómetro y del *management*, en el riesgo marginal de la catástrofe ecológica, la doble explotación de las mujeres, en que surja la trampa de la deuda, la cual, como decía Deleuze, un lector de Nietzsche, es como que “jode el infinito” y nos liga a la maldad infinita del chantaje y la coacción del trabajo. Es necesario tener todo esto en cuenta; sin embargo, es una dimensión del análisis que nos desvía del punto central del presente trabajo.

A continuación, vienen los años setenta. Para quien hace la crítica de la economía política, la constitución nuevamente resulta ser el punto de convergencia de una serie de procesos. Se trata de aquello que por esos años era definido como el “Estado-plan”: una modificación general y

ulterior del Estado y de las instituciones. Este cambio significa, en un sentido materialista y marxista, que la crítica de la constitución no puede quedarse en la idea de que ella es la gran ideología que se limita a hacer posible el mercado, sino que, al contrario, esta debe más bien asumir el hecho de que en el mercado se interviene y se planifica. Esto quiere decir que el Estado se vuelve un aliado de los procesos de la empresa, colabora con estos procesos y sostiene las estrategias de apertura de los mercados y la competencia dentro de estos, seleccionando y favoreciendo a los sectores productivos más avanzados. En el “Estado-plan” se configura una suerte de alianza estratégica o, como la llamarían hoy en día, utilizando un término “técnico” y supuestamente aséptico, una sinergia entre Estado y empresa. Un “pacto” que se vale de las instituciones, pero también de la multiplicación de instancias administrativas, de experiencia, de comités técnicos, etc., todos funcionales a la estructuración y a la implementación del “plan” que concentra las inversiones en sectores estratégicamente funcionales a la competencia internacional del país.

Esto quiere decir que si el Estado nunca es neutro, en esta fase del desarrollo capitalista él abandona descaradamente su pretendida neutralidad y se convierte en uno de los grandes jugadores del mercado, ofreciendo las estructuras, asignando recursos y capitales, invirtiendo en formación e investigación en sectores que se proyectan como decisivos para la valorización y el progreso. Es decir, es una activación constante del Estado en la dirección de la sociedad y de sus dinámicas productivas, en el lanzamiento de los procesos de desconstitucionalización del mando que explotarán en los años sucesivos. Si el Estado se convierte en un jugador dentro del mercado, si el Estado se vuelve “Estado-plan”, si el Estado utiliza las instituciones y su propio potencial de innovación y de reforma para proyectar los procesos, para implementar estrategias, para colaborar con el capital en la conquista y posterior defensa de cuotas en el mercado. Si todo esto ocurre, es evidente que la jerarquía de funciones normativas se hará bendecir constitucionalmente. Esto quiere decir que los órdenes institucionales que la constitución establece como división de los poderes y como forma legítima de ejercicio del mando, a saber, la distinción entre público y privado, la verticalidad del acto administrativo como ejecución de la decisión soberana, la sustracción del derecho de la batalla política entre las partes y la codificación de su neutralidad,

modifican radicalmente su propia naturaleza y significado.

Los años sucesivos están marcados por una fuerte intensificación de estos procesos. Antes que todo, estos tendrán lugar de forma incremental en el exterior de la discusión pública que debería darse en torno a ellos, para así llegar a una síntesis en el parlamento. De tal manera, las funciones de planificación y de intervención económica del Estado marginalizan las funciones y las prerrogativas clásicas del parlamentarismo. En segundo lugar, hay que destacar que es aquí que se desencadena la crisis definitiva de la representación política. Resulta evidente que mientras más se concentra el capital, cuando el mercado funciona menos de lo que debería funcionar según su ideología —es decir, como un juego de oferta y demanda, donde solo los más fuertes sobreviven y logran construir las condiciones para contratar con los aparatos del Estado e imponer la propia participación en el gran plano de modernización económica del país: en la industria automovilística, química, etc.—, tanto más se concentra, del otro lado, la insurrección obrera. Nos referimos a los años setenta. Cuando se concentra el capital en dos o tres grandes conglomerados de fábricas y empresas, tanto más crece la relevancia de la composición social que es puesta a trabajar. Cuanto más crece la relevancia del trabajo vivo, más crece la insubordinación y la autonomía de los sectores de clase que denuncia el pacto entre Estado y capital, el que se afirma también a través de la cooptación del “plan” de los sindicatos y representaciones de partidos de “izquierda”.

Hablamos aquí de un pasaje que produjo una serie de desastres a mediados de los setenta. Un efecto de estos —al menos, para la parte que los percibía de este modo, la que se vio atacada— es el modo a través del cual es organizada la respuesta a esta crítica de la centralidad del parlamento y de la representación política. Es desde este punto donde se lanza el proceso de progresiva gubernamentalidad de los poderes que cooptan las funciones de *governance*, aquellas a las que la retórica de los periódicos llama “poderes fuertes”: *lobbies*, agencias administrativas, comités de expertos dentro de los cuales se materializa la planificación. En este sentido, la crisis del parlamento y la representación política, la crisis del control de la legalidad —otro problema inscripto en el sistema de poderes de la constitución— y la gradual autonomía del ejecutivo son todos problemas que dan cuenta de la multiplicación, tecnificación,

privatización y flexibilización de los polos administrativos. Creo que se puede afirmar, y no como obsequio a una suerte de linealidad dialéctica, que esta tercera fase de modificación del Estado, la del “Estado-plan”, está en el origen de la contemporaneidad. Lo está al menos por estos tres procesos, todos reabsorbidos y redefinidos en los procesos que marcan la transición de la que somos parte. Transición caracterizada, como decíamos, por la crisis de la representación política y de la centralidad del parlamento, por la creciente preponderancia e incidencia de la decisión técnico-administrativa, por la multiplicación, flexibilización y omnipresencia de las autoridades administrativas como tipo ideal de la gestión y de la regulación política general.

Cuando instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo dictan planes para asumir deudas, o diseñan políticas para Argentina o Grecia, se trata justamente de estos poderes “administrativos”. Son poderes administrativos que se encargan de las tareas de planificación, lo que significa que nada pasa por sus parlamentos, o mejor dicho nada que termine por desautorizarlos radicalmente. Aún existen voces nostálgicas que nos dicen que en Grecia lo que está en cuestión es la democracia. Al contrario, yo creo necesario pensar la política y el conflicto decididamente por fuera de los parlamentos y de las formas clásicas y nobles de la democracia representativa, que hoy ya han decaído. Cuando hablamos de autoridades administrativas, no hablamos de la administración clásica, de las cadenas de transmisión ejecutiva de la decisión, sino de las autoridades administrativas independientes, de los comités de expertos, de las agencias en las que el mando se ha reorganizado de modo extraconstitucional. Esto acontece en forma de multinivel en términos de *governance*, para así responder a los procesos de insurgencia que, en los años setenta, habían vuelto imposible el mecanismo de filtro y decantación entre los movimientos sociales y la constitución, un mecanismo organizado por las instituciones representativas.

Como podemos ver, hablamos aún de los años setenta y todavía, en realidad, hablamos de nosotros. De como se solía decir: *nobis fabula narratur*. A partir de esto, orientamos las conclusiones de este trabajo. A mediados de los setenta, prácticamente todos los científicos políticos se dan cuenta de que el mecanismo de separación y repartición entre Estado y sociedad, entre movimientos sociales y representación, entre el mando

y el mercado, han saltado. Esto conlleva que los procesos deben ser leídos moviendo la recíproca e inextricable implicación de Estado y sociedad. De modo simplificado, podríamos decir que en el debate politológico de los años setenta se confrontan dos tesis opuestas. La primera, representada entonces por Claus Offe y un joven Jürgen Habermas, plantea la idea de que nos encontramos en curso a una progresiva e inexorable estatización de la sociedad. Que este progresivo desligarse de lo político, de las figuras de mediación y representación y del parlamento, lo que se refleja en el cuerpo vivo de los procesos económicos y sociales, se desarrolla como una suerte de “colonización” institucional, que tiene por objetivo conducir al orden aquello que ya no puede ser reconducido. Para entender esto con una o dos imágenes, quizás sea suficiente leer lo que Foucault plantea en entrevistas que concede a periódicos en la segunda mitad de los años setenta, en las que explicita los motivos de la reformulación analítica del poder (ideas que desarrolla, al mismo tiempo, en los cursos en el *Collège de France*). El ingreso en la “época de la gubernamentalidad” —la misma que Offe y Habermas interpretan, por el otro lado, en términos más simplistas y confusos respecto de los análisis de la Escuela de Fráncfort, como “estatización de la sociedad”— está provocado por una serie de procesos globales que marcan, kantianamente, una edad diferente del mundo. Es por esto que Foucault pone en evidencia a los propios interlocutores: el 68 francés no es el 68 francés, sino, más bien, un proceso iniciado dos o tres años antes en Túnez; que la Revolución iraní del 79 introduce a una nueva época de la política; o cómo se ha entrado evidentemente en un tiempo marcado por la gubernamentalidad de los dispositivos del poder en respuesta a los procesos destituyentes y posrepresentativos, los que han hecho de la figura del “disidente perpetuo” su propio ícono (algo particularmente visible cuando Foucault toma posición a favor de Klaus Croissant, abogado defensor de los militantes políticos alemanes). Resulta evidente en este caso, al menos desde mi punto de vista, que él tiene en mente, al mismo tiempo, la experiencia de Solidarnosc en Polonia y los movimientos antagonistas de Italia de los años setenta. La reacción frente al “Estado-plan” y la progresiva subsunción real de la sociedad por parte del capital producen también una generalización de las insurgencias, de las insurrecciones, del rechazo al trabajo. ¿Cómo registra, al mismo tiempo, la ciencia política este proceso de implicación? El Estado diseña

una serie de trayectorias de intervención en lo social, que tienen fundamentalmente el objetivo de prevenir la conflictividad, de dar lugar a un sistema de mediaciones multiplicadas y difundidas en el cuerpo de la sociedad. Porque ese primer esquema de mediación del conflicto, aquel que se organiza en los años sesenta por medio de la cooptación de sindicatos y partidos, evidentemente no resulta así. Multiplicar los nudos administrativos, flexibilizar la intervención, multiplicar las autoridades y las agencias de gobierno significa buscar construir dentro de la sociedad aquellos nervios institucionales que pueden permitir volver nuevamente eficaz el compromiso y los equilibrios. Porque el compromiso encabezado por el Estado y por la funciones de mediación ofrecidas por el sistema de partidos —lo planteado por Offe y Habermas—, evidentemente, no funciona más.

Por el otro lado, tenemos la tesis opuesta, que es la que nos interesa. Es decir, no la estatización de la sociedad, sino la socialización del Estado. Es la idea que defienden en una relación trilateral en 1973 algunos jóvenes personajes como Samuel P. Huntington²¹, Michael J. Crozier y Joji Watanuki, es decir, quienes estarán entre los exponentes más influyentes del *think thank* republicano de Reagan y Bush. ¿Cuál es su tesis? La opuesta a la de Offe y Habermas, y, por ello, es que las planteamos en estos términos, como estatización de la sociedad, por un lado, y socialización del Estado, por el otro. Esta tesis plantea que el cruce entre Estado y sociedad no funciona más. No lo hace porque los movimientos que se tienen por delante producen un exceso de quejas que no son procesables por el sistema de instituciones de la democracia representativa. Entonces, la democracia está en crisis porque se ha vuelto ingobernable, aunque debiéramos decir que la democracia es crisis. En otro tiempo, la política consistía en arrojar candidatos, programas políticos, en dejarse encantar por la magia de la representación y por agendas políticas concentradas en las grandes cuestiones de principios. Pero, por lo demás, la política terminaba ahí. Pero los años sesenta y setenta producen una conflictividad que remite a toda la esfera de reproducción de la fuerza de trabajo. Se abren las cuestiones de la ecología, de las mujeres, del derecho al estudio y al tiempo libre, y se contesta así, de forma radical, al proceso de salarización de la sociedad. De este modo, se conducen procesos de subjetivación política radical sobre aquello que en la época se llamaban “necesidades”. Todo esto desde

el punto de vista reaccionario de Huntington, Crozier y Watanuki, quienes hacen esta relación de la crisis de la democracia porque tienen en mente la reconquista del control sobre la sociedad, hacia un problema de conservación y de persecución del orden. Esto obliga a repensar las instituciones porque la crisis, evidentemente, no puede ser recuperada multiplicando las instituciones de compromiso dentro del cuerpo de la sociedad. Y, al contrario, se vuelve necesaria una rearticulación general del derecho y de las instituciones.

Si desde aquí queremos hacer la crítica a la economía política de la administración del Estado y de la constitución, solo obtenemos problemas y no más certezas. Y, más aún, si la última certeza que tenemos es que los años ochenta —los años en los que los análisis de Huntington, Crozier y Watanuki, en relación con la Trilateral sobre la crisis de la democracia y la hipótesis que surge, son los vencedores— son los años en los que es proyectado, implantado y, en gran parte, desarrollado el sistema de *governance* posestatal al que aún hoy nos enfrentamos. Los años ochenta son aquellos en los que se pone en su lugar el sistema de tecnologías políticas e institucionales que empujará la globalización económica y jurídica. Son los años en los que se lleva adelante un ataque fundamental a todas las instituciones residuales de mediación entre trabajo y capital. Los años de la contrarrevolución liberal de Reagan y Thatcher. O, para sintetizarlos, los años en que Foucault, empujado por la urgencia de la actualidad, comienza a trazar la genealogía de la gubernamentalidad neoliberal, la que se comprendía en la fórmula “de la soberanía a la *governance*”. Esta consistía en una progresiva administrativización de los procesos políticos, en una rearticulación global de las instituciones, la que traza los espacios y tiempos posnacionales de la política. Un proceso que margina al Estado, no para hacerlo desaparecer (como podríamos ser inducidos ingenuamente a pensar), sino para reestructurar su función, para llevarla más allá del compromiso fordista clásico y reposicionar así el Estado como unión intermedia de la *governance* global. Un proceso al cual, como podemos notarlo, la crisis financiera de los últimos años puso tal vez también en crisis, pero que quizás empuje ulteriormente hacia delante, es decir, que se expanda e incremente ulteriormente en aquello que podemos comenzar a llamar hoy una tentativa salida neoliberal a la crisis del neoliberalismo. Con todo lo que esto implica en términos del

tecnicismo posrepresentativo de la política: nuevas formas de judicialización no estatal de las relaciones sociales y una cesión progresiva del monopolio estatal de la violencia. Aquí, sin embargo, aún encontramos un partido que jugar, en la medida en que aquí se radican los conflictos que marcan el último tiempo desde las campañas de Occupy a las revoluciones de Medio Oriente, desde los movimientos antisistémicos de los universitarios a los Indignados. Sin embargo, el referirnos a las líneas tendenciales de esta curva nos conduce a terrenos que desconozco.

Entonces ¿qué es la *governance*? Antes que nada, es hacer pasar la política —entendida, en un sentido muy amplio, como el conjunto de “funciones de regulación”— por instituciones no representativas, donde se valoran los saberes expertos, en los que la vieja fábula de la representación se pone totalmente a un lado y los órdenes políticos e institucionales se estabilizan en un sentido posdemocrático. Existen quienes, en este horizonte y en las retóricas reflexivas de los apologetos de la *governance* o de la sociedad civil global, ven aspectos potencialmente positivos en términos de un incremento de la participación o de suplencia (a través de las ONG, de la web, de los comités). En relación a aquella participación que en las democracias maduras parece renunciar a las clásicas figuras de la representación política o de los parlamentos, existen, por ejemplo, quienes se entusiasmaron por la primera elección del presidente Obama en Estados Unidos. Pero, ¿cuántos votaron? Un porcentaje irrisorio de aquellos que tienen derecho a voto. Por tanto, el gran suceso representativo —celebrado como aquellos que hubiesen modificado la historia estadounidense— se revela como el producto de un bajísimo nivel de participación de la liturgia electoral. Aquello que otros han llamado, con referencia al antiguo *sacré du roi*, el *sacré du peuple*. El dato referente a la elección de Obama podría ser confirmado (tal vez con la excepción de algunos países de América Latina), si evaluamos la tendencial caída de la participación electoral en las principales democracias contemporáneas. Los sostenedores de la positividad de la gubernamentalidad de los poderes —y, por lo tanto, del descentramiento de la decisión y de su organización en base a procesos periféricos de mediación entre agencias administrativas y grupos organizados de la sociedad civil— nos dicen que como la participación ya no va más allá de esto, del rito del sufragio y de

las instituciones clásicas de la representación como los partidos, los sindicatos o los parlamentos, la participación puede, por tanto, hacerse crecer y organizar en la contraposición entre diferentes actores involucrados por los niveles, múltiples y diferenciados, de la *governance* (metropolitana, comunal y universitaria). Es decir, entre los *stakeholders* de un proceso político pensado en términos económicos como una continua “contradicción” de decisiones responsables y eficientes. En términos banales, esto significa que si el objetivo es, por ejemplo, organizar la *governance* de las migraciones, lo que se hace no pasa solamente a través de las leyes represivas como son la *Bossi-Fini* o la *Turco-Napolitano*, sino que se organizan esquemas de *governance* de las migraciones dentro de las que se cooptan²², no a los migrantes o a los ciudadanos, sino a las agencias de expertos sobre los problemas de inmigración y su control (sean estas Cáritas, las guardias de fronteras, los técnicos de las oficinas de trabajo o los representantes de la Organización Internacional para las Migraciones [IOM], que organiza las campañas para la repatriación de los clandestinos). O, tal vez, cooptando a las mismas comunidades étnicas de los migrantes. Escogiendo las más sensibles al compromiso y a la “representación” del migrante, entendiéndolo no como una subjetividad ligada al propio proyecto singular migratorio, sino como miembro de una espectral comunidad nacional. *Governance* quiere decir que, si el objetivo es reorganizar la universidad, esta reorganización tiene lugar a través de procesos que marginan la relevancia, aunque solo imaginaria, de las representaciones estudiantiles o del trabajo, pero que cooptan al gobierno de la universidad como si se tratase de un consejo de administración empresarial. Esto es, por medio de las redes de intereses involucradas en la existencia de la universidad en un territorio y por los procesos económicos, políticos y formativos que se reproducen a través de esta: la región, los poderes locales, los grandes bancos, las fundaciones, los industriales y, selectivamente, también las organizaciones sindicales o corporativas (asociaciones de profesores, de profesionales, de estudiantes) que intentan positivamente colaborar con el gobierno de estos procesos.

Por este motivo es atrasado embanderar la constitución. Hay quienes expresan el propio placer a través del fetichismo de la constitución y la legalidad, pero ese no es nuestro problema. Para que contemporáneamente una serie de procesos referidos a la política —esto

es, el Estado y las instituciones— estuvieran irresistiblemente marcados por este proceso de gubernamentalidad y, por tanto, se contrastasen con los procesos de subjetivación política que se producen en los niveles que están organizados y que marcan toda la gama de gradaciones, espacios y tiempos respecto de los que la función del gobierno involucra la vida de las personas. En el proceso de *governance*, más que la posibilidad de un relanzamiento de la democracia participativa, se encuentran en juego cuestiones decisivas que refieren a tiempos y espacios de la reproducción del trabajo vivo contemporáneo. Concluida la narración sobre una identidad de clase organizada en el perímetro de la gran fábrica fordista, cuya voz era delegada al sindicato y al partido, temo que, a través de la representación política, no es posible hacer más nada: si luego se quieren hacer tumultos —una versión “disciplinada” y regulada del conflicto— para poder así inventar la posibilidad de una representación general de los movimientos, y luego ofrecerla a la máquina política y lucrar con alguna ventaja periférica en el corrupto sistema de partidos italiano, como decía, no es posible hacer más nada. Por el tipo de racionalidad técnico-administrativa que da lugar, la función de la *governance* asume, entre otras cosas, roles que podríamos definir como semiconstituyentes. Y es esto lo que vuelve evanescente su contraste en el terreno de los poderes constituidos. Nos referimos, por ejemplo, a los procesos de financiación que siguen los programas de *corporate governance*, y que tienen una incidencia material en nuestras vidas. Estos procesos no pueden ser contrastados reactivando la vieja fantasía según la cual hay una economía real, auténticamente productiva, y una economía financiera, puramente especulativa, fantasía que nos permite retirarnos de esta última y reinstalar una autonomía de lo político capaz de aprovecharla. En este sentido, creo que la *governance* financiera y el chantaje de la deuda deben ser contrastados en el plano de la *governance* financiera con el rechazo de pagar la deuda. De igual modo la *governance* universitaria debe ser contrastada a nivel de la *governance* universitaria y de la autovalorización del trabajo cognitivo. Ambos contrastes no deben dejarse encantar por la nostalgia de las manos callosas del obrero fabril, ni por las sirenas del público, ambas ideas relacionadas con un modelo y una práctica de las instituciones, casi totalmente, superada por la realidad.

A modo de conclusión, podemos plantear que lo que falta a la

governance se refiere a: a) la pérdida de centralidad de las instituciones representativas; b) un fundamental tecnicismo de los saberes de la política y de sus procedimientos decisionales; y c) mecanismos de cooptación que no simulan siquiera reconocer las representaciones y que, al contrario, se valen de saberes expertos en el interior de los cuales —siguiendo a Foucault— se articulan, organizan y expanden también los poderes concretos reales. En la *governance* está en juego un tecnicismo de la política que nos aleja del Estado y de la constitución. Y, por tanto, para clarificar esta idea, podemos volver a la semántica general del término 'gobierno'. La *governance* circunda y arrincona como perno del proceso político a la soberanía, la representación, el Estado y la constitución, valorizando, por el contrario, una serie de tecnologías en las que resuena una semántica muy antigua del *gobierno*. Recordemos el modo en el que los lingüistas nos explican que el término 'gobierno', uno de los más comunes en el léxico político europeo (*to govern, gouverner, governare, gubernare, kybernaó*), nos conduce al campo metafórico de la navegación. *Kybernaó* parece reactualizar y hacer posible en el léxico europeo una antigua raíz sánscrita, la de *kubara*, la barra del timón. Desde la antigua metáfora, que recorre Platón y Cicerón, gobernar quiere decir conducir. El acto de conducir, la *gubernatio navis rei publicae*, indica un acto incierto, difícil y riesgoso, que es el de la navegación. De aquí, la elipse de la que partí: toda la historia constitucional del Estado moderno ha trabajado para la disolución de la elipse que ve enfrentados uno a otro, quien gobierna y quien es gobernado. El pueblo, ennoblecido en la ficción representativa de la voluntad general —esto es, la clase desde el punto de vista del partido que la representa— es integralmente recompuesto y reabsorbido en la decisión sobre sí mismo y sobre su propio destino político, que es imaginado como lo que lo autoriza y lo vuelve legítimo: *we the people*, ¡aquí la constitución! Es decir, somos, al mismo tiempo, súbditos y soberanos, la unidad que hace desaparecer detrás de sí al conflicto, la desidia, el choque entre gobernante y gobernado, entre súbdito y soberano, entre gobierno y lo ingobernable.

Es la metáfora de la navegación la que nos ayuda a entrar en la reactualización de la elipse gubernamental que guía este trabajo. Los procesos de *governance* son procesos de gobierno que saben que afrontan una navegación riesgosa. Esto ocurre porque, en términos banales, es fácil contrastarlos activando la nostalgia por las formas

representativas clásicas, por el hecho de que las autoridades gubernamentales son autoridades “técnicas”, es decir no elegidas, y, por lo tanto, ilegítimas cuando se cargan de tareas de regulación general. Recordemos en este punto a Huntington y a sus amigos, porque la génesis misma de la *governance* es producida por el conflicto. Esto es lo que obliga al Estado a gubernamentalizar los propios dispositivos, el hecho por el cual este debe constantemente afrontar una navegación riesgosa, la navegación del éxodo de los mecanismos tradicionales de la decisión política, la navegación de la insurgencia y de la insubordinación. “Hemos entrado en la época de los gobernados”, dijo Foucault. Yo planteo que esto de “los gobernados” debe ser entendido como un genitivo subjetivo: son los gobernados quienes deben ser constantemente perseguidos y capturados por los dispositivos de gobierno. Resultan volátiles los flujos financieros que la *governance* económica y política buscan territorializar y poner bajo control y, por el contrario, como vemos, estos se demuestran ingobernables en sus dinámicas, y lo es tanto más el conjunto de líneas de fuga que, según Deleuze, definen el plano de lo social. Gubernamentalizar los dispositivos del Estado significa forzar, continuamente, al mando a inventarse prótesis normativas e institucionales que puedan ser inherentes a los procesos sociales para buscar reconducirlos al control. Incluso si esto se escapa —consideremos las trayectorias centrífugas de la libertad y de la subjetivación— se demuestra como evidentemente no anticipable y no del todo controlable. Estas trayectorias de la libertad y de la subjetivación son trazadas por la nueva composición del trabajo vivo, por el capitalismo cognitivo y sus estructuras, por una cooperación social que ha separado definitivamente los muros de las fábricas y la medida del salario. Justamente, por esto rechazan lo uno del mando, es decir, la representación en un sentido clásico. Nos encontramos así frente al problema de reabrir la investigación para entender cómo se articula esta *governance* en los espacios y en los tiempos diferenciados que la introducen en nuestras vidas singulares y colectivas. Para de este modo atravesar un duro trabajo de análisis sobre los circuitos de la explotación y de las diferencias que los marcan. Estamos, por tanto, frente —políticamente en frente— al problema de recomponer las luchas. Se trata de enfrentar un constante problema de recomposición, porque el sistema con el que trabaja hoy el gobierno es el de dividir y pluralizar, de obligar, para que puedan ser

governados, a los gobernados a reivindicaciones sectoriales y parciales. A escindir y a fijar las resistencias para enfrentarlas y vencerlas una por una. Si entonces queremos hacer la crítica de la economía política de la administración, es decir, si queremos hacer la crítica de la economía política de la *governance* contemporánea, más que del Estado y de la constitución, debemos quitarnos de la cabeza la idea de que la política pase, en forma privilegiada, por el Estado. Se deben seguir, más bien —de modo teórico, en el plano de la investigación y del análisis, y de modo político, organizando y recomponiendo las líneas de conflicto—, los procesos de articulación del mando sobre los diferentes niveles específicos sobre los que ellos se están produciendo según lógicas y tecnologías siempre puntuales. Ligándose de esta forma a la producción y a la reproducción de códigos, de saberes expertos, de nuevos planes normativos. Si queremos que desde la crítica de la economía política de la *governance* siga una crítica política —imposible no hacerlo—, el trabajo que debe desarrollarse es el de traducir uno en el otro, y así recomponer los hilos de una resistencia de los gobernados que el mando trabaja por escindir y fijar en las reivindicaciones marginales y sectoriales.

Este es, creo, el límite político del mismo Foucault: enfatizar y valorizar conflictos y luchas fragmentarias y parciales, aquellas relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, antinucleares o pacifistas, todas dirigidas a inventar formas de vida singulares y no comunes, enfrentando la *governance* multinivel en los niveles que esta elija en cada oportunidad. Para confrontarse ahí con los gobernados. Cediendo en aquello que menos le interesa y utilizando el compromiso obtenido como ulterior instrumento de control (si se nos permite la ironía, parece más fácil ver los matrimonios gay como una posibilidad que el fin de la masacre de inmigrantes en medio del mediterráneo o en los círculos infernales del trabajo precario). Significa entonces pensar la política como simple trabajo de agitación en el interior de los límites del terreno elegido por el mando, sin lograr poner en crisis la lógica general. Es esta lógica la que debe ser desafiada. Y no será posible hacerlo sin recomponer las luchas en un incomprensible y subversivo poder constituyente capaz de imponer y de defender frente a quien gobierne —y no importa quién lo haga— la *Magna Charta* de la multitud.

VI. MÁS ALLÁ DEL NEXO SOBERANÍA REPRESENTACIÓN: ¿UN FEDERALISMO SIN ESTADO?

Giuseppe Duso

1. LA FORMA POLÍTICA MODERNA Y LA PLURALIDAD: INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

El actual horizonte político pone, en diversos niveles, el problema de concebir realidades políticas que tengan un carácter unitario y, al mismo tiempo, que no anulen la diversidad y la dimensión política de los sujetos que se encuentran en estas como constituyentes de una comunidad política. En este ámbito, los procesos que determinan a la Unión Europea son emblemáticos, puesto que muestran con evidencia que es necesario pensar una realidad política que no excluya, sino que sea compatible con la pluralidad de los miembros que la constituyen. Igualmente emblemáticas son las dificultades que encuentra el intento de una constitución europea. En efecto, estas muestran cuán ardua resulta la tarea de componer unidad y pluralidad. Mucho más aún cuando se es consciente de que este objetivo no parece armonizar con el modo de pensar la política que se ha sedimentado en la realidad de los Estados nacionales. La relación entre el contexto de los conceptos políticos modernos fundamentales y la forma-Estado no es fortuita y contingente, sino esencial y estrecha al modo de aparecer como inevitable. Por esto, la superación de la configuración de la política que va más allá del escenario en el que se encuentran determinados los Estados nacionales implica también la superación del contexto de conceptos que han dado lugar al modo moderno de pensar la política y de organizar la vida en común de los hombres.

Este contexto tiene en su centro el concepto *poder*, que en la modernidad condiciona totalmente la concepción de la política. Esto se presenta en la forma de la *soberanía*, es decir, del único poder que es propio del cuerpo político en su totalidad: una función de mando a la que todos deben obedecer y que debe resultar dependiente de un proceso de legitimación que tiene en la base la voluntad de todos los ciudadanos. Frente a la voluntad colectiva, no son pensables otros sujetos políticos: una pretensión que resulte significativa políticamente, que se enfrente y vaya contra la voluntad colectiva, es considerada ilegítima y debe castigarse.

Esta lógica permea de por sí la *forma política* que se produce en dicho contexto y que encuentra su manifestación histórica en el Estado y sus reglas, en la constitución. Esta última, instrumento fundamental para organizar la vida en común y el orden, es pensada, a partir de la Revolución francesa (pero también por la americana), sobre la base de la distinción entre sujeto individual y sujeto colectivo; entre sociedad civil, como esfera en la que se mueven los intereses particulares, y Estado, como el lugar del mando y de la obligación. No son tolerados cuerpos y agregaciones dotadas de una dimensión política, como aparece claramente tanto en la teoría (emblemático en esto es Sieyes) como en la realidad que se da en la Revolución francesa y que marca el fin de la pluralidad de *potestates* y de agregaciones políticas que eran propias del *Ancien régime*. Este imaginario es el que caracteriza las constituciones; y si este ha permitido la superación de la incrustación de los privilegios que han caracterizado a una sociedad comprendida jerárquicamente, es este el que va a impedir que se logre pensar una pluralidad de sujetos políticos al interior de una realidad política¹. Frente a la expresión unitaria del sujeto colectivo, no es soportable ninguna voluntad que pretenda tener carácter decisional: una voluntad política expresada por singulares² o por grupos es entendida inmediatamente como subversiva, como un atentado al orden constituido.

Pero, desde el momento en que la realidad contemporánea exige como indispensable la capacidad de pensar la pluralidad y la diferencia en diversos niveles, se ha difundido la opinión de que es necesario superar el modo de pensar la política que tiene en su centro el concepto de soberanía, aunque a esta opinión no corresponda por lo general la capacidad de practicar otras modalidades de pensamiento. En todo caso,

esta opinión resulta acompañada normalmente por la ausencia de conciencia de cuál es la lógica de la soberanía realmente: si una determinada conciencia existiese, estaría también presente la exigencia de superar aquellos conceptos que han producido aquel de la soberanía, con lo absoluto y unívoco que la connota. La referencia no puede no ir a la función fundante atribuida al *individuo*, que es, fuera de toda experiencia, pensado como una realidad subsistente en sí, determinable prescindiendo de las relaciones que le son constitutivas. Y, por otro lado, a los conceptos *igualdad* y *libertad*, que son consustanciales al de individuo y al rol que viene a asumir³. Pero si se individualiza en el iusnaturalismo moderno el laboratorio en el que el dispositivo de la soberanía tiene su génesis, se entiende que es también una concepción de la política que tiene en su base los derechos de los individuos que necesita interrogar atentamente⁴.

En la presente reflexión, nos queremos preguntar si, para comprender la realidad política que está frente a nosotros —y el problema de la constitución de Europa puede ser particularmente emblemático— es necesario ir más allá del dispositivo conceptual moderno con el que es pensada —y se sigue pensando, a pesar de todo— la política. Si es de verdad necesario pensar la *pluralidad*, se deberá pensar la unidad de un modo nuevo y diferente: un modo que vuelva no solo posible, sino indispensable, el pensamiento de la pluralidad. Esto implica la superación del concepto moderno de *poder político* y de su *legitimación* y, por tanto, también la superación del nexo entre soberanía y representación, el cual intenta poner la relación de diferencia junto a la de identidad, entre sujeto individual y sujeto colectivo, y en el *pueblo* aquella función identitaria que caracteriza la concepción moderna de democracia.

Dicho intento, que no pretende ofrecer modelos constitucionales nuevos y alternativos, sino solo interrogarse sobre los principios que están en la base de la constitución y sobre los procedimientos que se desprenden de esta (por ejemplo, las elecciones), requiere antes que todo tener una mirada histórica amplia. Una mirada que no esté encerrada apriorísticamente por la intención de universalidad de los conceptos modernos y de sus presupuestos: una mirada que se interroge sobre la misma génesis del derecho constitucional moderno, génesis que me parece que caracteriza de modo ineludible su lógica⁵. Y esta mirada no

puede no tener una naturaleza *filosófica*, si, logrando emanciparse de las concepciones corrientes de la filosofía política, entendida como disciplina, o como construcción de cuadros normativos, o concepciones del mundo, se reconoce en el trabajo filosófico la interrogación de los presupuestos y de los valores sobre los que se fundan las disciplinas. Esta interrogación de los conceptos modernos tiene, por lo tanto, una naturaleza histórica y filosófica⁶.

El intento va aún más allá de esta pregunta, y tiende a indicar qué dirección, a partir de las aporías surgidas, es posible tomar para comprender nuestra realidad y orientar la praxis⁷. En esta fase del razonamiento emergerán dos categorías que tienen un carácter estratégico: la de *gobierno* y la de *federalismo*. Para no caer en malentendidos, es necesario anticipar que la categoría de gobierno no puede ser entendida refiriéndose al uso contemporáneo del término, sino que alude a un modo diferente de entender la política de aquel que usualmente empleamos para comprender el concepto *poder*. También en relación con el término 'federalismo' es necesario dar una advertencia análoga. Este no es entendido en el sentido que se asume en el debate actual, ni incluso el que refiere a la realidad europea. Esto, en efecto, se mueve en el interior de la problemática que oscila entre el *Estado federal* y la *federación de Estados*; habitualmente, la óptica federal es justamente aquella que tiene particularmente presente los intereses unitarios y centrales de un agregado. Me parece que este uso de la noción es completamente interno al dispositivo conceptual de la soberanía y del Estado y, por lo tanto, también a la lógica de la relación entre sujeto individual y sujeto colectivo⁸. Con el término 'federalismo' se quiere más bien aludir a un modo diferente de pensar la política. Uno en el que el individuo no cumpla un rol fundante y en el que la unidad de una realidad política no sea pensable sino a través de la pluralidad. Esto significaría pensar la conducción, no en la forma de *poder* y de soberanía, sino más bien de *gobierno*, y pensar como central no tanto el problema de la legitimación democrática, sino más bien el de la *participación* y, por lo tanto, de la dimensión política de los sujetos en cuestión.

2. ¿MÁS LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EUROPA?

Como se ha dicho, la exigencia de pensar la pluralidad en el ámbito del orden creado por la constitución surge con evidencia en el interior del debate relativo a *una constitución para Europa*. Nos debemos preguntar en qué condiciones esto es posible. Nuestro razonamiento puede partir del déficit de legitimación democrática que por varias partes ha sido atribuido a los procesos que llevan a la aparición de la Unión Europea. Si, por un lado, la indicación de esta carencia es ampliamente compartida, por el contrario se diversifican las posiciones en relación con la línea de comportamiento que este propósito debe tener: están quienes piensan que dicho *déficit* no es posible de superar, no al menos en un tiempo breve, y aquellos que proponen vías para un proceso de democratización más veloz. En ambos casos, no obstante, la legitimación democrática es vista como un resultado obvio que se debe perseguir, o que estaría bien conseguir, incluso si en la situación actual no parece posible. Se trata, entonces, de un valor indiscutido. Pero si nos preguntamos en qué consiste la mencionada legitimación democrática, y si se comprende la relación intrínseca que esta tiene con el dispositivo de la soberanía, la convicción de que la legitimación democrática es justamente lo que Europa necesita empieza a vacilar.

El término 'democracia' es habitualmente un contenedor de las exigencias más diversas. Así también, la expresión "legitimidad democrática" es habitualmente entendida de modos diversos y vagos. Si buscamos dar a esta un significado preciso desde el punto de vista de las estructuras constitucionales, podemos encontrar ayuda en aquello que también, en un célebre ensayo, recuerda Dieter Grimm. Se refiere a un proceso que presupone un único pueblo, formado por ciudadanos iguales que, sin distinción de grupo y de pertenencia, dan lugar a un cuerpo representativo que ejerce el único poder al que todos están sometidos⁹. El medio que debería realizar la conjunción entre la voluntad de los singulares y el ejercicio del poder justamente fundado son las elecciones periódicas. Se comprende bien que, en la base de esta imagen, se encuentra la construcción teórica que ha tomado cuerpo a través de las doctrinas modernas del derecho natural y que ha encontrado su realización histórica en las constituciones a partir de la Revolución francesa. En suma, la legitimación democrática implica aquel horizonte y aquellos procesos que caracterizan teóricamente la soberanía moderna y que se han sedimentado en la doctrina del Estado y en las constituciones

democráticas. Justamente, como se trata de esto, Grimm se muestra escéptico en la posibilidad de que dicho proceso se pueda realizar ahora para Europa. Ello en cuanto a que por el momento faltan los presupuestos para un único pueblo europeo, y también en cuanto a que los Estados que han dado lugar a los tratados que llevarían a una constitución europea no pretenden desaparecer como sujetos políticos en el momento en que la Unión Europea se haya vuelto plenamente una realidad política¹⁰.

Más optimistas son aquellos que se declaran defensores de una constitución europea y tienen las esperanzas de ver realizada de modo más completo la legitimidad democrática mediante la intervención de los ciudadanos a través del voto y el carácter plenamente decisorio del parlamento y de los órganos de carácter ejecutivo que se deberían basar directa o indirectamente en las elecciones. Se puede notar fácilmente que la legitimación repite los mecanismos que son propios del Estado democrático y que, extendidos a Europa, harían de esta un nuevo mega Estado, que combine en sí los Estados que en ella tienen lugar. Es significativo también, que un constitucionalista como Böckenförde, en un ensayo de 1997, tome la legitimación democrática de Europa como problema, se ocupe de la cuestión de si esta es posible para Europa, pero no ponga en cuestionamiento el significado y el valor del mecanismo de procedimiento que distinguiría dicha legitimación.

Hay que preguntarse si de verdad hay una gran diferencia de fondo entre los *euroescépticos* y los *eurooptimistas* o defensores de la constitución europea, o bien si la discordia no sucede en el interior de un terreno teórico compartido, que no pone en cuestionamiento la conceptualización sobre la que se funda la doctrina del Estado y que, por tanto, no logra pensar en modo diferente la realidad política. Esto sucede tanto en el caso en que Europa es pensada como un Estado, como en el caso en que es escéptico a esta alternativa. El problema es que ambos casos permanecen quietos frente a la realidad de los Estados. Sin recordar que la vía que llevaría a la constitución se funda en tratados, tratados de los que son autores los Estados europeos, los que, a su vez, pretenden no desaparecer como sujetos políticos, sino más bien permanecer como *Herren*, es decir, como sujetos políticos y no simplemente súbditos en el interior de una nueva *Herrschaft*¹¹. En consecuencia, se oponen a una constitución para Europa en cuanto se

comprende que Europa como Estado haría desaparecer los Estados que darían lugar a esta nueva realidad¹².

Así también, cuando se dice que los *señores* de la Constitución europea no deberían ser en realidad los Estados, sino los ciudadanos, quienes formarían un único pueblo, tampoco se nos abre un nuevo modo de pensar. La propuesta de una *Europa de los pueblos* no muestra la capacidad de entender políticamente de modo diferente al *pueblo*, ni produce un pensamiento diferente de la política. Se tiende a sustituir el obrar de los organismos de los Estados singulares a favor de organismos unitarios europeos que no están legitimados por la voluntad de los gobiernos y de los poderes de los Estados singulares, sino, más bien, directamente por las elecciones de los ciudadanos europeos. Se producirían de ese modo organismos legislativos y ejecutivos que actuarían de modo unitario y tendrían una base democrática. Se comprende que, también en este caso, los Estados nacionales serían superados por la constitución de un Estado superior, caracterizado por la misma cifra teórica, por los mismos procedimientos y fundado enteramente en el dispositivo de la soberanía. Es entonces necesario detener la atención brevemente sobre este dispositivo y sobre la incapacidad intrínseca de pensar la pluralidad.

3. EL DISPOSITIVO DE LA SOBERANÍA Y LA COACCIÓN A LA UNIDAD POLÍTICA

La democracia moderna, entendida como forma de organización constitucional, tiene sus raíces en el laboratorio conceptual constituido por la ciencia del derecho natural¹³, donde han nacido los dos conceptos que se presentan como pilares de las modernas constituciones: el de *soberanía del pueblo* y el de *representación política*. Estos dos conceptos parecen caracterizar las constituciones modernas en cuanto a que, a partir de los procesos revolucionarios de Francia, no hay constitución que no presuponga un sujeto que dé la constitución, y el único sujeto que aparece legitimado para ello es el colectivo, el pueblo entero. Igualmente, no hay constitución que no prevea un cuerpo representativo, en cuanto a que sin este no existe la posibilidad de dar lugar a la expresión de la voluntad y a la acción del sujeto colectivo¹⁴.

Si miramos la realidad contemporánea, se puede pensar con razón que la soberanía del pueblo es una palabra vacía: no solo las decisiones son fruto de procesos complejos y de un cruce de fuerzas que debilita la confianza en una auténtica capacidad decisional de los organismos destinados a expresar la voluntad del pueblo, sino que las mismas constituciones ponen en acto una serie de vínculos, al interior de los cuales se deben mover el legislativo y el ejecutivo, de modo tal que la soberanía del pueblo, que caracteriza la democracia en su forma simple y más inmediata, parece en realidad haber perdido gran parte de absolutez¹⁵. Me pregunto todavía si la constitución, en su función legitimadora del poder puede liberarse fácilmente de la idea de un sujeto constituyente y de la dimensión del pueblo como grandeza constituyente¹⁶. Es importante acentuar que el nexo soberanía-constitución no significa pensar que estamos destinados a permanecer en el interior de este, sino más bien señalar que la superación de la soberanía exige un cambio de pensamiento más radical de lo que se cree: requiere superar el modo en el que es entendida la constitución, pero también el horizonte conceptual que está en su base.

Esto cobra mayor razón si se tiene conciencia de que el concepto de soberanía no es un concepto originario, sino que es el resultado de una construcción lógica, y que es exactamente esta construcción la que atribuye al individuo el rol de fundador de la política y del poder. Y son los conceptos de igualdad y libertad los que garantizan este nuevo rol del individuo. En otras oportunidades, he intentado mostrar el modo en que está arraigado el concepto moderno de soberanía al proceso de legitimación, que no solo afirma la necesidad de un poder absoluto y superior a todo poder natural de los singulares para garantizar los derechos, sino también la exigencia de que esto sea el resultado de la misma voluntad de los individuos singulares, como sucede en la escena del contrato social. Por esto, se puede decir que, no con Bodin, sino que con Hobbes nace la historia de la soberanía moderna. Y, ya en Hobbes, son la igualdad —atribuida a los individuos en el estado de naturaleza— y la noción nueva de libertad las que producen, con la *consecuencialidad de una razón geométrica*, el concepto de soberanía¹⁷. Y es la misma lógica la que requiere que se piense la autoridad solo sobre la base de un proceso de *autorización* que reconoce en la voluntad de los singulares el momento fundante y legitimador. Pero, si esto es verdad, significa que la

superación de la soberanía también implica la superación del rol de los conceptos de individuo, de igualdad y libertad, al menos, en el modo en que han sido concebidos en este contexto. Es más, es necesario superar la misma modalidad de pensar lo político, que encuentra su punto de partida en los derechos de los individuos. Es necesario, entonces, ir más allá del círculo lógico que, desde los derechos de los individuos, funda el poder irresistible del cuerpo común, del Estado, que se vuelve la única fuente del derecho entendido como el conjunto de las leyes.

Habitualmente, aquellos que pretenden poner en discusión el concepto de soberanía, piensan principalmente en ella como una dimensión vertical, que parte de lo alto y condiciona el actuar de aquellos que están sometidos y deben obedecer; es decir, piensan en la dimensión muda del mando. Desde esta óptica, las constituciones son consideradas como el conjunto de los vínculos puestos al poder, que debe ser limitado a favor de los derechos de los ciudadanos. Suele reconducirse dicha función limitante al iusnaturalismo, tomado como aquella corriente de pensamiento que se ha puesto la tarea de afirmar los derechos de los individuos y la limitación del poder. Estas opiniones no parecen recoger aún la lógica de los conceptos y la realidad de los procesos. En efecto, si la constitución consistiese en una simple limitación del poder, esto significaría que el poder nace de una instancia diferente. Pero no es así. En realidad, el poder que es concebido por la constitución es aquel que está arraigado a ella, aguas arriba y aguas abajo, según surge de la célebre distinción de Sieyes entre el poder constituyente y el poder constituido. El poder es un poder pensado jurídicamente, en la doble forma: del sujeto como el único que puede dar la constitución, y de aquel poder que, fundado en la voluntad de los ciudadanos a través de las elecciones, se presenta en el conjunto de poder legislativo y poder ejecutivo. Por lo tanto, el poder político no es una instancia ajena a la constitución, sino que se coloca *con ella y por ella*.

Si se desplaza la atención a las doctrinas modernas del derecho natural, parece aún más difícil sostener que el iusnaturalismo sea una doctrina de *limitación del poder*. También aquí debe repetirse que esto sería verdadero si, en estas doctrinas, el poder apareciese como una instancia ajena a aquella razón que pone los derechos de los individuos¹⁸. Pero, en todos los textos de los iusnaturalistas esto no es así. Nos encontramos frente a una construcción teórica, es decir, a un proceso

lógico que, a partir de los individuos imaginados como iguales y libres, funda un poder de coacción que aparece como justo, racional y la única vía que puede garantizar y realizar los derechos —en realidad, no solo realizarlos, sino antes, lograr pensarlos—¹⁹. Para una tarea semejante, es necesario que la fuerza del poder colectivo sea inconmensurable a la de los singulares, y que sea también independiente, en los contenidos a los que da lugar, de la voluntad de estos últimos. De este modo, se presenta la situación paradójica según la cual la soberanía nace de los derechos y de la voluntad de todos, pero también es ajena y opuesta a las voluntades individuales. El poder y la expresión de mando tienen una cifra unitaria, que es la del sujeto colectivo, el que por una parte aparece como idéntico a los singulares entendidos en su conjunto, pero también opuesto a ellos. No se trata aquí de un proceso de unificación y acuerdo de voluntades diversas, sino de la expresión de la única voluntad política como la voluntad de todos. Las diferencias y la pluralidad de los sujetos políticos desaparecen en el interior de este modo de concebir la unidad.

4. LA REPRESENTACIÓN Y LA PÉRDIDA DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS

Si se pone como tema la modalidad de la expresión de la voluntad soberana del sujeto colectivo, no puede no surgir el otro pilar de las constituciones, aquel del cuerpo representativo. En realidad, el concepto de representación resulta necesariamente ligado al de soberanía. Esto surge de la lectura del mismo *Leviatán*, si no se permanece enjaulado en la confusión de las interpretaciones y si se tiene presente el proceso lógico que se despliega en el texto. En efecto, la descripción del nacimiento y de las características de la soberanía, expuestas en los capítulos XVII y XVIII, está precedida por la posición y por la solución del problema sobre el modo en el que es concebible la unidad de un ente artificial constituido por una multiplicidad de individuos. Es justamente en el capítulo XVI donde se encuentra el secreto de la constitución de la soberanía: se trata del *nuevo concepto de representación*, que pone conjuntamente la posibilidad de pensar el sujeto colectivo y la modalidad de legitimación del ejercicio del poder²⁰. La persona civil es pensable solo si hay alguien que la *representa*, es decir, que expresa su voluntad, y el representante

tiene esta función en cuanto a que es querido por todos. Ya no se piensa que la *autoridad* descienda desde lo alto o se base en un modo trascendente de lo divino o en las cualidades y prestigio de algunas personas; esta puede ser solo el fruto de la voluntad de todos, es decir, de un proceso de *autorización*.

Dicho proceso de creación de la autoridad, que en Hobbes tiene un carácter meramente lógico, es la fuente de procedimientos concretos en las constituciones modernas²¹: en efecto, son las elecciones las que se encargan de realizar el proceso de la fundación desde lo bajo de los organismos que están destinados a actuar políticamente. Son las elecciones las que tienen la tarea de mostrar que el poder no es de alguien en particular, sino de todo el cuerpo político. Visto que todos son miembros del Estado, las elecciones deberían poner en evidencia la pertenencia de todos al poder. Dicha imagen es tan fuerte y difundida que se puede encontrar a menudo la afirmación de que “en democracia, todos los ciudadanos son soberanos”, o que deberían serlo por derecho. Esta afirmación es ciertamente insostenible porque, si la soberanía consiste en la decisión máxima y eficaz del actuar común y si las voluntades individuales no pueden ser hipotetizadas como distintas y diversas (de otro modo, no aparecería siquiera el problema del orden político), bien se comprende que una característica como la de soberanía no puede ser atribuida a otros más que a la totalidad del cuerpo político.

Aunque inconsistente, la imagen de los “ciudadanos soberanos” es significativa en cuanto muestra cuán necesaria es la relación de identidad entre los singulares y el sujeto colectivo para el proceso de legitimación. En realidad, la afirmación se traduce en lo siguiente: “el pueblo es soberano”. Las dos afirmaciones anteriores parecen posibles gracias a la función que adquiere el concepto de pueblo, el que, si por una parte indica una realidad singular, por la otra comprende a todos los ciudadanos. Se trata entonces de preguntarse si y cómo puede darse dicha identidad entre el sujeto colectivo singular y los muchos individuos que lo constituyen. Para esto, es útil reflexionar sobre el famoso estribillo que afirma que “el pueblo es libre cuando obedece a las leyes que él mismo se ha dado”. Se entiende que no se trata de una identidad inmediata, ya que el pueblo es en cuanto sujeto colectivo que hace las leyes —o mejor, son aquellos que, unitariamente, *representan* a este sujeto— mientras los ciudadanos singulares son quienes las obedecen. En

suma, quien obedece no es *el mismo* que hace las leyes. Aun así, la democracia tiene la necesidad de afirmar dicha identidad, y las elecciones —y el correspondiente concepto de representación— son justamente el medio que debería realizar el pasaje de las voluntades individuales a la colectiva. Resulta, entonces, necesario reflexionar sobre *este concepto de representación*, que caracteriza las elecciones tal como son concebidas hoy, para comprender cuál es la naturaleza de la relación entre la voluntad individual y la voluntad colectiva, y cuál es la relación existente entre la formación de esta última y las modalidades de legitimación que aparecen casi connaturalizadas con la constitución.

Es a partir de la Revolución francesa cuando irrumpe en la historia el nuevo concepto de representación: ya no se trata de representar las partes del pueblo frente al rey y a su gobierno, sino de *dar forma* a una voluntad común que no preexiste y que no tiene más objetividad que este proceso de formación. Esta representación de la voluntad común no puede tener en su base más que la expresión concreta de la voluntad de los ciudadanos: “no hay representación sin elección” se repite en la Francia revolucionaria, y esta convicción ha penetrado en el sentido común hasta el punto de identificar hoy el sistema representativo con la constitución democrática. En la base de las elecciones están, en efecto, los ciudadanos en una dimensión de igualdad, sustraídos a cualquier tipo de pertenencia, vínculo, relación o agrupación. Se trata, entonces, de entender en qué consiste la expresión de voluntad que actúa en el voto y cuáles son sus presupuestos.

Suele decirse que en la elección ocurre un acto de transmisión de voluntad política. Sin embargo, en realidad la acción política puede ser propia solo del sujeto colectivo, puesto que en el evento electoral no es el pueblo el que vota, sino los ciudadanos singulares, quienes no transmiten su voluntad política; antes que nada, porque su voluntad es privada y no política y también porque el producto del voto no se determina en acciones a cumplir, sino en personas a elegir. Con el voto se designan a aquellos que, con los otros elegidos, expresarán su voluntad común y harán las leyes. Sería como decir: “yo autorizo a aquel a expresar por mí la voluntad común que aceptaré como mi voluntad política”. No estamos entonces frente a un acto de transmisión de voluntad política, sino frente a un acto de *autorización*, esto es, de conferir la autoridad a quienes deben expresar la voluntad común y deben ejercer el poder. Pero esta es

justamente la lógica de la constitución de la autoridad que habíamos encontrado en el capítulo xvi del *Leviatán* de Hobbes, según el cual se constituye a la persona artificial, la persona civil, a través del acto con el que se declaran autores de las acciones que hará el actor o los actores políticos (los representantes). También en las elecciones se presenta la aporía relativa al sujeto político propia del concepto de representación que emerge en Hobbes: en efecto, son todos *autores* de acciones que no cumplen y los *actores* cumplen acciones de las que no son autores y, por lo tanto, en el fondo, no son responsables²².

En la fórmula del *mandato libre* se expresa bien que lo que caracteriza a las elecciones modernas no se trata de una transmisión de voluntad, en oposición a las medievales o a las castas de representación. Con el voto no se da un mandato vinculante o imperativo, sino que justamente se delega al diputado la expresión *libremente* de la voluntad del sujeto colectivo junto con los otros representantes. Podríamos detenernos a analizar todos los cambios que esta relación formal ha tenido. Particularmente, en relación al advenimiento de los partidos de masas, quienes por medio de sus programas se comprometen en determinadas direcciones, creando así, de alguna manera, un vínculo determinado entre las voluntades de los electores y la voluntad que se expresará en el parlamento; debido a este aspecto, hay quien habla de la actual reemergencia de un mandato vinculante. En relación con esto, antes que todo, podría constatarse que los programas de los partidos no tienen tanto la finalidad de indicar las acciones políticas que realmente pretenden cumplir, como el consenso que se quiere obtener para agrandar la propia base electoral y, por lo tanto, aumentar la propia influencia en el ejercicio del poder. Pero no pretendo profundizar en esta cuestión, basta con recordar aquí que un vínculo de partido no está aún considerado por la constitución, la que no renuncia a la libertad del mandato por un mandato vinculado con sujetos tales como los partidos, los cuales no son siquiera reconocidos como verdaderos y propios sujetos políticos, sino solo como instrumentos asociativos aptos para transmitir y agrupar las opiniones y las elecciones.

La conquista de la igualdad, que connota las elecciones modernas, y la eliminación de un voto corporativo, son pagadas con la pérdida de cualquier elemento objetivo que no sea la arbitrariedad y, por tanto, la opinión de quién vota. No se tendrá presente la complejidad de las tareas

del Estado moderno, de la delegación y del gobierno, para sostener que casi la totalidad del cuerpo electoral, sin que tenga una instrumentación adecuada del conocimiento y sin estar anclado a relaciones sociales determinadas, vota en relación a la convicción de lo que la propaganda electoral logra producir en ellos²³. En las elecciones democráticas son, entonces, los instrumentos de formación de la opinión pública los que tienen la máxima importancia y esto, a su vez, crea un problema ulterior: porque no todos los ciudadanos se encuentran en una situación de paridad en relación con la propiedad y las posibilidades de actuar a través de los medios de comunicación, aunque a este propósito la difusión de la computadora e Internet haya implicado una notable innovación sobre la cual la reflexión actual es impostergable.

La presente reflexión no se propone cumplir un análisis de la política actual, sino solo reflexionar sobre la relación entre los principios fundamentales y los procedimientos constitucionales en relación con el tema de la pluralidad y del protagonismo político de los ciudadanos. En relación con esto, las elecciones así concebidas implican una extraña situación. Por una parte, son el único acto político que los ciudadanos cumplen y, por la otra, en cuanto se resuelven en un acto de *autorización*, se les sustrae la posibilidad de ser *actores* políticos: los reducen a un ámbito privado. El éxito del voto es la *despolitización* del ciudadano. Esto es así porque ellos no contribuyen efectivamente a hacer la ley, no determinan, por lo tanto, el contenido del mando al que están sometidos: justamente porque el poder está fundado desde lo bajo, su contenido (sin que haya transmisión de voluntad política) está decidido desde lo alto. Sin embargo, la lógica legitimadora requiere que todos deban reconocerse en la voluntad del sujeto colectivo y, por lo tanto, deben obedecer *a priori* a su mando. El fundamento teórico de la democracia consiste en la idea de que el mando viene del pueblo y, por lo tanto, el mando al que estamos sujetos es también el *propio* mando; la voluntad representada es la voluntad política que todos deben tener y, por ello, no es posible oponerse sino en la forma del delito, de un reclamo indebido que debe ser castigado.

Frente a esta observación, habitualmente se sostiene que la solución del problema residiría en la democracia directa, aun cuando esta parece impensable en la situación moderna, caracterizada por los grandes Estados y por la división del trabajo; por ello, la lejanía del ciudadano de

la política aparece como estructural e inevitable. En realidad, nos acercamos a la comprensión de la raíz del problema solo si comprendemos que esta aporía de la democracia representativa no se supera ni siquiera a través del concepto de democracia directa, en el que todos estamos *inmediatamente* pensados como actores políticos. Como, de hecho, se puede ver en el *Contrato social* de Rousseau, ni siquiera la negación de la representación a favor de una expresión directa de la voluntad del pueblo escapa a la aporía: se debe recordar que también Rousseau, en el momento en que se quiere pensar la expresión directa de la voluntad del pueblo en el punto más alto, el del proceso de constitución del Estado, está obligado a recurrir a la figura del gran Legislador que reproduce el dualismo de las voluntades que surge de otra manera en la representación hobbesiana²⁴. También aquí es necesario reconocer que aquello que produce la pérdida de politicidad de los singulares es exactamente aquello que teóricamente está en el centro de las doctrinas contractualistas e históricamente en la base de las constituciones modernas, es decir, la función fundante atribuida a los singulares y, por lo tanto, la identidad y, al mismo tiempo, la alteridad (extrañeza) de multiplicidad y unidad.

Con este propósito, se puede sacar una primera consideración: la raíz de la aporía consiste —en relación al concepto de soberanía aún antes que al de democracia— en la intención de eliminar el mando en la sociedad. En la negación de aquello que ha estado por muchos siglos —a partir de los griegos— en el centro de la reflexión política, esto es, que la realidad política está constituida por quien gobierna y por quien es gobernado, y que la relación de gobierno ya sea natural o racional, corresponde, por lo tanto, a la naturaleza del hombre y de la comunidad. Justamente, la absolutización de la voluntad del singular y de la libertad, entendida como absoluta independencia de la voluntad, produce la sumisión plena y sin reservas al sujeto colectivo: esta dependencia absoluta no puede más que ser legitimada a través de la imputación del propio mando a quien debe obedecer. Esto vale para Hobbes, para quien no se puede no obedecer al soberano porque eso equivaldría a la contradicción de *no querer aquello que se ha querido*, lo cual vale también en democracia porque el origen del poder está en la voluntad de todos. Por lo tanto, es el resultado del supuesto de que la voluntad de cada uno cuenta como la de todos, que los ciudadanos se encuentren privados de una dimensión

política *frente* al poder: porque el poder es ya, en el fondo, *su poder*.

Pero una segunda consideración es aún más relevante en cuanto que toca el punto central de la presente reflexión. La razón de la aporía está en el modo de entender la unidad política en el contexto del dispositivo de la soberanía y de la democracia. Mejor aún: la razón está en el hecho de que lo colectivo es pensado sobre la base del concepto de individuo, entendido como una realidad consistente en sí misma. Si se parte de la multitud indiferenciada de los individuos, las infinitas diferencias no pueden jugar ningún rol y no puede sostenerse lógicamente la idea de pensar en un acuerdo entre distintas voluntades reconocidas en su politicidad. En efecto, paradójicamente, en el momento en que las doctrinas *contractualistas* producen el concepto de soberanía, se termina el modo contractualista de entender la política, esto es, como acuerdo y concordia entre voluntades diferentes ²⁵. El mecanismo del contrato crea algo nuevo: el *poder único* de la sociedad. Desde el momento en que la sociedad no puede no estar caracterizada por una forma de unidad, si el punto de partida, racionalmente fundante, son muchos individuos, la unidad no puede ser pensada sino como *otra* y, por lo tanto, como diferente y contrapuesta a ellos. Esto vale tanto para la lógica representativa, como también para una hipotética voluntad del pueblo que se puede expresar directamente. La aporía de la soberanía democrática, entonces, consiste en el hecho de que el mando colectivo está atribuido al pueblo y, por lo tanto, también a todos, pero en el mismo momento está contrapuesto a todos. En síntesis, la raíz lógica de la aporía está en la relación *muchos/ uno*. Una relación que es de identidad y, al mismo tiempo, de contraposición. Desde esta perspectiva de la unidad, no es posible pensar la pluralidad. Para realizarlo, es necesario pensar de otro modo la unidad política y, por ende, superar el momento genético constituido por la multitud de los individuos singulares: *es necesario superar la relación, intrínseca a nuestras constituciones, de sujeto individual y sujeto colectivo*.

5. OTRO MODO DE ENTENDER LA UNIDAD: EL PRINCIPIO DEL GOBIERNO

Pero si, más allá de las aporías aquí señaladas, la descrita es la lógica de la legitimación democrática, se comprende bien que esta no es concebible

para Europa (que sería entendida como un Estado soberano) si no se borran los miembros que la constituyen. Dejando a un lado, por el momento, el modo en que estos miembros, es decir, los Estados, son entendidos, se puede decir que para concebir a *Europa como realidad política* es necesario *pensar la política de un modo diferente* de la forma política que ha imperado en los siglos del así llamado *jus publicum europaeum*, período en el que han sido centrales las figuras de los Estados soberanos. Esto significa pensar de un modo diferente la *unidad política* y, con esta, también el *mando* que da lugar a la obligación política. Los miembros de esta realidad no deben desaparecer frente a un mando que es pensado como propio, pero que es aún extraño y contrapuesto a ellos. La unidad de esta nueva realidad debe mantener la pluralidad de las diferencias de los miembros que la constituyen. Si se busca individualizar dicho modo de pensar, se puede utilizar el término 'federalismo', pero con la conciencia de que no se trata de una modalidad interior al horizonte conceptual del Estado (moderno), como una variante suya, sino que es un modo diferente de pensar la política. Un modo que no implica el concepto de soberanía-poder y tampoco los procedimientos de legitimación democrática, uno que no parte del rol fundante de los individuos y, por lo tanto, que se encuentra más allá de la relación —que en realidad solo es fruto de la *imaginación teórica*— entre individuo y Estado²⁶.

Se ha dicho que si el razonamiento político parte de la ficción que sostiene que, en la base, los individuos son iguales y autónomos y, por lo tanto, son una multitud indistinta de individuos, el único resultado lógico está constituido por la soberanía y por el modo en que esta comprende la unidad política, la cual no logra nunca mediar entre sí a los sujetos que en ella se encuentran. Otro modo de pensar la unidad requiere, por ende, que no se use el concepto de individuo en los modos en los que lo ha usado la ciencia política moderna. Incluso la experiencia que nos rodea muestra que también el rol del individuo es una ficción: en realidad, son numerosas las agrupaciones presentes en la sociedad que actúan también indirectamente, independientemente de los que sostienen los cánones de la legitimación democrática sobre las decisiones políticas. Por ello, partes, grupos, agrupaciones, relaciones: una pluralidad que es necesario que se logre pensar —y, con ello, también responsabilizar— políticamente: una pluralidad no de realidades autónomas suficientes en

sí, sino de sujetos que son parte de una realidad común por necesidad. En este caso, estamos frente a una realidad política compuesta por múltiples partes que deben trabajar para estar de acuerdo, pero que, al mismo tiempo, a causa de su diversidad e intereses, pueden divergir y estar en conflicto.

Si se considera una realidad política como plural, y el acuerdo, como una tarea que debe actuarse continuamente y, al mismo tiempo, siempre en riesgo, resulta necesario pensar en una guía, un mando, una función que, en la larga tradición precedente al nacimiento de los conceptos modernos, era llamada *gobierno*²⁷. Este es un modo diferente de entender el mando en cuanto a que implica, por una parte, la conciencia de la alteridad entre quien tiene el mando y quien obedece y, por la otra, la irreductibilidad de una dimensión meramente formal, en cuanto que es irrenunciable la relación con puntos de referencia compartidos y el juicio sobre los contenidos que, de vez en cuando, caracterizan al mando. Justamente, por estos motivos, en la noción de gobierno no está la pasividad que es propia de quien está sujeto al poder: aquella pasividad —obediencia *a priori* a cualquier mando que venga desde el sujeto colectivo a través de quienes han sido autorizados— es, de hecho, concebible solo en cuanto a que se imagina que quien obedece es también el que manda en el fondo. La comprensión de que el mando viene de quien gobierna, aunque —y no puede ser de otro modo— quien gobierna sea elegido e instituido justamente por los gobernados, redundando en que la voluntad expresada por el gobernante es justamente la suya y no la de la totalidad de los gobernados y, por lo tanto, del sujeto colectivo, sino que también los gobernados están *presentes políticamente* de modo institucional, frente a quien gobierna. Es en este sentido en que son políticamente activos, *actores políticos* ellos mismos, aunque no tengan a su disposición —es más, por eso mismo— una decisión soberana y no se identifiquen con la voluntad soberana. Pero esto es pensable si la pluralidad no es la ficción de los singulares, sino aquella determinada por las formas de agrupación que están presentes en la sociedad.

De este modo, se entiende de manera diferente la *unidad* de una realidad política. Esta implica necesariamente la pluralidad, pero, justamente por ello, necesita una relación *ad unum* que consiste en la instancia del gobierno. Cuanto más fuerte es la presencia política e institucional de una pluralidad de sujetos, tanto más unitaria debe ser la

instancia de guía y de gobierno: sería contradictorio que se pudiese ella misma como intrínsecamente plural, tal vez en cuanto constituida por miembros no solo diferentes, sino también en conflicto entre ellos²⁸. En el caso de la unidad propia de la forma política, los sujetos desaparecen políticamente y su voluntad política es aquella que está expresada en el nexo soberanía-representación, es decir, por la representación como modo de expresión de la única voluntad del sujeto político. Aquí, entonces, actúa una dialéctica continua y difícil entre pluralidad de las partes y unidad del gobierno: ciertamente, una dialéctica que no está resuelta *a priori* por la garantía y por la seguridad que ha constituido el máximo fin de la forma política moderna.

Si, en esta otra concepción de la unidad se supera la relación de identidad y oposición, que es, al mismo tiempo, la de sujeto individual y sujeto colectivo, de individuo y soberanía, nos encontramos con que hay que pensar la representación de modo diferente. Esta, de hecho, no da forma a la única voluntad del sujeto colectivo, sino que permite la presencia política de los sujetos diferentes; no se basa en la igualdad/indiferencia de los individuos, sino que se refiere a diferencias determinadas con las que, en términos generales y también plurales, tienen que vérselas los sujetos. La representación concebida de este modo permitiría a las distintas partes de la sociedad estar presentes políticamente con sus necesidades, intereses y puntos de vista frente al gobierno, pero ser también, al mismo tiempo, responsables en relación con las decisiones que refieren a la vida común.

Ciertamente, para entender de este modo la pluralidad de una realidad política, se debe dar un horizonte compartido: nos debemos sentir parte de un todo. Si no está este esfuerzo, que es siempre nuevo y diferente, y se considera inevitable que las opiniones —único punto de referencia en el momento en que todo elemento objetivo se ha disuelto en el arbitrio de los puntos de vista subjetivos— sean diferentes y opuestas entre ellas, entonces, a la contraposición de las opiniones no puede hacerse frente más que con la unicidad y formalidad de la obligación política. Pero esta es justamente el acontecimiento soberano que no es compatible con la pluralidad política, sino que es consonante con un pluralismo ideológico y de opiniones. Si tenemos esto presente, no me parece que se deba compartir la afirmación de que la época moderna es la época del pluralismo contra el absolutismo que caracterizaría los siglos

precedentes. Me parece que se corresponde mejor con el dispositivo moderno con el que se piensa la política que reconoce que la absolutización del punto de vista subjetivo deja el campo a la pluralidad indefinida de las opiniones, que tiene correlación con la unidad política de la soberanía.

6. ¿UN FEDERALISMO SIN ESTADO?

En este modo diferente de pensar la unidad política, podríamos estar tentados de encontrar alguna cosa que nos lleve hacia el pasado. En efecto, no es difícil reconocer cierta consonancia entre este cuadro y el de la literatura jurídica imperial alemana o, incluso, encontrar vínculos con modos antiguos de entender la política. Pero esto sucede no porque se hace referencia a modelos antiguos, sino porque se puede comprender mejor el presente si no se permanece en el interior de los conceptos producidos por la teoría moderna²⁹, o, mejor, porque nos apropiamos de la posibilidad de pensar la realidad política y la cuestión que está en su centro justo en el momento en el que se logra superar la pretensión de universalidad de los conceptos modernos y la necesidad de permanecer en el interior de sus supuestos.

No es casual que las referencias a la *Política* de Althusius estén en relación frecuentemente tanto con los procesos de unificación de Europa como con el escenario global en el que, por una parte, la complejidad y la pluralidad de las relaciones y de los procesos muestran como inservible el dispositivo simple y unívoco de la soberanía, y, por otra parte, el derecho retoma una dimensión no reductible a la fuente única del Estado, como por mucho tiempo ha sucedido. Debe reconocerse que reflexionar hoy sobre el pensamiento de Althusius resulta muy productivo, pero con la condición de que no se lo lea bajo la mirada de los conceptos modernos, como sucede cuando se lo interpreta, por ejemplo, como una concepción del *poder desde abajo*, como una concepción de la soberanía diferente o como un pensamiento de la política que la reduce a la única dimensión horizontal de la cooperación. Si se evitan estos malentendidos, se puede observar en él la capacidad de pensar la realidad plural y la configuración, a través del principio de gobierno y las modalidades de la representación, de una concepción de la política que puede efectivamente ser entendida como federal, si con este término se alude a una dimensión

de pactos y plural de la política y a una función del derecho y de la justicia que la conceptualización de la soberanía ha intentado negar, considerándolas peligrosas para la seguridad y para el orden³⁰.

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que el pensamiento de Althusius no puede ser reducido a un *modelo* al que mirar para afrontar nuestro problema. Se trata de una manera de pensar *gobierno* y *pluralidad* en una situación que, por una parte, tiene como fondo unitario el Cristianismo y la Biblia, y, por la otra, la idea del imperio y la realidad de una sociedad estamental que se encuentra jerárquicamente organizada. Hoy, no podemos poner en estos términos nuestro problema. Tan productivo es nuestro abordaje del pensamiento de Althusius, como necesaria la conciencia de que pensar a través de las categorías de *gobierno* y *pluralidad* hoy, y en relación con el tema de Europa, es una tarea nuestra y absolutamente nueva. Una que no puede encontrar atajos o modelos a aplicar.

En todo caso, el esfuerzo de pensar Europa con las categorías del *gobierno* y de la *pluralidad* parece ser más productivo que todos los intentos que quedan enredados en las mallas de los conceptos del dispositivo de la soberanía. Mientras los procesos de la legitimación democrática implican la pérdida de la subjetividad política de los miembros, a favor de la nueva unidad a la que dan lugar, a través de estas categorías es posible pensar, al mismo tiempo, la unidad, pero también la permanencia política de los miembros que contribuyen a la formación de la nueva realidad. Ciertamente, no se trata de una unidad garantizada *a priori*, como sucede en el caso de la soberanía, en la que la expresión de la única voluntad está garantizada por la construcción formal y por la ley de la mayoría. Aquí, al contrario, la unidad es un camino siempre en la toma, que implica el debate del control y la discusión continúa de los miembros asociados: por lo tanto, una pluralidad de sujetos siempre presentes y, al mismo tiempo, una guía y una función de mando que trabaja de acuerdo con las partes.

Si nos detenemos a reflexionar sobre los *miembros* que constituyen esta pluralidad, me parece que ya no podemos entenderlos a través de la forma de la estatalidad, a la que es esencial la característica de la soberanía. Por ello, si es verdad que el instrumento constitucional en su función clásica está relacionado con la soberanía y con un modo de entender la unidad política que no parece utilizable para Europa, es

también verdadero que recordar que los procesos de formación de Europa han requerido ciertos tratados y la forma del *tratado* implica la necesaria autonomía decisional de los contratantes (que, al contrario, desaparece en la constitución³¹). Este es un modo reductivo de leer la realidad actual, uno que no logra entender a Europa como realidad política nueva. En efecto, se corre el riesgo de permanecer anclados a la imagen de los Estados soberanos en un momento en que la realidad parece transformada. Aquellos Estados, de hecho, que pretenden considerarse miembros de una realidad más amplia y unitaria, cambian de naturaleza, como también están cambiando de naturaleza sus constituciones: en cuanto partes de una nueva realidad, no tienen más la autonomía y la independencia que caracteriza la decisión soberana. Es justamente un nuevo modo de pensar la unidad política que parece necesario, no tanto aumentando los centros más o menos en competencia entre ellos, sino reconociendo la pluralidad de los sujetos políticos que constituyen la unidad, y esto también en el interior de la realidad que ha sido definida a través de la forma-Estado hasta ahora. En esta dirección, el concepto de soberanía debería ser superado tanto por Europa como por los Estados unificados.

Si pensar federalmente es *otro modo de pensar la política*, este no puede no incluir también a aquellos agregados que son los miembros de la Unión Europea. Ya se ha dicho que en cuanto tal, el dispositivo de la soberanía aparece como aporético y, tanto conceptualmente como en las prácticas de los procedimientos a las que da lugar, produce la pérdida de la dimensión política de los ciudadanos: vuelve impensable la participación política. Si, para pensar esta dimensión activa de los miembros de Europa, así como de los miembros de los Estados, es necesario aquello que hemos llamado un nuevo modo de pensar la política, de este modo no se evoca algo utópico o que se coloque en un futuro que vendrá. Por el contrario, esto es necesario tanto en el análisis crítico de los conceptos de la forma política moderna, como para entender la realidad en la que vivimos.

En lo que refiere a la teoría, puede notarse que, si es verdad, como se ha recordado, que la democracia (sobre la base del concepto de soberanía) consiste en una estratagema lógica que tiende a negar el gobierno y el mando del hombre sobre el hombre, haciendo de quien obedece la fuente misma del mando, entonces no logra evitar el mando en

su heteronomía en relación con la voluntad subjetiva individual. Que el mando provenga de quien lo tiene, por quien ejerce el poder, resulta una realidad más allá de las estrategias de legitimación, solo que dicha realidad no logra ser pensada si se permanece en el interior de las teorías de la legitimación. En síntesis, las teorías de la soberanía y de la democracia no pueden no implicar el gobierno, pero, al mismo tiempo, no permiten que este sea pensado³².

Del mismo modo, en la concepción contemporánea de la democracia no está borrada la pluralidad. No tanto aquella vinculada con las infinitas diferencias entre los singulares, que aparecen como políticamente irrelevantes en su infinita variedad, sino en aquella de las agrupaciones que, ubicadas en la *sociedad civil*, ejercen indirectamente, con capacidades y fuerzas diferentes entre ellas, influencia y eficacia en las decisiones políticas, volviendo poco relevante la igualdad que se expresa en el voto. Pero, también en relación con esto, la imaginación dicotómica de sociedad civil y Estado, que está en la base de las constituciones, por una parte, legitima estas agrupaciones con la simple expresión de sus necesidades e intereses, y, por la otra, impide individualizar su responsabilidad política. En suma, la realidad que llamamos Estado es menos comprensible siempre a la luz de los conceptos fundamentales con los que se lo menciona: una instancia soberana, la legitimación que viene de la representación, la igualdad que caracteriza el peso de los singulares para la formación de la voluntad política, una unidad que impide el condicionamiento de las partes en cuanto está por encima de estas, la distinción entre sociedad civil y Estado, la afirmación de que el poder es de todos los ciudadanos a través del mecanismo de las elecciones, la reconducción del gobierno a mero poder ejecutivo y, por lo tanto, a aquel poder del sujeto colectivo que se expresa en el Parlamento. También la constitución, que se basa sobre estos principios, es cada vez menos capaz tanto de hablar de la realidad, a cuya realización contribuye, como de normativizar esta realidad. No solo no logra construir la norma fundamental, sino que, justamente a partir de la racionalidad formal que se expresa en ella, vuelve posible un juego de fuerzas en la realidad política que no es llevado a la luz y que aparece en contradicción con las intenciones que caracterizan a los mismos principios constitucionales. Por ello, y también por parte de algunos constitucionalistas, es que se ha comenzado a utilizar el término 'deconstitucionalización para indicar la

situación en la que nos encontramos en relación a la forma clásica y con la función que la constitución ha tenido hasta hoy³³.

Tal vez, entonces, aquella vía que se ha indicado como *federalismo* resulta necesaria para Europa, pero también para las realidades estatales, para hacer posible el pensamiento de la pluralidad y para hacer efectiva la participación política de los ciudadanos. Si así fuese, la tarea que tenemos frente a nosotros es la de transformar la constitución, no sobre la base de un modelo resolutivo de una vez y para siempre, sino en la óptica de un cambio continuo orientado por la conciencia de los problemas que hemos intentado poner a la luz y con la intención de hacer posible una participación de los ciudadanos en la vida política. Es, en efecto, con la exigencia de la participación que se imbrica el tema de la pluralidad en el horizonte de un pensamiento federalista, tal como aquí se ha indicado.

VII. HACIA UNA DECONSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARTICULARISMO NORMATIVO EN AMÉRICA LATINA

Aldo Mascareño

1. INTRODUCCIÓN

En la teoría constitucional transnacional es conocida la tensión entre órdenes constitucionales emergentes en sistemas sociales y las constituciones nacionales¹. La unidad dogmática de constituciones políticas locales, la jerarquía de normas y cortes y la politización de conflictos a partir de intereses locales son factores que contrastan con una institucionalización de normas transnacionales más bien débil, con el funcionamiento descentralizado de las Cortes (en su mayoría, arbitrales), y con el carácter preeminentemente técnico de los conflictos en el plano transnacional. Como consecuencia de esto, emergen múltiples choques entre los órdenes normativos transnacionales y los imperativos políticos locales, donde los intereses estatales se encuentran con los de actores privados en campos como el comercio, las finanzas, los deportes e Internet.

Para enfrentar estos choques, en la región europea, se han desarrollado codificaciones supranacionales en diferentes sistemas sociales, proyectos de armonización en áreas críticas y una compleja estructura de *governance* multinivel². Ciertamente, esto no implica una reducción de conflictos entre sectores transnacionales e intereses nacionales, ni tampoco un estado de armonía o coherencia total entre ambos. Más bien, si se tiene en cuenta la proliferación de sistemas de negociación orientados a la producción de soluciones, probablemente aumenten los problemas de coordinación. Los esfuerzos de coordinación

guiados políticamente condujeron a la región europea a la construcción de mecanismos intermediarios en los que los conflictos entre normas constitucionales emergentes y órdenes locales políticamente constituidos podían ser procesados y decididos no solo de forma política, sino también técnica, y si no decididos, al menos expuestos públicamente en forma de responsabilidad atribuida. En la actualidad, no existen en otras regiones de la sociedad mundial estructuras comparables a esta estructura supranacional de la región europea, esto a pesar de que los sistemas operan de forma global e interactúan de facto a través de regiones culturalmente diferenciadas.

América Latina, por ejemplo, cuenta con una larga tradición constitucional de dos siglos y un aún más largo proceso de integración a las estructuras sistémicas de la sociedad mundial, particularmente en aspectos económicos, jurídicos, políticos, educacionales, artísticos e, incluso, tecnológicos³. Sin embargo, no existen estructuras supranacionales operativas que pudiesen coordinar sectores transnacionales *constituyentes* con políticas nacionales y órdenes legales locales. En un sentido político-institucional, no existe una *región latinoamericana* y, por tanto, ante la ausencia de instituciones regionales intermediarias, el constitucionalismo estatal está menos influenciado por formas de constitucionalismo transnacional.

Para explicar esto, sostengo la hipótesis de que algunas formas de particularismo normativo han prevalecido en los constitucionalismos latinoamericanos locales. Estas formas de particularismo —que emergen desde elites políticas, de corte conservador o populista, y que se orientan hacia la búsqueda y aseguramiento de posiciones de poder y privilegio económico— chocan con el universalismo normativo de un constitucionalismo sectorial, lo que suprime a nivel local cualquier posibilidad de dar pie a formas de interpenetración institucional constructiva o produce procesos de desdiferenciación de las operaciones sistémicas. Por tanto, para tratar este problema, es necesario un doble movimiento: por un lado, una deconstitucionalización del particularismo normativo local y, por otro lado, y al mismo tiempo, una interpenetración normativa constituyente con las normas universales de las constituciones transnacionales emergentes.

Para proveer los elementos centrales de este argumento partiré con una caracterización general de la incorporación de América Latina a la

sociedad mundial e ilustraré en paralelo su prevaleciente particularismo normativo (2). Continúo con las consecuencias de ese particularismo en los arreglos constitucionales latinoamericanos (3). A modo de contraste, reconstruiré la relación entre el inevitable particularismo normativo de la clausura sistémica y el carácter universalista del constitucionalismo sectorial a través de lo que llamo *momentos de universalidad* (4). Sobre el trasfondo de este marco analítico, aclararé los problemas del particularismo constitucional y los choques entre órdenes nacionales y transnacionales con dos ejemplos políticamente opuestos: Venezuela y Chile (5). Finalizo con algunas observaciones a modo de conclusión (6).

2. PARTICULARISMO NORMATIVO EN LA DIFERENCIACIÓN FUNCIONAL LATINOAMERICANA

Las instituciones coloniales organizaron el modo en que América Latina reinterpretó y concretizó su diferenciación funcional y las definiciones centrales del proceso de construcción del Estado durante el siglo XIX. Por un lado, la estructura decisional centralizada del periodo colonial promovió estructuras políticas y jurídicas cada vez más complejas (procedimientos, reglas, formas de especialización administrativa, mecanismos de supervisión) que, por el otro, orientaron la diferenciación funcional emergente, especialmente en ámbitos como la economía, el derecho y la educación⁴. La centralización de las operaciones sociales en el incipiente sistema funcional de la política demandaba, por su parte, la exclusión de alternativas competitivas. Como se sabe, la estratificación prevaleció durante el período colonial como forma de diferenciación social generalizada. Esto implicó una diferenciación de privilegios institucionalizada, una concentración de la toma de decisiones en los estratos superiores y una indiferenciación de dogmáticas religiosas y principios normativos socialmente generalizados; en otras palabras, un particularismo normativo ampliamente extendido.

El particularismo colonial estaba enraizado en un mecanismo contractual desarrollado por la monarquía española para controlar las cortes medievales y centralizar el poder. Este mecanismo se conoció como *pactismo*:

El pactismo describe un régimen constitucional en el que la monarquía obtenía permiso para legislar en tanto reconociera de modo contractual ciertos privilegios privados de tipo legal y judicial existentes en la sociedad, y en los cuales la aprobación de leyes particulares estuviera ligada a manifiestas condiciones previas y a la compensación de agravios específicos. Para ello, delegados de grupos privilegiados de carácter privado concedían el pago de impuestos a la monarquía a cambio de compensaciones específicas y la preservación de derechos consuetudinarios particulares⁵.

En ese sentido, las Cortes no eran cuerpos representativos. Más bien, “actuaban principalmente como agentes de negociación particulares y fuentes de arbitraje jurídico”⁶. Las reformas borbónicas del siglo XVII intentaron normalizar, al menos en un plano administrativo, este particularismo político y la indiferenciación de la política y la religión a través de un pluralismo legal tradicional⁷. Sin embargo, la Iglesia católica, a través de su densidad política y simbólica, junto a las presiones de grupos particulares ubicados en la base del orden social, prevaleció por medio de redes informales y mecanismos de cooptación de representantes. Como consecuencia, el particularismo prosperó como fuerza política, definió un estilo específico de acción política. En la perspectiva de Thornhill: “La monarquía no consiguió elevarse por sobre sus tardías estructuras feudales de particularismo residual, y un alto nivel de privatismo gubernamental permaneció como rasgo del gobierno español hasta el siglo XX”⁸.

Sin embargo, y aún bajo las protecciones particularistas, las reformas borbónicas adquirieron relevancia en América Latina para la integración de las operaciones económicas en el comercio global. La promoción del libre comercio a través del “Reglamento para el Comercio Libre de España e Indias” (1763) institucionalizó a América Latina como región económica de la Corona. El objetivo, no obstante, no era el bienestar de las “Indias”, sino compensar la influencia inglesa en el comercio colonial. Ciertamente, no existieron ventajas comerciales significativas al adoptar esta posición periférica, aun cuando la inclusión en relaciones económicas mundiales conectara operaciones concretas con expectativas de intercambio monetario que resultaban cruciales para la diferenciación de un sistema económico autónomo en América Latina, especialmente en el periodo de formación de las repúblicas durante el siglo XIX. Ensayistas

como D. F. Sarmiento⁹, J. B. Alberdi¹⁰ y A. Bello¹¹, intelectuales altamente influyentes en la organización política y legal del Estado en América Latina, apoyaron el libre comercio como medio para alcanzar bienestar social y progreso civilizatorio. No obstante, ello, un elemento central en el proceso de construcción del Estado y la operación de la diferenciación funcional en el continente fue la formación de sistemas jurídicos.

Los procesos revolucionarios del siglo XIX no disolvieron la concentración de poder político y económico del periodo colonial. No existió en tal sentido una revolución burguesa en los países latinoamericanos, sino un movimiento de elites políticas (criollos, una generación de descendientes europeos nacidos en el territorio latinoamericano) impulsadas principalmente por motivaciones económicas de carácter particularista. Equipados con la semántica política de la Europa moderna (libertad, igualdad, democracia y Estado de derecho), los nacientes Estados-nación enfrentaron un *momento constitucional* en ausencia de las experiencias concretas desde las que provenían estos conceptos políticos¹². Los orígenes de una constitucionalización simbólica¹³ —a saber, un texto constitucional que presentaba un contenido universal, pero carente de efectividad factual— pueden ser hallados aquí. En tal caso, la cooriginalidad del poder político y jurídico, propia de los Estados democráticos y a través de la cual se estabilizan las expectativas normativas universalistas, no consiguió llegar a un punto de clausura circular. En tal contexto, política y derecho se encuentran siempre abiertos a influencias particularistas que provienen de comunidades culturales, redes locales e intereses religiosos. En trabajos anteriores¹⁴ he interpretado esto como un proceso de desdiferenciación del poder político por sobre la validez jurídica. Al ser el elemento central del periodo republicano, tal apertura operacional de la política y el derecho hacia influencias externas no-procedimentales conduce a una organización concéntrica de la diferenciación funcional en América Latina. Esto conlleva: a) una instrumentalización del aparato estatal por parte de intereses y grupos particularistas; b) una diseminación extrapolítica del poder particularista hacia sectores no-políticos (el arte, la educación, la ciencia, la familia); c) la obstrucción episódica de formas emergentes de autonomía sistémica en sectores distintos de la política, y la consecuente subordinación de estos a una

política particularista; d) el desarrollo de redes de estratificación y reciprocidad que limitan el acceso público a los resultados de la diferenciación funcional; y e) una tensión creciente entre la política nacional particularista y las operaciones a nivel transnacional de sistemas funcionales autónomos.

Emerge así una descripción dual de la región latinoamericana. Por un lado, América Latina es incluida en eventos de la sociedad mundial, principalmente a través del comercio y la circulación de ideas políticas de carácter universalista. Por otro, esta inclusión en la sociedad mundial se caracteriza por rasgos particulares que definen la forma institucional del Estado y el modo en que América Latina enfrenta el proceso de diferenciación funcional, esto es: a) elites oligárquicas crean Estados constitucionales con bajos niveles de participación política y altos grados de exclusión; b) el orden constitucional queda atrapado en una tensión entre expectativas universalistas (inclusión, participación democrática, virtudes republicanas) y la captura del Estado por los intereses hegemónicos y particularistas provenientes de las elites; y, como consecuencia de lo anterior, c) la diferenciación de los sistemas sociales tiene que enfrentar la diseminación extrapolítica de carácter particularista del medio poder, que intenta instrumentalizar los rendimientos de diversos sistemas sociales a través de redes de estratificación y reciprocidad.

3. CONSECUENCIAS CONSTITUCIONALES

Este complejo escenario sociohistórico produce, principalmente, tres concepciones constitucionales en América Latina durante el siglo XIX: a) modelos conservadores; b) modelos populistas; y c) constituciones liberales¹⁵. Por supuesto, estas concepciones corresponden a tipos ideales, no obstante en los orígenes del constitucionalismo latinoamericano encajan bien con los proyectos constitucionales concretos de los Estados nacientes, y, al hacerlo, expresan diferentes formas de particularismo normativo a su vez.

El modelo conservador se enfoca en la defensa política de una particular concepción del bien promovida por el Catolicismo. En ese marco, el poder coercitivo del Estado es aplicado para preservar un orden

moral específico de la sociedad, el cual excluye visiones alternativas. Los derechos humanos modernos son considerados adaptables a la escala de valores humanos defendidos por las elites católicas, las que se consideran a sí mismas representantes de los más altos valores morales y, consecuentemente, argumentan que “la mayoría del pueblo no se encuentra adecuadamente preparado para entender aquellas concepciones valiosas de una buena vida”¹⁶. De tal modo, la construcción de un orden constitucional está edificada sobre una exclusión basal de diversos valores y prácticas, o, en el mejor de los casos, estos están categorizados en una escala sustantiva de rectitud moral. Institucionalmente, ello implica una estructura de poder centralizada que es ajena a la interferencia de los sectores subordinados que han sido excluidos, a saber, Parlamentos débiles, un fuerte presidencialismo, y Senados compuestos por terratenientes. Cercanas a esta concepción constitucional conservadora se encuentran las Constituciones chilenas de 1823 y 1833, las ecuatorianas de 1842 y 1851, así como también las Convenciones Constitucionales de México (1851) y Argentina (1853). Durante el siglo xx, la Constitución chilena de 1980 encarna un caso paradigmático de constitucionalismo conservador.

Mientras el modelo conservador defiende el particularismo católico, el modelo populista preserva el particularismo del *pueblo*. La figura del pueblo se convierte en el fundamento último de legitimidad y autoridad, en cuyo nombre se considera a otras instituciones democráticas con una relevancia secundaria (por ejemplo, el Senado y los poderes ejecutivo y judicial). Incluso los parlamentos bicamerales se vuelven sospechosos de dividir la voluntad popular¹⁷. Equilibrios y contrapesos no son parte del vocabulario del populismo constitucionalista. En este sentido, el particularismo de las constituciones populistas latinoamericanas yace justamente en una visión unilateral del proceso de toma de decisiones y en la identificación práctica y simbólica de la voluntad de la mayoría en la voluntad del líder populista. La infalibilidad de la *volonté générale* se convierte así en la infalibilidad de un hombre (o mujer). En este sentido, el modelo constitucional populista encuentra un piso común con los totalitarismos europeos¹⁸. Algunos casos de este programa constitucional en América Latina pueden observarse en la primera Constitución mexicana (1814) y en la posterior Constitución revolucionaria de 1911, la Constitución cubana de 1916 y sus reformas ulteriores (1992), la

Constitución venezolana de 1999 y, en cierta medida, la Constitución boliviana de 2009.

El modelo liberal, por su parte, se acerca a valores universalistas y a arreglos democráticos institucionales; esta es probablemente la razón por la que sea difícil encontrar expresiones concretas de esta práctica constitucional en América Latina. El constitucionalismo liberal promueve un arreglo institucional autónomo aunque interdependiente, una neutralización de los particularismos morales en la esfera pública y una limitación del poder estatal, particularmente en relación al paradójico mecanismo de un *Estado de excepción constitucional*, generalmente aplicado en los arreglos conservadores como forma de preservar los privilegios de las elites bajo condiciones políticas inestables¹⁹. Buenos ejemplos de estos programas constitucionales liberales pueden encontrarse en la primera Constitución venezolana de 1811, en las Constituciones peruanas de 1856 y 1861, y en la moderna Constitución brasileña de 1988.

Al comparar el constitucionalismo latinoamericano con el estadounidense, M. Schor²⁰ desarrolla un interesante argumento para explicar los orígenes del particularismo constitucionalista de América Latina:

Las elites o redactores que dieron forma a las constituciones latinoamericanas creían que el desarrollo económico debía ocurrir antes de que a las masas se les pudiera permitir participar en la democracia. En consecuencia, estas elites optaron por constituciones moldeables [...]. Las reglas formales del juego tenían que ser moldeables si las elites querían mantener su poder, pero las consecuencias han sido “calamitosas” como Madison conjeturó. Cada cambio de liderazgo político es potencialmente una crisis constitucional en cuanto que la selección de nuevos líderes significa que las reglas básicas del juego podrían ser cambiadas con la adopción de una nueva constitución²¹.

A juicio de Schor, las elites latinoamericanas del siglo XIX eran conscientes de los problemas de exclusión de principios del período republicano, como también lo eran del potencial conflicto político proveniente de la disolución de los privilegios institucionalizados del período colonial. Por ello, con el fin de prevenir turbulencias sociales, la estratificación (entendida como la concentración de poder y dinero en los estratos superiores) tenía que preservarse de algún modo. La alternativa

elegida fue un fuerte presidencialismo sostenido por las elites políticas y económicas. Sin embargo, un presidencialismo fuerte falla al momento de estabilizar estructuras normativas constitucionales, precisamente, porque depende más de intereses políticos (y personales) que de normas jurídicas. Las normas constitucionales se vuelven más bien un instrumento para ejercer y mantener el poder en vez de ser una fuerza limitante frente a los excesos políticos. El alto número de constituciones promulgadas en distintos países de América Latina en los últimos dos siglos revela la primacía de la voluntad política por sobre las normas constitucionales (15 constituciones en Perú, 18 en Bolivia, 20 en Ecuador, 16 en Venezuela). Las constituciones son adaptadas a intereses políticos particularistas antes que a una praxis política de normas universalistas.

Como consecuencia de lo anterior, la relación entre expectativas normativas públicamente generalizadas y las constituciones se debilita: “La gente tiene poca confianza en constituciones que podrían ser cambiadas tan fácilmente. Sin apoyo popular, la constitución no puede entregar la matriz institucional requerida para alcanzar acuerdos políticos”²². La confianza en redes particularistas con poder y conexiones para evitar la ley —o incluso para promover y aplicar una nueva constitución— parece mucho más eficiente que la confianza institucional.

El particularismo constitucional en América Latina tiene importantes raíces históricas. El problema no está en una identidad cultural esencialista de *ser latinoamericano*, como algunos han propuesto²³, sino que corresponde a un problema sociológico. La paradoja es que el particularismo es contrario al constitucionalismo en cuanto a la promoción y mantención de valores universalistas. Al tomar en consideración la preeminencia de intereses políticos particulares por sobre un gobierno de normas, el constitucionalismo latinoamericano implica más bien una deconstitucionalización del orden social; por ejemplo, un primado del poder coercitivo en vez de normas universalistas como medio para el manejo de contingencia y reducción de complejidad. Esto explica la continua politización de los sistemas funcionales en la mayoría de los países latinoamericanos, los obstáculos en la construcción de estructuras regionales de coordinación supranacional y los problemas al tratar con los principios normativos universalistas de la emergente constitucionalización sectorial transnacional.

4. EL UNIVERSALISMO NORMATIVO EN LAS CONSTITUCIONES SECTORIALES TRANSNACIONALES

No hay duda sobre los problemas de la diferenciación funcional en relación a la construcción de una sociedad mundial socialmente integrada. Breve y lúcidamente, N. Luhmann ha advertido al respecto:

Hoy el problema es mucho peor que antes. Podemos continuar con nuestros hábitos y volver a demandas morales que estarán tan justificadas como siempre, pero ¿quién escuchará esas quejas y quién reaccionará ante ellas si la sociedad no puede controlarse a sí misma? ¿Y qué podemos esperar si sabemos que el mismo éxito de los sistemas funcionales depende de su indiferencia? Cuando la evolución ha diferenciado sistemas cuya complejidad depende de la clausura operacional (y el caso paradigmático es, por supuesto, el cerebro humano), ¿cómo podemos esperar incluir todo tipo de preocupaciones dentro del sistema? El punto es que no nos encontramos en una fase de *posthistoria*, sino, por el contrario, en una fase de evolución turbulenta sin resultados previsibles²⁴.

Si el éxito del funcionamiento sistémico depende de la indiferencia, nos encontramos entonces enfrentados con un problema mayor de integración sistémica, y, consecuentemente, con la mayor barrera que la constitucionalización sectorial transnacional tiene que superar. La coordinación a través de indiferencia sistémica (coordinación negativa) es útil hasta el punto en que la producción simbólica de un determinado sistema excede sus propios mecanismos de control de las consecuencias para el entorno derivadas de su propio funcionamiento²⁵. Más allá de ese punto, solo las reglas de contención de operaciones transferenciales de prácticas sistémicas sobreproductivas pueden tener algunos resultados positivos en los sistemas afectados. Estas reglas de contención, sin embargo, son desarrolladas desigualmente en los diversos escenarios sistémicos. La economía reacciona de forma bastante poderosa y eficiente contra intervenciones políticas, pero la ciencia tiene que adaptarse por sí misma a programas de financiamiento que han sido políticamente definidos. Al mismo tiempo, y de modo incremental, las relaciones íntimas han desarrollado barreras en contra del control religioso interno (al menos, en las sociedades occidentales, esto incluso para personas religiosas), pero poco puede hacerse en contra del hecho de que la mayor

parte de las comunicaciones cotidianas en la familia tratan de problemas de dinero, y con eventos en los medios en segundo lugar.

La indiferencia sistémica es definitivamente un poderoso mecanismo de los sistemas para hacerse autónomos. Hace posible ignorar ruidos en el entorno y concentrarse en las propias operaciones. Sin embargo, esto se vuelve problemático en la medida en que los ruidos provengan de crisis presentes en otras prácticas sistémicas. La economía puede ser indiferente a la inequidad mientras los pocos ricos sean capaces de indicar el valor positivo del código económico y la mayoría no-rica observe esto desde el lado reflexivo. O la política puede ser indiferente a las redes de la mafia en cuanto que estas redes preserven cierto orden sobre sus territorios, reduzcan el desempleo a través de sus actividades ilegales y paguen regularmente sus sobornos a los políticos. Al mirar hacia el lado, los sistemas continúan con su *business as usual*, mientras las crisis se desarrollan de forma gradual, pero persistente, en los entornos sistémicos.

Si uno entonces extrae de esto una conclusión intermedia, esta es: particularismo como modo normativo de operación sistémica. Como concepto sociopolítico, el particularismo cuenta con un sentido claramente definido:

El “particularismo” describe la actitud [*Mentalitat*] sobre la que se basan valores políticos y programas de grupos políticos particulares o sociales, pertenecientes a un todo social o político. Estos grupos defienden y dan prioridad a la autonomía, independencia y los intereses particulares de las partes antes que al interés general, aunque estos rara vez se encuentren preparados para un desanclaje real (separatismo)²⁶.

Ciertamente, no considero aquí a los sistemas como grupos sociales, ni tampoco como promotores de intenciones políticas. Pero, a nivel semántico, ellos definitivamente construyen órdenes normativos que conceden prioridad a su propia autonomía: autonomía del banco central en finanzas, independencia judicial en la aplicación de las leyes, soberanía nacional en las políticas del Estado, inviolabilidad de la esfera privada en las relaciones íntimas, de las fuentes en los medios, de la confesión en la religión, originalidad en el arte, de la producción del conocimiento en la ciencia. Para cada sistema, las expectativas normativas en otros campos (o en la sociedad como un todo) son

irrelevantes o, al menos, de importancia secundaria al compararlos con la reproducción interna propia del sistema. Obviamente, el código tiene aplicabilidad universal: la economía funciona donde sea que se pague con dinero, la política opera donde sea que las decisiones encuentren aceptación, pero la construcción normativa de un sistema se enfoca primariamente en defender (¡y expandir!) contrafactualmente sus bordes; los sistemas reaccionan contra la intervención externa (libertad negativa) y promueven un crecimiento simbólico de sus propios discursos semánticos y prácticas operativas (libertad positiva). Esta construcción normativa opera como medio para justificar sus autonomías en términos semánticos, para elaborar la dimensión valórico-substancial de sus programas, para motivar las selecciones de los individuos, y para excluir preocupaciones alternativas o redirigirlas hacia el código de operación propio.

Es cierto que los choques entre sistemas no se originan en las normas, sino en operaciones que colisionan. Las normas son un subproducto de las operaciones sistémicas, y no a la inversa. Aun así, el lado expresivo de cada conflicto debe ser escenificado a través de las normas: ¿debiera una periodista revelar sus fuentes cuando devela un escándalo político? ¿Debieran las autoridades de los bancos centrales ser criminalmente responsabilizadas por las crisis financieras? ¿Es importante la vida sexual de un político para postular a cargos públicos? Normalmente, estos conflictos son presentados como problemas éticos y, en consecuencia, se enfrentan con soluciones de carácter ético que, por lo general, no tocan los problemas operativos fundamentales. El punto ciego de las reflexiones éticas es que las normas particularistas en conflicto son, de hecho, colisiones entre sistemas autónomos. La pregunta constitucional busca tratar esos problemas de modo operativo y en clave normativa universalista.

En sociología, la diferencia entre universalismo y particularismo fue originalmente reflejada en términos de la teoría de la acción por Talcott Parsons como un problema de contingencia:

Al confrontar cualquier situación, el actor enfrenta el dilema de si tratar los objetos en la situación de acuerdo a una norma general que cubre *todos* los objetos de esa clase, o si tratarlos de acuerdo a su posición en una relación particular a él o su colectivo, independientemente de la subsumibilidad de los objetos bajo una norma general. Este dilema

puede ser resuelto dándole primacía a normas o estándares de valor ampliamente generalizados y que tienen una base de validez que trasciende *cualquier* sistema de relaciones específico en el que ego se encuentre inmerso, o dándole primacía a estándares de valor que asignan prioridad de estándares *integrales* a la relación particular de sistema en la que el actor se relaciona con el objeto²⁷.

Parsons, al llamar a esta diferencia un dilema del actor, enfatiza el hecho de que la selección de normas en un sistema dado es contingente a las decisiones de este, es decir, que ambas alternativas no son necesarias pero tampoco imposibles. Esto es que las normas particularistas que emergen de la clausura operativa pueden ser compensadas por expectativas normativas universalistas que, en palabras de Parsons, tienen una base de validez que trasciende cualquier sistema de relaciones específicas. En el constitucionalismo transnacional, ese es el rol del derecho.

Los sistemas sociales nunca son completamente autónomos; siempre existen puntos de heteronomía. Si esta externalización ocurre ahora con la ayuda de constituciones, el momento de la heteronomía aparece cuando el sistema social se refiere al derecho. La identidad del sistema social se define de forma heterónoma a través de normas legales y puede entonces definirse autónomamente de ese modo. Mientras la unidad de un sistema social se desarrolla a través de la concatenación de sus propias operaciones, su identidad se crea en su constitución por medio de la *re-entry* de descripciones legales externas en su propia autodescripción²⁸.

Por medio de la interpenetración —y no de acoplamientos (!)—, el derecho provee al sistema de expectativas normativas universalistas, ayudándolo a reconstruir su propia identidad. Al interior del sistema, no existe una norma fundamental internamente construida que pueda hacer esto; entonces, el problema se enfrenta con una expansión de los derechos fundamentales al interior de sistemas autónomos²⁹. En las políticas de Estado, los derechos fundamentales protegen a los individuos de la desdiferenciación de las intervenciones del poder del Estado, protegiendo de ese modo la diferenciación funcional³⁰. En la política sistémica, dos consideraciones se vuelven cruciales. En primer lugar, los sistemas debieran “contrarrestar tendencias autodestructivas y [en segundo lugar] limitar el daño de sus entornos sociales, humanos y

naturales”³¹. Al resolver el primer problema, el sistema ecualiza sus propios riegos; al resolver el segundo, protege sus propias condiciones de posibilidad. Conseguir esto significa (auto)trascender el particularismo normativo y encontrar —al interior del sistema, aunque externamente provisto— una norma de interés general. A esto se le puede llamar un *momento de universalismo normativo*³². Esto implica, por un lado, la construcción de principios normativos generales al interior del sistema, aplicables a todo contexto social, incluso globalmente, y, por otro, la especificación de esos principios a los problemas que emergen de las tendencias autodestructivas de un sistema particular y sus consecuencias para el entorno.

Por cierto, la existencia de expectativas normativas universales al interior del sistema no es suficiente para la prevención o el control de daños. Se requiere de una institucionalización a través del derecho³³. La institucionalización demanda a su vez un reconocimiento previo de la rectitud generalizada adjunta a la norma universal. En el campo del comercio transnacional, principios universales como *la buena fe y el trato justo* son, por ejemplo, fácilmente traducibles en operaciones legales. Sin embargo, estos principios no provienen de operaciones legales, sino de procesos reflexivos presentes en prácticas comerciales que apuntan a estabilizar la tendencia autodestructiva del comercio de tomar ventajas injustas sobre la otra parte involucrada³⁴. Un rol similar juega la *prudencia* en las finanzas. En su forma más sencilla y original, esta establece que “solo las ganancias conseguidas al momento del balance habrán de ser incluidas”³⁵. Casos como el de Enron y la crisis *subprime* muestran qué tan importante es la norma y también la diferencia moderna entre una aproximación microprudencial —que previenen los altos costos del no-pago de instituciones financieras particulares— y una macroprudencial —que “reconoce la importancia de efectos de equilibrio general y busca salvaguardar al sistema financiero como un todo”—³⁶. *Fair play* es la norma equivalente en el deporte. Este busca establecer límites a los posibles excesos del código de competición en el deporte, a las propias consecuencias que ponen al deporte y su entorno humano en peligro (*doping*, corrupción, violencia). Mientras que, en las sociedades antiguas, la moralidad del deporte se basaba en el honor³⁷, en la sociedad moderna —al menos desde el siglo XIX— esta se

fundamenta en la rectitud (*fairness*). En este sentido, la rectitud refleja en el deporte el principio político de igualdad, esto es, “que todos tienen la posibilidad de competir, y que las condiciones de la competición debieran ser las mismas para todos los competidores”³⁸.

Para que pueda existir una constitucionalización transnacional, estos principios universales necesitan ser validados por decisiones jurídicas, pero no habría nada que validar si no existiese un sentido de rectitud dentro del sistema. Tal sensibilidad no es transferida por el derecho dentro del sistema, sino que se desarrolla de modo incremental a través de prácticas sistémicas que conectan las operaciones propias con eventos en el entorno que resultan relevantes como consecuencia de requerimientos funcionales³⁹. En otras palabras, los sistemas aprenden cognitivamente a actuar de modo normativo, o, al menos, a sostener esta expectativa en algunos aspectos fundamentales relativos a su propia autodesestabilización y a otras consecuencias relevantes de su funcionamiento para el entorno. De tal modo, los sistemas aprenden a actuar contrafácticamente en la medida en que se constitucionalizan:

Los objetivos contrafácticos son universales por naturaleza, tales como los esfuerzos por la realización de un libre comercio nodiscriminatorio, un acceso libre, global y sin censura a Internet, un acceso básico a la salud en todo el mundo, y una inclusión de todos los seres humanos bajo el paraguas de los derechos humanos que no sea solo formal sino que también de facto⁴⁰.

Al hacer esto, la interpenetración del *sistema específico/ sistema jurídico* provee al derecho de nuevas expresiones de universalismo normativo y, a cambio, el derecho provee al sistema particular con validación de sus discursos normativos. La consecuencia más relevante de esto es que, gracias a esos momentos de universalismo normativo, el sistema específico y la constitucionalización sectorial se enlazan normativamente con una democracia constitucional (a través de derechos fundamentales), con principios universales del sistema internacional de Estados (a través de normas de *ius cogens*) y con el nivel supranacional de los miembros de la especie humana (a través de derechos humanos).

La pregunta es ahora qué ocurre cuando este arreglo sistémico global de normas constitutivas particularistas y la constitucionalización universalista autolimitante se encuentran con los contextos sociales

particularistas del constitucionalismo latinoamericano.

5. El PARTICULARISMO CONSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA

Considerando los modelos constitucionales latinoamericanos discutidos más arriba (conservador, populista y liberal) y las construcciones normativas en el constitucionalismo transnacional, examinaré a continuación las consecuencias para la diferenciación funcional y la constitucionalización transnacional de dos casos paradigmáticos: el caso venezolano, como modelo de un constitucionalismo populista y de politización del orden social, y el caso chileno, como ejemplo de una monetarización de la diferenciación funcional por medio de un modelo neoliberal que combina valores conservadores y perspectivas individualistas-liberales respecto de la organización económica.

5. 1 VENEZUELA

El 25 de abril de 1999 —tres meses después de que Hugo Chávez asumiera la presidencia—, los ciudadanos venezolanos tuvieron que responder una sencilla, pero crucial, pregunta: “¿Llama usted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo orden legal que garantice el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa?”. El 31,6% del padrón electoral participó en el plebiscito. De este grupo, el 81,1% contestó la pregunta afirmativamente. Luego de elegir representantes para la Asamblea Nacional Constituyente, el nuevo órgano disolvió el Congreso Nacional —que había sido electo en 1998— e introdujo dos nuevos poderes del Estado: el Ciudadano y el Electoral. El 15 de diciembre de 1999, la nueva Constitución entró en vigencia⁴¹.

Desde entonces, las transformaciones de la sociedad venezolana han sido profundas y entremezcladas, tanto en un plano político-institucional⁴², como en términos semánticos⁴³. La nueva Constitución reemplazó la Constitución liberal de 1961, derivada del denominado “Pacto de Punto Fijo” entre los grandes partidos venezolanos Acción Democrática (ad) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), y que se orientaba a dar estabilidad a la

democracia venezolana ante amenazas militares y movimientos subversivos de izquierda. La sucesiva elección de gobiernos entre estos dos partidos y la consecuente ausencia de pluralismo electoral (una típica deflación de compromisos valóricos en sentido parsoniano⁴⁴), sin embargo, había deslegitimado el sistema, que ya mostraba signos de crisis desde las revueltas del denominado *caracazo* de 1989 y los golpes militares liderados por el mismo Hugo Chávez en febrero (activamente) y noviembre (desde su lugar de reclusión) de 1992⁴⁵.

La Constitución de 1961 no contaba con mecanismos para cambios constitucionales radicales (nueva constitución por medio de Asamblea Constituyente), sino solo para enmiendas. Por ello, en diciembre de 1998, la Corte Suprema de Venezuela —con Chávez ya a la cabeza del gobierno— fue requerida para pronunciarse sobre la constitucionalidad del llamado de Chávez a una Asamblea Constituyente. La decisión de la Corte fue promulgada en el fallo n.º 11 de enero de 1999 bajo una fuerte presión política proveniente de la compulsión de transformación institucional del nuevo gobierno. Esta presión política se dejó ver incluso en el propio fallo, en varios pasajes en los que se alude a “la intención de un importante sector de la vida nacional, liderado por el Presidente constitucionalmente electo [...] de convocar a un referéndum consultivo”; a la constatación de situaciones de hecho tales como: “se ha anunciado pública y oficialmente que se convocará a un referéndum consultivo”; o también a cuestiones de orden puramente político tales como: “se han producido movimientos populares dirigidos a recaudar el número de firmas de electores inscritos legalmente exigido para tomar la iniciativa”; o formulaciones asertóricas del tipo “el cambio que el país exige”⁴⁶. Por otro lado, los jueces debían hacer frente a una opinión pública caracterizada por la deslegitimación generalizada del antiguo modelo institucional, válido desde 1961. En ese contexto, rechazar la legitimidad del requerimiento interpuesto a favor de la Asamblea Constituyente, la que justamente expresaba la intención de una renovación de la institucionalidad fallida, no parecía una alternativa posible para la Corte. Tomando esto en consideración, dos puntos principales fueron significativos en la decisión de la Corte respecto de lo que habría de venir: a) en una doctrina relativamente común en América Latina y cuyos orígenes están en formulaciones schmittianas, la Corte estableció que el poder constituyente (el *pueblo*) era “anterior y superior al orden

jurídico”, y que b) su poder no se acaba al transferir competencias a instituciones o al gobierno⁴⁷. Con el primer argumento, la autoridad era elevada a un estatus místico más allá de cualquier norma jurídica, tal como en los regímenes totalitarios; con el segundo argumento, se introducía la posibilidad de un permanente cambio del orden constitucional. En uno de los párrafos más relevantes del fallo n.º 11 se indica:

El artículo 2 de la Constitución de la República de Venezuela, según los criterios interpretativos tradicionalmente expuestos, consagra exclusivamente el principio de la representación popular por estimar que la soberanía reside en el pueblo, pero que este no puede ejercerla directamente sino que lo hace a través de los órganos del poder público a quienes elige, es decir, que el medio para depositar ese poder soberano es el sufragio. Un sistema participativo, por el contrario, consideraría que el pueblo retiene siempre la soberanía ya que, si bien puede ejercerla a través de sus representantes, también puede por sí mismo hacer valer su voluntad frente al Estado. Indudablemente quien posee un poder y puede ejercerlo delegándolo, con ello no agota su potestad, sobre todo cuando la misma es originaria, al punto que la propia Constitución lo reconoce. De allí que el titular del poder (soberanía) tiene implícitamente la facultad de hacerla valer sobre aspectos para los cuales no haya efectuado su delegación. La Constitución ha previsto a través del sufragio la designación popular de los órganos de representación; pero, no ha enumerado los casos en los cuales esta potestad puede directamente manifestarse [...]. Conserva así el pueblo su potestad originaria para casos como el de ser consultado en torno a materias objeto de un referendo⁴⁸.

Para un gobierno que pretendía reconstruir todo el orden social fundado en la noción de *pueblo*, este había sido el primer paso. En el aniversario de su gobierno en 2009, Chávez identificó tres fases de su revolución. La primera, el “ciclo de tormenta” desde 1989 hasta 1999, es decir, desde el año del *caracazo* hasta la toma de poder. La segunda fase es la de formación del gobierno revolucionario desde 1999 hasta 2009. Y la tercera se proyectaba desde 2009 hasta 2019 como un ciclo de consolidación de la revolución y que se vio alterada con la muerte de Chávez en 2013⁴⁹. En una formulación algo más sucinta y técnica, Ryan Brading⁵⁰ ha identificado dos momentos en la revolución bolivariana: el período de revolución pasiva (en relación al concepto gramsciano) y el de revolución radical. El primero abarcaría el momento germinal del

proyecto chavista, probablemente desde 1991, momento en que se funda el Movimiento V República para la campaña de 1998 y en el que Chávez adopta un tono moderado que lo acerca a la clase media y a sectores empresariales. Este momento concluiría en 2001, año en que Chávez se niega a la negociación con Fedecámaras (asociación de comercio venezolana), bancos y grupos empresariales para establecer acuerdos en torno a las múltiples reformas (agraria, bancaria, propiedad, industria petrolera, entre otras) que estaba llevando a cabo en su gobierno. La radicalidad de estas reformas fue la que condujo a los intentos golpistas de 2002, cuando, según Brading los sectores de elite se dieron cuenta de que no podrían continuar manejando la revolución “desde arriba”⁵¹. El triunfo de Chávez frente a estos intentos por derrocarlo abrió el camino a la fase de revolución radical⁵².

En este camino, la propia Constitución bolivariana se transformó en un obstáculo. El intento de reforma de 2001 buscaba transformar el Estado federal en uno centralizado, dar poderes adicionales al presidente con reelección indefinida, politizar las fuerzas armadas y convertir formalmente a Venezuela en un Estado socialista. Una reforma de esta naturaleza habría requerido una nueva Asamblea Constituyente, pero el mecanismo utilizado fue el de una consulta, considerado en tal sentido, inconstitucional⁵³. La reforma fue rechazada. No obstante, en 2009 se realizó una nueva consulta para aprobar una enmienda constitucional que otorgaba la posibilidad de reelección indefinida a Chávez. Esta fue aprobada con 54% de preferencias en febrero de 2009⁵⁴. Sin embargo, el mecanismo de mayor utilidad para llevar adelante el programa revolucionario, aun en contra de la voluntad popular, fueron las denominadas “leyes habilitantes”:

Dado que el Presidente Chávez perdió el referendo constitucional que había promovido durante el año 2001 con el fin de ajustar la Constitución de 1999 a un modelo socialista, decidió hacer uso de los poderes otorgados por la Ley Habilitante de 2001 para “legitimar” por este medio la mayoría de las propuestas hechas en el marco del proyecto de reforma constitucional que fue rechazado por el pueblo el 2 de diciembre de 2001⁵⁵.

Las leyes habilitantes se transformaron en el mecanismo privilegiado para lograr una permanente politización de las esferas sociales en nombre del *pueblo*, y en ausencia de balances institucionales. En su

artículo 203, la Constitución de 1999 estableció la existencia y función de estas leyes:

Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar plazo de su ejercicio⁵⁶.

Se trataba de una especie de licencia dada por la Asamblea Nacional al presidente, permitiéndole gobernar vía decretos por un periodo de tiempo definido (entre 6 y 18 meses). Cinco leyes habilitantes fueron aprobadas por la Asamblea Nacional entre los años 1999 y 2013.

Un buen ejemplo de este mecanismo son las leyes del año 2001. Estas autorizaban al presidente a intervenir en múltiples áreas para reponer las propuestas de la reforma constitucional rechazada en el mismo año: a) estructura del Estado, b) participación popular, c) valores presentes en la función pública, d) en la economía (con el objetivo de crear a nuevo modelo económico y social), e) en las finanzas públicas y los impuestos, f) en la protección pública y la policía, g) en la ciencia y la tecnología, h) la organización territorial, i) la seguridad y defensa nacional, j) en transportes, infraestructura y servicios, k) en energía⁵⁷. El acta de 2013 —con Nicolás Maduro como presidente— introducía, entre otras, la lucha contra la corrupción y la promoción de una ética y moral socialista, la lucha contra los poderes extranjeros que intentan “destruir la patria” económica, política y mediáticamente, la consolidación de la justicia social para alcanzar una buena vida y la felicidad del pueblo venezolano, y el fortalecimiento de la planificación, racionalización y regularización de los asuntos financieros y económicos⁵⁸.

Esta forma de politización concéntrica y constitucionalizada de todo el orden social es opuesta al carácter descentralizado de la diferenciación funcional y la constitucionalización transnacional. Esto se puede analizar en un nivel operativo y normativo. En términos operativos, mientras la constitucionalización transnacional de la diferenciación funcional resalta la primacía del derecho por sobre la política, en el populismo constitucional esta primacía es entregada a la política por medio de una forma de autoridad autopromulgada y no-procedimental. No existe una interpenetración entre el derecho y la política que pudiera validar las

decisiones políticas. La validez no proviene del derecho, sino de una construcción semántica generada en la política misma: la autoridad mística del *pueblo*. Haciendo uso de esta, la política condensa y desdiferencia los símbolos del poder y la validez, y de ese modo instrumentaliza las operaciones legales a través de decisiones políticas. No hay modo de escapar de esta autocompletitud artificial, pues el poder constituyente es solo el símbolo de la política constituyente y el gobierno concretiza esto más allá de cualquier forma de derecho positivo.

A nivel normativo, esta unidad operacional de poder y derecho implica un particularismo radical. No hay parámetros externos —como derechos fundamentales, jurídicamente sancionados, que pudieran construir barreras contra la politización— para confrontar y compensar las decisiones. Por el contrario, el particularismo de *nación y pueblo* es reconstruido y presentado como un valor externo y superior ante el cual las decisiones políticas pueden ser evaluadas. Pero no hay *pueblo* fuera de la política. El universalismo del *pueblo* es cercano a un universalismo religioso: pretende ser universal sin considerar que no existe aceptación universal desde fuera. Esta es la razón por la que la aceptación normativa debe ser promulgada por la fuerza en el populismo constitucional: expropiando compañías en nombre de un “interés social difuso”⁵⁹, cerrando o controlando las corporaciones mediáticas⁶⁰, o usando escuelas, organizaciones y lugares de trabajo para instruir a los venezolanos en los valores socialistas que se enfrentan a la “ideología individualista del capitalismo”⁶¹.

Por tanto, cuando el populismo constitucional se encuentra con el constitucionalismo transnacional aparecen variadas incompatibilidades: a) aquellas entre operaciones políticamente centralizadas de un Estado-nación y las operaciones policontextuales y autónomas de los sistemas sociales, b) entre el impredecible particularismo del interés social del pueblo y el universalismo sustantivo y procedimental del constitucionalismo transnacional, c) entre la unilateralidad de las decisiones en el constitucionalismo populista y el acto de balance interpenetrante del universalismo jurídico y la autolimitación sistémica en la constitucionalización transnacional, y d) entre la politización de la diferenciación funcional a nivel nacional y la constitucionalización de los particularismos sistémicos en la arena transnacional. Expropiaciones, duros discursos en contra de los “poderes extranjeros”, la aspiración de

controlar los flujos de información global y el renacimiento de la semántica del “desarrollo endógeno”, propuestas por la CEPAL a mediados del siglo xx como mecanismo contra la desigual distribución del bienestar, son todas formas de expresar las incompatibilidades entre el populismo constitucional venezolano y la constitucionalización transnacional de los sistemas funcionales.

Bajo tales circunstancias, la única vía de escape parece ser deconstitucionalizar el particularismo de la unidad entre *pueblo* y gobierno, de modo tal que la relación entre política y derecho evolucione desde la indiferenciación hacia la interpenetración. El caso chileno provee de nuevas ideas al respecto.

5.2 Chile

La Constitución chilena actual fue promulgada en 1980, bajo la dictadura de Pinochet (1913-1990). Como en el caso venezolano, los ciudadanos chilenos también “aprobaron” esta Constitución en el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, con las alternativas “sí” (61,5%) o “no” (29,6%). Luego del golpe de Estado en contra del gobierno constitucional de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1913, la Junta Militar (un consejo compuesto por los tres generales de las fuerzas armadas y el general director de la policía) consideró que la constitución válida hasta 1913 (la Constitución de 1925) estaba en los orígenes de la descomposición política que condujo al golpe. Por ello, la Junta comisionó a un grupo selecto de juristas conservadores de derecha la formulación de un borrador para una nueva constitución, la cual debía cambiar no solo la organización política del país, sino el orden social en su totalidad. El texto fue llamado “borrador”, ya que previo a su promulgación debía ser revisado, modificado y aprobado por la Junta y, de acuerdo al plan, presentado posteriormente a la decisión popular en un acto plebiscitario. En cualquier caso, entre 1913 y 1980 la Junta no actuó en un vacío legal. En 1914, esta adoptó el Estatuto Jurídico de la Junta de Gobierno a través del cual el dictador era investido como “Jefe Supremo de la Nación” y designado como cabeza de los poderes ejecutivo y legislativo. No obstante, fue la Constitución de 1980 la que, en un acto fundacional, reconfiguró Chile, haciendo de la Junta Militar un poder constituyente (contra)revolucionario⁶².

Las transformaciones sociales producidas por la dictadura y su Constitución apuntaban en una dirección exactamente opuesta al caso venezolano. Mientras que el marco institucional venezolano de 1961, previo a Chávez, había sido diseñado para excluir la política de izquierda (exclusión del Partido Comunista en el “Pacto de Punto Fijo” de 1958), el golpe chileno reaccionó en contra del proyecto socialista del gobierno de Allende, estableciendo así una configuración de rostro doble —y en apariencia contradictoria— de las relaciones sociales: un conservadurismo católico en el sistema de valores y una visión neoliberal en el sistema económico. En términos normativos, la Constitución chilena representa un caso paradigmático del modelo conservador presentado por Gargarella⁶³: el poder coercitivo del Estado es usado para promover y defender la visión de mundo particularista de la elite conservadora. Tal como fue establecido en la “Declaración de Principios de la Junta Militar” en 1914 (una base preliminar del borrador constitucional), “el gobierno chileno respeta la concepción cristiana del hombre y la sociedad [...]. El hombre posee derechos naturales que son previos al Estado, derechos que emanan desde la naturaleza misma de los seres humanos, a saber, del Creador”⁶⁴. Esta concepción más bien medieval del Cristianismo, se expresa en la constitución en términos de formas naturalizadas de autoridad (una autoridad jerárquica y una democracia protegida), de legitimidad (un fuerte presidencialismo y una restricción del pluralismo), de familia (como el “núcleo fundamental de la sociedad”), de la propiedad (como derecho natural) y de la persona humana (como iguales en dignidad y derechos)⁶⁵. En términos políticos, sin embargo, ni la centralidad del ser humano, ni tampoco la importancia de la familia fueron de ayuda para evitar la tortura, persecución y asesinatos llevados a cabo por el régimen. Más bien, la dictadura:

[...] se basó en el pensamiento político católico tanto para justificar el golpe como para argumentar que los intentos del régimen de privatizar y descentralizar la economía eran aplicaciones de los principios sociales papales, particularmente del principio de subsidiariedad propuesto por el papa Pío xi en 1931⁶⁶.

El principio de subsidiariedad resulta de crucial importancia al momento de explicar tanto una especie de invisibilidad de los órdenes transnacionales en la política chilena como para dar cuenta de la

adopción de las políticas neoliberales en el campo económico. La versión católica original de este principio propone que:

Aquello que los individuos pueden hacer por sí mismos y con su propio esfuerzo no debiese ser quitado y entregado a la comunidad; lo mismo se puede decir de sociedades o grupos menores o menos expandidos respecto de sus relaciones con grupos o sociedades más grandes o de mayor rango⁶⁷.

En esta visión, “sociedades de mayor rango” significa el Estado. La versión católica descansa en una concepción jerárquica de una sociedad ordenada en la que la familia es la primera unidad social y el Estado la mayor. El Estado abarca así a las familias y las organizaciones intermedias, las coordina como un todo asumiendo las funciones que estas no pueden llevar a cabo. Tal como el mismo Pío xi argumenta en sus encíclicas, esta clásica visión corporativista y conservadora es autoritaria en su centro:

Por tanto, aquellos en el poder debieran estar seguros que mientras más perfectamente se preserva el orden jerárquico entre las distintas asociaciones, y en observancia del principio de la “función subsidiaria”, más fuertes serán la autoridad y la eficiencia social, y más feliz y próspera será la condición del Estado⁶⁸.

Un orden social controlado por el Estado no tiene sensibilidad por la transnacionalidad. Es un orden en el cual el Estado busca mantener la autonomía de los sistemas sociales dentro de sus límites, y controlarlos heterónomamente a través de una membresía compulsiva y regulaciones comprehensivas⁶⁹. De este modo, no existe la posibilidad de considerar seriamente la formación de regímenes privados, ni tampoco la de reconocer la validez de órdenes normativos más allá del Estado que tengan influencia en las asociaciones intermedias dentro de este. Así, no hay espacio para aceptar la legitimidad de colisiones entre órdenes nacionales y transnacionales. La solución es siempre una: la supremacía del Estado prevalece. No obstante, al mismo tiempo el corporativismo autoritario chileno promovió cierto grado de autonomía para niveles inferiores, en cosas “menos importantes”, las que distraerían al Estado de sus funciones principales (la seguridad interna y externa). Esto fue lo que pavimentó el camino para el liberalismo en la arena económica.

El caso chileno se caracterizó por una peculiar combinación de políticas autoritarias respecto de los asuntos públicos —control de los medios, sindicatos, proscripción de partidos políticos, persecución política y tortura, prohibición de manifestaciones artísticas disidentes, intervención de universidades, control de asociaciones comunitarias— y de políticas liberales en el campo económico. En palabras de Hilbink:

Mientras este modelo tenía sus raíces en un pensamiento corporativista católico, su pretensión no-partidista y su foco en el orden y la estabilidad encajaban bien en la mentalidad y los deseos de los economistas neoliberales que habían sido empoderados para reestructurar la economía⁷⁰.

Para los civiles de derecha que apoyaban el golpe y la dictadura (y, claramente, para los militares), la experiencia socialista del gobierno de Allende era considerada traumática. Más allá de razones político-ideológicas, la profundización de la reforma agraria, la nacionalización de industrias, el control del precios y la ambición general de construir una economía planificada, eran vistas como las principales causas del estancamiento económico de Chile. En ese sentido, la sociedad chilena entre 1913 y 1989 se acercó a reproducir las condiciones de experimento controlado: sin oposición de los sujetos, con una erradicación coercitiva del comportamiento desviante, un “inicio desde cero” en sentido económico y político, y una hipótesis constitucionalmente establecida; a saber, mientras menor la intervención del Estado, mayor la eficiencia de la economía.

La Constitución chilena se asimilaba de este modo a una constitución económica, con un *orden público económico*. La autopoiesis de la economía se podía desarrollar libremente, no solo nacionalmente, sino también de modo transnacional contradiciendo la estructura del corporativismo autoritario y produciendo un giro radical respecto de las tendencias latinoamericanas, presentes desde 1930, que promovían un desarrollo interno y una industrialización por sustitución de importaciones. La constitucionalización de la economía como un sistema autónomo fue también una innovación en la doctrina constitucional:

El hecho de que el nuevo carácter constitucional incluyese no solo aspectos políticos sino que también sociales y económicos, la hacía la primera constitución plena que haya tenido Chile.

Después de todo, todas las constituciones previas habían sido *solo políticas*.

Al traducir aspectos cruciales de las operaciones económicas en términos constitucionales, se concede a la economía no solo protección contra intervenciones políticas (libertad negativa), sino también un poder simbólico masivo para explorar alternativas de interpenetración con el entorno (libertad positiva). El problema, sin embargo, era que la constitución plena no era realmente plena. Otros campos sociales no estaban constitucionalizados. Estos carecían tanto de protección constitucional como de incentivos simbólicos para buscar interpenetraciones con el entorno. En tales términos, el problema no era la constitucionalización de la economía en sí, sino el hecho de que sin la constitucionalización de otros sectores, las tendencias expansionistas simbólicas de las comunicaciones económicas podían actuar desenfrenadamente sobre sistemas no constitucionalizados como la educación (primaria, secundaria y superior), el sistema de salud, los servicios básicos, servicios sociales, el sistema de transporte y el sistema de pensiones. La consecuencia de esta constitucionalización asimétrica de los sistemas sociales es la monetarización de la sociedad.

La monetarización de la sociedad significa que, fundamentalmente, el medio simbólico del dinero define el acceso, pero también operaciones fundamentales en sistemas no-económicos. Concretamente, la monetarización fue llevada a cabo a través de un amplio programa de privatización y disolución de regulaciones públicas: privatización del sistema de salud, de las pensiones, del sistema escolar y universitario, de las telecomunicaciones, del transporte público, de los servicios básicos e, incluso, del orden público a través de guardias privados en lugares tanto privados como públicos⁷². El acceso a todos estos sectores, y especialmente la calidad de sus servicios, dependía del pago de personas individuales o familias. Mientras más se paga, mejor es la operación del sistema en términos de eficiencia (costo/ beneficio), eficacia (logro de objetivos) y oportunidad (adecuación de los rendimientos). Así, los precios se vuelven un medio de calidad operativa en diferentes sistemas sociales: gatillan procedimientos operativos alternativos que resultan en rendimientos claramente estratificados del mismo tipo general.

Dos consecuencias principales surgen de esto. Por un lado, si la calidad de los rendimientos depende de pagos y el funcionamiento

económico se encuentra constitucionalizado, entonces el efecto más relevante de esto es la legitimización constitucional de la estratificación. Así como en sociedades estratificadas los privilegios están jurídica y semánticamente institucionalizados, la constitucionalización asimétrica de los sistemas sociales produce estratificación al monetarizar tanto la calidad operativa de funciones específicas como los accesos personales a sus resultados. La desigualdad se constitucionaliza indirectamente a través de la constitucionalización de la economía, como también por medio de la desdiferenciación constitucionalmente legitimada de otros sistemas sociales. Por otro lado, la constitucionalización chilena de la economía colisiona con la constitucionalización sectorial en términos de la dimensión limitativa de las constituciones económicas transnacionales. Los mecanismos limitantes en las constituciones transnacionales debieran restringir tanto el crecimiento sistémico excesivo como los daños sobre los entornos sociales, naturales y humanos. En el caso chileno, se trata de una constitución nacional que no cuenta con barreras contra la expansión económica.

Ciertamente, la práctica económica transnacional de la economía chilena ha sido *civilizada* en las últimas décadas, particularmente a través de acuerdos internacionales, contratos y la participación en foros económicos globales. Por otro lado, desde la redemocratización del sistema político en 1990, regulaciones específicas e instancias de supervisión han provisto al menos un marco procedimental para tratar con el *orden público económico*. Pero el carácter constitucional de la economía y las debilidades de sus funciones limitantes permanecen activos. Los cambios constitucionales previstos debieran, por tanto, incluir la deconstitucionalización de valores católicos particularistas y, si es que no una deconstitucionalización de la economía, al menos una constitucionalización de las expectativas normativas universalistas que protegen tanto la autonomía de otros sistemas como la sensibilidad frente a los daños en los entornos sociales, naturales y humanos.

6. CONCLUSIÓN

Como la mayor parte de Occidente, América Latina entra al proceso de diferenciación funcional como periferia colonial. La posición resulta paradójica: la región se vuelve parte de la sociedad mundial, pero juega

un rol subordinado dentro de ella. Esto produce una permanente doble tensión entre, por un lado, la diferenciación global de los sistemas funcionales y la concretización regional de las operaciones sistémicas, y, por otro, entre las normas universalistas de la sociedad mundial y el particularismo normativo de origen local y regional. En las estructuras coloniales esta tensión se resuelve a favor de una concentración del poder político en las elites españolas y sus visiones semánticas particulares. La transición a Estados independientes durante el siglo XIX reproduce estos patrones, pero cambia a los actores: las elites españolas son reemplazadas por elites oligárquicas locales que, en un plano estructural, construyen un Estado altamente excluyente con un fuerte presidencialismo y una baja participación política, y, en la dimensión normativa, capturan el aparato del Estado con sus intereses hegemónicos particularistas.

El constitucionalismo no está en buena compañía ni con un presidencialismo fuerte ni con el particularismo normativo. Por un lado, mientras el constitucionalismo aspira a un gobierno de reglas, el presidencialismo descansa en la voluntad política e intereses de corto plazo. En este sentido, la confianza pública se redirige desde las estructuras a las personas, de modo tal que las constituciones no se encuentran en posición de representar expectativas normativas públicamente generalizadas. Como consecuencia de ello, su legitimidad se debilita. Por otro lado, el compromiso particularista se transforma en alternativa cuando normas constitucionales universales tienen una eficacia limitada o definitivamente no la tienen. De hecho, el particularismo normativo prevalece en el constitucionalismo latinoamericano tanto en constituciones católicas conservadoras como en las populistas. El constitucionalismo liberal es una experiencia más bien inusual de la política latinoamericana.

La pregunta que surge de esto es si el constitucionalismo transnacional tiene una oportunidad de enfrentarse al constitucionalismo particularista latinoamericano. No hay duda respecto del particularismo de los sistemas sociales. El código posee una primacía sobre consideraciones del entorno que concede prioridad a su propia autonomía. Choques y colisiones entre sistemas se originan predominantemente en esa indiferencia hacia el entorno. La pregunta constitucional reacciona a ello desde un punto de vista universalista,

buscando construir una relación de interpenetración entre sistemas en colisión y un derecho que debiera evitar tanto las tendencias autodestructivas de los sistemas funcionales como los daños que estos provocan en sus entornos sociales, naturales y humanos.

Al revisar el caso venezolano (constitucionalización populista) y el chileno (constitucionalización conservadora-liberal), he mostrado que las expectativas normativas universalistas en la constitucionalización sectorial transnacional difícilmente pueden ser reconciliadas con una constitucionalización local particularista. En Venezuela, el populismo constitucional identifica poder y derecho con el gobierno, produciendo así una fuerte *politización* de toda la sociedad que depende de una voluntad política particularista correspondientemente ficcionalizada y manejada a través de la semántica del *pueblo*. En el caso chileno, se observa una estructura constitucional compleja y contradictoria. Por un lado, el corporativismo conservador autoritario no reconoce órdenes normativos más allá del Estado que tengan una influencia en los asuntos locales; el constitucionalismo transnacional se vuelve así un problema más bien ficticio. Por otro lado, la constitucionalización nacional de la economía produce una relación asimétrica entre diferentes sistemas funcionales, lo que genera una monetarización de toda la sociedad y una constitucionalización de las inequidades sociales. La función limitante de la constitución económica transnacional —que, en realidad, se ha desarrollado de forma incompleta por el momento— tiene pocas posibilidades frente a tal escenario.

Por cierto, la función limitativa de las constituciones no se circunscribe a la constitucionalización transnacional. La limitación del poder político a través de derechos fundamentales ha sido siempre el principal objetivo de la constitucionalización. Sin embargo, conseguir esto demanda una traducción efectiva de expectativas normativas universalistas en forma de derecho vigente. Cuando las constituciones son capturadas por intereses particularistas y visiones de mundo normativas provenientes de las elites políticas, sean estas de origen populista-autoritario o conservador, como en los casos de Venezuela y Chile respectivamente, la función limitativa se transforma en limitación de normas universalistas. Esto implica una severa restricción de la capacidad de los sistemas funcionales de reintroducir en sí mismos las consecuencias de su propio funcionamiento para sus entornos sociales,

naturales y humanos. Sin principios universalistas operando dentro del sistema, la indiferencia y el descuido son condiciones normales para el sistema.

En tal sentido, se requiere de una deconstitucionalización del constitucionalismo normativo para coordinar la autonomía funcional con los problemas del entorno. La producción continua de crisis sociales y catástrofes de alto impacto son indicadores de la lejanía de tal objetivo. Las crisis son claramente una condición normal en la compleja sociedad mundial actual. Las estructuras constitucionales a nivel nacional o transnacional, en tanto puedan estabilizar efectivamente sus funciones limitativas, son un importante antídoto frente a crisis que se incrementan y que, en ocasiones, se convierten en catástrofes que reconstruyen todo el orden social. Un arreglo constitucional estable es de ayuda para detener las crisis antes de su transformación en catástrofes. El ejemplo de la crisis financiera en los últimos años muestra las dramáticas consecuencias de la ausencia (o, al menos, de la debilidad) de esa función constitucional limitativa en las finanzas globales.

En términos de una perspectiva histórica, América Latina ha experimentado variadas crisis de amplio alcance. Revoluciones, golpes militares, profundas crisis económicas, transformaciones económicas radicales, prácticas rentistas (*rent-seeking*) y corrupción, una desigualdad constante y exclusiones estructurales profundas son rasgos comunes de la historia contemporánea del continente. Esto significa que las estructuras constitucionales tienen, por un lado, problemas al momento de alcanzar sus funciones limitativas y, por otro, están lejos de poder coordinar la autonomía funcional de los sistemas sociales con las preocupaciones presentes en sus entornos. Si la hipótesis de la captura de las estructuras constitucionales por intereses y normas particularistas es acertada, entonces una deconstitucionalización del particularismo y una reconstitucionalización por la vía de expectativas normativas universalistas debiera ser una estrategia de utilidad para alcanzar tanto autolimitación sistémica (particularmente en política y economía) como una preocupación por el entorno. Las presiones provenientes de procesos de constitucionalización transnacional emergentes pueden ser de gran utilidad para cumplir esta tarea, siempre y cuando estas no sean absorbidas por el campo gravitatorio del particularismo conservador o populista latinoamericano. No obstante, los esfuerzos principales y las

luchas más relevantes, que buscan combinar autonomía sistémica y una interpenetración multilateral no intrusiva con el entorno, es algo que aún yace a nivel local.

TERCERA PARTE
DEBATE CONSTITUYENTE
EN CHILE

VIII. EL DEBATE CONSTITUCIONAL EN CHILE. LA CUESTIÓN DE LA LEGITIMIDAD

Valentina Verbal

1. INTRODUCCIÓN

Una de las dimensiones principales del debate constitucional que actualmente vive Chile se refiere a la cuestión de la legitimidad. No solo en cuanto a la falta de legitimidad de origen de la Constitución de 1980 — por haber surgido en dictadura—, sino por la forma en que, en general, las constituciones logran (o deben lograr) este atributo.

Una primera visión —quizás la hegemónica, hasta ahora— sostiene que la legitimidad de las cartas fundamentales depende de la participación directa del pueblo en los procesos constituyentes que las generan. En torno a este planteamiento, se sitúan los defensores de la Asamblea Constituyente (AC), que tienden a afirmar que este procedimiento es el más idóneo para lograr que la constitución se elabore con la participación del conjunto de la ciudadanía¹.

Una segunda visión —menos desarrollada en este debate, y que es la que intentaré defender— afirma que la legitimidad constitucional se consigue, esencialmente, a partir del consenso mayoritario de las elites que forman parte del juego político y que integran tanto el gobierno como la oposición. Esta visión argumenta que la instancia *natural* de legitimación de las constituciones está (o debe estar) radicada en el Congreso Nacional, ya que se trata del espacio por excelencia para la deliberación política.

Asumiendo desde ya una posición favorable a una nueva constitución para Chile², recogeré dos conceptos fundamentales para este trabajo: legitimidad y consenso. Siguiendo a Juan J. Linz, la legitimidad puede entenderse como “la creencia de que, a pesar de sus limitaciones y

fallos, las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas”³. El segundo concepto, el consenso, según Giovanni Sartori, se da en tres niveles: a) sobre los valores últimos, nivel que opera con respecto a la comunidad; b) sobre las reglas del juego, que hace lo propio con respecto al régimen político; y c) sobre políticas de gobierno, que se refiere a la adhesión a las propuestas de quien ejerce el poder ejecutivo⁴. Y agrega: “El consenso que verdaderamente es condición necesaria es el procedimental, el acuerdo sobre las denominadas *reglas del juego*”⁵.

Adherido a este marco teórico, en las páginas que siguen, argumentaré que, en la conformación de la creencia de la que habla Linz, es esencial el rol que cumplen las elites políticas, tanto de gobierno como de oposición⁶. En este sentido, buscaré demostrar que esto es lo que siempre ha sucedido en la historia de Chile (2), en particular con la Constitución de 1980 (3). Por último, cuestionaré la idoneidad de la AC como vía de legitimación (o relegitimación) constitucional, precisamente por apuntar a la exclusión de las mencionadas elites (4).

2. LEGITIMIDAD DE LOS PROCESOS CONSTITUYENTES EN CHILE: VISIONES HISTORIOGRÁFICAS

En términos historiográficos, es posible distinguir las mismas visiones descritas en la introducción: a) aquella que basa la legitimidad constitucional en la participación directa del pueblo en la elaboración de las cartas fundamentales, y b) aquella que la centra en los consensos fundamentales que se dan en el seno de las elites políticas⁷.

Si destacamos el hecho de que la comunidad de historiadores ha estado bastante presente en el debate constitucional actual⁸, quien lleva hoy la batuta en la primera de tales visiones es, sin lugar a dudas, Gabriel Salazar. A través de su obra *En el nombre del poder popular constituyente*, y en el marco de consideraciones ideológicas y prácticas de diversa índole⁹, Salazar recorre los distintos procesos constituyentes de la historia de Chile con el objeto de demostrar que en ninguno de ellos, salvo en el de 1828¹⁰, ha participado el pueblo como actor fundamental.

En este mismo sentido, Sergio Grez sostiene que este país nunca ha contado con una constitución legítima porque siempre las cartas

fundamentales se han elaborado de espaldas al pueblo y a partir de procesos violentos:

Todos los textos constitucionales han sido elaborados y aprobados por pequeñas minorías, en contextos de ciudadanía restringida (como ocurrió con algunas variantes en el siglo XIX) o como imposiciones de la fuerza armada (como sucedió durante ese mismo siglo e invariablemente durante el siglo XX). Las tres cartas principales (1833, 1925 y 1980) tuvieron como parteras a las fuerzas armadas que actuando como “garantes” del Estado o del orden social, pusieron sus fusiles y cañones para inclinar la balanza a favor de soluciones constitucionales propiciadas por facciones social y políticamente minoritarias¹¹.

Pero siendo cierta la presencia de “fusiles y cañones” en los procesos constituyentes¹², dado que estos suelen emerger de graves crisis institucionales —comenzando, para el caso de las naciones hispanoamericanas, por la misma Guerra de Independencia—, lo relevante para la segunda visión es que, tarde o temprano, sea posible para las elites políticas arribar a un consenso fundamental sobre las reglas del juego. Sin despreciar el papel de la ciudadanía en la legitimidad de los sistemas políticos¹³, el rol que asumen las elites termina siendo muy importante. Y en torno al documento que llamamos *constitución*, resulta clave la forma en que se establecen las relaciones (frenos y contrapesos) entre los distintos poderes, en particular entre el ejecutivo y el legislativo.

Este elemento es, también, de la máxima importancia en cuanto a la regulación de las fuerzas armadas. La gran cantidad de insubordinaciones militares que se produjo en el proceso de formación de la República en Chile (1823-1830) se debió, en buena medida, al establecimiento —según los términos de Samuel P. Huntington— de un control civil subjetivo más que objetivo. Esto significa que la supremacía civil se radicó en el Congreso más que en el presidente, atrayendo a los militares al juego político¹⁴. Aunque, valga aclarar, este tipo de control fue la tónica en la primera superación del absolutismo, ya que se creía —casi dogmáticamente— en el papel preeminente de las asambleas legislativas, incluso en materia de subordinación castrense.

En la línea de la visión que centra la legitimidad constitucional en los consensos políticos, cabe mencionar el punto de vista desarrollado por Gonzalo Vial Correa. En el año 2006, al cerrar una historia de Chile de

dos tomos —que representó la síntesis de toda su obra precedente—, hablaba de un “consenso incompleto”. ¿Qué quería decir con esto? Que, al momento de que Michelle Bachelet asumió su primer mandato presidencial, el país había logrado un consenso en materia política y económica, pero no en cuanto al tipo de familia y vida sexual que el Estado debería promover¹⁵. O sea, reduce la falta de consenso a las cuestiones que hoy se suelen calificar como “valóricas”. En cambio, en torno a la Constitución de 1980 concluye que “prácticamente se ha cerrado el proceso que el concertacionismo consideraba indispensable para 'democratizar' la Constitución”¹⁶.

Otro planteamiento —distinto al anterior, pero también a favor de los consensos como base de la legitimidad constitucional— es el que aporta Sofía Correa Sutil. Esta autora, a través de un artículo publicado en 2015, defiende la tesis de que las constituciones se legitiman —sea de origen o de ejercicio— cuando se dan de manera simultánea profundas reformas constitucionales y electorales, poniendo como ejemplo emblemático el proceso llevado a cabo durante la década de 1870¹⁷.

Sin embargo, no puede dejar de considerarse que el punto débil de esta interpretación es que las reformas “parlamentaristas” de 1873 y 1874¹⁸ condujeron, casi inevitablemente, a la Guerra Civil de 1891, lo que puede ser una demostración de que la legitimidad no siempre va de la mano de la estabilidad, al menos para el caso de los gobiernos. Además, estas reformas condujeron a lo que Alberto Edwards denominará “anarquía parlamentaria”¹⁹, por el hecho de la constante caída de los gabinetes de parte de las mayorías partidistas que funcionaban en el Congreso²⁰.

Dicho lo anterior, no cabe duda de que las reformas indicadas del siglo XIX, pese al denominado *parlamentarismo a la chilena*²¹ al que finalmente se llegó (1891-1925), legitimaron la misma Constitución “portaliana” de 1833, gracias al consenso mayoritario de los grupos que formaban parte de la deliberación política que se daba en el Congreso.

Lo mismo —*mutatis mutandis*— puede sostenerse para la Carta de 1925, que fue legitimada con el paso del tiempo y no en base a reformas tan estructurales²². No hay que olvidar que en el origen de esta Constitución participaron activamente los militares, y recién pudo comenzar a regir en plenitud a partir de 1932, al asumir Arturo

Alessandri Palma su segundo mandato presidencial.

3. LA CONSTITUCIÓN DE 1980. LEGITIMACIÓN Y DESLEGITIMACIÓN

Si para la legitimidad del sistema político (consagrado en una determinada constitución), resulta fundamental el consenso al que arriban las elites partidistas, no es descabellado afirmar que fueron estas mismas elites —de manera transversal²³—, las que legitimaron la Constitución de 1980.

En este sentido, y tomando como punto de referencia dos casos de intelectuales orgánicos de la ex Concertación²⁴, es fácil constatar que esta coalición no cuestionó radicalmente la legitimidad de origen de la Constitución de 1980, sino solo su contenido más o menos autoritario²⁵. Es decir, bajo los 20 años de la Concertación (1990-2010), siempre se pensó que la Carta fundamental se tornaría legítima en la medida en que se eliminaran los *enclaves autoritarios*. Por otra parte, puede también sostenerse que, durante ese período, no habría existido un cuestionamiento al modelo económico “neoliberal”²⁶ como un todo, el que se estimaba válido en la medida en que fuese administrado por dicha coalición y no por la derecha.

En una obra del año 2000, Manuel Antonio Garretón sostiene que lo clave es la “democratización incompleta en Chile”. Y si bien plantea la necesidad de pensar en una nueva constitución, lo hace de manera bastante tímida y resaltando el término de “la transición” y el consiguiente paso de un régimen dictatorial a uno democrático:

A nuestro juicio, estamos frente a un régimen de naturaleza distinta de la dictadura, aunque no se trate de una democracia completa, y todo el sentido del cambio de dictadura a este régimen fue dado por la idea de establecer una democracia²⁷.

Y luego agrega que, no obstante, es valorable la existencia de gobiernos de mayoría para la Concertación gobernante, el desafío vigente es de carácter institucional: “por la presencia de los enclaves autoritarios”²⁸. Además, resulta interesante leer su defensa de la “democracia de consensos” en la medida en que “se trata de 'acuerdos

sobre los fundamentos' y no arreglos políticos puntuales sobre aspectos específicos en los que sí debe decidir la mayoría”²⁹. Por último, frente a la disyuntiva “Reforma o nueva Constitución”, señala que no hay que dar una respuesta única y que se pueden hacer ambas cosas a la vez:

Una de las fórmulas para ello sería incluir en las reformas urgentes para democratizar la actual Constitución, una cláusula transitoria que genere un mecanismo (Asamblea, Comisión, proyecto del Ejecutivo o cualquier otro) para elaborar en un plazo definido una nueva Constitución, sin ruptura institucional ni estructuras paralelas³⁰.

Nótese que, si bien se define como partidario de una nueva carta, aclara que a esto debe caminarse de manera paralela a la vía reformista. Además, no le asigna mayor importancia al mecanismo como base de la legitimidad del documento elaborado.

Un segundo caso a mencionar es el de Pablo Ruiz-Tagle, quien en 2006 centró su análisis en el contenido autoritario de la Constitución, a pesar de la reforma de un año antes, encabezada por el expresidente Ricardo Lagos³¹. Si bien cuestionaba la legitimidad de origen de la Carta de 1980, sobre todo por haber sido elaborada por la Junta de Gobierno, concluye que fue validada en 1989 por el poder constituyente originario (el pueblo)³². Pero su crítica central se dirige en contra de su carácter excesivamente autoritario, todavía vigente luego de las reformas de 2005: “Pienso que la Constitución chilena vigente puede ser caracterizada como una Constitución 'Gatopardo', es decir, una Constitución que mientras más se reforma, acendradamente retiene sus rasgos autocráticos”³³.

Frente al procedimiento, Ruiz-Tagle descarta de plano la Asamblea Constituyente, ya que se trata de:

[...] una posibilidad que no se ajusta a las circunstancias políticas del período en que se ha restaurado la democracia. Esta alternativa se habría justificado al iniciarse este período, si se hubiese pensado en redactar un texto completamente nuevo³⁴.

Claramente, se pronuncia a favor de “la conjunción de reforma constitucional e interpretación constitucional”, poniendo como ejemplo la vía seguida por los liberales decimonónicos que lograron quitarle poder al presidente³⁵. Incluso, en cuanto al órgano encargado de acometer esta

tarea, se manifiesta partidario del Senado que, a partir de las reformas de 2005, se libró:

[...] de la incrustación autoritaria constituida por los senadores designados y vitalicios. Me parece que el Senado debe ser el *locus* plenamente democrático donde puede surgir una concepción constitucional más democrática que responda a principios constitucionales avanzados³⁶.

En suma, y aunque propone reformas profundas a la Constitución, Ruiz-Tagle sostiene la tesis de que la ilegitimidad de origen se subsana desde el mismo Congreso por la vía deliberativa y gradualista.

A *contrario sensu*, puede sostenerse que este proceso de legitimización elitaria de la Constitución de 1980 —con todas sus reformas posteriores, incluidas las que Ricardo Lagos selló con su firma en 2005— cesó durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). Asimismo, en este momento comenzó a ser cuestionado con fuerza el modelo económico. En otras palabras, la consideración de la Constitución actual como ilegítima se debe, en buena medida, al rechazo generalizado del sistema de libre mercado dentro de un sector político.

En efecto, la Concertación no aceptó que el modelo fuera administrado por la derecha, con lo cual el modelo habría tendido —supuestamente, claro está— a mostrar su cara más oscura. Esto coincidió con la llegada al poder de un empresario, con quien la *perversidad* del sistema económico adquirió un simbolismo de mucho mayor peso.

Lo anterior puede también apreciarse a partir de la lectura de algunos intelectuales públicos de la ex Concertación, que durante el gobierno de Piñera escribieron sobre el modelo. Puede referirse el mismo caso de Manuel Antonio Garretón, quien en 2012 publicó el libro *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado*. Su tesis puede resumirse en que, a diferencia de la Concertación, que buscó corregir el modelo:

[...] el gobierno de derecha, encabezado por Sebastián Piñera, no busca corregir ni el modelo socioeconómico neoliberal ni el modelo político de democracia incompleta, sino profundizar ambos³⁷.

Un segundo caso de deslegitimación intelectual es el de Fernando

Atria, quien en 2013 publicó *Neoliberalismo con rostro humano*, en el que plantea básicamente que las instituciones fueron abiertamente “diseñadas para neutralizar, no canalizar, la agencia política del pueblo chileno”³⁸, y que:

[...] esto llevó a la Concertación, durante sus veinte años, a administrar esa neutralización. Por eso hoy la deslegitimación del sistema institucional (la demanda de nueva Constitución) y la crítica a una Concertación que habría traicionado al movimiento que la llevó al poder después de la gesta del 5 de octubre, son en realidad expresión del mismo descontento³⁹.

Tanto Garretón como Atria resultan paradigmáticos para sustentar la idea de que la ilegitimidad del sistema político y económico (y de la Constitución que los consagra), se produjo efectivamente recién, durante el gobierno de centroderecha encabezado por Sebastián Piñera⁴⁰. Por supuesto, desde mucho antes había sectores en el país que tenían una postura de rechazo al modelo en su doble faz (política y económica). Pero se trataba de grupos que no integraban la Concertación y que, por sí mismos, no conformaban una mayoría suficiente. Al mismo tiempo, parece bastante claro que la entrada del Partido Comunista (pc) a la actual coalición de gobierno — la Nueva Mayoría— terminó por sellar la ilegitimidad de la Constitución⁴¹.

Tal vez desde el gobierno de Sebastián Piñera, se repitió una ley histórica que, para el caso de la fusión liberal-conservadora que se opuso al expresidente Manuel Montt desde 1856, René León Echaiz describe en los siguientes términos: “Nadie se parece tanto a un liberal que un conservador en la oposición”⁴². Lo que podría parafrasearse como la conclusión de que la otrora Concertación se terminó —convenientemente — pareciendo a los partidos de fuera de esta coalición, especialmente al pc.

4. LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, ¿UN PROCEDIMIENTO ADECUADO DE (RE)LEGITIMACIÓN CONSTITUCIONAL?

La discusión en torno al procedimiento se ha centrado en la supuesta falta de representatividad del Congreso Nacional para actuar como poder constituyente⁴³. Este argumento se sustentaba —hasta hace muy poco

tiempo— en la vigencia del sistema electoral binominal: una de las “trampas”⁴⁴ que, conforme a la teoría de Fernando Atria, anulaban el despliegue de la *agencia política del pueblo*⁴⁵. Sin embargo, la derogación del sistema binominal ha dado paso a la falta de legitimidad en cuanto tal de la clase política, sobre todo a partir de los casos de financiamiento irregular (o ilegal) de las campañas electorales, que el país está conociendo desde hace varios meses⁴⁶. El mismo Atria ha sido categórico en señalar que: “El Parlamento no tiene legitimidad suficiente para el proceso constituyente”⁴⁷.

Por eso, es que los partidarios de una AC insisten —de manera un tanto ambigua— en que este mecanismo supone una mayor participación de la ciudadanía. ¿Cómo hacen esto? Básicamente, señalando que, a diferencia del actual Congreso, la AC estaría mayoritariamente conformada por personas “comunes y corrientes” —por *ciudadanos*—, y no por políticos profesionales, a los que despectivamente califican de “incumbentes”.

Pero ¿qué garantiza que la AC estará integrada, más que por representantes de los partidos políticos, por dirigentes de organizaciones sociales? ¿Qué asegura que los segundos no terminen siendo controlados por los primeros? Hasta ahora, lo que se ha visto es que algunos sectores políticos y sociales — partidarios del mecanismo en discusión— han sido cooptados por el actual gobierno. La elección como diputado de Giorgio Jackson, miembro de Revolución Democrática (rd), con cupo protegido en el distrito de Santiago Centro, es una expresión de este fenómeno⁴⁸.

De esta manera, resulta al menos inverosímil que la clase política forme una mayoría que se autoexcluya de la elaboración de una constitución. Este punto lo ha hecho ver con meridiana claridad Jorge Correa Sutil al afirmar que:

[...] si la Asamblea Constituyente se quiere constituir conforme al derecho vigente, es condición necesaria que los parlamentarios de derecha elegidos popularmente decidan renunciar al derecho, del que actualmente disponen, a ejercer ellos mismos el poder constituyente y que lo deleguen enteramente en otro órgano electo: la asamblea, seguida de un plebiscito⁴⁹.

Pero más allá de la posibilidad real de una AC ciudadana, no puede

dejar de subrayarse el hecho —todavía poco puesto sobre la mesa— de que los partidarios de este procedimiento están pensando en una fórmula corporativista, tendiente a reemplazar (aunque sea solo para el proceso constituyente) la democracia representativa, basada en los partidos políticos y en el voto individual⁵⁰.

¿Qué es corporativismo? Una buena definición, por su carácter didáctico, la aporta Rodrigo Borja Cevallos, al sostener que se trata de la ficción que afirma que:

[...] la sociedad política no se divide en personas sino en grupos organizados de personas: en corporaciones, que cumplen funciones diferentes en el proceso de la producción con arreglo a la división social del trabajo. Luego son las corporaciones las que deben tener voz y no las personas⁵¹.

Como se sabe, una de las grandes conquistas históricas de las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX⁵² puede resumirse en esta triple consideración: a) los individuos son universos y no partes de una maquinaria mayor (la sociedad o el Estado); b) valen por ser quiénes son y no por el hecho de pertenecer —menos aún, por efecto de la cuna en que les tocó nacer— a determinados grupos u organizaciones sociales; y c) los derechos políticos son individuales y no colectivos⁵³.

Stanley Payne sostiene que si bien el corporativismo —como separación de las personas en grupos de interés— es más antiguo que el fascismo, no cabe duda de que con esta última ideología surge y se desarrolla, a diferencia de un sistema corporativista meramente social, uno de carácter político o estatal⁵⁴.

Pese a que no resulte plausible afirmar que los partidarios de la AC aspiran al establecimiento de un régimen corporativista —es decir, como un sistema político permanente—, sí basan la supuesta mayor legitimidad de aquella en un mecanismo de este carácter. De hecho, la mayoría de las propuestas que se han difundido sobre elección, composición y funcionamiento de una eventual AC ha tenido un carácter abiertamente corporativista. Una de ellas es la de Gabriel Salazar, quien plantea la organización de una Asamblea Constituyente “de abajo hacia arriba”, es decir, a partir de las asambleas populares locales, intercomunales y regionales, de la cual derive “una entidad federativa real y concreta

(aunque esta no esté todavía formalmente 'institucionalizada'), a lo que se agrega que:

[...]entonces y solo entonces, estaremos en condiciones de convocar a una Asamblea Nacional (Popular) Constituyente que podamos manejar por nosotros mismos. Con exclusión de las “clases” políticas civil y militar, y con la posibilidad de decidir con sabiduría qué y cuánto podemos conservar de la Constitución anterior, y qué acordar y establecer en la Constitución nueva para que exprese no solo nuestro “proyecto” o nuestra “voluntad”, sino lo que *ya hemos hecho* en lo local y en lo regional, donde ese proyecto y esa voluntad es, *ya*, una realidad⁵⁵.

Más adelante, descarta los mecanismos tradicionales, institucionales, por basarse en el voto individual, procedimiento que apunta “a elegir entre candidatos que 'autoproponen' su imagen o que los 'partidos' proponen”⁵⁶. Este rechazo tajante al voto individual, y en general a la democracia representativa, lo había expresado con anterioridad:

Es cierto que todos nuestros políticos y todos nuestros jurisconsultos, cuando nos hablan con (supuesta) sabiduría sobre el Estado, nos han recitado siempre la misma letanía: que los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), que las facultades del Presidente, que las facultades del Congreso Nacional, que los requisitos de la ciudadanía, de las elecciones sobre la base del voto individual, de los partidos políticos que representan los distintos ángulos de la opinión ciudadana, etc.⁵⁷.

La segunda propuesta, que ha sido promovida por la organización Marca ac, se basa en una asamblea integrada por 200 delegados, que no podrán ser candidatos a las elecciones que se lleven a cabo durante la realización del proceso constituyente, ni a las inmediatamente siguientes. En segundo término, los escaños elegidos por votación directa serán 110, es decir, un poco más de la mitad. Tercero, habrá 50 escaños sorteados, excluyendo a militantes de partidos políticos, además de candidatos a elecciones de representación popular. Cuarto, los escaños para congresales en ejercicio no podrán exceder de 20. Quinto, se reservan otros 20 escaños para indígenas⁵⁸. Y, sexto, se establece una cuota de género de un 40%. Sofía Correa no duda en afirmar que:

Es llamativo en las propuestas de Asamblea Constituyente la desconfianza y rechazo hacia la

democracia representativa y, por tanto, hacia sus instituciones nucleares como son el Congreso Nacional, espacio por excelencia para el acuerdo y la negociación política, y los partidos en cuanto canales de representación plural y articuladores de intereses divergentes. Tal es el caso evidente de la organización Marca AC, cuya propuesta hemos analizado⁵⁹.

Y concluye que:

[...]estamos ante un planteamiento corporativista, aunque de izquierdas. La representación corporativa con democracia directa y mandato imperativo en reemplazo de la representación a través de partidos políticos constituye un camino hacia el caudillismo autoritario, en la medida en que se excluye la negociación política, que es la que permite construir entendimientos mirando la totalidad social en una temporalidad más extensa que el presente inmediato⁶⁰.

A la luz de las propuestas descritas, queda bastante claro que los partidarios del mecanismo de AC tienen como telón de fondo un desprecio por la democracia representativa, expresada, sobre todo, en su rechazo a los partidos políticos y al voto individual. Si realmente fuera un mecanismo tan idóneo para hacer una constitución, ¿por qué no lo es para legislar? ¿Por qué, derechamente, no se propone como un sistema permanente?

Por otra parte, y entrando a responder la pregunta de este apartado, cabe sostener que —al menos, en los términos en que ha sido planteada— la AC lejos está de constituir un procedimiento adecuado para la deliberación de las elites políticas y, en consecuencia, para la generación de un consenso fundamental sobre las reglas del juego.

Desde la visión que se ha defendido en este trabajo, el lugar para la formación de este consenso es (y debe ser) el Congreso Nacional por la vía de representantes elegidos a partir del voto individual. Además, por el hecho de que, a diferencia de las organizaciones sociales —que persiguen fines particulares—, los partidos políticos canalizan de mucha mejor manera la voz de los ciudadanos a través de ideas de carácter global⁶¹.

Por lo demás, ¿qué garantiza que las elites políticas —que serán las que realmente jugarán en la *cancha* creada por la nueva constitución—, ratificarán *a posteriori* la supuesta legitimación constitucional hecha por la ciudadanía, con exclusión o con fuertes restricciones hacia las

primeras?

5. CONCLUSIONES

Lo anteriormente escrito puede resumirse en tres grandes conclusiones. La primera es que los sistemas políticos son legitimados de manera fundamental por las elites que integran el gobierno y la oposición, independiente de la mayor o menor participación del pueblo en los procesos constituyentes. Esto es lo que siempre ha ocurrido en la historia de Chile⁶². La segunda es que resulta bastante claro que la ex Concertación legitimó la Constitución de 1980 durante los 20 años en que estuvo en el poder, pero que hizo justamente lo contrario cuando lo perdió, de manos de la centroderecha. Y la tercera es que, si bien las propuestas de AC que se han planteado pueden resultar en apariencia atractivas, al rechazar el papel preeminente de las elites políticas en la construcción de un consenso fundamental sobre las reglas del juego, se convierte en una vía inadecuada de legitimación constitucional.

¿Cómo lograr la (re)legitimación del orden constitucional? Aceptando que el Congreso es el escenario adecuado para esta tarea por la vía de los consensos... fluye la necesidad de una nueva constitución. ¿Nueva en qué sentido? Básicamente, en términos simbólicos o “litúrgicos”: las elites políticas que conforman el gobierno y la oposición deben concordar en un documento que sea mutuamente aceptado como propio y no, en los términos de Jorge Correa Sutil, que se erija como “una carta de triunfo de una de las posiciones confrontadas por sobre otras”⁶³.

De acuerdo a la visión defendida en este trabajo, un segundo requisito es que la carta fundamental sea *mínima*. Esto quiere decir, ahora siguiendo a José Francisco García, que la “constitución no busca (ni debe) zanjar las controversias sociales fundamentales”⁶⁴, sino que debe apuntar a fijar las reglas del juego de carácter procedimental.

En cambio, cuando una constitución es *máxima* —cuando regula una gran cantidad de detalles, siendo efectivamente una carta de triunfo ideológica de un sector político en contra de otro—, tiende a restarle espacio a la deliberación política que se da en el Congreso. Esto, además, es muy importante para la estabilidad del sistema democrático: para prevenir futuras crisis institucionales, como la que en Chile culminó con

el golpe de Estado de 1973⁶⁵.

En este sentido, tiene razón Jorge Correa cuando dice que “mientras en el país no haya un consenso acerca del 'modelo', la Carta fundamental no debe abrazar ninguno”⁶⁶. Pero es a lo contrario a lo que tiende una constitución máxima. Básicamente, porque supone la ampliación del poder ejecutivo y —a partir de la consagración más extensa de los “derechos sociales”⁶⁷— del ámbito de acción del judicial. Todo esto afecta la deliberación y negociación políticas, que son esenciales para la estabilidad democrática.

Quizás sea el momento de volver la mirada al liberalismo clásico, que vio en el constitucionalismo un proceso de limitación del poder del Estado en favor de los individuos y de la cooperación social; y no de un gobierno que, al no ser capaz de cumplir todo lo que promete, se hace protagonista de constituciones verdaderamente tramposas⁶⁸. Y no pocas veces de manera dramática.

IX. POTESAD CONSTITUYENTE

Francisco Zúñiga

1. PROEMIO

El presente escrito pretende motivar un debate en la academia acerca del ejercicio del poder constituyente en el “nuevo ciclo”¹ que vive nuestro país, y que fue objeto de un debate en la Agrupación de Constitucionalistas Socialistas (ACS) desarrollado en el seno del Instituto Igualdad. Por ende, su contenido en nada compromete al actual gobierno o a los partidos que le dan soporte, y a las definiciones que este realice acerca de la operación constituyente.

El programa de gobierno y la voluntad política del gobierno de la presidenta Bachelet en este cuadrienio (2014-2018) es abrir o promover un proceso constituyente que otorgue a Chile una nueva carta fundamental, originada, discutida y promulgada en democracia, y mucho se ha dicho en el debate público sobre el procedimiento que seguirá el poder ejecutivo y la “coalición” gobernante para cumplir tal objetivo. Así, mientras unos han defendido la necesidad o conveniencia de ajustarse estrictamente al procedimiento de reforma previsto en el texto constitucional vigente, en el otro extremo, otros han llamado a invocar el poder constituyente originario para que el pueblo directamente se otorgue una nueva carta magna. Entremedio, diversas opciones intermedias también han estado presentes en el debate².

Este debate acerca de la forma o el “procedimiento” no escapa a los reduccionismos, maximalismos o afirmaciones realizadas desde un estilo hierático o posturas coriáceas. Al mismo tiempo, se observa cierta impaciencia frente a la actual procrastinación de la operación constituyente, fruto de, probablemente, definiciones de estrategia

política.

Con todo, si bien el gobierno aún no ha determinado la forma o procedimiento conforme al cual cumplirá su cometido, sí contamos con algunas definiciones muy elementales, en el sentido que tal procedimiento debe ser institucional, democrático y participativo. El programa de gobierno hecho público por la presidenta Bachelet durante la pasada campaña electoral expone estos lineamientos en los siguientes términos:

La Nueva Constitución Política deberá elaborarse en un proceso: i) democrático; ii) institucional, y iii) participativo.

Proceso Democrático: La Nueva Constitución debe generarse en un contexto en que se escuchen todos los puntos de vista, se hagan presentes todos los intereses legítimos y se respeten los derechos de todos los sectores.

Proceso Institucional: El logro de una Nueva Constitución exigirá de todas las autoridades instituidas una disposición a escuchar e interpretar la voluntad del pueblo. La Presidencia de la República y el Congreso Nacional deberán concordar criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios.

Proceso Participativo: La ciudadanía debe participar activamente en la discusión y aprobación de la Nueva Constitución. Para tal efecto, el proceso constituyente supone, de entrada, aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, precisamente, una deliberación que satisfaga esta condición.

Tales definiciones elementales no permiten, *ex ante*, definir el procedimiento o forma. Luego, a título puramente prospectivo, a continuación se revisarán algunas fórmulas hipotéticas conforme a las cuales se abre el proceso constituyente conducente a una nueva constitución.

2. LA NUEVA CONSTITUCIÓN EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA MICHELLE BACHELET JERIA

Como se anotó, el programa de gobierno ofrecido al electorado por el comando de la actual presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria contiene varias ideas que determinan el contenido y las características del procedimiento que se seguirá en el proceso constituyente que se pretende

impulsar. Así, se parte de la idea de que la actual Constitución, incluso con las múltiples modificaciones que ha sufrido:

[...] está sustentada en una desconfianza a la soberanía popular; de allí las diversas limitaciones a la voluntad popular mediante los mecanismos institucionales de contrapesos fuertes a dicha voluntad, siendo el ejemplo más evidente el mecanismo de los *quorum* contra mayoritarios para la aprobación y modificación de leyes importantes. Por ello, se continúa más adelante, Chile debe reencontrarse con sus tradiciones republicanas y dar origen a la Nueva Constitución, en la que confluyan las tradiciones liberal, democrática y social y que sea fruto de un auténtico consenso constitucional³.

La idea toral subyacente a la nueva Constitución es superar la vieja Constitución, estatuto del poder otorgado, autoritario en lo político y neoliberal en lo económico; con nula legitimidad democrática de origen, al estar fundada en un “fraude” plebiscitario y adicionalmente estar aquejada de una muy parcial e insatisfactoria legitimidad de ejercicio; lo que es determinado por el “falso consenso” que atraviesa el ciclo reformador que se inicia en 1989 con las 54 reformas promulgadas mediante la Ley n.º 18.825 y precedida de un plebiscito “semicompetitivo”.

Más adelante, el programa de gobierno agrega que la nueva Constitución:

[...] deberá sustentarse en nuestras mejores tradiciones democráticas; en el desarrollo doctrinal y experiencias de las democracias modernas del mundo occidental; y en el conjunto de derechos, principios y normas plasmados en el derecho internacional de derechos humanos.

Por ello, el programa da especial importancia a las características y contenidos mínimos que debiese tener su catálogo de derechos humanos reconocidos, sujetos a los “principios y convenciones internacionales” y propendiendo a su “progresividad, expansividad y óptima realización posible”; y luego, a los elementos que debiese tener el sistema político de un Chile que se constituya en un efectivo Estado social y democrático de derecho.

En consonancia con el deseo de contar con una constitución cuyo contenido cumpla con todas esas características y con la constatación de

que “el reclamo por una nueva Carta Fundamental no es un prurito de especialistas ni la obsesión de elites sobreideologizadas”, sino “un objetivo planteado desde larga data por sectores democráticos, y levantado actualmente por una gran cantidad de organizaciones políticas, sociales, juveniles, regionales, sindicales, de género y representativas de pueblos indígenas”, es que el programa opta por un proceso constituyente que sea “democrático, institucional y participativo”.

Si bien tales caracteres son muy brevemente desarrollados, sí aclaran cuestiones fundamentales. En cuanto democrático, en el proceso deben escucharse todos los puntos de vista, hacerse presentes todos los intereses legítimos y respetarse los derechos de todos los sectores. En cuanto participativo, debe buscarse que la ciudadanía participe activamente no solo mediante la aprobación del texto, sino también en su discusión, lo cual supone “aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, precisamente, una deliberación que satisfaga esta condición”.

De estas tres características, quizá la más polémica es aquella que opta por un proceso institucional. Para algunos, al parecer, ello implica la opción por parte de la presidenta de la República de apegarse estrictamente a las normas sobre reforma constitucional de las que dispone el texto vigente de la Carta magna. Sin embargo, si se atiende a lo señalado por el propio programa, se ve que la idea que se busca transmitir, si bien cercana, no es necesaria o exactamente esa. Al respecto, recordemos, dice:

El logro de una Nueva Constitución exigirá de todas las autoridades instituidas en una disposición a escuchar e interpretar la voluntad del pueblo. La Presidencia de la República y el Congreso Nacional deberán concordar criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios.

Como se ve, la intención es generar una nueva constitución que sea un acuerdo básico de convivencia democrático y legítimo de nuestra sociedad, en que todos sean escuchados: una constitución democrática debe ser una suerte de gran contrato social que nos reúna a todos y, en tal sentido, se opta no por un proceso unilateral en que se busque aplastar adversarios, sino abrir canales entre gobierno y Congreso Nacional para

que toda la ciudadanía (y no solo los partidos e intereses representados en el Parlamento) discuta y acuerde su carta fundamental. Por ello, no necesariamente se utilizará el mecanismo actualmente previsto en la actual Constitución; si este es insuficiente para permitir tal discusión amplia y participativa, deberán reformarse o crearse los procedimientos que la hagan posible.

El subyacente pacto político institucional a una nueva constitución, que le confiere un *plus* de legitimidad, debe asentarse en la superación de la lógica del “falso consenso”, tan propia del antiguo ciclo reformista (1989-2010), para enfrentarse a una “hoja en blanco” a fin de pensar, deliberar, escribir una nueva constitución desde un auténtico consenso y también desde el disenso. Y, al mismo tiempo, debe esquivar conscientemente la “trampa del consenso”, impuesta desde reglas procedimentales (*quorum* reforzados, ordinario y extraordinario) de reforma constitucional que habilitan el veto o bloqueo de una minoría calificada⁴. En este orden de ideas, se hace necesario superar la concepción defensiva o numantina de la Constitución vigente como soporte institucional de la paz y prosperidad del país en las últimas décadas, y como “seguro” de un cierto sector de la sociedad política frente a otro. Además, se hace necesario superar una idea anticuada de consenso revestida de actitudes melifluas, condescendientes, bajo la apariencia de “realismo” estratégico frente a la “sombra de la dictadura” proyectada en la permanencia de Pinochet en la escena política como comandante en jefe del Ejército de Chile durante parte de la transición o capturada ideológicamente por el “fin de la historia” (el capitalismo financiero global y su ideología) pregonada con fuerza a partir de 1989 (cuya versión más divulgada es el “consenso de Washington”), que conlleva un cierto “gatopardismo” en la práctica política (“política de los acuerdos”) y sus resultados⁵.

Incluso más, desde la ensoñación dogmática-constitucional de filiación ideológica (neo)conservadora y (neo)liberal, se llega a argumentar que todas las constituciones de Occidente son rígidas, y que la rigidez es una garantía normativa de la estabilidad de las normas iusfundamentales, dejándose de lado lo obvio, y es que tal hiperrigidez del capítulo xv de la Constitución es una herencia autoritaria, mejorada por la reforma constitucional de 1989, y no la decisión soberana del pueblo de una autolimitación procedimental del poder constituyente.

El actual juicio crítico a la “política de los acuerdos” o a la “democracia de los acuerdos”, tan propia del ciclo transicional, no se extiende a los acuerdos, dado que la construcción de consensos e identificación de disensos es propia de la política democrática, acoplada a los momentos de conflicto e integración; y necesaria como factor atemperador de todo el proceso político. Tales acuerdos suponen un grado no desdeñable de “amistad cívica” y republicanismos. Nuestra crítica es al tipo de acuerdos cuyo parto es resultado de la “trampa del consenso” y del “falso consenso”, tipos de acuerdos que imprimen su sello a las numerosas reformas constitucionales introducidas a la Constitución de 1980 y que terminan reduciendo a un mínimo la “legitimidad de ejercicio” del estatuto del poder.

Asimismo, si entendemos la democracia en términos básicamente procedimentales (como lo hacen Kelsen o Bobbio), “la política de los acuerdos” (el compromiso tan propio de la política democrática) concierne a las reglas preliminares y reglas del juego del sistema político democrático, que dan soporte a las instituciones contramayoritarias, y no a las reglas de estrategia, o a la ejecución de programas de gobierno, o a la ejecución de políticas públicas en que quedan impresas las señas de identidad ideológico-programática de partidos o coaliciones gubernamentales y define el rol de la oposición, en el marco de los controles y responsabilidades tan propios de un Estado de derecho⁶. De lo contrario el “mayoritarismo”, como argumento en contra de la “democracia de los acuerdos” o de la “política de los acuerdos”, carece de solidez o es aporético.

3. UNA PROPUESTA DE REFORMA TOTAL A LA CONSTITUCIÓN

Recapitulando en el tema que abre fuegos: el poder constituyente y sus modalidades de ejercicio, el programa de gobierno nos otorga ciertas luces sobre las características que debería tener el procedimiento que desemboque en una nueva Constitución. Sin embargo, son lineamientos que por sí solos no son suficientes. Por ello, esbozamos a continuación una posible vía que cumple cabalmente con los principios fijados por el programa. Esta consiste, por una parte, en la formación de una comisión de expertos que permita avanzar, escuchando a todos los sectores, en los contenidos de la nueva Carta, y, por la otra, en la aprobación de las

reformas más inmediatas que permitan realizar un verdadero proceso deliberativo y democrático, a la vez, de forma institucional.

3.1 Formación de una Comisión de Reformas Constitucionales

El primer paso consistiría en que la presidenta de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma y mediante decreto presidencial, anunciara la conformación de una comisión de expertos pluridisciplinaria, formada por personas provenientes de todas las culturas políticas e ideologías, que se avoque al estudio de las reformas constitucionales que el gobierno anunciaría a fines de este mismo año.

3.2 La reforma “corta” a la Constitución

Aparte, se trabajaría paralelamente en dos líneas de trabajo complementarias: una reforma constitucional “corta” y otra “larga”. La reforma corta buscaría resolver el déficit de legitimidad democrática que tiene la actual Constitución, que bloquea cualquier intento de reforma constitucional a través de la exigencia de mayorías calificadas e impone así la lógica del “falso consenso” constitucional.

Para la reforma “corta” se debería ingresar al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional que enmiende el capítulo xv, intitulado “Reforma de la Constitución”, por el que se introducirían las siguientes enmiendas parciales:

- El inciso 2° del artículo 127, que establece los *quorum* de $\frac{3}{5}$ y $\frac{2}{3}$ se cambia, instituyéndose un único *quorum* reforzado de aprobación del proyecto de reforma constitucional de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. Además, se propone relevar el mecanismo de audiencias públicas en el *iter* de reforma, para asegurar participación de los movimientos sociales, *think tanks*, universidades, pueblos indígenas, regiones, entre otros.
- Un nuevo artículo 130, que establezca que el proyecto de reforma total de la Constitución, despachado por las cámaras en cualquiera de sus trámites constitucionales (segundo, tercero o posteriores, si se ejerciera el veto presidencial), deberá ser sometido a referéndum

antes de su promulgación, referéndum que deberá verificarse dentro del término de 30 días contados desde que se produzca la sanción del proyecto de reforma constitucional.

Como se ve, la reforma corta produce un “emparejamiento de la cancha”, es decir, del proceso deliberativo y decisorio en torno a la reforma, favoreciendo así un auténtico consenso constitucional y no imponiendo una lógica de vetos o bloqueos. Ya que la intención sería que el proyecto de reforma total se someta a estas nuevas reglas, el proyecto corto debe ser tramitado con suma urgencia. Así, quienes hoy disponen del poder de veto o bloqueo deberán decidir de antemano si conservan o no ese poder o si se abren a la forja de un auténtico consenso constitucional.

3.3 La reforma total de la vieja Constitución

Concluida —o, al menos, muy avanzada— la tramitación del proyecto de reforma corta, el proyecto de nueva Constitución debería ingresarse al Congreso Nacional, donde se debe abordar la totalidad de los contenidos de la Carta vigente. La reforma total no significa hacer *tabula rasa* de la Constitución actual, sino una revisión o enmienda de la totalidad de su preceptiva, razón por la cual no importa, necesariamente, la supresión o sustitución de la totalidad de ella.

La reforma total a la Constitución significa, técnicamente, que esta no reconoce límites materiales o temporales, es decir, cualquiera de sus disposiciones puede ser enmendada. Al mismo tiempo, la reforma total designa un concepto cualitativo, una suerte de cambio en el “ADN” de la vieja Constitución. Por ello, una nueva carta fundamental, fruto de la reforma total, incorporaría nuevos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, derechos individuales y colectivos; y un nuevo arreglo institucional en materia de régimen político, autonomías constitucionales y descentralización del poder político territorial. Pero, además, se haría cargo de los cerrojos o bloqueos de la vieja Constitución, a saber: los *quorum* de reforma, el sistema electoral público, los *quorum* de leyes de supramayoría y la competencia preventiva del Tribunal Constitucional.

El proyecto de reforma total de la vieja Constitución debería ingresar

con urgencia simple y con una declaración de la presidenta de la República con el fin de valorar la eventual formación de una comisión bicameral que, con un plazo definido, se avoque al estudio y acuerdo en torno a este proyecto.

La reforma total de la vieja Constitución, como procedimiento genético propio del poder constituyente derivado de la nueva Constitución, dispondrá de un plusvalor de legitimidad democrática, dado por el mecanismo de audiencias públicas y de un directo recurso a la soberanía del pueblo mediante el Referéndum Constituyente. Este Referéndum Constituyente debería verificarse dentro de los 30 días siguientes al despacho de la reforma total por las Cámaras del Congreso Nacional y la sanción de su texto por la presidenta de la República.

4. OTRA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO: PLEBISCITO CONSTITUCIONAL

Prospectivamente, debemos hacernos cargo de otra propuesta de reforma constitucional de interés anclada en la figura *iuris* del *plebiscito constitucional*. La cual, a su vez, se ajusta —a nuestro juicio— a la triada definitoria del procedimiento conducente a una nueva Constitución, a saber: democrática, institucional y participativa. Esta propuesta, que no compartimos, se asemeja en algunos aspectos a la formulada por Atria en diversos trabajos, y posee dos defectos notorios: su excesiva legitimación plebiscitaria —lo que deja con poco campo a la democracia deliberativa— y lo forzado o artificioso que aparece su incrustación en el subsistema de normas iusfundamentales de la Constitución vigente. El plebiscito constitucional es una opción de trabajo que no aborda derechamente la apertura de las reglas “de la competencia de la competencia”, presentes en el capítulo xv de la Constitución vigente, para zafar del “metacerrojo” del *quorum* reforzado extraordinario. Pero, como se señaló más arriba, dentro de los límites fijados por el programa del gobierno caben diversas formas de abordar el proceso constituyente, a través de procedimientos también institucionales.

Así, por ejemplo, en la hipótesis del “plebiscito constitucional”, se ha propuesto reformar la Constitución actual para llamar al pueblo a que se pronuncie directamente sobre su intención de darse a sí mismo una nueva Carta magna.

Como se sabe, el artículo 15 actual reza de la siguiente manera:

En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario.

Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución.

Para dar cabida a un proceso democrático, institucional y participativo, una opción es una reforma constitucional mediante la adición de un inciso tercero del siguiente tenor:

Durante la primera mitad de su período, el presidente de la República podrá convocar a plebiscito nacional con el fin de que la ciudadanía se pronuncie sobre elementos esenciales de las políticas públicas que contemple su programa de gobierno. Asimismo, dicha consulta plebiscitaria podrá versar sobre la introducción de reformas integrales o parciales a la presente Constitución y su resultado será vinculante para los órganos del Estado concernidos en su implementación.

Al mismo tiempo, habría que adecuar el numeral 4° del artículo 32 vigente (el que faculta al presidente de la República a llamar a la ciudadanía a plebiscito en los casos del artículo 128), añadiendo allí la referencia al nuevo inciso tercero del artículo 15. Complementariamente, podría añadirse una nueva disposición transitoria a la Constitución, en cuya virtud se faculte a la presidenta de la República para que, en ejercicio de la atribución conferida en el nuevo inciso tercero del artículo 15, convoque a un plebiscito nacional a más tardar el 11 de marzo de 2016 para obtener un pronunciamiento de la ciudadanía acerca de la forma, modalidades y alcances de un proceso de reforma integral a la actual Carta magna, entre las cuales se podría contemplar la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Con todo, es una opción de apertura del proceso constituyente, que recurre a la reforma constitucional para instituir un procedimiento democrático, institucional y participativo, opción que, no obstante, no compartimos por no abordar la modificación sistemática de las reglas acerca “de la competencia de la competencia”.

5. LA NUEVA CONSTITUCIÓN MEDIANTE EL RECURSO AL PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO

Como ya se ha insistido bastante, los caminos posibles para el proceso constituyente deben cumplir con los estándares ya fijados, es decir, ser institucionales, participativos y democráticos. En tal contexto, sea que el gobierno opte por el camino de la reforma corta y la reforma total del texto constitucional, por el de la reforma del artículo 15 recién descrita o por otra propuesta al Congreso Nacional, estará definiendo una prioridad política y dándole al Parlamento la oportunidad de ejercer el poder constituyente derivado que este posee. Esta prioridad es del todo justificable, desde el momento en que la presidenta de la República no puede negar *ab initio* que el Congreso Nacional es titular de la potestad constituyente derivada y, por tanto, cuenta con la legitimidad para reformar la Constitución.

Sin embargo, podría ocurrir que la propuesta de reforma constitucional presentada a la consideración del Congreso Nacional sea rechazada de plano por la oposición, condenando un proyecto de reforma total a la lógica del falso consenso constitucional y de los bloqueos o vetos. En este segundo escenario, el gobierno debería abrirse a una operación constituyente que permita un proceso constituyente primigenio mediante el recurso al poder constituyente originario del pueblo, a través de técnicas como la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente y/o el Referéndum Constituyente. En esta operación constituyente se abren escenarios que comprenden transiciones sustentadas con posibilidades como un derecho constitucional de transición, un vínculo con el pasado o un hecho revolucionario. Como bien lo destaca Vergottini cuando, mientras analiza transiciones, afirma:

El tránsito de una forma de Estado a otra, y por lo tanto la introducción de una nueva Constitución precedida por decisiones constitucionales con valor provisional, puede implicar un hecho revolucionario que ponga fin al ordenamiento constitucional, o la subversión del antiguo orden por obra de una determinación formal de un órgano del ordenamiento mismo, o, por último, la determinación consensual tanto de órganos del ordenamiento preexistente como de los órganos instituidos en la fase de transición. En todos los casos, la naturaleza constituyente del evento debe identificarse en la afirmación de una concepción del derecho y del Estado inconciliable con la anteriormente vigente, que conduce a la introducción de un nuevo fundamento de validez del ordenamiento positivo⁷.

En este caso o hipótesis de ejercicio de poder constituyente

originario, la institucionalidad del procedimiento se construye *in fieri* y en base a una norma hipotética fundamental⁸, distinta a la *Grundnorm* del orden constitucional que fenece y a la Constitución jurídico-positiva basal del sistema de normas, desatando la competencia de la competencia⁹.

Desde el poder constituyente originario como matriz de un nuevo orden, más allá del debate en torno a la exquisitez dogmática de la autorreferencia¹⁰ o del derecho constitucional de transición, lo cierto es que la validez-legitimidad construida en el proceso histórico-temporal de ejercicio de este poder, no permite calificar las decisiones de los órganos estatales intervinientes de inconstitucionales por estar situados fuera de “la competencia de la competencia” disciplinada por el sistema de normas. Es simplemente una sucesión de fuentes soportantes de la validez de sistemas de normas. Las posibilidades reales de ese poder constituyente y la eventual existencia de un nexo o ligazón de órdenes constitucionales, estará determinado finalmente por la facticidad; es decir, por la tosca materia: la política y sus factores reales.

Con todo, resulta inocultable que, a pesar de la condicionante fáctica (política) del ejercicio del poder constituyente originario democrático, sus posibilidades de legitimidad democrática real son poderosas y para nada, al menos necesariamente, resultado de una “democracia plebiscitaria”¹¹.

6. CONCLUSIONES

En primer lugar y como se vio, el procedimiento genético de la nueva Constitución debe ser institucional, democrático y participativo, sea tal Carta fruto del poder constituyente derivado (vía reforma total de la vieja Constitución o plebiscito constitucional) o del poder constituyente originario (Congreso Constituyente, Asamblea Constituyente y Referéndum Constituyente).

Con todo, si es fruto del poder constituyente derivado, puede incorporar el Referéndum Constituyente como mecanismo doble: tanto para resolver los conflictos de bloqueo entre los órganos que ejercen la potestad constituyente (la presidenta de la República, el Congreso Nacional y sus cámaras) en cualquier etapa del *iter* procedimental, como para obtener la ratificación del obrar constituyente de los poderes

instituidos por la soberanía del pueblo, antes de la ley promulgatoria de la reforma constitucional.

También se hace necesario incorporar al alumbramiento de la nueva Constitución mecanismos eficientes de estudio, deliberación y acuerdo en el interior del Congreso Nacional, como *verbi gratia* la comisión bicameral, y de participación y consulta de la ciudadanía y de los movimientos sociales, a través de audiencias públicas. Todos son mecanismos de resorte reglamentario interno, pero muy valiosos. Adicionalmente, el ejercicio del poder constituyente debe zafarse de *quorum* reforzados ordinarios ($\frac{3}{5}$ de parlamentarios en ejercicio) y extraordinarios ($\frac{2}{3}$ de parlamentarios en ejercicio). Los que operan formalmente como una garantía normativa de hiperrigidez de la actual Carta, pero que en la realidad son una herramienta para el bloqueo decisonal y los vetos de contenido en la reforma constitucional. En suma, son el entramado conformador de la “trampa del consenso”. Por ello, resulta razonable restituir el *quorum* reforzado de la Constitución de 1925, de mayoría absoluta de parlamentarios en ejercicio.

De esta última manera, la nueva Constitución superaría el déficit de legitimidad democrática de la vieja Constitución, pero además superaría el déficit democrático del poder constituyente derivado de la vieja Constitución. Ello significa que no solo la nueva Constitución debe tener un procedimiento de reforma institucional, democrático y participativo, sino que además, idealmente debe tenerlo también la Constitución vigente concernida en la reforma total, lo que puede lograrse modificando *in fieri* el actual Capítulo xv.

En segundo lugar, la nueva Constitución, sea fruto del poder constituyente derivado o del poder constituyente originario, debe estar soportada sobre un gran acuerdo nacional acerca de sus “bases”, un acuerdo que debe reflejar en la mayor medida de lo posible el pluralismo político e ideológico de la sociedad. La idea de acuerdo o pacto nacional de tipo político-constitucional subyacente a la nueva Constitución le conferiría un plus de legitimidad y estabilidad normativa real. Primordialmente, tal acuerdo nacional debe ser gestado en el Congreso Nacional, si se opta por la reforma total de la vieja Constitución. En caso contrario, tal acuerdo debe ser gestado al interior del Congreso Constituyente o de la Asamblea Constituyente. En ambos casos (poder constituyente derivado o poder constituyente originario), la sociedad civil

y sus movimientos sociales deben participar y ser escuchados en la usina de la nueva Constitución y expresarse como cuerpo electoral o ciudadanía a través de un Referéndum Constituyente.

En la construcción de la legitimidad democrática real de una nueva Constitución, como hemos dicho, se hace necesario superar la lógica de la imposición o la fuerza desnuda presente en la vieja Carta y también, en cierta medida, en otras constituciones históricas de nuestro país. La idea de pacto o acuerdo nacional de tipo político-constitucional (plural, deliberativo, transparente) está al servicio de esa legitimidad democrática tan necesaria para un efectivo “patriotismo constitucional”¹².

Este pacto nacional sustantivo, y formalmente distinto a los anteriores, supera la “trampa del consenso” y el “falso consenso”, teniendo como punto de partida la “hoja en blanco”, que como hemos sostenido no es *tabula rasa* o partir de cero, sino hacer política democrática sin camisas de fuerza. La lógica de la *tabula rasa*, o partir de cero pretende ir más allá de una operación constituyente enderezada al alumbramiento de una nueva Constitución, como si se tratase de reescribir la historia institucional de nuestro país o si se atribuyese al proceso constituyente/ acto constituyente una virtualidad catártica y liberadora.

El porvenir del “momento constitucional” que atraviesa nuestro país, momento débil o fuerte, y las posibilidades concretas de la operación constituyente, de tener éxito en nuestro proceso político, tendrán su palabra a través del tiempo, dependiendo, finalmente, de la política o de la facticidad¹³.

X. PROCESO CONSTITUYENTE ORIGINARIO¹

Renato Cristi

UN ARTÍCULO de prensa, publicado en *El Mercurio* el 21 de septiembre de 2005, reporta que, luego de la promulgación de las reformas constitucionales de ese año, un número de juristas se reunió para debatir la decisión del Ejecutivo de identificar la Constitución vigente en Chile como “Constitución de 2005”. El entonces senador Andrés Chadwick, participante en ese debate, afirmó lo siguiente: “Por muy importante que hayan sido las reformas, que hemos compartido y consensuado, sigue siendo la Constitución de 1980. Se mantienen sus instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz. Para que haya una nueva Constitución se requiere de un proceso constituyente originario, no de un proceso de reformas”². El mismo artículo de prensa consigna que el Decreto Supremo de 17 de septiembre de 2005, que fija el texto refundido de la Constitución, se refiere a ella como “Constitución de 1980”.

En su reciente libro, *La Constitución tramposa*, Fernando Atria encuentra en la opinión expresada por Chadwick un argumento en favor de la necesidad de una Asamblea Constituyente originaria que promulgue una nueva constitución para Chile. Atria piensa que quienes se oponen a la idea de una Asamblea Constituyente originaria lo hacen porque estiman que las reformas constitucionales que promulgó el expresidente Lagos dieron origen a una nueva constitución, la Constitución de 2005. Atria, por el contrario, cree que eso es un error y se muestra en perfecto acuerdo con Chadwick cuando este afirma que esas reformas no pueden ser consideradas un “proceso constituyente originario”³. Para entender exactamente qué quiere decir Chadwick con la idea de “proceso constituyente originario” es conveniente tomar en cuenta lo que sostuvo 25 años antes, el 24 de agosto de 1980, en una inserción que un número de profesores universitarios publicaron en *El Mercurio* y que incluía su

firma. Esta inserción, titulada “Declaración de Profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile respecto de la Convocatoria a Plebiscito para Ratificar la Constitución”⁴, tiene por objeto definir el sentido de la decisión del gobierno militar de convocar a un plebiscito con ocasión del otorgamiento de la Constitución de 1980⁵.

Cuando Chadwick habla de un “proceso constituyente originario” reconoce, al hacerlo, que el poder constituyente originario ha entrado en actividad o en ejercicio. Ahora bien, la “Declaración” define esta noción de la siguiente manera: “En virtud del Poder constituyente originario [...] la comunidad se da por primera vez un ordenamiento jurídico, o bien lo vuelve a crear con independencia del anterior en forma revolucionaria”⁶. La “Declaración” define, a continuación, al sujeto titular del poder constituyente: “Si la revolución es legítima, el Poder constituyente originario para el establecimiento de la nueva institucionalidad reside en quienes encabezan la revolución. La revolución tiene un *efecto destructivo* de la institucionalidad vigente”⁷. Estas definiciones rigen para el caso chileno porque “se ha demostrado que la revolución del 11 de septiembre de 1973 fue legítima por haberse cumplido todos los requisitos del derecho de rebelión”⁸. Una vez que se destruye la Constitución de 1925, corresponde a un nuevo sujeto del poder constituyente originario *crear* una nueva. Y, para proceder con ello, su poder es ilimitado:

[...] el Poder Constituyente originario no reconoce limitación formal alguna en su ejercicio, ya que el ordenamiento jurídico positivo fundamental será precisamente el resultado de dicho ejercicio, sin que preexista otro alguno vigente al cual deba sujeción. Es por ello que, por su naturaleza, todo lo concerniente al Poder Constituyente originario no pertenece propiamente al mundo jurídico⁹.

La “Declaración” presupone que una constitución, definida como el “ordenamiento jurídico positivo fundamental”¹⁰, reposa sobre algo aún más fundamental, a saber, la decisión del poder constituyente originario. En Chile, en 1973, la Constitución de 1925 fue destruida revolucionariamente por la Junta Militar al reemplazar al pueblo como titular del poder constituyente originario¹¹. Por esta razón, la Junta Militar quedó facultada para otorgar una constitución escrita, una

facultad que pudo decidir ejercer o no ejercer. En eso residía su ilimitación formal, como lo percibe claramente la “Declaración”: “El ejercicio del Poder Constituyente originario, como quiera que no está subordinado a una institucionalidad anterior, no reconoce en lo formal límite alguno”¹². Este reconocimiento de la ausencia de toda limitación material y formal del poder asumido por la Junta Militar implicaba redefinir el valor del plebiscito que se convocó en 1980. No se trata de un plebiscito democrático en el que se exprese la voluntad del pueblo —el pueblo ha sido despojado revolucionariamente de su poder constituyente originario—, sino de una simple consulta popular cuyo valor lo va determinar, en última instancia, el nuevo sujeto del poder constituyente originario, es decir, la Junta Militar.

Restarle valor democrático al plebiscito es precisamente la conclusión a la que lógicamente arriban Guzmán y los demás firmantes de la “Declaración”. Una vez que la Junta decide ejercer su poder constituyente originario, el convocar una consulta plebiscitaria es también materia sujeta a su discreción. Esa consulta tendrá la validez que el poder constituyente originario quiera otorgarle. Es correcta, por tanto, la conclusión de la “Declaración” sobre la premisa de la ilimitación formal:

En consecuencia, bien pudo la Honorable Junta de Gobierno, en cuanto titular del Poder Constituyente originario, haberse limitado en su ejercicio a los estudios efectuados por la Comisión Constituyente, el Consejo de Estado y ella misma y haber dictado y puesto en vigencia la nueva Constitución sin más trámite. Luego, mal puede restarse validez a la convocatoria a plebiscito que por razón de prudencia y no de necesidad jurídica se ha estimado del caso llevar a cabo, cuando pudo haberse prescindido de este trámite¹³.

La “Declaración” también afirma que un resultado negativo en el plebiscito de 1980 no tiene efecto jurídico alguno. El poder constituyente originario de la Junta no se hubiera extinguido ni cambiado de titular en el caso de que el pueblo se hubiera pronunciado negativamente. Decir, por lo tanto, que se trató de un plebiscito fraudulento no tiene sentido. Lo que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1980 fue una mera consulta popular sin efectos vinculantes. Esto es lo que pensó Andrés Chadwick en agosto de ese año.

El mismo Chadwick reitera, 25 años más tarde, lo que afirmó en

1980 junto a sus colegas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sigue todavía pensando que la Constitución vigente en 2005 es la Constitución del 1980. Se mantienen, afirma, “sus instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz”¹⁴. Esa matriz no es otra que el poder constituyente originario de la Junta Militar. Por esa misma razón, el proceso de reformas que ha tenido lugar en Chile a partir de 1989, y que ha culminado en el 2005, no ha significado la génesis de una nueva constitución. Para ello, hubiera sido necesario un “proceso constituyente originario”, y ello no ha sucedido. Para que tal proceso pueda desarrollarse es necesario activar un nuevo sujeto del poder constituyente originario, pero en Chile sigue vigente el poder constituyente originario de la Junta Militar. Cuando Chadwick dice que la Constitución de 1980 todavía existe, y que no se puede considerar la reforma de 2005 como “un proceso constituyente originario”, reitera con ello que esa Constitución está todavía animada por la misma matriz que la generó en 1980, esta es, el poder constituyente originario de la Junta Militar. Esta es la trampa que arma Chadwick, y que logra atrapar al argumento fundamental de Atria en *La Constitución tramposa* sin que este último se percate.

Al igual que Chadwick y los demás firmantes de la “Declaración” emanada de los profesores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Atria acepta como válida la idea de que es necesario un proceso constituyente originario para dejar atrás la Constitución de 1980 y que, por tanto, la actual sigue estando presa del poder constituyente de Pinochet y la Junta Militar. Las muchas reformas que se le han hecho han supuesto la continuidad de ese poder constituyente. Esa es la trampa que monta Chadwick. Y Atria, preso en ella, se ve forzado a afirmar lo siguiente:

Es necesario, volviendo a la correcta afirmación de Andrés Chadwick en 2005, “un proceso constituyente originario”, es decir, un proceso de decisión constitucional que no esté determinado por las trampas de 1980¹⁵.

Veamos ahora lo que significa haber caído en la trampa. Atria acepta la idea de Chadwick y los firmantes de la “Declaración” de la ausencia de toda limitación formal y substancial por parte del poder constituyente

originario. Aún más, al reconocer que no se trata de un poder normativo, acepta lo que esa “Declaración” considera ser su ilimitación. Escribe Atria: “el Poder constituyente no es un poder normativo conferido por una norma anterior”¹⁶. Se trata de una “decisión” sobre la identidad y forma política que está “radicalmente desvinculada a toda regla o procedimiento, porque de otro modo estaría reconociendo normatividades anteriores y eso sería contradictorio”¹⁷. Atria, sin embargo, piensa que se puede liberar de esa trampa cuando, apartándose de lo que establece la “Declaración”, reconoce que “solo el pueblo tiene Poder constituyente, solo el que tiene Poder constituyente es pueblo, solo una decisión del pueblo es constitución”¹⁸. Por ello, la forma constitucional debe “habilitar al pueblo para actuar”¹⁹. Si no lo hace, si lo que busca la forma constitucional es inhabilitar al pueblo, “la dictación de un texto constitucional no necesariamente es la dictación de una constitución”²⁰. De ahí que Atria pueda arribar a la siguiente conclusión:

A mi juicio [...] la llamada Constitución de 1980 no es una constitución, es una camisa de fuerza [...]. No es una decisión que pueda ser entendida por el pueblo como propia, en lo que respecta a su forma y modo de existencia, sino que es una maraña de dispositivos cuya finalidad más precisa es negar el Poder constituyente del pueblo²¹.

Esta conclusión es, a su vez, la premisa que Atria emplea para derivar la necesidad de una Asamblea Constituyente. Como Atria apela a la noción *poder constituyente* está claro que la asamblea que tiene en mente ejerce el poder constituyente originario, es decir, es una asamblea que, en la expresión del expresidente Lagos, “parte de cero” y se escribe en una “hoja en blanco”²². Según Atria, una Asamblea Constituyente originaria es necesaria porque la Constitución de 1980 no es propiamente una constitución y, por ello, no procede su mera reforma, sino la creación de una nueva. Esto no significa que Atria se sume a quienes erradamente consideran que se trata de una Constitución que no tiene legitimidad alguna por ser producto de un plebiscito fraudulento²³. Lo que hace Atria es simplemente negar que estemos aquí frente a una constitución real, sea esta considerada legítima o ilegítima. Para Atria, la llamada “Constitución del 80” no sería más que “un conjunto de leyes constitucionales”, y ello porque “no constituye al pueblo sino lo niega, al

hacerlo incapaz de actuar”²⁴.

Atria, al reconocer y aceptar la noción *poder constituyente originario*, también reconoce y acepta implícitamente la noción *poder constituyente derivado*. Esta última noción denota la facultad, no de crear, sino de reformar una constitución. Por ello, opera al interior de la constitución misma, y corresponde a lo que Sieyes llama “*pouvoir constitué*”, es decir, el poder constituyente constituido. Se diferencia del poder constituyente originario que, como reconoce Atria, es un factor político extraconstitucional. Resulta, por tanto, ambigua la afirmación de Atria cuando señala que la Constitución de 1980 es “una maraña de dispositivos cuya finalidad más precisa es negar el Poder constituyente del pueblo”²⁵. Ambigua porque no especifica que aquello que neutraliza o niega la Constitución de 1980 es el poder constituyente derivado, y no el poder constituyente originario. Esta ambigüedad le permite descalificar, al igual que Chadwick, a quienes consideran que, a partir los plebiscitos de 1988 y 1989, el pueblo ha recuperado el poder constituyente originario que le fuera despojado el 11 de septiembre de 1973. Esa recuperación se logró como resultado de una vasta movilización popular, la cual implicó grandes sacrificios y muestras de indudable heroísmo. Me parece que negarle esa conquista al pueblo constituye una negación de la realidad y una grave injusticia.

Pero Atria va más allá aún. Quienes piensan que, en la actualidad, el pueblo es el sujeto del poder constituyente originario y creen en la necesidad de apropiarse de la Constitución de 1980 para introducirle reformas, sufren, según Atria, de una ilusión, de un autoengaño, porque no hay ahí nada en realidad, nada real de lo que uno pudiera “apropriarse”. Acusa así de “mala conciencia”, de sufrir del síndrome del “tío Tom”, de estar “enamorado de sus propias cadenas”, a quienes creen que en los plebiscitos de 1988 y 1989 el pueblo retomó su poder constituyente originario²⁶. Para ilustrar esa mala conciencia, Atria cita mi argumento en una nota de su libro²⁷, pero lo hace en forma incompleta. Una cita más completa la encontramos en su artículo “Sobre la soberanía y lo político”²⁸, que además incluye un inteligente y detallado comentario crítico sobre el análisis que desarrollo acerca de la noción de poder constituyente en *El pensamiento político de Jaime Guzmán*²⁹.

En definitiva, Atria cuestiona en su artículo la siguiente afirmación

que se encuentra en ese libro:

Si bien es cierto que este plebiscito [de 1989], y el sentido de las reformas que introduce, confirma que el Poder constituyente ha sido retomado por el pueblo, esa toma de posesión es parcial. Persisten en el texto constitucional aprobado ciertas instituciones que no permiten la plena expresión del nuevo sujeto de Poder constituyente³⁰.

A continuación de esta cita trunca, Atria comenta:

Al decir que la recuperación por el pueblo del Poder constituyente es “parcial”, Cristi parece sostener que el Poder constituyente estaría dividido. Algunas de las “leyes constitucionales” de la llamada Constitución de 1980 descansarían sobre el Poder constituyente de la Constitución de 1973, y otras sobre el Poder constituyente de la Constitución de 1989³¹.

Esto estaría en contradicción, según Atria, con lo que habría señalado en *Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism*³². En ese libro, doy cuenta de la osada temeridad (*reckless temerity*) de Schmitt, quien llegaría a ser el *Kronjurist* del régimen nazi, al afirmar que, por medio de la *Ermächtigungsgesetz* del 24 de marzo de 1933, el Reichstag le habría otorgado a Hitler una “porción” del poder de dictar leyes constitucionales³³. Osada temeridad porque Schmitt sabía perfectamente que el poder constituyente originario es indivisible, y lo que estaba haciendo era, en realidad, otorgarle el poder constituyente en su totalidad a Hitler, tal como Guzmán lo otorga en su totalidad a Pinochet y la Junta Militar. En su artículo, Atria se pregunta: “Pero si el Poder constituyente [...] no puede ser dividido, ¿cuál puede ser el significado de la afirmación de que en 1989 el pueblo accedió a ‘una porción’ del Poder constituyente?”³⁴.

En respuesta a la pregunta de Atria, debo decir que cuando afirmé que la recuperación por parte del pueblo del poder constituyente originario en 1989 fue “parcial”, en ningún caso sostuve que el poder constituyente hubiera quedado dividido en “porciones” entre el pueblo y la Junta Militar. Lo que he sostenido es que ese año, el pueblo de Chile recuperó *totalmente* su poder constituyente originario, pero tuvo también que aceptar, por las circunstancias del caso, un ejercicio parcial de su poder constituyente derivado. Entre esas circunstancias, la

principal fue el atentado frustrado de 1986 que, por la incompetencia de sus autores tanto intelectuales como materiales, fortaleció enormemente el poder político del dictador y debilitó a su adversario principal, la Concertación de Partidos por la Democracia. Ese fortalecimiento hizo creer a Pinochet que podía convocar a un plebiscito y ganarlo fácilmente. Pero su derrota política de 1988 condujo a la disolución definitiva de la Junta Militar en 1990. Mal podría decirse, entonces, que una porción del poder constituyente originario residió, a partir de entonces, en una Junta Militar que había dejado de existir efectivamente a partir del 10 de marzo de 1990³⁵. Hay que reconocer, sin embargo, que, a pesar de haber derrotado a Pinochet en las urnas, los negociadores de la Concertación actuaron con exagerada pusilanimidad frente a la Junta Militar. También es necesario admitir que uno de sus principales negociadores, Edgardo Boeninger, demostró tener una marcada preferencia por el modelo económico impuesto por la Junta, y, junto con los otros negociadores de la Concertación, pensó que el exceso de autoridad presidencial no era un defecto del sistema, sino una necesidad para reinstalar la democracia en Chile.

Para los efectos de este argumento es necesario considerar otro aspecto del pensamiento constitucional de Atria, a saber, su negación de que Pinochet y la Junta Militar hayan sido sujetos de poder constituyente originario. En su opinión, el único sujeto legítimo de poder constituyente originario es el pueblo. Pero esto constituye un error histórico, hecho que Carl Schmitt trae a la luz en su obra³⁶. Los casos que Schmitt considera tienen en vista, como punto de partida, la Constitución francesa de 1814, otorgada por Luis xviii, quien expresamente se constituye como sujeto del poder constituyente originario. Queda así establecido, a partir de ese momento, el principio constitucional que se denominó “principio monárquico”³⁷. Este mismo principio que coloca al jefe de gobierno fuera de, y por sobre, la esfera constitucional, definió al káiser en la Constitución prusiana de 1871. En la misma situación quedó Hitler en 1933, cuando destruye la Constitución de Weimar, y Franco en 1938, cuando destruye la Constitución española de 1931³⁸.

De estas consideraciones, Atria deriva su idea de que la Constitución de 1980 no es realmente una constitución porque su sujeto constituyente originario no es el pueblo. Debido a que no es concebible otro sujeto constituyente originario, se trata de una no-constitución que obliga a no

tomarla en cuenta. Atria no considera que la Junta Militar *destruyó* la Constitución de 1925 y que eso significó la destrucción del sujeto constituyente originario que la sostenía. Lo que entró en escena, en ese momento, fue un nuevo sujeto constituyente análogo al que determina el principio monárquico. Dirigida por Guzmán, la Junta pudo arrogarse entonces la facultad de otorgar una nueva constitución, no fundada en la soberanía popular, sino en una legitimidad de otro signo. Esto queda en evidencia por el hecho de que el plebiscito de 1980 no activó al poder constituyente originario del pueblo. Así lo reconoce la “Declaración de Profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile” citada más arriba.

Fundado en estas premisas, Atria razona de la siguiente manera. Si la Constitución de 1980 no es realmente una constitución, no es legítimo considerar que las reformas introducidas en 1989 y en 2005 hayan sido expresiones del poder constituyente del pueblo. Por ello, es necesario ahora activar ese poder constituyente originario con el fin de promulgar una nueva constitución. Ello determina perentoriamente la necesidad de saltarse la institucionalidad actual y convocar una Asamblea Constituyente originaria. Pero esto es ver las cosas desde el interior de la trampa armada por Chadwick. Para Atria, siguiendo la lógica planteada por Chadwick, lo que importa es el proceso constituyente, y no el resultado³⁹. Por mi parte, creo que una Asamblea Constituyente originaria no es un proceso político necesario, y posiblemente tampoco prudente, para asegurarle un carácter plenamente democrático a nuestra constitución. Para entender esto es preciso escapar de la trampa tendida por Chadwick y afirmar imperiosamente que, en 1988 y 1989, la Constitución de 1980 deja de estar fundada en el poder constituyente originario de la Junta Militar. Lo que los plebiscitos de esos años generan es, en verdad, la Constitución de 1989. Se trata de una constitución legitimada por plebiscitos democráticos y fundada ahora en el poder constituyente originario del pueblo, pero cuyo ejercicio democrático, como poder constituyente derivado, es reconocidamente parcial por razones circunstanciales y no de principio⁴⁰.

Tenemos entonces una constitución democrática parcialmente efectiva debido a los “cerrojos” antidemocráticos que no fueron completamente eliminados, ni por esa convocatoria democrática ni tampoco por la de 2005, sino que en muchos casos estos se fortalecieron.

Aquí tiene toda la razón Atria. Pero esto no significa que no puedan considerarse otras soluciones, posiblemente extrainstitucionales, que resulten más efectivas en la práctica que la inmediata convocatoria a una Asamblea Constituyente originaria, soluciones que tengan la virtud de hacer resaltar la continuidad constitucional chilena (imposible no pensar en la amenaza de Roosevelt de “atochar” [*pack*] la Corte Suprema en la primavera de 1937 para lograr la transformación constitucional que significó el *New Deal*). Gabriel Salazar piensa que un movimiento social-ciudadano que quiera activar el poder constituyente del pueblo debe tener en cuenta “la continuidad necesaria entre pasado y presente, entre su memoria acumulada y la realidad que quiere construir socialmente, entre su poder real y la tarea por realizar”⁴¹. Solo de esa manera puede asumir la tarea constituyente “sin tener que dar ese peligroso salto al vacío que va desde el mero descontento a la vaguedad de la utopía”⁴².

El argumento de Atria me obliga a avanzar dos precisiones con respecto a la noción de poder constituyente. La primera toma en cuenta la afirmación de Atria de que “la llamada Constitución de 1980 no es una constitución, es una camisa de fuerza”⁴³, y que no es más que “un conjunto de leyes constitucionales”⁴⁴. Solo el pueblo es sujeto de poder constituyente, de modo que Pinochet y la Junta Militar no pueden reclamar para sí un ejercicio constituyente originario. Atria reitera: la Constitución de 1980 no es más que “una maraña de dispositivos cuya finalidad más precisa es negar el poder constituyente del pueblo”⁴⁵. Esa “maraña de dispositivos” son los tres cerrojos y el metacerrojo, que acertadamente identifica Atria, y que no permiten la reforma de la Constitución, impidiendo así el pleno ejercicio del poder constituyente derivativo del pueblo.

Atria establece, en un extraordinario reconocimiento, que “la subsistencia de estos cerrojos es la marca de continuidad de la Constitución actual con la de Pinochet”⁴⁶. Es importante notar que Atria no se refiere aquí a la Constitución de 1980, sino que ahora distingue entre la Constitución de Pinochet, es decir, la Constitución de 1980, y la Constitución actual, a la vez que afirma la continuidad de ellas. Esto coincide con lo que he sostenido en mi interpretación de lo que sucede en 1988 y 1989, y que Atria disputa. Primero, el hecho de que Atria distinga entre esas dos constituciones es correcto porque, mientras una está animada por el poder constituyente originario que Guzmán le reconoce a

Pinochet, la otra lo está por el poder constituyente originario que reconquista el pueblo. Habría que agregar un dato esencial. El pueblo retoma heroicamente su poder constituyente originario producto de una intensa lucha política que culmina con los plebiscitos de 1988 y 1989. Segundo, a pesar de ser dos constituciones “constitutivamente” distintas, hay que reconocer una cierta continuidad entre ellas. Como indiqué más arriba, aunque el pueblo haya retomado totalmente su poder constituyente originario, el ejercicio de su poder constituyente derivado ha sido solo parcial. Persisten en la Constitución actual trabas para que el pueblo pueda ejercitar en plenitud su poder de reformarla. A pesar de que Atria, como hemos visto, rechaza esta interpretación, él mismo parecería confirmarla cuando afirma:

La eliminación de todo cerrojo [...] y su reemplazo por reglas que busquen habilitar al pueblo para actuar y no neutralizarlo, sería la destrucción de la Constitución de Pinochet, y su reemplazo por otra democrática. Eso sería una nueva constitución, *incluso si el resto del texto no fuera modificado*⁴⁷.

Este argumento requiere ser precisado. Atria se refiere a la destrucción de la Constitución de Pinochet, olvidando que ha distinguido entre esa Constitución y la Constitución actual. Para ser precisos habría que decir que la eliminación de los cerrojos debería destruir la Constitución actual, y no la de Pinochet. En primer lugar, no se puede destruir la Constitución de Pinochet porque esta ya no existe —aunque Chadwick afirme tramposamente lo contrario, y Atria comparta ese juicio—. No tiene sentido alguno decir que la Constitución actual está animada por el poder constituyente originario de Pinochet. Para afirmar eso, uno tendría que admitir que Chadwick tiene la razón en no tomar en cuenta la lucha política popular que condujo al triunfo plebiscitario en 1988 y 1989. Esa lucha significó la vuelta de la democracia y la reconquista del poder constituyente originario por parte del pueblo vencedor⁴⁸. ¿Está dispuesto Atria a seguir el camino trazado por Chadwick y negar la derrota política de Pinochet? ¿Está dispuesto a negar esa tradición de lucha popular y el “aprendizaje” que fue producto de esa “cosecha de experiencias”⁴⁹, ahora visible en la movilización de los estudiantes en 2011?

En segundo lugar, tampoco me parece posible decir, como sostiene Atria, que la eliminación de esos cerrojos destruye la Constitución actual.

Lo que sucede es que la Constitución actual inhibe el pleno ejercicio del poder constituyente derivativo del pueblo, lo que es ciertamente un resabio en el texto de la Constitución actual que se hereda de la Constitución de Pinochet. Pero la eliminación de ese resabio no destruye la Constitución. Todo lo contrario, la perfecciona en un sentido democrático. Se trataría de la misma evolución democrática que Atria le atribuye a la Constitución de 1925. Destruir una constitución es destruir su poder constituyente originario y eso no es lo que debe ocurrir, sino todo lo contrario. Si se aceptara lo que equivocada y tramposamente hace Chadwick, a saber, identificar la Constitución chilena actual con la “Constitución del 80” de Pinochet, entonces sí podría hablarse de una destrucción de la Constitución actual.

La segunda precisión tiene que ver con su referencia a la Constitución de 1925. Si se considera que la derrota plebiscitaria de la Junta Militar en 1988, confirmada por el plebiscito de 1989, destruyó su poder constituyente, ese hecho dejó sin efecto la destrucción previa de la Constitución de 1925. Con esto se abre la posibilidad de retomar la continuidad constitucional en Chile, la que se extiende, al menos, hasta 1828. ¿Cómo olvidar que la Constitución de 1833 se promulgó como una reforma de la de 1828? ¿Y que la Constitución de 1925 se promulgó como reforma de la de 1833? El mismo Atria reconoce que la Constitución de 1925, que fuera impuesta originalmente en forma no democrática⁵⁰, fue con el tiempo democráticamente “apropiada” por el pueblo⁵¹. ¿Qué obstáculos encontraría el legítimo constituyente actual para restaurar la Constitución de 1925 y proceder, en seguida, a su completa y exhaustiva reforma? ¿Cuál sería el obstáculo para restaurar selectivamente, y en plenitud, sus artículos 109 y 110, reformados por la ley 17.284 del 23 de enero de 1970, referentes a la función de los plebiscitos? ¿No se abriría así la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, que, por supuesto, no sería originaria como exige el argumento de Chadwick, y que tuviera en cuenta “la continuidad necesaria entre presente y pasado” de que nos habla Salazar, para evitar así el “salto al vacío” y la “vaguedad de la utopía” que teme?

Es interesante notar que Atria no se muestra desfavorable a una idea como esta. En primer lugar, se muestra de acuerdo con Salazar cuando afirma que “una nueva constitución no es partir de cero en el sentido de negar la historia”⁵². Considera así que, por razones de continuidad

histórica, es posible reconocer que hay instituciones definidas por la Constitución de 1980 que representan un aprendizaje histórico que “tenemos el deber de mantenerlas para que queden a disposición de las generaciones futuras”⁵³. Y, en segundo lugar, en una cualificación todavía más avanzada de lo que entiende por un comienzo “en blanco”, Atria se abre a la posibilidad de establecer un lazo de continuidad con la Constitución de 1925. Aunque muy esquemáticamente, y no como “propuesta concreta”, sugiere el siguiente procedimiento:

[...] un proceso de dictación de una nueva constitución en el que decidamos por referencia a la última decisión constitucional que fue aceptada en su momento por todos y que no contenía trampas, es decir, la Constitución de 1925 en su estado posterior a la última reforma en democracia, en 1971⁵⁴.

Por mi parte, pienso que no es necesario respetar el veredicto que publica Guzmán en *El Mercurio* el 5 de octubre de 1975, cuando, con osada temeridad, declara que la Constitución de 1925 había muerto y que quedaban a la vista solo sus “colgajos”. Esta declaración de Guzmán es una prueba más de su deslealtad cívica con respecto a esa Constitución y al poder constituyente del pueblo que la sostenía.

Algunos han visto en el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 23 de agosto de 1973 una legitimación democrática del golpe del 11 de septiembre y de la nueva institucionalidad que promulga, pero es la restauración de la institucionalidad quebrantada, y no su destrucción, lo que explícitamente establece el Acuerdo, que en su parte esencial sostiene:

Representar a S. E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros [...] que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado [...], les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos.

Es claro que en la mente de los diputados de oposición que firman este Acuerdo en 1973 predomina la idea de “asegurar el orden

constitucional” vigente y no la de crear revolucionariamente una nueva institucionalidad gremialista y neoliberal. Me parece que este documento confirma el hecho de que la Constitución de 1925 fue destruida por un acto de alta traición por quienes no respetaron “el juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes” que prestaron. Me parece también que esa Constitución traicionada merece un gran gesto restaurador que permita retomar la continuidad de nuestra tradición constitucional republicana hecha trizas por Guzmán, el Mefisto de la dictadura⁵⁵. Los chilenos hemos pagado un alto precio por la decisión de Guzmán de reconocer a Pinochet y la Junta Militar como sujetos del poder constituyente originario, y destruir, de esa manera, la Constitución histórica de nuestra Independencia. La derrota plebiscitaria de Pinochet en 1988 permitió al pueblo recuperar su poder constituyente. En virtud de esa reconquista, se ha abierto la posibilidad de restaurar nuestra Constitución histórica. En esto no hay nada revolucionario. La Revolución chilena ya tuvo lugar a partir de 1810, con la que dejamos atrás al antiguo reino. La tarea que compete ahora es la de restaurar y perfeccionar el sentido democrático de nuestra Constitución histórica.

XI. NUEVA CONSTITUCIÓN Y PODER CONSTITUYENTE: ¿QUÉ ES “INSTITUCIONAL”?¹

Fernando Atria

EN LA campaña presidencial de 2013, la Nueva Mayoría obtuvo una contundente victoria con un programa que contenía, como uno de sus puntos centrales, la promesa de una nueva constitución. El programa especificaba las características generales de lo que se ha dado en llamar “el mecanismo” para el cambio constitucional: se trataría de un proceso “democrático, participativo e institucional”. Mucho se ha especulado acerca del significado de estos términos, en particular de qué quiere decir que se trate de un proceso “institucional” y qué tensiones hay, en el contexto de la institucionalidad chilena actualmente vigente, entre esa característica y las otras dos. Estas cuestiones son importantes, pero no es este el momento para detenerse en ellas. En efecto, la forma jurídica específica del mecanismo dependerá del grado de desarrollo que tenga la demanda social y política por una nueva constitución en su momento. Pero además, no estamos todavía en condiciones de dar por sentado que lo entendemos por el problema *general* de la forma del cambio constitucional. No se trata de que sepamos cuál es el problema y solo nos preguntemos cómo ha de ser solucionado. Debemos, por tanto, detenernos en indagar acerca de la naturaleza del problema.

1. ¿CÓMO DISTINGUIR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL?

Debemos, entonces, partir desde algunos pasos atrás. Tenemos que reflexionar, en primer lugar, sobre la relación entre el cambio constitucional y la nueva constitución, entre el procedimiento y el

producto. Tratándose del cambio constitucional, el tipo de producto buscado se anticipa en el proceso, de modo que hablar acerca del proceso es una manera de hablar acerca del producto. En este sentido, podemos entender mejor cuál es el proceso adecuado cuando tenemos claridad respecto de su producto.

El producto buscado es una *nueva constitución*, y no una *reforma constitucional*. Pero la distinción entre estas dos cuestiones es mucho menos obvia de lo que podría parecer a primera vista. Esto puede apreciarse mirando la discusión que siguió a la publicación de la ley 20.050, que hoy conocemos como la reforma constitucional de 2005. Visto *desde hoy*, esa discusión sobre esta cuestión en 2005 se nos aparece curiosamente invertida. Esto es lo que hace a este episodio crucial ahora que hablamos de nueva constitución. Nos provee, por así decirlo, de una imagen en negativo del poder constituyente: un momento en que todos entendieron las cosas al revés. El expresidente Lagos y la Concertación entendieron que el problema constitucional había sido solucionado porque la Constitución ya no era la de 1980 o “de Pinochet” y podía ser lícitamente llamada “de 2005”. El propio Lagos, al promulgar la ley 20.050, afirmó que después de esas reformas “Chile cuenta [...] con una Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido”. La derecha se opuso a esta nueva denominación. El diario *El Mercurio* sostenía que las reformas “no alteran en lo sustancial el texto de 1980”, mientras que el entonces senador Andrés Chadwick sostuvo algo que hoy sería considerado un argumento para respaldar la demanda por una nueva constitución: por muy importante que hayan sido las reformas, que hemos compartido y consensuado, sigue siendo la Constitución de 1980. Se mantienen sus instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz. Para que haya una nueva constitución se requiere de un proceso constituyente originario, no de un proceso de reformas².

La pregunta, entonces, por la diferencia entre una reforma constitucional y una nueva constitución, una pregunta que pareciera corresponder a los cursos de teoría de la constitución, es una pregunta políticamente relevante hoy. Y, adicionalmente, ya tenemos una pista: no podemos descansar en lo que los agentes creen que están haciendo, porque estos pueden estar tan equivocados como el comentarista o el jurista. Y como el gobierno ha afirmado que Chile necesita una nueva

constitución, y como hay una demanda ciudadana de una nueva constitución, es importante hoy reflexionar para tener un criterio que podamos utilizar cuando llegue el momento. Esto es, un criterio que nos permita saber si lo que se nos presenta es una reforma constitucional o una nueva constitución, y nos muestre también por qué la diferencia es importante.

Quiero sugerir que para esta pregunta hay, en principio, dos respuestas posibles.

La primera es la respuesta que daría un jurista. La perspectiva característica del derecho siempre se aprecia de modo perspicuo desde la obra de Hans Kelsen. Kelsen diría que una nueva constitución es una constitución dictada a través de mecanismos no previstos en la constitución anterior, mientras que una reforma constitucional sería el resultado de un ejercicio de potestades constitucionales ordinarias de reforma. Una creación libre de ataduras, en el caso de una nueva constitución; o el seguimiento de un procedimiento preestablecido constitucionalmente, en el caso de una reforma constitucional.

Las constituciones escritas contienen por lo común determinaciones especiales relativas a los procedimientos mediante los cuales solamente ellas pueden ser modificadas. El principio de que la norma de un orden jurídico vale durante todo el tiempo que transcurra hasta que su validez no sea terminada en la manera determinada por ese orden jurídico, o hasta que sea remplazada por la validez de otra norma de ese orden jurídico, es el principio de legitimidad. Este principio, con todo, se aplica a un orden jurídico estatal con una limitación altamente significativa. No tiene aplicación en caso de revolución. Una revolución, en el sentido amplio de la palabra, que abarca también el golpe de Estado, es toda modificación no legítima de la constitución —es decir, no efectuada conforme a las disposiciones constitucionales— o su remplazo por otra. Visto desde un punto de vista jurídico, es indiferente que esa modificación de la situación jurídica se cumpla mediante un acto de fuerza dirigido contra el gobierno legítimo, o efectuado por miembros del mismo gobierno; que se trate de un movimiento de masas populares, o sea cumplido por un pequeño grupo de individuos. *Lo decisivo es que la constitución válida sea modificada, o remplazada enteramente, por una nueva constitución, de una manera que no se encuentra prescripta en la constitución hasta entonces válida*³.

Nótese que, como lo deja en claro la frase destacada, para Kelsen lo importante no es la continuidad del *texto*. La distinción no está entre el

caso en que el texto sea modificado y el caso en que sea reemplazado enteramente. Si cualquiera de esas cosas se hace mediante el ejercicio de potestades constituidas, es una reforma constitucional, una modificación de la constitución vigente. Si se hace a través de formas distintas, es una nueva constitución. La respuesta kelseniana (jurídica) es puramente formal, no mira en absoluto al contenido.

En contraste con la aparente superficialidad de la respuesta del jurista, la segunda respuesta parte desde un concepto sustantivo de lo que es una constitución. No puedo detenerme aquí en el argumento para esto, por lo que permítanme presentar derechamente la conclusión⁴: una constitución es una decisión fundamental sobre la identidad y forma de una unidad política. En la tradición democrática, particularmente, esta decisión hace posible que la *unidad* política pase a ser un *agente* político por la vía de establecer(le) mecanismos de imputación de voluntad: así, por ejemplo, la comprensión democrática de los procedimientos de formación de la ley entiende que estos son mecanismos de formación de la voluntad del pueblo. La ley es una declaración de la voluntad del pueblo, una “declaración de la voluntad soberana”. Si la constitución es una decisión sobre la identidad y forma de la unidad política, ¿cuál es entonces la forma que asume el pueblo chileno bajo la “constitución” de 1980? La respuesta es clara: está neutralizado⁵. La decisión en la que consiste la constitución de 1980 es la de neutralizar, de impedir la agencia política del pueblo. Bajo ella hay unidad política, pero no agencia política. Se trata entonces de una constitución que cumple una función precisamente contraria a la función que la tradición democrática le asigna a toda constitución, a saber, habilitar al pueblo creando formas de acción para este. Por consiguiente, desde una perspectiva sustantiva y democrática, una nueva constitución significa reemplazar esta decisión neutralizadora por otra habilitadora. Eso contaría como una nueva decisión sobre la forma del pueblo, una que lo habilite para actuar políticamente. Una reforma constitucional, por otra parte, es toda modificación de reglas constitucionales que mantenga la neutralización.

Es interesante notar que estas dos respuestas pretenden ser respuestas a la misma pregunta, pero pareciera que estuvieran hablando de cosas distintas. ¿Cómo es posible vislumbrar dos respuestas tan notoriamente disímiles entre sí a la misma pregunta? Lo que ocurre es que son dos maneras de decir lo mismo, usando lenguajes diferentes.

Porque la decisión sobre la forma y modo de existencia de la unidad política no es solo una decisión abstracta o teórica. Es una decisión que se manifiesta en instituciones. Esas instituciones, entonces, contienen la decisión fundamental y, por consiguiente, su acción la ratifica y no puede impugnarla. Es importante notar que esta afirmación debe ser entendida políticamente y no de modo teórico. La afirmación se sostiene, incluso:

[...] en Estados donde, como ocurre en Inglaterra, por virtud de la pretendida soberanía del Parlamento inglés, pueden acordarse leyes constitucionales en vías del procedimiento legislativo ordinario. Sería incorrecto sostener que Inglaterra pudiera transformarse en una República soviética mediante “simple acuerdo mayoritario del Parlamento”⁶.

Cuando la decisión fundamental es, como en Chile, una de neutralización, esa decisión también se manifiesta en instituciones, que es donde se contiene la decisión neutralizadora. La neutralización no es una decisión *de* esas instituciones, sino algo *acerca* de ellas. Por consiguiente, en la medida en que nuevas decisiones se tomen a través de esas formas institucionales, la decisión fundamental en la que dichas instituciones descansan será ratificada, no podrá ser impugnada.

La mejor demostración de este punto es, precisamente, la reforma constitucional de 2005. Que la ley 20.050 fuera una nueva constitución era una imposibilidad. Pero una imposibilidad política, no conceptual. Ello porque la neutralización en que consiste la Constitución de 1980 se encuentra en sus formas procedimentales, lo cual significa que mediante una decisión tomada a través de esas formas solo podrán tomarse decisiones neutralizadas, es decir, decisiones que no afecten la neutralización. Si la pregunta es la pregunta substantiva: ¿por qué no hubo en 2005 una nueva constitución? La respuesta puede bien ser la del jurista: porque la ley 20.050 se produjo a través del ejercicio de potestades ordinarias de reforma conforme al artículo 127 del texto constitucional (esto es una reforma en términos del jurista). Y recíprocamente, si la pregunta es la pregunta formal: ¿puede darse una nueva constitución a través de los mecanismos institucionales vigentes? La respuesta bien puede ser substantiva: no, porque el sentido de los mecanismos, de las formas institucionales, es preconfigurar las posibilidades, dejando a salvo la decisión fundamental en la que la constitución consiste.

2. SOBRE LO “INSTITUCIONAL”: UNA DISCUSIÓN PURGADA DE TODO FORMALISMO

Ahora que contamos con un concepto de constitución, podemos preguntarnos qué quiere decir que un procedimiento para elaborar una nueva constitución sea “democrático, participativo e institucional”. Hemos dicho que no es este el momento para la determinación precisa de estas características, pero también hemos dicho que tratándose del cambio constitucional, el tipo de producto buscado se anticipa en el proceso, de modo que hablar acerca del proceso es una manera de hablar acerca del producto, y describir el resultado que es necesario es caracterizar el mecanismo a través del cual dicho resultado puede ser logrado.

Ya estamos en condiciones de entender que la dimensión “institucional” de este procedimiento no puede implicar que esa nueva constitución sea generada mediante el ejercicio de potestades ordinarias de reforma constitucional (aquellas contenidas en el artículo 127 del texto constitucional), porque ello arrojaría como resultado (y esto después del 2005 no es sorpresivo) nada más que una reforma constitucional, tanto en términos jurídicos como en términos sustantivos. Pero entonces, ¿cómo puede haber un procedimiento “institucional” para dictar una *nueva constitución*?

Es decir, ¿cómo puede haber una nueva constitución dictada a través de un proceso institucional? De acuerdo al argumento de la sección 1, esto parece una contradicción en los términos. Pero es importante notar que no es una contradicción *en los términos*, sino una contradicción *política*, porque el argumento que conectaba la respuesta política y la respuesta jurídica no es un argumento teórico o conceptual, sino político. La diferencia es importante. Cuando Schmitt dice que sería incorrecto decir que el Parlamento inglés puede, por un simple acuerdo mayoritario, hacer del Reino Unido una república soviética, su afirmación no es una predicción sobre lo que puede o no ocurrir en el futuro. Schmitt lo dice con precisión: si hubiera una decisión de ese tipo, sería “incorrecto” sostener que se trata de “un simple acuerdo mayoritario del Parlamento”, porque lo correcto sería decir que no es un “simple acuerdo”, sino un golpe de Estado o una declaración de independencia (dependiendo de si uno está contra él o con él), y el cuerpo que lo tomó no es el Parlamento

de Westminster, sino una facción golpista o una asamblea revolucionaria. Lo que esto implica es que la discusión sobre el sentido de la nueva constitución debe ser una discusión enteramente purgada de formalismos jurídicos. Esto opera en ambos sentidos: como es enteramente purgada, no tiene sentido decir que una nueva constitución solo se puede dar fuera de mecanismos “institucionales”, pero también es decir que no se puede dar a través de esos mecanismos. Este es el sentido de la afirmación de que el poder constituyente no está atado por las instituciones constituidas: como es pura sustancia (porque es el origen de toda forma), no está vinculado por las formas. Pero esta ausencia de vinculación puede operar en cualquier sentido.

Como ha de estar purgada de todo formalismo, de lo que se trata no es de analizar teórica o conceptualmente qué quiere decir *poder constituyente* y qué relación tiene con la noción de *poder constituido*. Cuando hablamos de un procedimiento “institucional”, debemos hacerlo con conciencia de dos elementos. El primero es el que se sigue de lo dicho en la sección 1: una nueva constitución no puede ser dada mediante el ejercicio regular de potestades constituidas, porque es en la constitución de esas potestades donde se aloja la neutralización constitucional que da cuenta de nuestro problema constitucional. El segundo es algo que, aunque sé que puede ser discutido como apreciación, es a mi juicio evidentemente verdadero: en la situación actual (y la que es probable que se mantenga por los próximos años), la viabilidad política de una nueva constitución mediante procedimientos “extrainstitucionales” es cercana a cero. De estos dos elementos, se sigue que parece que estamos en un callejón sin salida. Y es en este punto donde los juristas tenemos algo importante que decir, porque ahora es cuando los juristas se encuentran en una posición en la que tienen una contribución específicamente profesional que hacer a la República, esa contribución que la llamada “doctrina constitucional” ha sido notoriamente incapaz de hacer en las últimas cuatro décadas⁷.

¿Cuándo, entonces, algo es “institucional”? Todo jurista sabe que, a pesar de lo que podría pensarse, esta pregunta no tiene una respuesta clara y siempre evidente. Yo supongo que hace siete décadas, en algún seminario de derecho civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un egresado de derecho en vías de titulación sorprendió a sus profesores con el argumento de que vender cosas embargadas era

perfectamente lícito (es decir, “institucional”)⁸. Yo supongo que todos los tradicionales profesores de derecho civil, quienes llevaban 80 años enseñando que hay objeto ilícito en la venta de cosas embargadas, deben haberse sorprendido: “¿no sabemos todos que es ilícito vender cosas embargadas?” quizás se preguntaron; “¿es que este joven viene a decirnos que hemos estado equivocados todo el tiempo sobre algo importante de nuestra especialidad profesional?”. Y, bueno, sí. Eugenio Velasco tenía la razón, y hoy es una tesis aceptada (sin que las reglas hayan cambiado) que la venta de cosas embargadas es lícita, aunque es ilícita su enajenación (salvo en las condiciones del artículo 1.464 del Código Civil).

A mi juicio, una de las cosas que marca la diferencia entre el que conoce el derecho y el que no lo conoce es precisamente que el primero sabe que el derecho deja espacios para discutir, en las circunstancias, sobre el estatus de “institucional” o “extrainstitucional” de algo. No quiero que se me interprete cínicamente. No estoy diciendo que uno siempre puede salirse con la suya y torcer las reglas a voluntad. Por eso, creo que el de Eugenio Velasco es un buen ejemplo. Él mostró que algo que había sido siempre considerado ilícito (la venta de cosas embargadas por decreto judicial) era perfectamente lícito y que, quienes habían sostenido por tanto tiempo que era ilícito, estaban jurídicamente equivocados.

Pero si esto es así, es posible que entre las dos observaciones que constituían nuestro dilema haya un espacio donde podremos encontrar la solución. El dilema era, recuérdese: si es mediante el ejercicio ordinario de las potestades de reforma constitucional, no hay solución al problema, porque ahí se aloja la neutralización; si es extrainstitucional, no hay solución al problema, porque es políticamente inviable. Pero nótese que este dilema supone que solo es “institucional” el ejercicio ordinario de las potestades de reforma constitucional. Necesitamos algo equivalente a la tesis Velasco, algo que nos abra posibilidades para pensar en vías institucionales que no estén afectadas por la neutralización que contiene el procedimiento del artículo 127.

En la formulación del dilema utilizada más arriba, este resulta de la suma de dos observaciones: una sobre los procedimientos regulares de reforma, que no son aptos para solucionar el problema porque ahí se aloja la trampa; y otra sobre las formas “extrainstitucionales”, que tampoco resultan aptas, ahora por inviabilidad política. Nótese, sin

embargo, la diferencia en la formulación: el primer elemento alude a “procedimientos regulares de reforma” y el segundo a lo “extrainstitucional”. Y la pregunta, naturalmente, es si hay algún procedimiento que no caiga en ninguna de estas dos descripciones, es decir, que no sea “extrainstitucional” (para que sea viable), pero que tampoco sea “ejercicio de poderes regulares de reforma” (para que pueda solucionar el problema).

Si el problema fuera “teórico” o “conceptual”, la respuesta sería negativa. Pero políticamente hablando, la pregunta es por el sentido, y entonces podemos decir algo más. Como lo ilustra la tesis Velasco, es posible que algo que parece “extrainstitucional” sea, cuando es considerado con cuidado, institucional. Yo creo que eso es lo que ocurre con el plebiscito constitucional⁹. Pero si esto es así, ¿cómo caracterizar lo que es “extrainstitucional”, eso que hoy no tiene viabilidad política? Mi respuesta sería: una estrategia es extrainstitucional, en este sentido, cuando ella es ilícita en primera persona, esto es, cuando quien actúa de ese modo no puede sino reconocer que su acción es contraria a derecho. Esto nos permite fijar un espacio entre las dos posibilidades que hemos identificado: se trata de formular una estrategia de cambio constitucional que pueda ser defendida como aplicación del derecho (aunque sea, como la tesis Velasco, novedosa), y que, por tanto, no resulte “extrainstitucional” en primera persona.

Habiendo aclarado esto, ahora podemos decir: que una estrategia “extrainstitucional” sea políticamente inviable hoy significa que la nueva constitución tendrá que tener un momento de validación institucional. Un momento en que el procedimiento de que se trate sea reconocido conforme a la institucionalidad vigente. Lo que no es unívoco es el *sentido* de ese momento. Porque dicho momento puede entenderse de dos modos: en el primero, se trata de un momento en que se toma una decisión sobre la forma y modo de existencia de la unidad política. Es decir, es un momento en el que se pretende producir una nueva constitución. Esto es lo que el argumento de la sección 1 muestra que no es posible: que una decisión tomada institucionalmente sobre la forma y modo no será sino una reiteración de la constitución vigente, es decir, una ratificación de la forma y modo de existencia actualmente vigente. Esto fue lo que ocurrió en 2005, cuando el momento institucional fue un momento en que se decidió sobre el contenido de la nueva regulación

constitucional. En consecuencia, fue solo una reforma constitucional. En el segundo, ese momento de validación institucional tiene el sentido no de *decidir*, sino de *abrir posibilidades de decisión* sin tomar decisiones sobre el contenido de la nueva ordenación. En este segundo sentido, no hay, por tanto, incompatibilidad en la idea de una nueva constitución dictada mediante un procedimiento que tiene un momento de validación institucional.

A mi juicio, por razones latamente explicadas en otro lugar¹⁰, creo que ese momento institucional podría ser un plebiscito convocado por la presidenta de la República, si para ello se cuenta con el acuerdo de ambas cámaras del Congreso. Muchos comentaristas, sin embargo, sin hacerse cargo del argumento, saltaron apresuradamente a la conclusión de que dicho plebiscito no sería suficientemente “institucional”, porque sería una suerte de “fraude a la ley [a la Constitución]”¹¹. Yo todavía no he escuchado una razón convincente que supere los argumentos dados en ese libro, pero asumamos que quienes criticaban no el argumento, sino su conclusión, tienen razón, y dicho plebiscito sería inconstitucional. Lo sería, de acuerdo a ellos, porque infringiría lo dispuesto en el inciso final del artículo 15 del texto constitucional: “Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución”.

Si la objeción a la posibilidad de un plebiscito constitucional es la regla del inciso final del artículo 15 recién citado, la solución evidentemente es modificar esta regla. La modificación podría consistir, por ejemplo, en insertar antes del punto final la expresión “y la ley”. Nótese que dada la ubicación del artículo 15 en el capítulo 2 del texto constitucional, su reforma estaría sujeta, conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 127, al *quorum* ordinario de $\frac{3}{5}$, y no al agravado de $\frac{2}{3}$ de los senadores y diputados en ejercicio.

Por razones que han sido explicadas con cierta detención en otra parte, a mi juicio, una regla que autorizara a la presidenta de la República a convocar un plebiscito a su propia voluntad no es conveniente¹². El riesgo es que la presidenta pudiera usar ese poder para solucionar sus conflictos con el Congreso en desmedro de este, reduciendo aún más la importancia de este último y concentrando todavía más el poder en esta figura. Pero está claro que si la razón para restringir el poder de la presidenta para convocar a plebiscito es proteger el Congreso, dicha

protección no se obtiene prohibiendo cualquier plebiscito no expresamente contemplado en la Constitución, sino requiriendo el acuerdo del Congreso para convocar a plebiscito. Esta es la conclusión a la que lleva, a mi juicio, una interpretación no pinochetista de la constitución actual. Pero si esta última tesis es rechazada, la reforma aquí sugerida sería suficiente¹³. Dicha reforma cuenta como el momento de validación constitucional de un proceso de nueva constitución. En ese sentido no sería “extrainstitucional”, pero sería un momento de validación institucional cuyo sentido no es decidir la cuestión sino abrirla, y por eso no implica el peligro de repetir el error de 2005, porque no se trataría de una decisión institucional que pretenda decidir el contenido de la nueva constitución, sino una que al abrir la cuestión permitiera superar la neutralización¹⁴.

3. LA NUEVA CONSTITUCIÓN COMO PROCESO

La celebración de un plebiscito constitucional no es importante solamente por el resultado que se obtenga (aunque es evidente que un resultado positivo para una nueva constitución sería una condición necesaria para que el proceso continuara). Es cuestión de pensar lo que significaría la realización de tal plebiscito: un período de intensa discusión constitucional, en el que se irían perfilando cada vez con mayor claridad posiciones diferentes, y en el contexto del cual la movilización social y política por una nueva constitución aumentaría considerablemente. En estas circunstancias, si después de (por hipótesis) un resultado favorable a una nueva constitución, surgiera la idea de realizarla mediante una “comisión bicameral” sometida a las reglas del artículo 127, la respuesta sería que dicha opción resulta, en ese contexto, ridícula. Esta reflexión nos da una pista acerca de lo que ha de seguir a continuación: los procedimientos que sean posibles dependerán del grado de desarrollo de la demanda ciudadana por una nueva constitución. Este es el argumento a favor de una Asamblea Constituyente. No es un argumento moral, es decir, normativo (de legitimidad). Es un argumento político: se trata de lograr el desarrollo de la demanda ciudadana por una nueva constitución hasta el punto de que cualquier solución distinta a una Asamblea Constituyente sea ridícula. La

Asamblea Constituyente solo será posible cuando sea necesaria.

Por eso, la campaña por la Asamblea Constituyente debe entenderse como la campaña por el desarrollo de la demanda ciudadana por una nueva constitución, y la asamblea marca el grado máximo de desarrollo. Porque nadie que entienda el significado de estas palabras podría negar que la forma más plena y adecuada para darse una nueva constitución es una Asamblea Constituyente: si una constitución es una decisión del pueblo sobre su identidad y forma política, entonces la forma de decisión que corresponde de modo más pleno a lo que una constitución es verdaderamente, es el modo más democrático, más participativo, más igualitario, etcétera. A mi juicio, esto es una trivialidad. Lo que no es trivial, desde luego, es si es adecuado esperar, para la nueva constitución, que la demanda ciudadana esté tan desarrollada que solo una Asamblea Constituyente sea suficiente respuesta a ella. Como el argumento por la Asamblea Constituyente no es normativo, sino político, la respuesta a esta pregunta no puede darse en abstracto. Ni menos por un jurista. Solucionar el problema constitucional no es tarea de los juristas, sino de los ciudadanos, pero los juristas pueden contribuir a ella, como yo he intentado hacerlo en estas líneas.

4. UNA RÉPLICA A RENATO CRISTI

Las consideraciones anteriores, sumadas a las de *La Constitución tramposa*, pueden proveer una perspectiva adecuada para comentar algunas de las observaciones y críticas de Renato Cristi a ese libro contenidas en su texto *El constitucionalismo del miedo*. Como cuestión preliminar, debo decir que me resulta difícil responder a sus observaciones por dos razones que, a mi juicio, están relacionadas. La primera es que no me queda claro qué es lo que para Cristi constituye un argumento que prueba una posición. La segunda es que su comentario no hace intento alguno por reconstruir el argumento que critica de modo coherente. Espero poder explicar, en la substancia de esta réplica, las razones que justifican la segunda observación¹⁵. Pero antes quiero discutir con cierta detención la primera.

4.1 Sobre el sentido de lo político:

¿qué cuenta como argumento?

Cuando digo que no me queda claro qué es lo que para Cristi cuenta como argumento, tengo presente algo como lo que sigue: Cristi nos recuerda (lo que ya había hecho en su libro sobre Jaime Guzmán¹⁶) que los profesores de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile firmaron una declaración en los días anteriores al plebiscito de 1980 declarando que, como el poder constituyente originario no reconoce limitación alguna, las condiciones de aprobación de una constitución son decisión de dicho poder, y entonces el hecho de que, “por razón de prudencia y no de necesidad política”, la Junta Militar haya convocado un plebiscito no significaba que la validez de la Constitución dependiera del resultado del plebiscito. Con una incapacidad de leer la situación política, de la que solo algunos profesores de Derecho son capaces, los profesores de la Universidad parecían creer que el resultado del plebiscito era incierto y decidieron hacer una declaración preventiva para afirmar la validez de la Constitución, incluso, en el caso de que el plebiscito se perdiera.

En lo que para mí es un paso enteramente injustificado e incomprensible, Cristi se mueve de hacer una afirmación acerca de lo que los profesores de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile dijeron a otra afirmación sobre lo que el plebiscito en realidad significaba. En efecto, inmediatamente después de citar la declaración, Cristi continúa: “Decir, por lo tanto, que se trató de un plebiscito fraudulento no tiene sentido. Lo que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1980 fue una mera consulta popular sin efectos vinculantes”¹⁷.

Esto último podrá ser correcto (aunque yo supongo que solo la udi, a estas alturas, estará de acuerdo con que decir que fue un plebiscito fraudulento “no tiene sentido”), pero si lo fuera no sería en virtud de lo que los profesores de dicha Universidad hayan o no dicho. El significado político de algo nunca depende de lo que los sujetos que actúan (o los observadores, como en este caso) dicen que está pasando, sino de lo que políticamente está pasando. Y lo que políticamente está pasando no es reducible a lo que alguien cree que está pasando. Nótese este punto: mi desacuerdo aquí con Cristi no alcanza a ser sobre si el plebiscito de 1980 fue una “mera consulta”, sino sobre cuáles son las razones que sirven para decidir si ese fue o no el caso.

Es decir, es interesante considerar la idea de que la Constitución de

1980 no descansa siquiera en un plebiscito fraudulento, y que dicho plebiscito en realidad no fue tal y, entonces, la Constitución tampoco fue tal, sino solo una medida de propaganda política que, cual Frankenstein, cobró vida pese a Pinochet. Lo que a mi juicio carece de sentido es pensar que si eso es, o no, así depende de lo que hayan dicho, o no, un grupo de profesores de Derecho(/a) de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo segundo no es, de ningún modo, un argumento que baste para siquiera dar plausibilidad a lo primero.

Algo similar puede decirse de otra cuestión, que Cristi y yo hemos discutido en intercambios anteriores, sobre la naturaleza de lo que comenzó el 11 de septiembre de 1973¹⁸. Las posibilidades, a mi juicio, son tres: o comenzó una *tiranía* (poder no sujeto a reglas jurídicas, en que siempre todo es posible para el tirano), o comenzó una *dictadura* (interrupción del derecho), que a su vez puede ser *comisaria* (suspende la constitución para protegerla) o *soberana* (no suspende, sino destruye la constitución, para dictar otra)¹⁹. La posibilidad de una dictadura comisaria (que restablecería la “normalidad” en un breve plazo, llamando, como se insinuó en algún momento, a elecciones en 1975) quedó rápidamente excluida, pero la decisión entre dictadura (soberana) y tiranía se mantuvo abierta hasta la madrugada del 6 de octubre de 1988, en que Pinochet se dio cuenta de que la “constitución” que había dictado como una manera de dar una pátina de legalidad a su régimen había sido, a su pesar, capaz de constituir, y por consiguiente no pudo obtener de la Junta Militar la ley de poderes especiales que solicitó para negar el resultado del plebiscito²⁰.

Para Cristi, las cosas se deciden por lo que alguien dice:

Tiene razón Atria cuando afirma “pero no es plausible sostener que el mismo 11 de septiembre se haya manifestado una ‘voluntad de dar una nueva constitución’”. No hay evidencia textual de que esto haya sido el mismo 11 de septiembre. Pero dos días más tarde, el 13 de septiembre de 1973, en las Actas Secretas de la primera sesión de la Junta de gobierno se consigna lo siguiente: “se encuentra en estudio la promulgación de una nueva constitución política del Estado, trabajo que está dirigido por el profesor universitario D. Jaime Guzmán”. Hay, por tanto, evidencia, dos días después del 11 de septiembre, que la Junta Militar reconoce y afirma el hecho de que Jaime Guzmán ha dado los primeros pasos en el proceso de creación de la nueva constitución²¹.

“Hay evidencia” de que la Junta Militar dijo algo, pero ¿qué prueba eso? Prueba que algunos miembros de la misma creían eso o, al menos, consideraron oportuno decir que creían eso. Políticamente hablando, eso es solo una afirmación. Esa afirmación es compatible con la lectura de lo de Pinochet como una tiranía, que por razones propagandísticas quería dar la impresión de regularización constitucional. Es compatible también con el hecho de que había contradicciones internas: yo creo, por ejemplo, que a Guzmán lo que le interesaba era un nuevo orden constitucional “tramposo” (es decir, uno que se sometiera a sus “anhelos”, aunque no tuvieran apoyo), mientras que a Pinochet le interesaba detentar el poder. Cristi cree que el sentido de esta afirmación es moralista, que lo que me importa es una argumento para denostar a Pinochet: “Atria objeta que se pueda afirmar que la Junta Militar se constituye como una dictadura, ya sea comisaria o soberana, porque ello sería reconocerle una actitud de respecto en relación al imperio de la ley y el Estado de derecho”²². Pero a mí no me interesa juzgar o moralizar, sino entender. Entender el proceso constituyente posterior a 1973 sin caer en los formalismos de Cristi: en el formalismo de creer que la dictadura era soberana porque se declaró soberana el 13 de septiembre, el formalismo de creer que, desde el 11 de marzo de 1981, hay una nueva constitución porque esa es la fecha del DL 3464, etcétera. De modo personal, lo que me interesa es discutir el problema constitucional alejado de todo formalismo jurídico.

4.2 El poder constituyente como poder del pueblo

Algo similar puede decirse acerca de la titularidad del poder constituyente. Entendido en un sentido formalista (ese sentido en que el poder constituyente se divide en poder constituyente originario y poder constituyente derivado, como si se tratara de dos especies del mismo género), la cuestión de qué es el poder constituyente es enteramente independiente de la cuestión de quién es su titular. Pero la idea de poder constituyente, como lo veremos algo más abajo, está internamente vinculada a la idea democrática, porque dado lo que es el poder constituyente, este solo puede residir en el pueblo.

Cristi no está de acuerdo. A su juicio, afirmar que el poder constituyente solo puede residir en el pueblo constituye:

[...]un error histórico, hecho que Carl Schmitt trae a la luz en su obra, como hago ver en el Ensayo IV de este mismo libro. Los casos que Schmitt considera tienen en vista, como punto de partida, la Constitución francesa de 1814, otorgada por Luis XVIII, quien expresamente se constituye como sujeto del Poder constituyente originario. Queda así establecido, a partir de ese momento, el principio constitucional que se denominó “principio monárquico”. Este mismo principio, que coloca al jefe de gobierno fuera de y por sobre la esfera constitucional, definió al Kaiser en la Constitución prusiana de 1871. En la misma situación quedó Hitler en 1933, cuando destruye la Constitución de Weimar, y Franco en 1938, cuando destruye la Constitución española de 1931²³.

Pero Schmitt se está refiriendo precisamente aquí al surgimiento de la idea democrática, al momento histórico en que la monarquía dejó de ser algo evidente y se enfrentó a la idea democrática y, al hacerlo, *debió recurrir al lenguaje de la democracia*. Ese es el momento en que comienza la decadencia del principio monárquico. Que el principio monárquico sea abandonado, como culminación de ese proceso de decadencia, no quiere decir que ya no existan monarquías, sino que ellas ya no constituyen un principio político legitimatorio (es decir, que sobre los reyes se lee hoy en la Revista *Hola*). Este proceso ha sido agudamente descrito por Ernst Wolfgang Bóckenförde, en un pasaje que conviene citar *in extenso*:

[El concepto de poder constituyente] era algo incompatible con el poder que correspondía a los monarcas, ya que su posición de dominio, incluso al sostener su soberanía hacia el exterior, se movía en un nexo de fundamentación completamente distinto. No obstante, en la época que sigue a 1815, en la confrontación entre monarquía y soberanía del pueblo como dos principios políticos formales, también los monarcas pretendieron asumir el poder constituyente. Ahora bien, este hecho solo da fe de hasta qué punto los nuevos principios de ordenación que surgieron en la Revolución francesa se habían convertido ya en algo indiscutible. La posición del monarca ya no se podía defender de forma plausible más que adoptando los conceptos y las posiciones jurídicas fundamentales desarrolladas a partir del principio de la soberanía del pueblo e intentando reclamarlas para el monarca. Y objetivamente esto no podía resultar.

El monarca, cuya posición reposaba sobre una instauración configurada jurídicamente, esto es, sobre una institución monárquica basada en un orden determinado de sucesión, no puede ser concebido también como el origen y la fuente, como aquello que no tiene forma y sin embargo da forma al orden jurídico y político, tal y como ocurre con la Constitución. Un

poder constitutivo del monarca como este no se puede fundamentar en el marco de un orden del mundo legitimado por Dios, en el que el monarca y su familia podían aparecer como legitimados de forma sacral, es decir, como representantes o delegados de la voluntad omnipotente de Dios. Para una ordenación secular del Estado esto ya no es posible. En su *Teoría del Estado*, Hermann Heller habla de la “dificultad insuperable que se plantea, en el marco de una concepción inmanente de lo universal, al querer atribuir el poder constituyente por la gracia de Dios a una familia”.

De acuerdo con todo ello, a la hora de señalar quién es el titular (sujeto) del poder constituyente, solo puede entrar en consideración el pueblo. El poder constituyente es conceptualmente poder constituyente del pueblo²⁴.

En el caso de la Junta Militar en 1973, puede decirse algo similar: el poder invocado por los militares golpistas fue el del pueblo (el bando n.º 5 pretende legitimar la acción de los militares golpistas en atención a que ellos actuaron “apoyado[s] en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar”). Por supuesto, los profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en defensa de su integrista característico, el cual los lleva a negar el desarrollo político occidental posterior a 1789, siguieron apelando a algo equivalente al principio monárquico. Y, entonces, Cristi concluye que el principio monárquico estaba vigente como principio de legitimación política.

4.3 El principio democrático y las trampas constitucionales

La cuestión también puede apreciarse por referencia al contenido de las trampas constitucionales. Es indudable que quienes redactaron el texto constitucional de 1980 no tenían compromiso genuino con la idea democrática, lo que se expresaba en su persistente preocupación de “mitigar los defectos y males del sufragio universal”²⁵. Algunos, como el profesor Raúl Bertelsen, creían (lo que no es extraño, dado que también se trataba de un profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile) que el principio democrático podía ser negado, y que, entonces, por ejemplo, el presidente de la República podía ser nombrado por un “comité de hombres buenos”, que él propuso llamar “el Consejo de la República”²⁶. Jaime Guzmán, sin embargo, fue capaz de

ver que la idea de constitución (y de poder constituyente) estaba en las condiciones políticas de la segunda parte del siglo xx, internamente vinculado al principio democrático, porque no hay otros principios de legitimidad política vigentes. Ante la propuesta del comisionado Bertelsen, la opinión de Guzmán es clara:

Piensa que se trata de un problema complejo, como lo manifestó en la reunión con el presidente de la República, y declara que su apoyo a la elección directa por sufragio universal no proviene de la creencia de que este sistema tiene todas las ventajas. Considera que también hay buenos argumentos para la fórmula del señor Bertelsen, pero que la ponderación de lo que es mejor es algo eminentemente prudencial y difícil de prever en sus resultados²⁷.

Es decir que, aunque a él le habría gustado que fuera de otro modo, el principio democrático (el poder constituyente del pueblo) era el único principio legitimatorio disponible. El poder constituyente solo puede ser del pueblo. Por eso, su adhesión al principio democrático es “eminentemente prudencial”, y la solución fue fingir que la Constitución se basaba en el principio democrático, pero neutralizarlo mediante las trampas constitucionales²⁸. Guzmán es explícito al respecto, al explicar el sentido del esfuerzo constitucional:

Que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario²⁹.

4.4 Poder constituyente y poderes constituidos

Cristi comienza comentando la afirmación de Andrés Chadwick que está citada en *La Constitución tramposa*³⁰ y también en la sección 1 de este artículo, conforme a la cual lo de 2005 es una reforma constitucional, no una nueva constitución, porque para que hubiera una nueva constitución sería necesario un proceso constituyente originario. Abusando algo de los términos, esta última afirmación es calificada por Cristi como “la trampa de Chadwick”³¹, una afirmación “equivocada y tramposa”³², en la que

además me acusa haber caído:

Atria acepta como válida la idea de que es necesario un proceso constituyente originario para dejar atrás la Constitución de 1980 y que, por tanto, la actual sigue estando presa del poder constituyente de Pinochet y la Junta Militar. Las muchas reformas que se le han hecho han supuesto la continuidad de ese poder constituyente. Esa es la trampa que monta Chadwick. Y Atria, preso en ella, se ve forzado a afirmar lo siguiente: “Es necesario, volviendo a la correcta afirmación de Andrés Chadwick en 2005, ‘un proceso constituyente originario’, es decir, un proceso de decisión constitucional que no esté determinado por las trampas de 1980”³³.

Pero esto es malinterpretar el argumento de principio a fin. Primero, Cristi omite toda referencia a la explicación de lo que caracteriza, en mis términos (no sé si también de Chadwick) a un “proceso constituyente originario” (una expresión que no hago mía como lo dejan en claro las comillas), a pesar de que dicha explicación aparece en el pasaje que él mismo cita: “es decir, un proceso de decisión constitucional que no esté determinado por las trampas de 1980”. La razón por la que Cristi no se hace cargo de esta calificación es que lo que él llama “un proceso constituyente originario” es una forma jurídica caracterizada por una asamblea.

Segundo, Cristi pasa de lo negativo a lo positivo de manera demasiado rápida e irreflexiva. Lo que estamos discutiendo no es una cuestión de taxonomías teóricas, sobre quién es el que efectivamente tiene el poder constituyente. Estamos discutiendo si es que el pueblo lo tiene o no. Y, como ya hemos establecido que el poder constituyente es solo del pueblo, al preguntarnos si lo tiene el pueblo nos estamos preguntando si hay poder constituyente, es decir, si vivimos bajo una constitución, es decir, bajo un conjunto de instituciones que entendemos como constituidas, como legitimadas por la voluntad de alguien. Uno podría, de hecho, formular la idea neutralizadora de Guzmán en términos anticonstitucionales: de lo que se trataba era de que no hubiera constitución, que no hubiera poder constituyente (del pueblo), porque se trataba de que viviéramos bajo instituciones que nos parecían naturales, que valían no porque alguien las hubiera querido, sino porque era la única manera en que es posible vivir dada nuestra naturaleza. La discusión sobre la Constitución de 1980, entonces, no es correctamente entendida como una discusión sobre la titularidad del poder

constituyente, porque ahí no hay discusión: es sobre la realidad política del poder constituyente. Lo que, a su vez, es una manera de decir sobre la manera en que entendemos nuestra convivencia común: estamos sujetos a la naturaleza, lo que entonces implica un determinado modelo económico (etcétera) que no depende de nuestra voluntad y vale porque siempre está ahí, porque es “natural”, o estamos sujetos a nuestra voluntad, y ese orden vale porque queremos que valga. Por supuesto que no creo que el pueblo chileno esté desde 1989 “preso del poder constituyente de Pinochet y la Junta Militar”. Lo que me interesa determinar es si estamos sujetos a un orden que descansa en la voluntad del pueblo (en su poder constituyente) o no. Y el “o no” no me obliga a intentar especificar aquí quién es ese a cuya voluntad estamos sujetos, porque quizás nuestra enajenación es total y experimentamos el orden como “natural”, en el sentido de que creemos que no estamos sujetos a nadie.

Tercero, el sentido de citar a Chadwick fue enfatizar lo dicho más arriba: que el sentido político de algo no es reducible a lo que los agentes políticos creen que están haciendo. En 2005, mientras el expresidente Lagos creía que estaba dictando una nueva constitución, Chadwick pensaba que estaba defendiendo la existente. En 2014, el ahora expresidente Lagos cree que es necesaria una nueva constitución, y sus críticos le citan sus palabras; mientras que Chadwick no cree necesaria una nueva constitución, porque la actual ha sufrido tantas reformas que ya no puede decirse que sea la de 1980, y sus críticos podrían citarle sus palabras de 2005. La conclusión, como está explicado en *La Constitución tramposa*, y también más arriba:

La confusión fue demasiado simétrica para ser casual. Esto muestra algo que es importante: no podemos descansar en lo que los actores creen que están haciendo para entender el sentido constitucional de lo que está pasando. Pero eso quiere decir no que podemos dar nuestros términos por sentados. Tenemos que tener un criterio independiente de lo que los actores creen que están haciendo para saber qué está pasando: qué es una constitución, cuándo una constitución es *nueva*, y qué relación hay entre eso y la exigencia de una Asamblea Constituyente³⁴

Cuarto, la verdad es que no me queda claro qué significa haber caído en “la trampa”. Entre otras cosas, porque Cristi siempre da por sentado el

significado de los términos que utiliza, cuando en realidad yo creo que en esta materia, mientras no hablemos “al revés” —en el sentido explicado en *La Constitución tramposa*—, no podremos salir de teorizaciones estériles. Cristi hace un esfuerzo por explicar qué es lo que quiere decir haber caído en la trampa. Primero dice que la trampa (“la idea de Chadwick”) es “la ausencia de toda limitación formal y substancial por parte del poder constituyente originario”³⁵. Cristi afirma que yo “reconozco” que no se trata de un poder normativo, al decir que una constitución es una decisión sobre identidad y forma política que está “radicalmente desvinculada [de] toda regla o procedimiento, porque de otro modo estaría reconociendo normatividades anteriores y eso es contradictorio”³⁶. Entonces yo ya estaría dentro de “la trampa” al decir que “solo el pueblo tiene poder constituyente”, por lo que la llamada “Constitución de 1980” no sería una nueva constitución. Esta reconstrucción del argumento es para mí enteramente ininteligible. Que una nueva constitución es una decisión que está desvinculada de normatividades anteriores es algo que a mi juicio es claro, y como hemos visto esa es la manera de unir la respuesta formal del jurista y la respuesta material política a la pregunta sobre cómo distinguir una nueva constitución de una reforma constitucional. Pero lo más insólito es lo que Cristi concluye. En *La Constitución tramposa* explico por qué, a mi juicio, la llamada “Constitución del 80” no es una constitución: como es una decisión de neutralización del pueblo, ella no puede ser entendida como fundada en el poder constituyente del pueblo; y como solo el pueblo tiene poder constituyente, no puede ser una constitución. Cristi continúa:

Esta conclusión es, a su vez, la premisa que Atria emplea para derivar la necesidad de una Asamblea Constituyente. Como Atria apela a la noción de Poder constituyente está claro que la asamblea que tiene en mente ejerce el Poder constituyente originario, es decir, es una asamblea que, en la expresión del presidente Lagos, “parte de cero” y escribe en una “hoja en blanco”³⁷.

¿“La premisa que Atria emplea para derivar la necesidad de una Asamblea Constituyente”? La pretensión de que en esta materia uno pueda derivar necesidades de premisas muestra que Cristi sigue preso en los formalismos que debe evitar esta discusión. Y si uno sigue el razonamiento que contienen los pasajes que el propio Cristi ha citado, la

manera de reconstruir el argumento está clara a mi juicio: es necesario un “proceso constituyente originario”, en el sentido de “un proceso de decisión constitucional que no esté determinado por las trampas de 1980”. Como ya hemos observado, Cristi no atiende a esta especificación de lo que el pasaje que critica quiere decir, y asume, de modo formalista, que un “proceso constituyente originario” es una Asamblea Constituyente. Como está explicado en *La Constitución tramposa*, y también en la sección 3 de este texto, esto es un error. La Asamblea Constituyente es el paradigma de una decisión “originaria” en el sentido de que se libera de las determinaciones contenidas en el orden institucional anterior, pero lo que importa es esto. La verdad es que si hubiera buscado no habría encontrado un mejor ejemplo de la confusión que introduce no entender que debemos hacer un esfuerzo por (en términos de *La Constitución tramposa*) hablar al revés. Porque Cristi habla siempre “al derecho”, es decir, siempre asumiendo que puede dar por sentados los conceptos que utiliza y entonces solo preguntarse por sus relaciones lógicas³⁸. Así, Cristi cree que del hecho de que la llamada “Constitución del 80” no sea una constitución *se sigue que* es necesario un proceso constituyente, y, del hecho de que sea necesario, *se sigue que* deba ser una Asamblea Constituyente, y, que del hecho de que sea una Asamblea Constituyente, *se sigue que* “parte de cero”. Pero el camino a ser recorrido es precisamente el inverso: hoy vivimos bajo una decisión neutralizadora. Que sea neutralizadora quiere decir que su contenido fundamental es negar la agencia política del pueblo; es decir, negar que a través de la acción política nosotros los ciudadanos podemos cambiar los términos de la vida en común. Ese es el sentido de los “cerrojos” constitucionales que justifica decir, con Guzmán, que ella configura la cancha de modo que quienes quieren instituciones distintas no pueden ganar, y han de terminar haciendo lo mismo que la udi “anhelaría”. La decisión neutralizadora se manifiesta en los cerrojos que están alojados en los procedimientos de decisión política, por lo que seguir esos procedimientos puede servir para cambiar muchas cosas —nunca he dicho ni creído que acabar con los senadores designados en 2005 fue, por ejemplo, una reforma puramente cosmética, pero que no haya sido cosmética no implica que sea una nueva constitución—, pero no servirán para cambiar la Constitución, es decir, no servirán para terminar con la neutralización. Como ocurrió en 1989 y en 2005. Eso es lo que quiere

decir “neutralización”. Pero, entonces, la decisión que acabe con la neutralización no puede ser tomada mediante los procedimientos ordinarios de reforma, donde se aloja la neutralización. Este “no puede”, no es una exigencia “lógica” sino política, que era la óptica, se recordará, que permitía unir la respuesta formal del derecho y la respuesta sustantiva de la política a la pregunta por la distinción entre constitución y reforma constitucional³⁹. Es en este sentido que es necesaria una nueva constitución, y eso es lo mismo que decir que es necesaria una decisión que no esté constreñida por decisiones anteriores. Este es el sentido en que ella debe partir de cero. “Partir de cero” no significa, como está cuidadosamente explicado en *La Constitución tramposa*⁴⁰, la fantasía infantil de que podemos hacer como si Chile no tuviera historia. Significa, más bien, que la nueva decisión constitucional ha de valer porque creemos que es correcta, no porque nos es impuesta. En esa nueva decisión podremos asumir algunas instituciones introducidas por la Constitución de 1980, pero no porque no podamos revisarlas dadas las neutralizaciones que esta contiene, sino porque nos hemos convencido de que son instituciones adecuadas. Una ley de reforma constitucional dictada conforme al procedimiento establecido en el artículo 127 del texto constitucional no sirve para esto, no porque sea “inmoral” o “ilegítima”, sino porque como en ese artículo está alojada la neutralización, no es posible distinguir lo que se mantiene porque está protegido por los cerrojos de lo que se mantiene porque creemos que es bueno que se mantenga.

4.5 1989 y todo eso

Aquí, para terminar, quiero comentar la interpretación de Cristi sobre el sentido constitucional del plebiscito de 1989, en que se aprobó un conjunto de reformas al texto permanente de la Constitución de 1980. Como Cristi y yo ya hemos intercambiado algunas observaciones al respecto, puede ser útil hacer una breve exposición de nuestra diferencia.

En *El pensamiento político de Jaime Guzmán*, Cristi afirma que en 1989 (o 1988) el pueblo recuperó el poder constituyente. Entonces ocurrió una transición inmediata, instantánea, de la dictadura a la democracia: “la transición también fue instantánea, completa y no gradual. El poder o potestad constituyente se trasladó, en esta ocasión, de

la Junta de gobierno al pueblo chileno”⁴¹. Cristi elabora:

Si bien es cierto que este plebiscito [de 1989], y el sentido de las reformas que introduce, confirma que el Poder constituyente ha sido retomado por el pueblo, esa toma de posesión es parcial. Persisten en el texto constitucional aprobado ciertas instituciones que no permiten la plena expresión del nuevo sujeto de Poder constituyente⁴².

En “Sobre la soberanía y lo político” yo comentaba lo extraño que es que Cristi sostenga que el poder constituyente pueda ser dividido, lo que parece que es una necesaria implicación de que ha sido recobrado “parcialmente”. Es extraño porque Cristi juzga con inusitada dureza a otro que, según él, afirmó que el poder constituyente era divisible. En efecto, cuando Hitler obtuvo en 1933 lo que Pinochet no logró el 6 de octubre de 1988, es decir, una ley de poderes extraordinarios, Carl Schmitt sostuvo que dicha ley atribuía al gabinete “una porción del poder de dictar leyes constitucionales [*verfassungsgesetzgebende Gewalt*]”⁴³. Esto es inaceptable, cree Cristi, porque:

Aun cuando decía que solo una “porción” del *poder de reformar la constitución* había sido conferido al gabinete, que él haya afirmado eso muestra temeridad irresponsable [*reckless temerity*]. Primero, Schmitt sabía perfectamente que el *poder constituyente* es indivisible (¿cómo podría ser de otro modo, si él fundaba la unidad política de un pueblo?). Entregar una porción de él es efectivamente entregarlo todo⁴⁴.

Es decir, como el poder constituyente es indivisible, fue temerario Schmitt al afirmar que el poder constituyente estaba dividido (Cristi malinterpreta aquí a Schmitt, como veremos). Pero en 1989 el pueblo chileno recuperó parcialmente su poder constituyente. Esto parece una contradicción. “Parcialmente” significa, después de todo, ‘perteneciente o relativo a una parte del todo’, por lo que Cristi parecía estar diciendo que en 1989 el poder constituyente habría quedado dividido: una “parte” en poder del pueblo y otra parte vaya a saber uno dónde. Ahora Cristi se corrige:

Cuando afirmé que la recuperación por parte del pueblo del poder constituyente originario fue “parcial” en 1989, en ningún caso sostuve que el poder constituyente había quedado

dividido en “porciones” entre el pueblo y la Junta Militar. Lo que he sostenido es que ese año, el pueblo de Chile recuperó *totalmente* su poder constituyente originario, pero tuvo también que aceptar, por las circunstancias del caso, un ejercicio parcial de su poder constituyente derivado⁴⁵.

Es más bien inusual elegir la fórmula lingüística “esa toma de posesión es parcial” para expresar la idea de que el pueblo ha recuperado “totalmente” el poder constituyente, pero ese no es el problema. La cuestión es qué quiere decir que el pueblo haya recuperado su poder constituyente. Lamentablemente, Cristi no cita la parte final del pasaje en que su afirmación es comentada, porque ahí estaba lo que importaba. A mi juicio, si en 1989 el poder constituyente ha sido recuperado “totalmente” por el pueblo, habrá que decir que las instituciones constitucionales desde entonces deben entenderse como instituciones a las que el pueblo se ha dado, en ejercicio de su poder constituyente ya recobrado. Es decir, el sentido que tiene el hecho de que el pueblo sea titular del poder constituyente es que las instituciones constituidas son reconducibles a su voluntad. Ahora Cristi insiste en la idea: “Lo que los plebiscitos de esos años [1988 y 1989] generan es, en verdad, la Constitución de 1989. Se trata de una Constitución legitimada por plebiscitos democráticos y fundada ahora en el poder constituyente del pueblo”⁴⁶.

Decir que, desde 1989, el poder constituyente reside en el pueblo es lo mismo que decir que las instituciones que contiene la Constitución *están legitimadas por plebiscitos democráticos y se fundan ahora en el poder constituyente del pueblo*. Por eso yo preguntaba, inmediatamente después de citar la afirmación de Cristi de que el pueblo recuperó el poder constituyente en 1989: “¿Quiere decir esto que desde 1989 debíamos entender que era [...] decisión del poder constituyente del pueblo que el Senado estuviera integrado por senadores designados?”. Lamentablemente, en su comentario a este pasaje, Cristi no creyó necesario responder a esta pregunta⁴⁷. Tendremos que hacerlo nosotros por él.

Cristi no querrá decir, supongo, que los senadores designados, el Tribunal Constitucional con su composición original, el sistema binominal, las leyes contramayoritarias y el Consejo de Seguridad Nacional fueron, en 1989, legitimadas por plebiscitos democráticos y

pasaron a quedar fundadas en el poder constituyente del pueblo. Por consiguiente, al decir que desde 1989 el poder constituyente en Chile reside en el pueblo, Cristi no está diciendo que las instituciones constituidas descansan en la voluntad del pueblo. Pero, entonces, ¿qué sí está diciendo? Una pista la da una afirmación suya un par de páginas más arriba, cuando dice que la recuperación por parte del pueblo de su poder constituyente originario “se logró como resultado de una vasta movilización popular que implicó grandes sacrificios y muestras de indudable heroísmo. Me parece que negarle esa conquista al pueblo constituye una negación de la realidad y una grave injusticia”⁴⁸.

Es decir, cuando Cristi dice que el pueblo recuperó totalmente su poder constituyente en rigor no está diciendo algo sobre la Constitución vigente, sino sobre el respeto y admiración que le merece el proceso de movilización que llevó al plebiscito del 5 de octubre. Que el pueblo tenga el poder constituyente no quiere decir que las instituciones constituidas se funden en su voluntad, y queda en pura moralidad abstracta. Esa es una marca de una reflexión formalista sobre la constitución y lo político, que carece de autoconciencia política (es decir, que no es consciente del sentido político de lo que afirma).

No cambia las cosas la introducción de la distinción entre poder constituyente originario y derivado⁴⁹. En realidad, por razones que he explicado en otra parte, no creo que esta manera de expresar la oposición sea correcta, porque el poder “constituyente” derivado en realidad no es poder constituyente⁵⁰. Es una potestad normativa, en cuanto a su forma igual que otras potestades normativas. Lo pintoresco de eso es que, en *El pensamiento político de Jaime Guzmán*, Cristi se manifestaba de acuerdo con esto:

La expresión “poder legislativo extraordinario” me parece más adecuada que “poder constituyente derivativo o constituido” para referirse a la facultad de reformar una constitución. Como se vio más arriba, el uso de las expresiones “poder constituyente originario” y “poder constituyente derivativo” contribuyó a enturbiar el sentido del proceso constitucional en Chile desde 1973 en adelante⁵¹.

Por eso, yo diría lo mismo respecto de 1988 o 1989: que la distinción entre “poder constituyente derivado” y “poder constituyente originario” (en la que ahora Cristi basa su argumento) contribuye a enturbiar el

sentido del proceso constituyente chileno. Cristi no explica qué lo llevó a pensar que una distinción que enturbiaba ahora es la distinción central.

Lo que suele llamarse poder constituyente “derivado” es el poder de dictar leyes constitucionales (esta distinción entre constitución y leyes constitucionales, aunque es una discusión fundamental para entender lo que estamos hablando y es discutida con cierta detención en *La Constitución tramposa*, no es siquiera mencionada por Cristi, salvo para ignorarla⁵²). La distinción entre *poder constituyente* y *potestades constituidas* es mucho más adecuada para tratar esta cuestión ya que apunta directamente a lo que es importante: en el caso del poder constituyente, se trata de un poder no constituido, es decir, un poder no dado por norma anterior alguna. Las potestades constituidas (que se diferencian por su contenido y, entonces, por sus diferentes configuraciones institucionales: la de dictar leyes constitucionales, la de dictar leyes ordinarias, la de dictar reglamentos, la de celebrar contratos, etcétera), si no son naturales, suponen un acto constituyente que no es entendido como ejercicio de potestades constituidas. La idea de poder constituyente surge de aquí, como una respuesta a la pregunta de por qué valen las reglas que constituyen las potestades normativas. Al decir que el poder constituyente reside en el pueblo, se está diciendo que ellas valen en la medida en que sean reconducibles al pueblo. Decir, como Cristi, que el poder constituyente “originario” (es decir, constituyente) reside en el pueblo desde 1989, pero que las potestades constituidas no son reconducibles a la voluntad del pueblo es malentender el sentido de la idea de poder constituyente, y reducirlo a una mera declaración de buena voluntad, sin contenido político alguno más que el de reconocer el heroísmo de quienes lucharon contra la dictadura. Esta reducción de los conceptos constitucionales fundamentales a pura normatividad, privándolos de todo contenido político real, es una marca de formalismo y parte de lo que explica la notoria esterilidad de la reflexión constitucional chilena aludida más arriba.

Este formalismo se manifiesta una y otra vez en la crítica de Cristi. Cristi dice que mi argumento es que, como la “Constitución” de 1980 no es en rigor una constitución (porque la decisión fundamental en la que consiste es neutralizar al pueblo, por lo que no puede ser entendida como fundada en la voluntad de este), “ello determina perentoriamente la necesidad de saltarse la institucionalidad actual y convocar una Asamblea

Constituyente original”⁵. Por las razones explicadas en la primera parte de este artículo y en *La Constitución tramposa*, creo que “saltarse la institucionalidad actual” no es la manera, y Cristi no podrá encontrar una afirmación mía que sostenga lo contrario. Lo que he dicho es negativo, no positivo: que, como la neutralización está alojada en los procedimientos institucionales, decidir a través de ellos es reproducir, no superar, la neutralización.

Cuando se trata de ofrecer una solución al problema constitucional, la sugerencia de Cristi es “restaurar selectivamente, y en plenitud, los artículos 109 y 110” de la Constitución de 1925, referidos a la función de los plebiscitos. La pregunta, entonces, es cómo se hace eso sin “saltarse la institucionalidad”. Cristi se pregunta: “¿Cuál sería el obstáculo para restaurar selectivamente, y en plenitud, sus artículos 109 y 110, reformados por la ley 17.284 del 23 de enero de 1970, referentes a la función de los plebiscitos?”⁵⁴.

Estos artículos permitían al presidente de la República convocar un plebiscito cuando una reforma constitucional hubiera sido enteramente rechazada por el Congreso. A mi juicio, por las razones explicadas más arriba, dar este poder unilateralmente al presidente no es conveniente. Pero si de “obstáculos” se trata, el principal que se me ocurre a mí es que esto sería una reforma al capítulo xv del texto constitucional vigente, que entonces requeriría $\frac{2}{3}$ de los votos de los senadores y diputados en ejercicio. La solución defendida más arriba (modificar el artículo 15 añadiendo, antes de su punto final, la frase “y la ley”) cumple una función análoga, aunque requiere solo de $\frac{3}{5}$ de los votos.

Pero, en lo que a nuestra discusión ahora se refiere, Cristi se revela todavía preso de su formalismo cuando explica el sentido de ese plebiscito: “¿No se abriría así la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, que, por supuesto, no sería originaria como exige el argumento de Chadwick [...]?”⁵⁵. A mi juicio, que sea lo que Cristi llama “originario” significa que no esté determinado en cuanto a sus posibilidades de decisión por la neutralización de la “Constitución” de 1980. Si no está determinado de ese modo, es “originario”, lo que quiere decir que la decisión que surja de él será una nueva decisión. Si está determinado, no será una nueva decisión, sino una decisión que se someta a la neutralización (es decir, una reforma constitucional, no una nueva constitución). Pero para Cristi esto no es lo importante. Lo

importante es un formalismo: no es originario porque estaría autorizado por una decisión anterior (Cristi no se refiere a cómo pasar de un plebiscito a una asamblea, pero asume que está pensando en que se plebiscite la posibilidad de una asamblea). Claro, en la sección 1 hemos visto que hay una vinculación entre estas dos cuestiones: si es autorizado por la institucionalidad vigente, no podrá impugnar la neutralización. Por eso, era importante distinguir los dos posibles sentidos que podía asumir el momento de validación institucional del cambio constitucional, como lo hicimos en la sección 2.

Recuérdese la manera correcta de entender la observación de Schmitt sobre lo que el Parlamento británico no puede hacer: Schmitt no está con eso prediciendo lo que puede o no pasar en Reino Unido, está diciendo que si el “parlamento británico” decidiera declarar a Reino Unido como una República soviética (y tuviera el poder político necesario para ello) ello debería ser entendido no como una “*Act of Parliament*” más, sino como una revolución (o un golpe de Estado), y el grupo de personas que lo hace en realidad no es el Parlamento de Westminster, sino una asamblea revolucionaria, aunque lo haya hecho en Westminster Palace. Del mismo modo, una asamblea como la que imagina Cristi, en la medida en que es creada conforme al ejercicio de potestades institucionales, surgirá sometida a determinaciones, referidas a lo que puede o no decidir y al procedimiento conforme al cual puede decidir, etc. Si la “asamblea” de Cristi se somete a esas determinaciones no es “originaria”, y lo que resulte de ella no es una nueva constitución. Si la asamblea no se somete a esas determinaciones, y reclama competencia de competencia (es decir, competencia para determinar sus propios procedimientos), entonces la situación deberá ser descrita diciendo que se trató de una asamblea “originaria”. Esto es pensar estas cuestiones libres de todo formalismo.

BIBLIOGRAFÍA

- Ackerman, Bruce. *We the People II. Transformations*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998.
- _____, *El futuro de la revolución liberal*. Barcelona: Ariel, 1996.
- _____, “Neo-Federalism?”, en *Constitutionalism and Democracy*, eds. Jon Elster y Rune Slagstad. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Actualidad Central. “Crisis política. ¿Es necesaria una nueva constitución?”, *CNN Chile*, 9 de mayo de 2015.
- Adams, Willi Paul. *The First American Constitutions. Republican Ideology and the Making of State Constitutions in the Revolutionary Era*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980.
- Adimark. *Encuesta de opinión pública*. Junio de 2014.
- Agamben, Giorgio. *Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life*. Stanford, CA.: Stanford University Press, 1998.
- Akerstram Andersen, Niels. *Power at Play*. Londres: Palgrave, 2009.
- Alberdi, J. B. *Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina*. Buenos Aires: Editorial Jackson, 1957.
- Albert, Mathias, y Barry Buzan. “Securitization, Sectors and Functional Differentiation”, *Security Dialogue* 42, 4-5 (2011): 413-425.
- Allen, J. W. *A History of Political Thought in the Sixteenth Century*. Totowa, N.J.: Rowman and Littlefield, 1977 [1928].
- Althusius, Johannes. *Politica methodice Digesta*. Indianápolis: A Liberty Classics Edition, 1995.
- Amstutz, Marc. “Eroding Boundaries: On Financial Crisis and an Evolutionary Concept of Regulatory Reform”, en *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation*, eds. Poul F. Kjaer, Gunther Teubner y Alberto Febbrajo. Oxford: Hart Publishing, 2011, 223-268.
- Amstutz, Marc, y Vaios Karavas. “Weltrecht: Ein Derridasches Monster”, en *Soziologische Jurisprudence: Festschrift für Günther Teubner zum 75. Geburtstag*, ed. Galf-Peter Callies et al. Berlín: De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2009, 645-672.
- Andersen, Torben M., y Tryggvi Thor Herbertsson. “Measuring Globalization”, *IZA Discussion Paper Series*, 817 (2003).
- Anderson, Benedict. *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica, 2007.

- Ansaldi, W., y V. Giordano. *América Latina. La construcción del orden*. Barcelona: Ariel, 2012.
- Appian. *Civil Wars, Book I*. Harvard: Harvard University Press, 2002.
- Arato, Andrew. "Multi-track Constitutionalism Beyond Carl Schmitt", *Constellations* 18, 3 (2011): 324-351.
- _____, "Redeeming the Still Redeemable: Post Sovereign Constitution Making", *International Journal of Culture, Politics, and Society*, 22 (2009): 427-443.
- _____, *Civil Society, Constitution, and Legitimacy*. Nueva York: Rowman & Littlefield Publishers, 2000.
- _____, "Forms of Constitution Making and Theories of Democracy", *Cardozo Law Review* 17, 2 (1995): 202-254.
- _____, "Dilemmas Arising from the Power to Create Constitutions in Eastern Europe", *Cardozo Law Review* 14 (1993): 661-674.
- Arendt, Hannah. *The Human Condition*. Chicago: Chicago University Press, 1998.
- _____, *Lectures on Kant's Political Philosophy*, ed. R. Beiner. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- _____, *On Revolution*. Nueva York: Penguin, 1990 [The Viking Press, 1963].
- _____, *Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought*. Nueva York: Viking, 1968.
- Aristóteles. *Politics*. Indianápolis: Hackett Publishing Company, Inc., 1998.
- Arnason, Johann P., Kurt A. Raaflaub y Peter Wagner, eds. *The Greekpolis and the invention of democracy: a politico-cultural transformation and its interpretations*. Nueva York: John Wiley & Sons, 2013.
- Arráiz, R. *Las constituciones de Venezuela (1811-1999)*. Caracas: Editorial Alfa, 2012.
- Ashcraft, Richard. *Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government*. New Jersey: Princeton University Press, 1986.
- Atria, Fernando. "La Constitución Tramposa y la responsabilidad del jurista", en *Nueva Constitución y Momento Constitucional. Visiones, antecedentes y debates*, ed. Francisco Zúñiga. Santiago: Legal Publishing Thomson Reuters, 2014.
- _____, *La Constitución tramposa*. Santiago: lom, 2013.
- _____, *Veinte años después. Neoliberalismo con rostro humano*. Santiago: Catalonia, 2013.
- _____, "Participación y alienación política: el problema constitucional", en *En Nombre Del Pueblo. Debate Sobre El Cambio Constitucional en Chile*, ed. Claudio Fuentes. Santiago: Ediciones Boll Cono Sur, 2010.
- _____, "Sobre la soberanía y lo político", en *Revista Derecho y Humanidades* 12 (2006): 47-93.
- Atria, Fernando et al. *El otro modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público*. Santiago:

Debate, 2013.

- Augsberg, Ino. "Observing (the) Law: The 'Epistemological Turn' in Public Law and the Evolution of Global Administrative Law", en *Public Law and the Evolution of Global Administrative Law: Regulatory Hybridization in the Transnational Sphere*, ed. Paulius Jurcys, Poul F. Kjaer y Ren Yatsunami. Leiden: Brill Publishing, 2013, 11-27.
- Azzellini, D. "Venezuela's Solidarity Economy: Collective Ownership, Expropriation, and Workers Self-Management", *The Journal of Labor and Society* 12 (2009): 171-191.
- Barclay, William. *De Regno et Regali Potestate adversus Buchanum, Brutum, Boucherium et reliquios monarchomacos*. París: G. Chaudiere, 1600.
- Bart, J., et al., eds. *La Constitution du 24 juin 1793. L'utopie dans le droit public frangais?* Dijon: Éditions Universitaires de Dijon, 1997.
- Bassa, Jaime, y Christian Viera. "Contradicciones de los fundamentos teóricos de la Constitución chilena con el Estado constitucional: Notas para su reinterpretación", *Revista de Derecho* 21, 2 (2008): 131-150.
- Beaud, Olivier. *Théorie de la Fédération*. París: Presses Universitaires de France, 2007.
- _____, "Démocratie, fédéralisme et constitution", en *L'Europe en voie de Constitution Pour un bilan critique des traveaux de la constitution*, eds. Beaud, Olivier et. al. Bruselas: Bruylant, 2004.
- _____, *Lapuisseance de l'Etat*. París: Presses Universitaires de France, 1994.
- Beck, Valentin. "Theorizing Fairtrade From a Justice-Related Standpoint", *Global Justice: Theory, Practice, Rhetoric* 3 (2010): 1-21.
- Bello, Andrés. "Las repúblicas hispanoamericanas", en *Fuentes de la cultura latinoamericana*, comp. L. Zea. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1995.
- Benton, L. *Law and Colonial Cultures*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Bethell, L. *Historia de América Latina. Vol. 7*. Barcelona: Crítica, 1991.
- Biral, Alessandro. "Hobbes: la societa senza sovrano", en *Il contratto sociale nella filosofia política moderna*, ed. Giuseppe Duso. Milán: FrancoAngeli, 1993, 51-108.
- Blumenwitz, Dieter. *La nueva constitución de la República de Chile*. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1983.
- Blumenwitz, Dieter, y Sergio Gaete Rojas. "Declaración de Profesores de Derecho de la Universidad Católica de Chile", en *La Constitución de 1980. Su legitimidad*. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1981, 47-54.
- Bobbio, Norberto. *Teoría general de la política*. Madrid: Trotta, 2003.
- _____, *El futuro de la democracia*. Barcelona: Plaza & Janes editores, 1985.
- _____, "Is There a Marxist Theory of the State? ", *Telos* 20 (1978): 5-16.
- Böckenforde, Ernst-Wolfgang. "El poder constituyente del pueblo. Un concepto límite del derecho constitucional", en *Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia*.

- Madrid: Trotta, 2000, 159-180.
- _____, “Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes. Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts”, en *Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zur Verfassungsrecht*. Fráncfort, 1991.
- Bodin, Jean. *On Sovereignty*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992 [1576].
- Brandalise, Adone. “Democrazia e deconstituzionalizzazione”, *Filosofia politica* 20, 3 (2006): 403-414.
- Brunkhorst, Hauke. “Constitutionalism and Democracy in the World Society”, en *The Twilight of Constitutionalism?*, eds. Petra Dobner y Martin Loughlin. Oxford-Nueva York: Oxford University Press, 2010, 179-200.
- Brunner, Otto. *Land and Lordship: Structures of Governance in Medieval Austria*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1992.
- Brutus, Julius (el Celta). *Vindiciae, contra tyrannos or, concerning the legitimate power of a prince over the people, and of the people over a prince*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994 [1579].
- Buchanan, George. *A Dialogue on the Law of Kingship among the Scots*. Edimburgo: The Saltire Society, 2006 [1579].
- Burbach, Roger, y Camila Piñeiro. “Venezuela’s Participatory Socialism”, *Socialism and Democracy* 21, 3 (2007): 181-200.
- Burchell, Graham. “Liberal Government and Techniques of the Self”, en *Foucault and Political Reason. Liberalism, Neo-Liberalism and Rationalities of Government*, eds. Andrew Barry, Thomas Osborne y Nikolas Rose. Chicago: Chicago University Press, 1996, 19-36.
- Burchell, Graham, Colin Gordon y Peter Miller. *The Foucault Effect. Studies in Governamentality*. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
- Burdeau, Georges. *Traité de Science Politique, Vol. IV*. París: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1983.
- Camou, Antonio. “El discurso sobre la crisis de gobernabilidad de las democracias capitalistas avanzadas: una revisión del informe de la ‘comisión trilateral’ (1975-2010)”, *Question* 1, 27 (2010).
- _____, *Los Desafíos de la Gobernabilidad*. México: FLACSO-ISUNAM, Plaza y Valdés, 2001.
- Carré de Malberg, Raymond. *La Loi, expression de la volonté générale*. París: Economica, 1984.
- _____, *Contribution à la Théorie Générale de l’Etat, Vol. II*. París: Librairie de la société du Recueil Sirey, 1922.
- Castells, Manuel. *Comunicación y poder*. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
- Castoriadis, Cornelius. “What Democracy?”, en *Figures of the Thinkable*. Stanford: Stanford

- University Press, 2007.
- _____, “Radical Imagination and the Social Instituting Imaginary”, en *The Castoriadis Reader*, ed. David Ames Curtis. Oxford: Blackwell Publishers, 1997.
- _____, *Philosophy, Politics, Autonomy. Essays in Political Philosophy*, ed. David Ames Curtis. Nueva York-Oxford: Oxford University Press, 1991.
- _____, “Pouvoir, politique, autonomie”, *Castoriadis, Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe III* (1990): 113-139.
- _____, “The First Institution of Society and Second-Order Institutions”, *Free Associations* 12 (1988): 39-51.
- _____, *The Imaginary Institution of Society*. Cambridge: Polity Press, 1987.
- _____, “La polis grecque et la création de la démocratie”, *Domaines de l'homme. Les carrefours du labyrinthe II* (1977): 261-306.
- Chignola, Sandro. “Governo, ordine politico, soggettivazione. Su federalismo e partecipazione. A proposito di federalismo”, seminario “Come pensare il federalismo?”, ed. Giuseppe Duso y Antonino Scalone. Padua: Dipartimento di Filosofia, Università di Padova, 2011, 20-21.
- _____, “In the Shadow of the State. Governance, Governamentalità, Governo”, en *Governance: oltre lo Stato*, ed. G. Fiaschi. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2008, 117-141.
- _____, “Sobre el Concepto de Historia”, *Ayer* 53 (2007): 75-95.
- _____, “Democrazia. Tocqueville e la storia del concetto”, en *Oltre la democrazia. Un itinerario attraverso i classici*, ed. Giuseppe Duso. Roma: Carocci, 2004, 209-239.
- _____, “Noi, ultimi viaggiatori?. Tocqueville e l’instabilità democrática”, *Contemporanea* II, 1 (1999): 111-118.
- _____, “Costituzione e potere sociale in Lorenz von Stein e Tocqueville”, en *Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna*, ed. Giuseppe Duso. Roma: Carocci, 1999, 341-361.
- Christodoulidis, Emilios. “Against Substitution: The Constitutional Thinking of Dissensus”, en *The Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form*, ed. M. Loughlin y N. Walker. OxfordNueva York: Oxford University Press, 2007, 189-208.
- Cicero. *De Re Publica, Book VI*. Harvard: Harvard University Press, 1994.
- Cisternas, Hernán. “Denominación de la Constitución abre debate entre juristas y parlamentarios”, *El Mercurio*, 21 de septiembre de 2005.
- Ciudadanos: “El proceso constituyente”, *CNN Chile*, 19 de octubre de 2015.
- Colón-Ríos, Joel. “Carl Schmitt and Constituent Power in Latin American Courts: The Cases of Venezuela and Colombia”, *Constellations* 18, 3 (2011): 365-388.
- Cordero, Gonzalo. “La Derecha en la Encrucijada”, *La Tercera*, 13 de abril de 2014.
- Corsi, Giancarlo. “Sociologia da Constituido”, *Revista da Faculdade de Direito da UFMG* 39

- (2001): 169-189.
- Couso, Javier. "Trying Democracy in the Shadow of an Authoritarian Legality: Chile's Transition to Democracy and Pinochet's Constitution of 1980", *Wisconsin International Journal* 29, 2 (2011): 393-415.
- Cristi, Renato. "Precisiones en torno a la noción de poder constituyente", en *El Constitucionalismo del Miedo. Propiedad, Bien Común y Poder Constituyente*, eds. Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle. Santiago: lom, 2014.
- _____, "Schmitt on Constituent Power and the Monarchical Principle", *Constellations* 18, 3 (2011): 352-364.
- _____, *El pensamiento político de Jaime Guzmán. Una biografía intelectual*. Santiago: LOM, 2011.
- _____, *El Pensamiento Político de Jaime Guzmán: Autoridad y Libertad*. Santiago: lom, 2000.
- _____, "The Metaphysics of Constituent Power: Schmitt and the Genesis of Chile's 1980 Constitution", *Cardozo Law Review* 21 (1999): 1749-1775.
- _____, *Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism: Strong State and Free Economy*. Cardiff: University of Wales Press, 1998.
- _____, "La noción de poder constituyente en Carl Schmitt y la génesis de la Constitución de 1980", *Revista Chilena de Derecho* 20 (1993): 229-250.
- Cristi, Renato, y Pablo Ruiz-Tagle. *El constitucionalismo del miedo. Propiedad, bien común y el poder constituyente*. Santiago: lom, 2014.
- _____, *La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano*. Santiago: RIL Editores, 2007.
- _____, *La República en Chile. Teoría y Práctica del Constitucionalismo Republicano*. Santiago: lom, 2006.
- Cummings, Wm. A. "The Monarchomachs. Theories of Popular Sovereignty in the Sixteenth Century", *Political Science Quarterly* 19, 2 (1904), 277-301.
- D'Entreves, Alexander Passarin. *The Medieval Contribution to Political Thought*. Oxford: Oxford University Press, 1939.
- Darnstadt, Thomas. *La trampa del consenso*. Madrid: Trotta, 2005.
- De Beze, Theodore. "Rights of Magistrates", en *Constitutionalism and Resistance in the Sixteenth Century*, ed. Julian H. Franklin. Nueva York: Pegasus, 1969 [1574].
- De Condorcet, Marquis. *Condorcet. Selected Writings*, ed. Keith Michael Baker. Indianápolis: The Bobbs-Merrill Company, Inc, 1976.
- _____, "Sur la nécessité de faire ratifier la Constitution par les citoyens", en *Oeuvres de Condorcet*. París: Firmin-Didot, 1847/1849.
- De Tocqueville, Alexis. *La democracia americana*. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

- De Vergottini, Giuseppe. *Las transiciones constitucionales. Desarrollo y crisis del constitucionalismo afinales del siglo xx*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002.
- Del Luchese, Filippo. "Machiavelli and constituent power: The revolutionary foundation of modern political thought", *European Journal of Political Theory* 0 (2014): 1-21.
- Derrida, Jacques. "Force of Law: 'The Mystical Foundation of Authority'", en *Deconstruction and the Possibility of Justice*, eds. Drucilla Cornell y Michael Rosenfeld. Nueva York: Routledge, 1992.
- _____, "Declarations of Independence", *New Political Science* 7, 1 (1986).
- Díaz, L. *Golpe al vacío*. Caracas: Lugar Común, 2012.
- Dinnen, Mark. "The Chávez' Government and the Battle over the Media in Venezuela", *Asian Journal of Latin American Studies* 25, 2 (2012): 25-53.
- Dippel, Horst. "The Changing Idea of Popular Sovereignty in Early American Constitutionalism: Breaking Away from European Patterns", *Journal of the Early Republic* 16, 1 (1996).
- Disch, Lisa. "Democratic representation and the constituency paradox", *Perspectives on Politics* 10, 3 (2012): 599-616.
- Dunning, Eric. "The Development of Modern Football", en *The Sociology of Sport: A Selection of Readings*, ed. Eric Dunning. Londres: Frank Cass, 1971.
- Duso, Giuseppe. "Begriffsgeschichte and the Modern Concept of Power", en *Political concepts and time: new approaches to conceptual history*, ed. J. Fernández. Santander: Cantabria University Press, 2011.
- _____, "Il potere e la nascita dei concetti politici moderni", en *Sui concetti politici e giuridici della costituzione dell'Europa*, eds. Sandro Chignola y Giuseppe Duso. Milán: Francoangeli, 2010, 176-184.
- _____, "Dalla storia concettuale alla filosofia politica", *Filosofia politica* I (2007): 65-84.
- _____, ed. *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna*. Milán: FrancoAngeli, 2006.
- _____, "La democrazia e il problema del governo", *Filosofia politica* 20, 3 (2006): 367-390.
- _____, "La costituzione mista e il principio del governo: il caso Althusius", *Filosofia politica* 19, 1 (2005): 77-96.
- _____, "La Génesis de la Representación Política Moderna", *Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional* 3 (2004).
- _____, ed. *Oltre la democrazia. Un itinerario attraverso i classici*. Milán: Carocci, 2004.
- _____, "Genesi e aporie dei concetti della democrazia moderna", en *Oltre la democrazia*, ed. Giuseppe Duso. Roma: Carocci editore, 2004.
- _____, "Crisi della sovranità: crisi dei diritti?", en *Il futuro dei diritti umani nella costruzione del nuovo ordine mondiale*, ed. Agostino Carrino. Nápoles: Guida, 2003, 83-

- _____, *La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*. Milán: Angeli, 2003.
- _____, “L’Europa e la fine della sovranità”, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 31 (2002): 123-126.
- _____, *La logica del potere: storia concettuale come filosofia politica*. Monza: Polimettrica, 2001.
- _____, “La libertà moderna e l’idea di giustizia”, *Filosofia Politica* 15 (2001): 5-28.
- _____, “Il governo e l’ordine delle consociazioni”, en *Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna*. Roma: Carocci, 2001, 77-94.
- _____, “Fine del governo e nascita del potere”, en *La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica*, ed. Giuseppe Duso. Roma-Bari: Laterza, 1999, 55-85.
- _____, “Una Prima Esposizione del Pensiero Politico di Althusius: La Dottrina del Patto e la Costituzione del Regno”, *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno* 25 (1996): 65-126.
- _____, “Patto sociale e forma politica”, en *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna*, ed. Giuseppe Duso. Milán: Angeli, 1993, 4-48.
- _____, “Fine del governo e nascita del potere”, *Filosofia Politica* 3 (1992).
- _____, “Logica e aporie della rappresentanza tra Kant e Fichte”, *Filosofia Politica* 1 (1987a): 31-55.
- Duso, Giuseppe, y Jean-Francois Kervégan, eds. *Crise de la démocratie et gouvernement de la vie*. Monza: Polimettrica, International Scientific Publisher, 2007.
- Duverger, Maurice. “Légitimité des gouvernements de fait”, *Revue du Droit Public* (1948).
- Dyzenhaus, David. “Constitutionalism in an old key: Legality and Constituent Power”, *Global Constitutionalism* 1-2 (2012): 229-260.
- _____, “The Politics of the Question of the Constituent Power”, en *The Paradox of Constitutionalism*, eds. Martin Loughlin y Neil Walker. Oxford: Oxford University Press, 2007, 129-146.
- El informante: “¿Por qué cambiar la constitución?”, *TVN*, 3 de diciembre de 2014.
- El País*, “El invierno estudiantil sacude Chile”, 21 de agosto de 2011.
- Elster, Jon. “Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process”, *Duke Law Journal* 45, 2 (1995): 364-396.
- Ewald, François. *L’Etat providence*. París: Grasset, 1986.
- Fairtrade International. “Fairtrade Labelling Organizations International”, online, <http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/about_us/Constitution_Fairtrade_International_EN_20131114.pdf>. [Consulta: 20-01-2015].
- Fenichel, Hanna. *The Attack of the Blob: Hannah Arendt’s Concept of the Social*. Chicago: University Of Chicago Press, 2000.

- Fernandois, Arturo. *Derecho Constitucional Económico. Regulación, tributos y propiedad*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2010.
- Fernandois, Joaquín. *Mundo y fin del mundo. Chile en la política mundial 1900-2004*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005.
- Festl-Pell, Diana. "Applying Macro-prudence in Financial Standard Setting", *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives* 1, 1 (2012): 15-31.
- Fioravanti, Maurizio. "Stato e costituzione", en *Lo stato moderno in Europa*. Bari-Roma: Laterza, 2002, 3-36.
- _____, *La scienza del diritto pubblico: dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*. Milán: Giuffré, 2001.
- Fischer-Lescano, Andreas, y Gunther Teubner. "Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law", *Michigan Journal of International Law* 25 (2004): 999-1046.
- Forsyth, Murray. "Thomas Hobbes and the Constituent Power of the People", *Political Studies* 29, 2 (1981): 191-203.
- Foucault, Michel. *The Courage of Truth (Lectures at the Collège de France)*. Londres: Palgrave Macmillan, 2011.
- _____, *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège De France, 1977-1978*. Nueva York: Picador, 2009.
- _____, *The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 1978-1979*. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2008.
- _____, *Nacimiento de la Biopolítica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.
- _____, *Defender la Sociedad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000.
- _____, *Power. The Essential Works of Foucault 1954-1984*, ed. J. D. Faubion Nueva York: The New Press, 2000.
- _____, *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. Nueva York: Vintage Books, 1990.
- Frank, Jason. "Unauthorized Propositions: *The Federalist Papers* and Constituent Power", *Diacritics* 37, 2-3 (2007): 103-120.
- Franklin, Julian. "Sovereignty and the Mixed Constitution: Bodin and his Critics", en *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, ed. J. H. Burns. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- _____, *Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
- _____, "Introduction", en *Constitutionalism and Resistance in the Sixteenth Century: three treatises*, ed. Franklin Julian. Nueva York: Pegasus, 1969.
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy. Theory and Practice in Europe and America*. Boston: Ginn and Company, 1950.
- Fritz, Christian. *American Sovereigns: The People and America's Constitutional Tradition*

- Before the Civil War*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Fuentes, Claudio. *El fraude*. Santiago: Hueders, 2013.
- _____, *El pacto. Poder, constitución y prácticas políticas en Chile 1990-2010*. Santiago: Ediciones udp, 2013.
- Fuentes, Claudio, y Alfredo Joignant, *La solución constitucional. Plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos*. Santiago: Catalonia, 2015.
- Fundación Democracia y Desarrollo, online, <<http://plataforma.tuconstitucion.cl>>.
- Gaete, Sergio. "El Poder constituyente", en *La Constitución de 1980. Su legitimidad*. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1981, 33-45.
- Gargarella, Roberto. "Latin American Constitutionalism, 1810-60", *Latin American Research Review* 39, 2 (2004): 141-153.
- Garretón, Manuel Antonio. *Política y sociedad entre dos épocas*. Rosario: HomoSapiens, 2000.
- Gauchet, Marcel. *La religion dans la démocratie*. París: Gallimard, 2001.
- Georges, Karl Ernst. *Ausführliches lateinisch-deutsches unddeutsch-lateinisches Handwörterbuch aus den Quellen zusammengetragen und mit besonderer Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten unter Berücksichtigung der besten Hilfsmittel*. Leipzig: Hahn, 1869.
- Germani, Gino. *The Sociology of Modernization*. Londres: Transaction Books, 1981.
- Gewirth, Alan. *Marsilius of Padua: The Defender of Peace*. Nueva York: Columbia University Press, 1951.
- Gierke, Otto. *Political Theories in the Middle Age*. Cambridge: Cambridge University Press, 1900.
- _____, *Natural Law and the Theory of Society 1500-1800*. Boston: Beacon Press, 1957.
- Giesey, Ralph E. "The Monarchomach Triumvirs: Hotman, Beza, and Mornay", *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance* 32, 1 (1970): 41-56.
- Gillespie, Michael Allen. *Ratifying the Constitution*. Kansas: University Press of Kansas, 1992.
- Ginzburg, Tom. "Fruto de la parra envenenada? Algunas observaciones comparadas sobre la constitución chilena", *Revista de Estudios Públicos* 133 (2014): 1-36.
- Giraudi, Giorgio, y M. Stella Righettini. *Le autorith amministrative indipendenti. Dalla democrazia della rappresentanza alla democrazia dell'efficienza*. Roma-Bari: Laterza, 2001.
- Gobierno de Chile. *Declaración de Principios del Gobierno de Chile*. Santiago: República de Chile, 1974.
- Gourgouris, Stathis. "On Self-Alteration", *Parrhesia* 9 (2010): 1-17.
- Grimm, Dieter. "The Achievements of Constitutionalism and its Prospects in a Changed World", en *The Twilight of Constitutionalism?*, ed. Petra Dobner y Martin Loughlin.

- Oxford-Nueva York: Oxford University Press, 2010, 3-22.
- _____, “Verfassung-Vertrag. Vertrag über eine Verfassung”, en *L’Europe en voie de Constitution Pour un bilan critique des travaux de la constitution*, ed. Beaud, Olivier et. al. Bruselas: Bruylant, 2004, 3-22.
- _____, “Una costituzione per l’Europa”, en *Il futuro della Costituzione*, ed. Gustavo Zagrebelsky, Pier Paolo Portinaro y Jorg Luther. Turín: Einaudi, 1996.
- _____, “Vertrag oder Verfassung”, *Staatswissenschaft und Staatspraxis*, 1995.
- _____, *Braucht Europa eine Verfassung?*. Múnich: Siemens-Stiftung, 1994.
- _____, *Die Zukunft der Verfassung*. Fráncfort: Suhrkamp, 1991.
- Groethuysen, Bernard. *Philosophie de la revolution Frangaise*. París: Gallimard, 1956.
- Grossi, Paolo. *Mitologie giuridiche nella modernità*. Milán: Giuffré, 2007.
- _____, “Il costituzionalismo moderno fra mito e storia”, *Giornale di Storia costituzionale* 11 (2006): 25-72.
- _____, *Prima lezione di diritto*. Roma-Bari: Laterza, 2003.
- Guizot, François. “L’esprit d’insurrection est un esprit radicalement contraire a la liberté”, *Discours h la Chambre des députés*, 29 de diciembre de 1830.
- Guzmán, Jaime. “El camino político”, *Realidad* 7 (1979): 13-23.
- _____, “El sufragio universal y la nueva institucionalidad”, *Realidad* 1 (1979): 33-44.
- Habermas, Jürgen. *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación de la vida pública*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009.
- _____, *Zeit der Übergänge*. Fráncfort: Suhrkamp, 2001.
- _____, *The Inclusion of the Other. Studies in Political Theory*. Cambridge, Mass.: The mit Press, 1998.
- _____, *Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of law and Democracy*. Cambridge, Mass.: The mit Press, 1996.
- _____, *La necesidad de revisión de la izquierda*. Madrid: Tecnos, 1991.
- Habermas, Jürgen, y William Rehg, “Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles?”, *Political Theory* 29, 6 (2001): 766-781.
- Hart, L. H. A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012 [1961].
- Hauriou, Maurice. *Précis de droit constitutionnel*. París: Sirey, 1929.
- Hegel, Georg W. F. “Grundlinien der Philosophie des Rechts. Oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse”, en *Werke in 20 Bänden mit Registerband, Band 7*. Fráncfort: Suhrkamp, 1986.
- Herrera, Hugo. *La derecha en la crisis del Bicentenario*. Santiago: Ediciones udp, 2014.
- Hidalgo, Paulo. *El Ciclo Político de la Concertación (1990-2010)*. Santiago: Uqbar Editores, 2011.

- Hilbink, Lisa. "The Constituted Nature of Constituents' Interests Historical and Ideational Factors in Judicial Empowerment", *Political Research Quarterly* 62, 4 (2009): 781-797.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan: Or the Matter, Forme, and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil*, ed. Ian Shapiro. New Haven: Yale University Press, 2010 [1651] [*Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil* (trad. de Manuel Sánchez Sarto). México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1980].
- _____, *On the Citizen*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998 [1642].
- Hobsbawm, Eric. *La era de la revolución, 1789-1848*. Buenos Aires: Crítica, 1997.
- Hoffe, Otfried. *Wirtschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürger: Politische Ethik im Zeitalter der Globalisierung*. München: C.H. Beck, 2004.
- Hofmann, Hasso. *Rappresentanza-Rappresentazione. Parola E Concetto Dall'antichità All'ottocento*. Milán: Giuffrè Editore, 2007.
- _____, "Riflessioni sull'origine, lo sviluppo e la crisi del concetto di costituzione", en *Sui concetti politici egiuridici della costituzionedell'Europa*, eds. Sandro Chignola y Giuseppe Duso. Milán: FrancoAngeli, 2005.
- _____, *Repräsentation: Studien zur Wort-und Begriffsgeschichte von der Antike bis zum 19. Jahrhundert*. Berlín: Duncker &Humbolt, 2003.
- _____, *Vom Wesen der Verfassung*. Berlín: Humboldt-Universität, 2002.
- Hotman, François. *Fraco-Gallia: Or An Account of the Ancient Free State of France*. Charleston: BiblioBazaar, 2007 [1573].
- Huneus, Carlos. "La interpelación de los estudiantes al sistema económico y político", *El Mostrador*, 16 de agosto de 2011.
- Jaffee, Daniel. *Brewing Justice. Fair Trade Coffee, Sustainability, and Survival*. Berkeley: California University Press, 2007.
- Jameson, J. Franklin. "The Early Political Uses of the Word Convention", *The American Historical Review* 3, 3 (1898): 477-487.
- Jameson, John Alexander. *The Constitutional Convention: Its History, Powers, and Modes of Proceedings*. Ithaca: Cornell University Library, 2009 [1867].
- Jászi, Oscar, y John D. Lewis. *Against the Tyrant. The tradition and Theory of Tyrannicide*. Nueva York: The Free Press, 1957.
- Jaume, Lucien. "Constituent Power in France. The Revolution and its Consequences", en *The Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form*, eds. Neil Walker y Martin Loughlin. Nueva York: Oxford University Press, 2008, 68-86.
- _____, "La théorie de la 'personne fictive' dans le 'Léviathan' de Hobbes", *Revue Française de Science Politique* 6 (1983).
- Jefferson, Thomas. *Jefferson: Political Writings*, eds. Appleby y Terence Ball. Cambridge:

- Cambridge University Press, 1999.
- Jessup, Phillip C. *Transnational Law*. New Heaven: Yale University Press, 1956.
- Joerges, Christian. "Rechtsstaat and Social Europe: How a Classical Tension Resurfaces in the European Integration Process", en *Rule of Law and Democracy. Inquiries into Internal and External Issues*, eds. Leonardo Morlino y Gianluigi Palombella. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2010, 163-186.
- Joerges, Christian, Poul F. Kjaer y Tommi Ralli, "A New Type of Conflicts Law as Constitutional Form in the Postnational Constellation", *Transnational Legal Theory* 2, 2 (2011): 153-165.
- Kalyvas, Andreas. *Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt and Hannah Arendt*. Nueva York: Cambridge University Press, 2009 [Londres: Cambridge University Press, 2008].
- _____, "The Basic Norm and Democracy in Hans Kelsen's Legal and Political Theory", *Philosophy and Social Criticism* 32, 5 (2006): 573-599.
- _____, "Popular Sovereignty, Democracy, and the Constituent Power", *Constellations*, 12, 2 (2005).
- _____, "Carl Schmitt and the Three Moments of Democracy", *Cardozo Review of Law* 21, 506 (2000): 1525-1566.
- _____, "Hegemonic sovereignty: Carl Schmitt, Antonio Gramsci and the Constituent Prince", *Journal of Political Ideologies* 5, 3 (2000): 343-376.
- Kantorowicz, Ernst H. *The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology*. Princeton: Princeton University Press, 1957.
- Karsenti, Bruno. "Elezione e giudizio di tutti", *Filosofia politica* 20, 3 (2006): 415-430.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Norms*. Oxford: Oxford University Press, 1991.
- _____, *Teoría pura del Derecho*. México D. F.: Editorial Porrúa-UNAM, 1991.
- _____, *Pure Theory of Law*. Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1989.
- _____, *Esencia y valor de la democracia*. Barcelona: Editorial Labor, 1977.
- King, Michael, y Chris Thornhill. "Luhmann on Law And Politics", en *Rethinking the Foundations of Modern Political Thought*, eds. Brett A. y Tully J. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- _____, *Niklas Luhmann's Theory of Politics And Law*. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Kjaer, Poul. *Constitutionalism in the Global Realm*. Oxon: Routledge, 2014.
- _____, "Transnational Normative Orders: The Constitutionalism of Intra and Trans-normative Law", *Indiana Journal of Global Legal Studies* 20, 2 (2013): 777-803.
- _____, "Legitimacy Through Constitutionalism", en *Legitimization in World Society*, eds. Aldo Mascareño y Katia Araujo. Surrey: Ashgate, 2012.

- _____, "Law of the Worlds-Towards an Inter-Systemic Theory", en *Recht Zwischen Dogmatik und Theorie: Marc Amstutz zum 50. Geburtstag*, eds. Stefan Keller y Stefan Wiprachtiger. Zürich: Dike Verlag, 2012, 159-175.
- _____, "Law and Order Within and Beyond National Configurations", en *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation*, eds. Poul F. Kjaer, Gunther Teubner y Alberto Febbrajo. Oxford: Hart Publishing, 2011, 395-429.
- _____, "The Concept of the Political in the Concept of Transnational Constitutionalism: A Sociological Perspective", en *After Globalization - New Patterns of Conflict and their Sociological and Legal Reconstruction*, eds. Christian Jorges y Tommi Ralli. Oslo: arena, 2011, 285-322.
- _____, "The Metamorphosis of the Functional Synthesis: A Continental European Perspective on Governance, Law and the Political in the Transnational Space", *Wisconsin Law Review* (2010): 489-533.
- _____, "The Political Foundations of Conflicts Law", *Transnational Legal Theory* 2, 2 (2011): 225-241.
- _____, *Between Governing and Governance. On the Emergence, Function and Form of Europe's Post-National Constellation*. Oxford-Portland: Hart Publishing, 2010.
- _____, "Post-Hegelian Networks: Comments on the Chapter by Simon Deakin", en *Networks: Legal Issues of Multilateral Co-operation*, eds. Marc Amstutz y Gunther Teubner. Portland: Hart Publishing, 2009, 75-86.
- _____, "Systems in Context: On the Outcome of the Habermas/Luhmann Debate", *Ancilla Iuris* 1 (2006): 66-77.
- Klabbers, Jan, Anne Peters y Geir Ulfstein. *The Constitutionalization of International Law*. Oxford-Nueva York: Oxford University Press, 2009.
- Klein, Claude. *Théorie et pratique de pouvoir constituant*. París: Presses Universitaires de France, 1996.
- Knodt, Eva, y William Rasch. "Systems Theory and the System of Theory", *New German Critique* 61 (1994): 3-7.
- Kooiman Jan. *Governing as Governance*. Nueva York: sage, 2003.
- _____, *Modern Governance*. Nueva York: sage, 1993.
- Koselleck, Reinhart. *Begriffsgeschichten*. Fráncfort: Suhrkamp Verlag, 2006.
- _____, *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*. Nueva York: Columbia University Press, 2004.
- _____, *Vergangene Zukunft*. Fráncfort: Suhrkamp Verlag, 1989.
- _____, "Linguistic Change and the History of Events", *The Journal of Modern History* 61, 4 (1989): 650-666.

- _____, “Wozu noch Historie?”, *Historische Zeitschrift* 212 (1971): 1-18.
- Koselleck, Reinhart, Otto Brunner y Werner Conze, eds. *Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Band 4*. Stuttgart: Klett Cotta, 2004.
- Koskenniemi, Martti. “Empire and International Law: The Real Spanish Contribution”, *University of Toronto Law Journal* 61, 1 (2011): 1-36.
- _____, “Miserable Comforters: International Relations as New Natural Law”, *European Journal of International Relations* 15, 3 (2009): 395-422.
- _____, *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Kramer, Larry D. *The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Kriegel, Blandine. *The State and the Rule of Law*. Princeton: Princeton University Press, 1995.
- La Fayette, Marquis de. *Mémoires, Correspondance et Manuscrits*, 1837-1838.
- Laband, Paul. *Le Droit de L'Empire Allemand. 6 Vols.*, eds. V. Giard y E. Briere. París: 1900-1901.
- Laboulaye, Édouard. *Questions Constitutionnelles*. París: Charpentier, 1872.
- Ladeur, Karl-Heinz, y Lars Viellechner. “Die transnationale Expansion staatlicher Grundrechte. Zur Konstitutionalisierung globaler Privatrechtsregimes”, *Archiv des Völkerrechts* 46, 1 (2008): 42-73.
- Larraín, Luis. *El regreso del modelo*. Santiago: Libertad y Desarrollo, 2012.
- Lawson, George. *Politica Sacra et Civilis*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992 [1660].
- Lazzarato, Maurizio. “Biopolitique/Bioéconomie”, *Multitudes* 22 (2005).
- Lefort, Claude. *The Political Forms of Modern Society*. Cambridge, Mass: mit Press, 1986.
- Levinson, Sanford, ed. *Responding to Imperfection. The Theory and Practice of Constitutional Amendment*. Princeton: Princeton University Press, 1995.
- Lindahl, Hans. “Constituent Power and Reflexive Identity: Towards an Ontology of Collective Selfhood”, en *The Paradox of Constitutionalism*, eds. Martin Loughlin y Neil Walker. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Livy. *History of Rome*. Harvard: Harvard University Press, 1997.
- Locke, John. *The Second Treatise of Government. An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991 [1689].
- López, Hernán. “La ruta de la nueva Constitución”, *La Tercera*, 10 de mayo de 2015.
- Loughlin, Martin. “What is Constitutionalisation?”, en *The Twilight of Constitutionalism?*,

- eds. Petra Dobner y Martin. Oxford-Nueva York: Oxford University Press, 2010, 47-72.
- _____, *Foundations of Public Law*. Nueva York: Oxford University Press 2010.
- _____, "In Defence of Staatslehre", *Der Staat* 48, 1 (2009): 1-28.
- _____, "Constituent Power", en *The Idea of Public Law*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Loughlin, Martin, y Neil Walker. *The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form*. Nueva York: Oxford University Press, 2008.
- Loveman, Brian, y Elizabeth Lira, eds. *Arquitectura política y seguridad interior del Estado, 1811-1990*. Santiago: dibam-lom, 2000.
- Luhmann, Niklas. *Teoría Política en el Estado de Bienestar*. Madrid: Alianza Editorial, 2007.
- _____, *Die Politik der Gesellschaft*. Fráncfort: Suhrkamp, 2002.
- _____, *Grundrechte als Institution*. Berlín: Druncker & Humblot, 1999 [Berlín: Duncker & Humblot, 1965].
- _____, *Complejidad y modernidad*. Madrid: Editorial Trotta, 1998.
- _____, *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Fráncfort: Suhrkamp, 1997.
- _____, "Globalization or World Society: How to Conceive of Modern Society?", *International review of sociology* 7, 1 (1997): 67-79.
- _____, *Poder*. México D.F.: Anthropos, 1995.
- _____, *Das Recht der Gesellschaft*. Fráncfort: Suhrkamp, 1993.
- _____, *Beobachtungen der Moderne*. Opladen: Westdeutsche Verlag, 1992.
- _____, "Verfassung als evolutionäre Errungenschaft", *Rechtshistorisches Journal* 9, 1 (1990): 176-220.
- _____, *Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie*. Fráncfort: Suhrkamp, 1988 [1984].
- _____, "Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft", en *Soziologische Aufklärung, Band 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1987.
- _____, "Die Zukunft der Demokratie", en *Soziologische Aufklärung, Band 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1987.
- _____, "Die Weltgesellschaft", en *Soziologische Aufklärung, Band 2: Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft*. Fráncfort: Suhrkamp, 1970.
- _____, *Legitimation durch Verfahren*. Fráncfort: Suhrkamp, 1969.
- Maclean, A. H. "George Lawson and John Locke", *Cambridge Historical Journal* 9, 1 (1947): 69-77.
- Madison, James. *The Federalist* XLIX, en Hannah Arendt, *On Revolution*. Nueva York: Penguin, 1990.

- _____, "The Federalist 54, 38", en *The Federalist Papers*, ed. Clinton Rossiter. Nueva York: The Modern Library, 1938.
- Maier, Pauline. *From Resistance to Revolution: Colonial Radicals and the Development of American Opposition to Britain, 1765-1776*. Nueva York: Alfred A. Knopf, 1972.
- Marshall, T. H. "Citizenship and Social Class", en *Class, Citizenship and Social Development*. Chicago: The University of Chicago, 1964.
- Marsilius of Padua. *Defensor Pacis*. Toronto: University of Toronto Press, 1956 [1324].
- Martinsen, Renate, Thomas Saretzki y Georg S. von Herausgegeben, eds. *Politik und Technik: Analysen zum Verhältnis von technologischem, politischem und staatlichem Wandel am Anfang des 21. Jahrhunderts*. Fráncfurt: Verlag, 2001.
- Marx, Karl. "The Civil Wars in France", en *The Marx-Engels Reader*, ed. Robert C. Tucker. Nueva York: W. W. Norton, 1978.
- _____, "Critique of Hegel's Doctrine of the State", en *Early Writings*. Nueva York: Penguin Books, 1975.
- Mascareño, Aldo. "Justicia global y justicia sectorial en la sociedad mundial. Momentos de universalidad en la lex mercatoria", *Dilemata* 13 (2013): 45-68.
- _____, "Sattelzeit y transición. Fundamentos estructurales y semánticos de la modernidad en América Latina", en *América Latina Moderna*, ed. A. Strück. Caracas: Ediciones Universidad Central de Venezuela, 2013, 1-44.
- _____, *Die Moderne Lateinamerikas*. Bielefeld: Transcript, 2012.
- _____, *Diferenciación y contingencia en América Latina*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010.
- Mascareño, Aldo, y Elina Mereminskaya. "The Making of World Society Through Private Commercial Law: The Case of the unidroit Principles", *Uniform Law Review-Revue de droit uniforme* 18, 3-4 (2013): 447-472.
- Mayol, Alberto. *El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo*. Santiago: lom, 2012.
- McClellan, James, y M. E. Bradford, eds. *Jonathan Elliot's Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Constitution as Recommended by the General Convention at Philadelphia in 1787. Vol. 2*. Cumberland, Va.: J. River Press, 1989.
- McCormick, John. *Machiavellian Democracy*. Nueva York: Cambridge University Press, 2011.
- McIlwain, Charles Howard. *Constitutionalism: Ancient and Modern*. Ithaca: Cornell University Press, 1947.
- _____, *The Growth of Political Thought in the West: From the Greeks to the End of the Middle Ages*. Nueva York: Macmillan Company, 1932.
- Meller, Patricio. "A Review of Chilean Privatization Experience", *The Quarterly Review of*

- Economics and Finance* 33 (1993): 95-112.
- Michelman, Frank. *Brennan and Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- _____, "Constitutional Authorship", en *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, ed. Larry Alexander. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Mommsen, Theodore. *Le Droit Public Romain, Vol. IV*. París: Thorin and Fils, 1884.
- Morandé, Pedro. *Cultura y modernización en América Latina*. Madrid: Ediciones Encuentro, 1987.
- Morgan, Edmund S. *Inventing the People. The Rise of Popular Sovereignty in England and America*. Nueva York-Londres: W. W. Norton & Company, 1989.
- Morgenthau, Hans J. "The Problem of Sovereignty Reconsidered", *Columbia Law Review* 48, 3 (1948): 341-365.
- Morris, Richard B. "The People and the States: Constitutional-making and Constituent Power", en *The Forging of the Union 1781-1789*. Nueva York: Harper and Row Publishers, 1987.
- Moulian, Tomás. *Chile actual. Anatomía de un mito*. Santiago: lom, 1997.
- Muñoz León, Fernando. "Recensión: Cristi, Renato, El pensamiento político de Jaime Guzmán: una biografía intelectual", *Revista de Derecho* (Universidad Austral), 25 (2012): 267-269
- Näf, Werner. "Frühformen des modernen Staates im Spätmittelalter", *Historische Zeitschrift* 225 (1951).
- Napoleón. *Correspondance de Napoleon I, Vol. III*. París, 1859.
- Navarrete, Jorge. "No va más", *La Tercera*, 12 de junio de 2011.
- Negri, Antonio. "From the Right to Resistance to Constituent Power", en *The Porcelain Workshop: For a New Grammar of Politics*. Los Ángeles, CA: Semiotext(e), 2008.
- _____, *Reflections on Empire*. Cambridge: Polity, 2008.
- _____, *A constitutionalização simbólica*. San Pablo: Editora Acadêmica, 2007.
- _____, *33 lezioni su Lenin*. Roma: Manifestolibri, 2004.
- _____, *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
- _____, *Macchina tempo: rompicapi, liberazione, costituzione*. Milán: Feltrinelli, 1982.
- _____, *Enciclopedia Fischer Feltrinelli (Stato e politica)*. Milán: Feltrinelli, 1970.
- Negri, Antonio, y Michael Hardt. "Sovereignty", en Antonio Negri, *Reflections on Empire*. Cambridge: Polity, 2008.
- Neves, Marcelo. *Transconstitutionalism*. Oxford: Hart Publishing, 2013.
- Nevins, Allan. *The American States during and after the Revolution, 1775-1789*. Nueva York: The Macmillan Company, 1927.
- Nicholls, Alex, y Charlotte Opal. *Fair Trade: Market-Driven Ethical Consumption*. Londres:

- Sage, 2005.
- Ober, Josiah. *Democracy and Knowledge: Innovation and Learning in Classical Athens*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- _____, "The Original Meaning of 'Democracy': Capacity to Do Things, Not Majority Rule", *Princeton/Stanford Working Papers in Classics*, Paper n° 090704, 2007, online. http://web.stanford.edu/group/dispersed_author/docs/OriginalMeaningDemocracy_Ober.pdf.
- _____, *Athenian Legacies: Essays on the Politics of Going on Together*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- _____, *Political Dissent in Democratic Athens: Intellectual Critics of Popular Rule*. Princeton: Princeton University Press, 1998.
- _____, *The Athenian Revolution: Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory*. Princeton: Princeton University Press, 1996.
- _____, *Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology, and the Power of the People*. Princeton: Princeton University Press, 1989.
- Ober, Josiah, y Charles Hendrick. *Demokratia: A Conversation on Democracies, Ancient and Modern*. Princeton: Princeton University Press, 1996.
- Oppliger, Marcelo, y Eugenio Guzmán, *El malestar en Chile ¿Teoría o diagnóstico?* Santiago: RILEditores, 2012.
- Oro Tapia, Luis. *¿Qué es la política?* Santiago: RILEditores, 2003.
- Otano, Rafael. *Crónica de la transición*. Santiago: Planeta, 1995.
- Paine, Thomas. "Rights of Man, Part i", en *Paine: Collected Writings*, ed. Eric Foner. Nueva York: The Library of America, 1995 [1791].
- _____, "The Forester, Letter IV, May 8, 1776", en *Paine: Collected Writings*, ed. Eric Foner. Nueva York: The Library of America, 1995 [1776].
- _____, "The Last Crisis XIII, 1783", en *Paine: Collected Writings*, ed. Eric Foner. Nueva York: The Library of America, 1995 [1783].
- _____, *Los derechos del hombre*. Madrid: Alianza Editorial, 1995. Palmer, R. R. *The Age of the Democratic Revolution. A Political History of Europe and America 1760-1800, Vol. I*. New Jersey: Princeton University Press, 1959.
- Parker, Cristián. *Otra lógica en América Latina: religión popular y modernización capitalista*. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 1996.
- Parsons, Talcott. *The System of Modern Societies*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1971.
- Parsons, Talcott, y Edward Shils. *Toward a General Theory of Action*. Cambridge: Harvard University Press, 1962.
- Pernice, I., y F. Mayer. "La costituzione integrata dall'Europa", en *Diritti e costituzione nell'Unione Europea*, eds. Gustavo Zagrebelsky et. al. BariRoma: Laterza, 2003, 43-68.

- Pettit, Philip. *On the People's Terms. A Republican Theory and Model of Democracy*. Nueva York: Cambridge University Press, 2012.
- _____, "Varieties of Public Representation", en *Political Representation*, eds. Susan Stokes et. al. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 61-89.
- _____, *Republicanism, A Theory of Freedom and Government*. Nueva York: Oxford University Press, 1997.
- Pietschmann, Horst. *Die staatliche Organisations des kolonialen Iberoamerika*. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag, 1980.
- Pío XI. *Encyclia Quadragesimo Anno*, 1931, online. <[http://goo.gl/ Q5YtK3](http://goo.gl/Q5YtK3)>. [Consulta: diciembre de 2013].
- Pitkin, Hanna. *The Attack of the Blob: Hannah Arendt's Concept of the Social*. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- _____, *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- PNUD, *Desarrollo Humano en Chile 2015. Los tiempos de la politización*. Santiago: PNUD, 2015.
- _____, *Mecanismos de cambio constitucional en el mundo. Análisis desde la experiencia comparada*. Santiago: PNUD, 2015.
- Pocock, John G. A. *The Machiavellian Moment*. Princeton: Princeton University Press, 1975.
- Preuss, Ulrich. "The Constitution as the 'Object of all Longing'", en *Constitutional Revolution. The Link between Constitutionalism and Progress*. New Jersey: Humanities Press, 1995.
- _____, *Constitutional Revolution. The Link between Constitutionalism and Progress*. New Jersey: Humanities Press, 1995.
- _____, "Constitutional Powermaking for the New Polity: Some Deliberations on the Relations between Constituent Power and the Constitution", en *Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy: Theoretical Perspectives*, editado por Michel Rosenfeld. Durham: Duke University Press, 1994.
- Raaflaub, Kurt, ed. *Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of Orders*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2006.
- Raaflaub, Kurt, Josiah Ober y Robert Wallace. *Origins of Democracy in Ancient Greece*. Berkeley, CA: University of California Press, 2007.
- Ramazani, Rouhollah K., y Robert Fatton. *The future of liberal democracy: Thomas Jefferson and the contemporary world*. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Rametta, Gaetano. "Le 'difficolta del potere costituente", *Filosofia politica* 20, 3 (2006): 391-402.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. Nueva York: Columbia University Press, 1993 [*Liberalismo político* (trad. de Sergio René Madero Báez). México D.F.: Fondo de Cultura Económica-

UNAM, 1995].

Regnault-Warin, M. *Mémoires pour servir à l'histoire de la vie du Général La Fayette et à l'histoire de l'Assemblée Constituante*. París: Chez Hesse et C, Libraires, 1824.

Renner, Mortiz. "Occupy the System! Societal Constitutionalism in Transnational Corporate Accounting", *Indiana Journal of Global Legal Studies* 20, 2 (2013): 941-964.

_____, "Death by Complexity-The Financial Crisis and the Crisis of Law in World Society", en *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation*, eds. Poul F. Kjaer, Gunther Teubner y Alberto Febbrajo. Oxford: Hart Publishing, 2011, 93-112.

Renson, Roland. "Fair Play: Its Origins and Meanings in Sport and Society", *Kinesiology* 41, 1 (2009): 5-18.

República Bolivariana de Venezuela. "Ley que autoriza al ciudadano Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan", *Gaceta Oficial*, N° 40.297, 2013.

_____, "Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan", *Gaceta Oficial*, N° 38.617, 2007.

Revista de Derecho Público. Número especial "Reformas Constitucionales", marzo de 2014.

Revista Time, "The protester", edición diciembre 2011.

Ronchi, Lorraine. *The Impact of Fair Trade on Producers and Their Organisations: A Case Study with Coocafé in Costa Rica*. Sussex: University of Sussex, 2002.

Rosavanlon, Pierre. "Revolutionary Democracy", en *Democracy Past and Future*, editado por Sam Moyn. Nueva York: Columbia University Press, 2007.

Ross, Robert N. "Ellipsis and the Structure of Expectation", *San Jose State Occasional Papers in Linguistics* 1 (1975): 183-191.

Rossiter, Clinton. *1787: The Grand Convention*. Nueva York: W.W. Norton & Company, 1987.

Rouquié, Alain. *A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina*. Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2011.

Runciman, David. "The paradox of political representation", *Journal of Political Philosophy* 15, 1 (2007): 93-114.

Salazar, Gabriel. *En el nombre del Poder popular constituyente (Chile siglo xxi)*. Santiago: lom, 2011.

Sallaberry, Juan Pablo. "Debate a la carta", *Revista Qué Pasa*, 7 de noviembre de 2013.

Salle, Jean-Baptiste. *Examen critique de la Constitution de 1793*. París: 1795.

Sánchez, Carlos. *El Poder Constituyente*. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1957.

Sarmiento, Domingo Faustino. *Facundo. Civilisation and Barbarism*. Londres: University of California Press, 2003.

- Sassen, Saskia. *The global city: New York, London, Tokyo*. Princeton: Princeton University Press, 2001.
- Schamis, Héctor. *Re-forming the State: The Politics of Privatization in Latin America and Europe*. Michigan: University of Michigan Press, 2002.
- Scharpf, Fritz W. "Legitimacy in the Multilevel European Polity", *European Political Science Review* 1, 02 (2009): 173-204. Y en *The Twilight of Constitutionalism?*, eds. Petra Dobner y Martin Loughlin. Oxford-Nueva York: Oxford University Press, 2010, 89-119.
- Schmitt, Carl. *Dictatorship*. Cambridge: Polity Press, 2013 [Die Dictatur. Berlín: Duncker & Humblot, 1994].
- _____, *The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol*. Chicago: The Chicago University Press, 2008.
- _____, *Constitutional Theory*. Durham: Duke University Press, 2008 [1928].
- _____, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*. Berlín: Duncker und Humblot, 1993 [1933].
- _____, *Teoría de la Constitución*. Madrid: Alianza, 1992 [1928].
- _____, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. Cambridge, Mass.: The mit Press, 1988 [1922].
- _____, "Das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich", *Deutsche Juristen-Zeitung* 38, 1 (1933): 455-458.
- Schor, Miguel. "Constitutionalism Through the Looking Glass of Latin America", *Texas International Law Journal* 41 (2006): 1-37.
- Schürmann, Reiner. *On Heidegger's Being and Time*. Abingdon: Routledge, 2008.
- Segovia, Carolina, y Ricardo Gamboa, "Chile: el año en que salimos a la calle", *Revista de Ciencia Política* 32, 1 (2012): 67.
- Shklar, Judith N. *Men and Citizen. A Study of Rousseau's Social Theory*. Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 1969.
- Sidney, Algernon. *Discourses Concerning Government*. Indianápolis: Liberty Fund, 1996 [1680].
- Sierra, Lucas, ed. *Diálogos constitucionales. La academia y la cuestión constitucional en Chile*. Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2015.
- Sieyes, Emmanuel. "Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l'homme et du citoyen", en *Orateurs de la Révolution française. Les Constituants, Vol. I*, eds. François Furet y Ran Halévi. París: Bibliotheque de la Pléiade, 1989.
- _____, *¿Qué es el Tercer Estado?* Madrid: Alianza Editorial, 2003 [Génova: Librairie Droz, 1970].
- Sigmund, Paul E. "Revolution, Counterrevolution, and the Catholic Church in Chile", *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* (1986): 25-35.

- Skinner, Quentin. "Hobbes on representation", *European Journal of Philosophy* 13, 2 (2005): 155-184.
- _____, "The Machiavellian Legacy: Origin and Outcomes of the Conflict Between Politics and Morality in Modernity", *EUI Working Paper* SPS 99/2, 68 (1999).
- _____, *Liberty Before Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- _____, "The Republican ideal of political liberty", en *Machiavelli and Republicanism*, eds. G. Bock, Q. Skinner y M. Viroli. Nueva York: Cambridge University Press, 1993, 293-390.
- _____, "Two Views on the Maintenance of Liberty", en *Contemporary Political Theory*, ed. Philip Pettit. Nueva York: McMillan, 1991, 35-58.
- Skocpol, Theda, Peter Evans y Dietrich Rueschemeyer. *Bringing the State Back In*. Nueva York-Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Spinoza, Benedict de. *A Theologico-Political Treatise*. Nueva York: Dover Publications, 1951 [1670].
- Stankiewicz, W. J. *Politics and Religion in Seventeenth-century France: A Study of Political Ideas from the Monarchomachs to Bayle, as Reflected in the Toleration Controversy*. Berkeley-Los Angeles, CA: University of California Press, 1960.
- Sternberger, Dorf. *Patriotismo Constitucional*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001.
- Stichweh, Rudolf. "Dimensionen des Weltstaats im System der Weltpolitik", en *Weltstaat und Weltstaatlichkeit. Beobachtungen globaler politischer Strukturbildung*, eds. Mathias Albert y Rudolf Stichweh. Heidelberg: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, 25-36.
- _____, *Inklusion und Exklusion. Studien zur Gesellschaftstheorie*. Bielefeld: Verlag, 2005.
- Stourzh, Gerald. "Constitution: Changing Meanings of the Term from the Early Seventeenth to the Late Eighteenth Century", en *Conceptual Change and the Constitution*, eds. Terrence Ball y J. G. A. Pocock. Lawrence, KS: University Press of Kansas, 1988.
- Strauss, Leo. *¿Qué es filosofía política?* Madrid: Ediciones Guadamarra, 1970.
- Tamanaha, Brian Z. "Understanding legal pluralism: past to present, local to global", *Sydney L. Rev.* 30 (2008): 375-411.
- Tarrow, Sidney. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
- Teichman, Judith A. *The Politics of Freeing Markets in Latin America: Chile, Argentina, and Mexico*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.
- Teubner, Gunther. *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- _____, "A Constitutional Moment? The Logics of 'Hitting the Bottom' en *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation*, eds. Poul F. Kjaer, Gunther Teubner y Alberto Febbrajo. Oxford: Hart Publishing, 2011, 3-42.

- _____, ed. *Global Law Without a State*. Aldershot: Dartmouth, 1997.
- The Economist*, “Chile’s discontents: the dam breaks”, 27 de agosto de 2011.
- The New York Times*, “With Kiss-Ins and dances, young Chileans push for reform”, 4 de agosto de 2011.
- Thornhill, Christopher. “A Sociology of Constituent Power: The Political Code of Transnational Societal Constitutions”, *Indiana Journal of Global Legal Studies* 20, 2 (2013): 551-603.
- _____, “Sociological Enlightenments and the Sociology of Political”, *Philosophy Revue Internationale de Philosophie* 259 (2012): 55.
- _____, *A Sociology of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- _____, “Niklas Luhmann and the Sociology of the Constitution”, *Journal of Classical Sociology* 10, 4 (2010): 315-337.
- Tilly, Charles. *Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook*. Barcelona: Crítica, 2010.
- Tocqueville, Alexis de. *Democracy in America*. Nueva York: Vintage Books, 1990 [1835].
- Tolerancia Cero. “Anuncio del proceso constituyente”. *CHV*, 5 de mayo de 2015.
- Torres, Ana Teresa. *La herencia de la tribu*. Caracas: Editorial Alfa, 2009.
- Ullmann, Walter. *Principles of Government in the Middle Ages*. Abingdon: Routledge, 2010 [1961].
- Urbinati, Nadia. *Democracy Disfigured: Opinion, Truth and the People*. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
- _____, *Democrazia in Diretta. Le Nuove Sfide Alla Rappresentanza*. Milán: Feltrinelli, 2013.
- _____, *Representative Democracy: Principles and Genealogy*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- Valenzuela, S. “La Constitución de 1980 y el inicio de la redemocratización en Chile”, *Working Paper 242*, The Hellen Kellogg Institute for International Studies (1997).
- Van Hulle, Karel. “Prudence: a Principle or an Attitude?”, *European Accounting Review* 5, 2 (1996): 375-382.
- Vane, Henry. *The Tryal of Sir Henry Vane*. Londres: 1662.
- Vanossi, Jorge R. *Teoría Constitucional. 2 Vol.* Buenos Aires: Depalma, 1975.
- Vatter, Miguel. “Republics are a Species of State. Machiavelli and the Genealogy of the Modern State”, *Social Research* 81, 1 (2014): 217-241.
- _____, “The quarrel between populism and republicanism: Machiavelli and the antinomies of plebeian politics”, *Contemporary Political Theory* 11 (2012) (3): 242.
- _____, “The People Shall Be Judge Reflective Judgment and Constituent Power in Kant’s

- Philosophy of Law”, *Political Theory* 39, 6 (2011): 749-776.
- _____, *Constitución y resistencia. Ensayos de teoría democrática radical*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2010.
- _____, “Republicanism or Modern Natural Right? The Question of the Origins of Modern Representative Democracy and the Political Thought of Giuseppe Duso”, *The New Centennial Review* 10, 2 (2010): 99-120.
- _____, “Il Potere Del Popolo E La Rappresentanza in Rawls E Nel Repubblicanesimo Civico”, *Filosofia Politica* 24, 2 (2010): 263-284.
- _____, “Pettit and Modern Republican Political Thought”, en *>NOMOS XLVI: Political Exclusion and Domination*, eds. Melissa S. Williams y Stephen Macedo. Nueva York: New York University Press, 2005, 118-163.
- _____, *Between Form and Event: Machiavelli’s Theory of Political Freedom*. Nueva York: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- Velasco, Eugenio. *El objeto ante la jurisprudencia*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1941.
- Véliz, C. *The New World of the Gothic Fox. Culture and Economy in English and Spanish America*. Berkeley: University of California Press, 1994.
- _____, *The Centralist Tradition of Latin America*. Princeton, NJ.: Princeton University Press, 1980.
- Vía Pública. “Proceso constituyente”, *24 Horas*, 13 de octubre de 2015.
- Villacañas, Jose. L. “Oltre la democrazia o cómo abandonar la teología política. A propósito de G. Duso editor. Oltre la democrazia. Un itinerario attraverso i classici”, *Aai iMOV. Revista de Filosofia* 39 (2006): 61-68.
- Viroli, Maurizio. *Machiavelli Founders of Modern Political and Social Thought*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Viroli, Maurizio, y Antony Shugaar. *The liberty of servants: Berlusconi’s Italy*. Princeton: Princeton University Press, 2012.
- Von Benda-Beckmann, Franz, Keebet Von Benda-Beckmann y Julia Eckert. *Germany Rules of Law and Laws of Ruling: On the Governance of Law*. Franham: Ashgate, 2009.
- Von Bezold, Friedrich. “Die Lehre von der Volkssouveranität während des Mittelalters”, *Historische Zeitschrift* 36 (1876).
- Von Mohl, Robert. *Staatsrecht, Völkerrecht und Politik (Constitutional law, international law and politics)*. Nabu Press, 2012 [1860].
- _____, *Encyklopadie der Staatswissenschaften (Encyclopedia of political sciences and political economics)*. Michigan: University of Michigan Library, 2009.
- _____, *Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates (Police science according to the principles of the constitutional state)*. Cestnut: Adamant Media Corporation, 2000.

- Von Rochau, Ludwig August. *Grundsätze der Realpolitik. Angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands*. Berlín: Ullstein, 1972.
- Von Stein, Lorenz. *Movimientos sociales y monarquía*. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1957.
- Watson, Alan, ed. *The Digest of Justinian*. Pensilvania: University of Pennsylvania Press, 2011.
- Weber, Max. "Bureaucracy", en *From Max Weber: Essays in Sociology*, eds. H. H. Gerth y C. Wright Mills. Abingdon: Routledge, 2009, 196-244.
- _____, *La política como profesión*. Madrid: Espasa Calpe, 2001.
- Willis, Garry. "James Wilson's New Meaning for Sovereignty", en *Conceptual Change and the Constitution*, eds. Terence Ball y K. G. A. Pocock. Kansas: University Press of Kansas, 1988.
- Willke, Helmut. *Regieren*. Wiesbaden: Springer VS, 2014.
- Wolin, Sheldon. "Transgression, Equality, and Voice", en *Demokratia: A Conversation on Democracies Ancient and Modern*, eds. J. Ober y C. Hedrick. Princeton: Princeton University Press, 1996.
- _____, "Norm and Form: The Constitutionalizing of Democracy", en *Athenian Political Thought and the Reconstruction of American Democracy*, eds. Peter Euben, John R. Wallach y Josiah Ober. Ithaca: Cornell University Press, 1994.
- _____, "Collective Identity and Constitutional Power", en *The Presence of the Past: Essays on the State and the Constitution*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990.
- Wood, Gordon S. *The Creation of the American Republic 1776-1787*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1998.
- _____, *Representation in the American Revolution*. Charlottesville: The University Press of Virginia, 1969.
- Young, Thomas. "To the inhabitants of Vermont, a Free and Independent State, bounding on the River Connecticut and Lake Champlain", en *History of Vermont, natural, Civil and Statistical, In Three Parts*, ed. Zadock Thompson. Burlington: Chauncey Goodrich, 1842.
- Zagrebelsky, Gustavo. "I paradossi della riforma costituzionale", en *Il futuro della costituzione*, ed. Gustavo Zagrebelsky et al. Turín: Einaudi, 1996, 293-314.
- _____, "Storia e costituzione", en *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno*, ed. Paolo Grossi. Milán: Giuffré, 1993, 177-227.
- Zagrebelsky, Gustavo, Pier Paolo Portinaro y Jorg Luther, eds. *Il futuro della costituzione*. Turín: Einaudi, 1996.
- Zumbansen, Peer. "Law and Legal Pluralism: Hybridity in Transnational Governance", en *Regulatory Hybridization in the Transnational Sphere*, eds. Paulius Jurcys, Poul F. Kjaer y Ren Yurakami. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013, 49-70.

Zúñiga, Francisco. "Nueva Constitución y Operación Constituyente. Algunas notas acerca de la Reforma Constitucional y de la Asamblea Constituyente", *Estudios Constitucionales* 11, 1 (2013): 511-540.

Zweig, Egon. *Die Lehre vom pouvoir constituent: ein beitrag zum staatsrecht der Franzosischen revolution*. Tubinga: J. C. B. Mohr, 1909.

AGRADECIMIENTOS

A CADA uno de los autores, por animarse a participar en la obra y contribuir en la deliberación de ideas en el marco del proceso constituyente en Chile.

A Felipe Padilla, por su trabajo profesional, diligente e infatigable en las traducciones y correcciones. No tenemos duda: sin su aporte este trabajo no hubiera sido posible.

A la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, por atreverse a abrir espacios de discusión que posibilitan el origen de libros como este.

Al Fondo de Cultura Económica, en especial a Julio Sau, por acoger libros que contribuyen a pensar la política y profundizar la reflexión democrática en nuestros días.

ÍNDICE DE AUTORES

DIEGO SAZO MUÑOZ

Cientista político, Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue director del Centro de Análisis e Investigación Política (CAIP) y editor de la revista *Pléyade*, dedicada a estudios de ciencias sociales y humanidades. Ha sido profesor de Teoría Política en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es compilador del libro *La revolución de Maquiavelo. El príncipe 500 años después* (2013). Actualmente, se desempeña como asesor político en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

ANDREAS KALYVAS

Doctor en Political Science, Columbia University (Estados Unidos). Es profesor asociado de Political Science en The New School for Social Research. Su investigación se centra en la teoría democrática y la historia de las ideas políticas, particularmente la relación entre democracia y constitucionalismo. Es autor de los libros *Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt* (2008) y *Liberal Beginnings: Making a Republic for the Moderns* (2008), con Ira Katznelson. Su trabajo sobre Carl Schmitt y poder constituyente le han valido el reconocimiento del mundo académico internacional. Su última obra es *Carl Schmitt, Dialogues on Power and Space* (2015), compilado con Federico Finchelstein.

MIGUEL VATTER

Doctor en Philosophy, New School for Social Research (Estados Unidos). Es profesor titular en la New South Wales University (Australia). Sus áreas de estudio son la historia del pensamiento político, la teoría legal y la filosofía contemporánea. Su trabajo *Between Form and Event. Machiavelli's Theory of Political Freedom* (2000) se cuenta entre las

interpretaciones más relevantes desde la filosofía continental de la obra de Maquiavelo. Entre sus últimas publicaciones, destacan *Constitución y resistencia. Ensayos de teoría democrática radical* (2012) y *The Republic of the Living: Biopolitics and the Critique of Civil Society* (2014). Ha sido un defensor del republicanismo en el debate público constitucional.

GONZALO BUSTAMANTE

Filósofo y doctor en Culture of Economics, Erasmus University Rotterdam (Holanda). Ha sido investigador visitante en el Institut für Sozialforschung de Fráncfort (Alemania), así como en la Università di Padova (Italia). Participa en The History of Concepts Group, American Political Science Association y Asociación Chilena de Ciencia Política. Junto a Andrés Estefane, es compilador del libro *La agonía de la convivencia, Violencia política, historia y memoria* (2014). Ha publicado artículos y reseñas en *Constellations. An International Journal of Critical and Democratic Theory*, *Dialogue: Canadian Philosophical Review*, *Philosophy & Social Criticism*, *Revista Cultura Económica*, entre otros. Actualmente, es profesor de Filosofía y Teoría Política de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

POUL F. KJAER

Doctor en Law, European University Institute (Italia). Es profesor en el Business and Politics Department, Copenhagen Business School (Dinamarca). Sus áreas de investigación son la teoría constitucional, la economía política y la gobernanza global. Entre sus últimas publicaciones, destacan *Between Governing and Governance: On the Emergence, Function and Form of Europe's Post-national Constellation* (2010) y *Constitutionalism in the Global Realm: A Sociological Approach* (2014).

SANDRO CHIGNOLA

Doctor en Storia del Pensiero politico e delle Istituzioni Politiche, Università di Torino (Italia). Es profesor titular de Filosofía Política en la Università di Padova (Italia). Sus áreas de especialización son la historia de los conceptos políticos, la teoría crítica y la teoría política alemana y francesa del siglo XIX y XX. Entre sus últimas publicaciones, destacan *Il*

tempo rovesciato. La Restaurazione e il governo della democrazia (2011) y *Foucault oltre Foucault. Una politica della filosofia* (2014). Su trabajo se ubica entre los más destacados de su generación en el mundo filosófico italiano.

GIUSEPPE DUSO

Licenciado en Filosofía, Università di Padova (Italia). Es profesor titular de la Facoltà di Lettere e Filosofia de la misma universidad. Su investigación se ha centrado en la historia de los conceptos políticos y la conceptualización de la democracia representativa. Estas líneas de trabajo le han valido un importante reconocimiento internacional. Entre sus últimas publicaciones, destacan *Ripensare la costituzione. La questione della pluralità* (2008), compilada en conjunto con Mario Bertolissi, y *Libertà e costituzione in Hegel* (2013).

ALDO MASCAREÑO

Doctor en Soziologie, Universität Bielefeld (Alemania). Es profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del Centro de Teoría Social y Política de la misma casa de estudios. Sus principales temas de investigación son las teorías sociológicas y del derecho, con especial énfasis en la sociología contemporánea y teorías de la cultura. Es autor y coeditor de *Die Moderne Lateinamerikas. Weltgesellschaft, Region und funktionale Differenzierung. Bielefeld* (2012), *Durch Luhmanns Brille. Herausforderungen an Politik und Recht in Lateinamerika und in der Weltgesellschaft* (2012), compilado con Peter Birle y Matias Dewey, y *Legitimization in World Society* (2012), trabajo conjunto con Kathya Araujo.

VALENTINA VERBAL

Magíster en Historia, Universidad de Chile. Es profesora del Departamento de Formación General de la Universidad Viña del Mar y en la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Entre sus líneas de investigación, se destaca la historia militar de Chile en el siglo XIX. Actualmente, es consejera del movimiento Evolución Política (Evópoli) y directora de Investigación del centro de estudios Horizontal. En el ámbito del debate ciudadano, su aporte ha sido en temas limítrofes, de género y constitucionales.

FRANCISCO ZÚÑIGA

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Con estudios de posgrado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile y la Academia Judicial. Sus principales áreas de investigación son el derecho público y comparado. Entre sus publicaciones, destacan varios libros colectivos sobre estudios constitucionales y sistemas electorales. Ha sido miembro de instituciones científicas internacionales y nacionales como la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, la Sociedad de Derecho Parlamentario y presidente de la Asociación por un Nuevo Constitucionalismo. Actualmente, es coordinador del Programa Constitucional, Legislación y Justicia de la Fundación Instituto Igualdad y miembro de su Consejo Directivo Académico.

RENATO CRISTI

Doctor en Philosophy, University of Toronto (Canadá). Es profesor del Department of Philosophy, de la Wilfrid Laurier University (Canadá). Sus áreas de especialización son la metafísica, el republicanismo y el constitucionalismo. Es autor del libro *El pensamiento político de Jaime Guzmán* (2000) y coautor, junto a Pablo Ruiz-Tagle, de *La república en Chile* (2006) y *El constitucionalismo del miedo. Propiedad, bien común y el poder constituyente* (2014). Ha sido protagonista, activamente, del debate público sobre el problema constitucional y la herencia del pensamiento de Jaime Guzmán.

FERNANDO ATRIA

Doctor en Law, University of Edinburgh (Escocia). Es profesor de Derecho en la Universidad de Chile. Su investigación académica se orienta al derecho civil, la filosofía del derecho y el derecho constitucional. Entre sus últimas publicaciones, destacan *El otro modelo: del orden neoliberal al régimen de lo público* (2013) y *La Constitución tramposa* (2013). Esta última obra recibió el premio Mejores Obras Literarias 2014 entregado por el Consejo del Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Junto a una destacada carrera académica, ha participado de modo fundamental en el debate sobre una nueva constitución, así como sobre la reforma educacional.

- ¹ Thomas Paine, *Los derechos del hombre* (Madrid: Alianza Editorial, 1995).
- ² Revista *Time*, “The protester”, edición diciembre 2011.
- ³ Charles Tilly, *Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook* (Barcelona: Crítica, 2010), 37-42, y Eric Hobsbawm, *La era de la revolución, 1789-1848* (Buenos Aires: Crítica, 1997), 61-62.
- ⁴ Miguel Vatter, *Constitución y resistencia. Ensayos de teoría democrática radical* (Santiago: Ediciones UDP, 2012).
- ⁵ Benedict Anderson, *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo* (México: Fondo de Cultura Económica, 2007), 23-24.
- ⁶ Sidney Tarrow, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza Editorial, 2009), 110-112.
- ⁷ Leo Strauss, *¿Qué es filosofía política?* (Madrid: Ediciones Guadarrama, 1970), 11.
- ⁸ Luis Oro Tapia, *¿Qué es la política?* (Santiago: RIL editores, 2003), 161.
- ⁹ Max Weber, *La política como profesión* (Madrid: Espasa Calpe, 2001).
- ¹⁰ PNUD, *Mecanismos de cambio constitucional en el mundo. Análisis desde la experiencia comparada* (Santiago: PNUD, 2015), 26-37.
- ¹¹ Manuel Castells, *Comunicación y poder* (Madrid: Alianza Editorial, 2009), 29-31.
- ¹² Estamos en presencia de prácticas legítimas cuando “la titularidad del poder político y la modalidad de su ejercicio coinciden con la creencia que determina quién debe gobernar y con la manera cómo debe hacerlo”. Véase Luis Oro Tapia, *¿Qué es la política?* (Santiago: RIL editores, 2003), 125.
- ¹³ Joaquín Fernandois, *Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004* (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005), 17.
- ¹⁴ Tomás Moulian, *Chile actual. Anatomía de un mito* (Santiago: LOM Ediciones, 1997), 81-134.
- ¹⁵ Carolina Segovia y Ricardo Gamboa, “Chile: el año en que salimos a la calle”, *Revista de Ciencia Política*, 32, n.º 1 (2012): 67.
- ¹⁶ “El invierno estudiantil sacude Chile” (*El País*, 21 de agosto de 2011).
- ¹⁷ “With Kiss-Ins and dances, young Chileans push for reform” (*The New York Times*, 4 de agosto de 2011).
- ¹⁸ “Chiles discontents: the dam breaks” (*The Economist*, 27 de agosto de 2011).
- ¹⁹ Alberto Mayol, *El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo* (Santiago: LOM Ediciones, 2012).

²⁰ Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente, Javier Couso y Alfredo Joignant, *El otro modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público* (Santiago: Debate, 2013).

²¹ Gabriel Salazar, *En el nombre del poder popular constituyente (Chile, siglo XXI)* (Santiago: LOM Ediciones, 2012).

²² Jorge Navarrete, “No va más” (*La Tercera*, 12 de junio de 2011); Carlos Huneeus, “La interpelación de los estudiantes al sistema económico y político” (*El Mostrador*, 16 de agosto de 2011); y Hugo Herrera, *La derecha en la crisis del Bicentenario* (Santiago: Ediciones UDP, 2014).

²³ Marcel Oppliger y Eugenio Guzmán, *El malestar en Chile ¿Teoría o diagnóstico?* (Santiago: RILEditores, 2012), 44-46.

²⁴ Luis Larraín, *El regreso del modelo* (Santiago: Libertad y Desarrollo, 2012).

²⁵ PNUD, *Desarrollo Humano en Chile 2015. Los tiempos de la politización* (Santiago: PNUD, 2015).

²⁶ Ídem, ib., 17.

²⁷ Adimark, *Encuesta de opinión pública* (junio de 2014).

²⁸ Claudio Fuentes, *El fraude. Crónica sobre el plebiscito de la Constitución de 1980* (Santiago: Hueders, 2014).

²⁹ Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle, *La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano* (Santiago: RILEditores, 2007), 177-196.

³⁰ Fernando Atria, *La Constitución tramposa* (Santiago: LOM Ediciones, 2014), 44-54.

³¹ Rafael Otano, *Crónica de la transición* (Santiago: Planeta, 1995), 83-85.

³² Claudio Fuentes, *El pacto. Poder, constitución y prácticas políticas en Chile 1990-2010* (Santiago: Ediciones UDP, 2013).

³³ Proyecto digital de la Fundación Democracia y Desarrollo: <<http://plataforma.tuconstitucion.cl>>.

³⁴ Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle (eds.), *El constitucionalismo del miedo. Propiedad, bien común y poder constituyente* (Santiago: LOM Ediciones, 2014), 179-192.

³⁵ Jürgen Habermas, *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación de la vida pública* (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009), 268-274.

³⁶ “Causa Justa. Entrevista a Michael Sandel” (*Revista Qué Pasa*, 22 de enero de 2016).

³⁷ Se destacaron: “Democracia y poder constituyente” (Universidad Adolfo Ibáñez, 17 de abril de 2014), donde participaron todos los autores de este libro y se originó la idea de la obra. También “Reforma constitucional: ¿Refundación del Estado o progreso institucional?” (Pontificia Universidad Católica, 10 de agosto de 2015).

³⁸ Entre ellos, “Debates constitucionales” (Centro de Estudios Públicos, 15, 22 y 29 de octubre de 2013), “Debate constitucional y su dimensión económica” (Libertad y Desarrollo, 1 de agosto de 2014), “Nueva constitución: hacia un pacto nacido en democracia” (Instituto Igualdad, 27, 28 y 29 de agosto de 2014), “Cambio constitucional en democracia” (PNUD, BID, IDEA Internacional, 22 de

enero de 2015), “Crisis política ¿cambio a la constitución?” (Chile, 21,13 de marzo de 2015), “Diálogos constitucionales” (Espacio Público, 17 de agosto de 2015) y “Los procesos de construcción constitucional en América Latina” (Universidad de Chile, 21 y 22 de octubre de 2015).

³⁹ Hasta octubre de 2015, el ministro del Interior, Jorge Burgos, recibió propuestas constitucionales de casi todos los conglomerados políticos de Chile: Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Democracia Cristiana (DC), Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Partido por la Democracia (PPD), Partido Socialista (PS), Izquierda Ciudadana (IC), Partido Comunista (PC), Partido Progresista (PRO) y Revolución Democrática (RD).

⁴⁰ Entre los principales están “Debate a la carta” (*Revista Qué Pasa*, 7 de noviembre de 2013) y “La ruta de la nueva Constitución” (*La Tercera*, 10 de mayo de 2015).

⁴¹ Se destacan *El Informante*: “¿Por qué cambiar la constitución?” (TVN, 3 de diciembre de 2014), *Tolerancia Cero*: “Anuncio del proceso constituyente” (CHV, 5 de mayo de 2015), *Actualidad Central*: “Crisis política ¿Es necesaria una nueva constitución?” (CNN Chile, 9 de mayo de 2015), *Vía Pública*: “Proceso constituyente” (24 horas, 13 de octubre de 2015), *Ciudadanos*: “El proceso constituyente” (CNN Chile, 19 de octubre de 2015), entre varios otros casos.

⁴² Lucas Sierra (ed.), *Diálogos constitucionales. La academia y la cuestión constitucional en Chile* (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2015).

⁴³ Claudio Fuentes y Alfredo Joignant, *La solución constitucional. Plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos* (Santiago: Catalonia, 2015).

⁴⁴ Las versiones originales: Poul Kjaer, “Transnational Normative Orders: The Constitutionalism of Intra -and Trans- Normative Law”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, vol. 20, Issue 2, 2013: 777-803; Giuseppe Duso, “Oltre il nesso sovranità-rappresentanza: un federalismo senza Stato?”, en Mario Bertolissi et al. (eds.), *Ripensare La Costituzione. La questione della pluralità* (Roma: Polimetria International Scientific Publisher Monza, 2008); Aldo Mascareño, “De-Constitutionalizing Latin America: Particularism And Universalism In A Constitutional Perspective”, en Giancarlo Corsi y Alberto Febbrajo, *Sociology of Constitutions: A Paradoxical Perspective* (Farnham: Ashgate, 2016); y Francisco Zúñiga, “Potestad constituyente”, *Revista de Derecho*, Escuela de Postgrado n.º 5, 2014: 307-318.

¹ “El mejor método de investigación es estudiar las cosas tal como estas se desarrollan desde sus inicios”. Véase Aristóteles, *Politics* (Hackett Publishing Company, Inc., 1998), libro I, 1252a: 2, 5.

² Ernst-Wolfgang Bockenforde, “Die Verfassungsgebende Gewalt des Volkes-Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts”, en *Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht* (Fránfort: Suhrkamp, 1991), 11-12; Andrew Arato, “Forms of Constitution Making and Theories of Democracy”, *Cardozo Law Review*, 17, 2 (1995): 202-254; Antonio Negri, *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999), 1; Martin Loughlin, “Constituent Power”, en *The Idea of Public Law* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 100; Martin Loughlin y Neil Walker, “Introduction”, en M. Loughlin y N. Walker (ed.), *The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 6.

³ Carl Schmitt, *Constitutional Theory* (Duke University Press, 2008 [1928]), 101-102, 105, 112, 120-121, 128-129, 136-139, 145-146; Cornelius Castoriadis, “What Democracy?”, en *Figures of the Thinkable* (Stanford: Stanford University Press, 2007), 122-124.

⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Gloucester: Peter Smith, 1989), 204; Ídem, *General Theory of Norms* (Oxford: Oxford University Press, 1991), 256; Jacques Derrida, “Force of Law: ‘The Mystical Foundation of Authority’”, en D. Cornell y M. Rosenfeld (eds.), *Deconstruction and the Possibility of Justice* (Nueva York: Routledge, 1992), 3-67; Claude Klein, *Théorie et pratique de pouvoir constituant* (París: Presses Universitaires de France [PUF], 1996), 194-199.

⁵ Raymond Carré de Malberg, *Contribution à la Théorie Générale de l'Etat, Vol. II* (París: Librairie de la société du Recueil Sirey, 1922), 483. Para una reformulación contemporánea de esta posición véase Giorgio Agamben, *Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press, 1998), 39-48. En relación a dos consideraciones sobre la desaparición del poder constituyente desde los discursos constitucionales contemporáneos véase Olivier Beaud, *La puissance de l'Etat* (París: puf, 1994), 210-214; y Antonio Negri, *Insurgencies*, 1-35, 303-336. Bruce Ackerman rechaza “el carácter arbitrario de los actos del poder constituyente” porque estos implican que “donde la ley termina [...] la política pura (o la guerra) comienzan”; véase Ackerman, *We the People II. Transformations* (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 11, 425. Para Jürgen Habermas, el poder popular constituyente invoca a una homogeneidad orgánica, sustantiva y étnica que reúne a una comunidad y, como tal, se inclina hacia un “etnonacionalismo militante” y hacia un modelo voluntarista y esencialista de política nacionalista; véase Habermas, *The Inclusion of the Other. Studies in Political Theory* (Cambridge: The mit Press, 1998), 148; e

Ídem, *Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of law and Democracy* (Cambridge: The mit Press, 1996), 462-490. De igual modo, Ulrich Preuss rechaza, en conjunto, al poder constituyente a favor de procesos negociados entre grupos e intereses plurales; véase Preuss, *Constitutional Revolution. The Link between Constitutionalism and Progress* (Nueva Jersey: Humanities Press, 1995), 19, 75-76, 95-98. Para críticas más recientes véase Hans Lindahl, “Constituent Power and Reflexive Identity: Towards an Ontology of Collective Selfhood”, en M. Loughlin y N. Walker (eds.), *The Paradox of Constitutionalism*, 19-24; David Dyzenhaus, “The Politics of the Question of the Constituent Power”, en M. Loughlin y N. Walker (eds.), *The Paradox of Constitutionalism*, 129-145; David Dyzenhaus, “Constitutionalism in an old key: Legality and Constituent Power”, *Global Constitutionalism*, 1, 2 (2012), 229-260; Andrew Arato, “Redeeming the Still Redeemable: Post Sovereign Constitution Making”, *International Journal of Culture, Politics, and Society*, 22 (2009), 427-443; Andrew Arato, “Multi-track Constitutionalism Beyond Carl Schmitt”, *Constellations* 18, 3 (2011), 324-351.

⁶ Jean Bodin, *On Sovereignty* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992 [1576]), libro i, 1-8; Julian Franklin, *Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973), 23, 54-68.

⁷ Thomas Hobbes, *On the Citizen* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998 [1642]), 73.

⁸ Benedict de Spinoza, *A Theologico-Political Treatise* (Nueva York: Dover Publications, 1951 [1670]), 207.

⁹ Antonio Negri y Michael Hardt, “Sovereignty”, en Antonio Negri, *Reflections on Empire* (Cambridge-Oxford-Boston: Polity, 2008), 48-59.

¹⁰ En el artículo original en inglés: “uncommanded commander”. Véase Jean Bodin, *On Sovereignty*, libro i, 1-8.

¹¹ Bodin, ib., libro i: 10, 49; Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 234-235. “La doctrina de la soberanía”, de acuerdo a L. H. A. Hart “afirma que en cada sociedad humana en donde existe la ley, existe de forma última, encontrada de modo latente, debajo de la variedad de formas políticas, tanto en una democracia como en una monarquía absoluta, esta simple relación entre sujetos que producen obediencia y un soberano que no rinde obediencia a nadie. Esta estructura vertical compuesta de súbditos y soberano es, de acuerdo a la teoría, tan esencial como la parte de una sociedad que posee derecho, o la columna vertebral lo es para el hombre”. Véase Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2012 [1961]), 50.

¹² Otto Gierke, *Natural Law and the Theory of Society 1500-1800* (Boston: Beacon Press, 1957), 40; Julian Franklin, “Sovereignty and the Mixed Constitution: Bodin and his Critics”, en J. H. Burns (ed.), *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700* (Cambridge University Press, 1991), 307.

¹³ Hans J. Morgenthau, “The Problem of Sovereignty Reconsidered”, *Columbia Law Review*,

48, 3 (1948), 341-365.

¹⁴ Bodin, *On Sovereignty*, libro i, 8, 11.

¹⁵ Hannah Arendt, *On Revolution* (Nueva York: The Viking Press, 1963), 154-158.

¹⁶ La observación de Judith Shklar de que “la palabra soberanía escasamente posee del todo un significado distinto del de monarquía absoluta” representa sucintamente esta poderosa tradición. Véase Shklar, *Men and Citizen. A Study of Rousseau's Social Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), 168.

¹⁷ Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1* (Nueva York: Vintage Books, 1990), 85; Hannah Arendt, “What is Freedom?”, en *Between Past and Future* (Nueva York: Penguin Books, 1993), 152, 164.

¹⁸ Negri, *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*, 332; y “Political Subjects: On the Multitude and Constituent Power”, en Negri, *Reflections on Empire*, 103.

¹⁹ ‘Stūtāo’ es, en sí, una palabra derivada de ‘stāre’, esto es, mantenerse firme y permanecer.

²⁰ Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern* (Ithaca: Cornell University Press, 1947), 23-42.

²¹ Theodor Mommsen, *Le Droit Public Romain, Vol. IV* (París: Thorin and Fils, 1884), 425-470; y Carl Schmitt, *Die Diktatur* (Berlín: Duncker & Humblot, 1994), 127-149.

²² Cicero, *De Re Publica* (Harvard: Harvard University Press, 1994), libro vi, 264-267; Livy, *History of Rome* (Harvard: Harvard University Press, 1997), libro IV, 24, 333-334; Appian, *Civil Wars, Book I* (Harvard: Harvard University Press, 2002), 185.

²³ Karl Ernst Georges, *Ausführliches lateinisch-deutsches und deutschlateinisches Handwörterbuch aus den Quellen zusammengetragen und mit besonderer Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten unter Berücksichtigung der besten Hilfsmittel* (Leipzig: Hahn, 1869), 1.151-1.152.

²⁴ Ala Watson, *The Digest of Justinian* (Pensilvania: University Pennsylvania Press, 2011), 1.1.6, 1:2.18.

²⁵ Ulrich Preuss, “The Constitution as the ‘Object of all Longing’”, en *Constitutional Revolution. The Link Between Constitutionalism and Progress* (Nueva Jersey: Humanities Press, 1995), 27.

²⁶ Otto Gierke, *Political Theories in the Middle Age* (Cambridge: Cambridge University Press, 1900), 46-47; Charles Howard McIlwain, *The Growth of Political Thought in the West: From the Greeks to the End of the Middle Ages* (Nueva York: Macmillan Company, 1932), 305; Alexander Passarin D'Entreves, *The Medieval Contribution to Political Thought* (Oxford: Oxford University Press, 1939), 59; Walter Ullmann, *Principles of Government in the Middle Ages* (Londres: Routledge, 2010 [1961]), 282.

²⁷ En 1327, esta posición contraria y disidente provocó que la Iglesia católica lo condenara como hereje.

²⁸ Otto Gierke, *Political Theories of the Middle Age*, 38-39, 146.

²⁹ Marsilio de Padua, *Defensor pacis* (Toronto: University of Toronto Press, 1956 [1324]), 61 (énfasis añadido).

³⁰ Ídem, ib., 87 (énfasis añadido).

³¹ Ídem, ib., 63-64.

³² Ídem, ib., 62, 64, 65 (énfasis añadido).

³³ Alan Gewirth, *Marsilius of Padua: The Defender of Peace* (Nueva York: Columbia University Press, 1951), 50-56.

³⁴ Marsilio, *Defensor pacis*, 63; Otto Gierke, *Political Theories of the Middle Age*, 24-26. 8.

³⁵ Marsilio, *Defensor pacis*, 64.

³⁶ Ídem, ib., 62 (énfasis añadido).

³⁷ Ídem, ib., 27.

³⁸ Ídem, ib., 53, 27-28, 53, 52, 54-55.

³⁹ Ídem, ib., 45, 48, 64, 87-88; véase Friedrich von Bezold, “Die Lehre von der Volkssouveranität während des Mittelalters”, *Historische Zeitschrift*, 36 (1876), 346; Alan Gewirth, *Marsilius of Padua: The Defender of Peace*, 172, 183.

⁴⁰ Marsilio, *Defensor pacis*, 45-46. Marsilio también anticipa la revolucionaria idea de la convención constitucional.

⁴¹ Retrospectivamente, Marsilio relegó el poder de comando a un estatus inferior incluso dentro del orden instituido, ubicándolo por debajo del acto de legislar, y, así, minimizando hacia adelante su significancia política. En su diferenciada jerarquía de poderes, el comando es secundario a la legislación, la cual es en sí inferior al acto de constituir. Este último pertenece exclusivamente a la comunidad entera, mientras que los primeros dos son concedidos a la estructura de gobierno constituida y permanecen subordinados a la autoridad soberana de la multitud.

⁴² Alan Gewirth, *Marsilius of Padua: The Defender of Peace*, 167-225.

⁴³ Marsilio, *Defensor pacis*, 46.

⁴⁴ Ídem, ib., 49-55.

⁴⁵ Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty* (Cambridge: The MIT Press, 1988 [1922]), 51, 36; y *Constitutional Theory* (Durham: Duke University Press, 2008 [1928]), 126-128. Véase también Ulrich Preuss, “Constitutional Powermaking for the New Polity: Some Deliberations on the Relations Between Constituent Power and the Constitution”, en M. Rosenfeld (ed.), *Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy: Theoretical Perspectives* (Durham: Duke University Press, 1994), 144-145.

⁴⁶ Marsilio, *Defensor pacis*, 29.

⁴⁷ Ídem, ib., 89-97.

⁴⁸ El jurista escocés-católico William Barclay acuñó el término *monarchomach* en su

polémico panfleto *De Regno et Regali Potestate adversus Buchanum, Brutum, Boucherium et reliquios monarchomacos* (París: G. Chaudiere, 1600); J. W. Allen, *A History of Political Thought in the Sixteenth Century* (Londres: Rowman and Littlefield, 1977 [1922]), 306-308. Véase también Wm. A. Cummings, “The Monarchomachs. Theories of Popular Sovereignty in the Sixteenth Century”, *Political Science Quarterly*, 19: 2 (1904): 277-301; Oscar Jászi y John D. Lewis, *Against the Tyrant. The Tradition and Theory of Tyrannicide* (Glencoe: The Free Press, 1957), 59-74; W. J. Stankiewicz, *Politics and Religion in Seventeenth-century France: A Study of Political Ideas from the Monarchomachs to Bayle, as Reflected in the Toleration Controversy* (Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 1960); Ralph E. Giesey, “The Monarchomach Triumvirs: Hotman, Beza, and Mornay”, *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*, 32, 1 (1970): 41-56.

⁴⁹ Julian Franklin, “Introduction”, en Franklin (ed.), *Constitutionalism and Resistance in the Sixteenth Century: Three Treatises* (Nueva York: Pegasus, 1969), 11-12; Pauline Maier, *From Resistance to Revolution: Colonial Radicals and the Development of American Opposition to Britain, 1765-1776* (Nueva York: Alfred A. Knopf, 1972), 3-49; Antonio Negri, “From the Right to Resistance to Constituent Power”, en *The Porcelain Workshop: For a New Grammar of Politics* (Los Ángeles: Semiotext(e), 2008), 109-126.

⁵⁰ Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy. Theory and Practice in Europe and America* (Boston: Ginn and Company, 1950), 129-131.

⁵¹ Julian Franklin, *Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory*, 47-53.

⁵² Esta es la clásica versión de Sidney, casi un siglo más tarde, la cual ejemplifica el sentido normativo de la soberanía popular basada en el poder de constituir. También testifica su permanencia discursiva más allá y posterior a los monarcómacos. Véase Algernon Sidney, *Discourses Concerning Government* (Indianapolis: Liberty Fund, 1996 [1680]), caps. 1, 6, 20; Otto Gierke, *Natural Law and the Theory of Society 1500-1800*, 256-7; y Julian Franklin, *Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory*, 43-48.

⁵³ J. W. Allen, *A History of Political Thought in the Sixteenth Century*, 311-312, 316-318; Oscar Jászi y John D. Lewis, *Against the Tyrant*, 52.

⁵⁴ Franklin, “Introduction”, en Franklin, *Constitutionalism and Resistance in the Sixteenth Century*, 37, 42-45.

⁵⁵ Francois Hotman, *Fraco-Gallia: Or An Account of the Ancient Free State of France* (Carolina del Sur: BiblioBazaar, 2007 [1573]), 82 (énfasis añadido).

⁵⁶ Theodore de Bèze, “Rights of Magistrates”, en Franklin (ed.), *Constitutionalism and Resistance in the Sixteenth Century*, 124, 126 (énfasis añadido).

⁵⁷ Ídem, ib., 104.

⁵⁸ Franklin, “Introduction”, 33.

⁵⁹ Theodore de Bèze, *Rights of Magistrates*, 106.

⁶⁰ Junio Bruto, el Celta (probablemente Philippe du Plessis-Mornay), *Vindiciae, contra*

tyrannos or, concerning the legitimate power of a prince over the people, and of the people over a prince (Cambridge: Cambridge University Press, 1994 [1579]), 68-76; Otto Gierke, *ib.*, 44-8; y Julian Franklin, "Introduction", 39-44.

⁶¹ Junio Bruto, *Vindiciae, contra tyrannos*, 71, 156.

⁶² Ídem, *ib.*, 99-102.

⁶³ Ídem, *ib.*, 75, 169.

⁶⁴ Ídem, *ib.*, 74 (énfasis añadido), 68-74, 92, 94, 130.

⁶⁵ Ídem, *ib.*, 78, 82.

⁶⁶ George Buchanan, *A Dialogue on the Law of Kingship Among the Scots* (Edimburgo: The Saltire Society, 2006 [1579]), 72.

⁶⁷ Otto Gierke, *Natural Law and the Theory of Society 1500-1800*, 241, 244, 257.

⁶⁸ Johannes Althusius, *Politica methodice Digesta* (Indianápolis: A Liberty Classics Edition, 1995), 72-73 (énfasis añadido), 93, 96-97, 110-111. Véase ídem, *ib.*, 191-200, en relación a la teoría de Althusius sobre la resistencia activa y el tiranicidio.

⁶⁹ Ídem, *ib.*, 70.

⁷⁰ Ídem, *ib.*, 72-73.

⁷¹ Ídem, *ib.*, 17. La refutación que hace Althusius de Bodin en el nombre de la soberanía popular como poder constituyente no solo rebate al paradigma monárquico de la soberanía, también cuestiona la legitimidad del Estado moderno. De hecho, el desarrollo de la soberanía como el poder de constituir formas de gobierno pasa a través del redescubrimiento de la federación como una alternativa superior a la autoridad unitaria e indivisible del Estado moderno. Althusius es tanto un pensador del poder constituyente del pueblo, como también el primer proponente moderno del federalismo, siendo este entendido como la vinculación mutua de familias, ciudades, gremios, comunidades y las provincias que se asocian en conjunto por la vía de promesas mutuas dentro de un cuerpo que constituye, el cual es exterior y anterior a toda forma del Estado. Con Althusius, por tanto, la federación se convierte en la expresión más apropiada y natural de la política constituyente; el Estado, en contraste, aparece como su enemigo. Véase Otto Gierke, *Natural Law and the Theory of Society 1500-1800*, 71-72.

⁷² Edmund S. Morgan, *Inventing the People. The Rise of Popular Sovereignty in England and America* (Nueva York-Londres: W. W. Norton & Company, 1989), 55-121; Martin Loughlin, "Constituent Power Subverted: From English Constitutional Argument to British Constitutional Practice", en *The Paradox of Constitutionalism*, 27-48.

⁷³ George Lawson, *Politica Sacra et Civilis* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992 [1660]), 21-30, 41-76, 88-125, 218-51; Algernon Sidney, *Discourses Concerning Government* (Indianápolis: Liberty Fund, 1996 [1680]), cap. 1.6: 10-11, 17, 20; cap. 2.3: 20-23, 30-32, 46-52, 69-76, 91-92, 97-107; John Locke, *The Second Treatise of Government. An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government* (Cambridge: Cambridge University Press,

1991 [1689]), 318-374, 406-428. Véase también A. H. Maclean, “George Lawson and John Locke”, *Cambridge Historical Journal*, 9, 1 (1947): 69-77; y Julian Franklin, *John Locke and the Theory of Sovereignty* (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 88-126.

⁷⁴ George Lawson, *Politica Sacra et Civilis*, 47, 46 (énfasis añadido).

⁷⁵ s. A., *Exercitation Concerning Usurped Powers* (Londres: s. e., 1650), 8,73 (énfasis añadido). Véase también s. A., *A Plea for Non-Scribers* (Londres: s. e., 1650), 26-27.

⁷⁶ George Lawson, *Politica Sacra et Civilis*, 48-49, 107-108; Julian Franklin, *John Locke and the Theory of Sovereignty*, 73-75; Edmund S. Morgan, *Inventing the People*, 88-93; J. Franklin Jameson, “The Early Political Uses of the Word Convention”, *The American Historical Review*, 3, 3 (1898), 477-487. Véase también Henry Vane, *The Trial of Sir Henry Vane* (Londres: s. e., 1662), 2-8, 18, 20-21.

⁷⁷ John Locke, *The Second Treatise of Government*, 333.

⁷⁸ Thomas Hobbes, *On the citizen*, caps. 5, 12, 94. Véase Murray Forsyth, “Thomas Hobbes and the Constituent Power of the People”, *Political Studies*, 29, 2 (1981), 191-203.

⁷⁹ Thomas Hobbes, *On the citizen*, caps. 7, 5, 94.

⁵⁰ John Locke, *The Second Treatise of Government*, párr. 149, 243, 366-367, 427-428 (énfasis añadido).

⁸¹ Ídem, ib., párr. 211, 406.

⁸² Ídem, ib., cap. 19, 406-428. Véase también Franklin, *John Locke and the Theory of Sovereignty*, 93-98; Richard Ashcroft, *Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government* (Nueva Jersey: Princeton University Press, 1986), 228-285.

⁸³ R. R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution. A Political History of Europe and America 1760-1800, Vol. I* (Nueva Jersey: Princeton University Press, 1959), 213-238; Gordon S. Wood, *The Creation of the American Republic 1776-1787* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1998), 306-389; Richard B. Morris, “The People and the States: Constitutional-making and Constituent Power”, en *The Forging of the Union 1781-1789* (Nueva York: Harper and Row Publishers, 1987), 115-116; Hannah Arendt, *On Revolution*; Larry D. Kramer, *The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review* (Oxford: Oxford University Press, 2005); David A. J. Richards, “Revolution and Constitutionalism in America”, en M. Rosenfeld (ed.), *Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy: Theoretical Perspectives* (Duke University Press, 1994), 85-142.

⁸⁴ Thomas Young, “To the inhabitants of Vermont, a Free and Independent State, building on the River Connecticut and Lake Champlain,” 11 de abril de 1777, en Z. Thompson (ed.), *History of Vermont, natural, civil and statistical, in three parts* (Burlington: Chauncey Goodrich, 1842), 106 (énfasis añadido); Thomas Paine, *Rights of Man, Part I*, en E. Foner (ed.), *Paine: Collected Writings* (Nueva York: The Library of America, 1995 [1791]), 467-468; James Madison, “The Federalist” n.º 54, 38, en C. Rossiter (ed.), *The Federalist Papers* (Nueva York: The Modern

Library, 1938), 348, 233-242.

⁸⁵ *American Declaration of Independence*, 4 de julio de 1776 (énfasis añadido).

⁸⁶ Thomas Paine, *Rights of Man. Part II*, en E. Foner (ed.), *Paine: Collected Writings*, 572 (énfasis añadido); Hannah Arendt, *On Revolution*, 203-204.

⁸⁷ Thomas Paine, "The Forester, Letter IV, May 8, 1776", en E. Foner (ed.), *Paine: Collected Writings*, 85-90; *Rights of Man. Part I*, en E. Foner (ed.), ib., 469; Thomas Jefferson, "Notes on the Virginia Constitution: Query XIII" [1784], J. Appleby y T. Ball (eds.), *Jefferson: Political Writings* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 327-31; James Madison, "The Federalist" n.º 37, 224-232.

⁸⁸ Allan Nevins, *The American States during and after the Revolution, 1775-1789* (Nueva York: The Macmillan Company, 1927); Willi Paul Adams, *The First American Constitutions. Republican Ideology and the Making of State Constitutions in the Revolutionary Era* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980); Edmund S. Morgan, *Inventing the People*, 237-262.

⁸⁹ John Alexander Jameson, *The Constitutional Convention: Its History, Powers, and Modes of Proceedings* (Cornel University Library, 2009 [1867]); Clinton Rossiter, *1787: The Grand Convention* (Nueva York: W. W. Norton & Company, 1987); Michael Allen Gillespie, *Ratifying the Constitution* (Kansas: University Press of Kansas, 1992).

⁹⁰ James Madison, "The Federalist" n.º 40, 250-259. Sobre este punto véase Hannah Arendt, *On Revolution*, 179-214; Jacques Derrida, "Declarations of Independence", *New Political Science*, 7, 1 (1986) 7-15; Bruce Ackerman, "NeoFederalism?", en J. Elster y R. Slagstad (eds.), *Constitutionalism and Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 153-94; Frank Michelman, "Constitutional Authorship", en L. Alexander (ed.), *Constitutionalism: Philosophical Foundations* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 64-98; Andrew Arato, *Civil Society, Constitution, and Legitimacy* (Nueva York: Rowman & Littlefield Publishers, 2000), 170-175; Jason Frank, "Unauthorized Propositions: The Federalist Papers and Constituent Power", *Diacritics*, 37, 2-3 (2007), 103-120.

⁹¹ Thomas Paine, *Rights of Man. Part II*, 579, 537, 545-558, 572-579.

⁹² James Madison, "The Federalist" n.º 40, 39: 257, 258, 243 (énfasis añadido).

⁹³ James Wilson citado en James McClellan y M. E. Bradford (eds.), *Jonathan Elliot's Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Constitution as Recommended by the General Convention at Philadelphia in 1787. Vol. 2.* (Cumberland: J. River Press, 1989), 432. Véase Garry Wills, "James Wilson's New Meaning for Sovereignty", en T. Ball y K. G. A. Pocock (eds.), *Conceptual Change and the Constitution* (University Press of Kansas, 1988), 99-106.

⁹⁴ Hannah Arendt, *On Revolution*, 232-239; Sheldon Wolin, "Norm and Form: The Constitutionalizing of Democracy", en P. Euben, J. R. Wallach y J. Ober (eds.), *Athenian Political*

Thought and the Reconstruction of American Democracy (Ithaca: Cornell University Press: 1994), 29-58.

⁹⁵ Christian Fritz, *American Sovereigns: The People and American's Constitutional Tradition Before the Civil War* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 11-46.

⁹⁶ Hannah Arendt, *On Revolution*, 232-281; Sanford Levinson (ed.), *Responding to Imperfection. The Theory and Practice of Constitutional Amendment* (Princeton: Princeton University Press, 1995).

⁹⁷ Carl Schmitt, *Constitutional Theory*, 124, 140-146, 271-279.

⁹⁸ Thomas Jefferson, "Letter to James Madison", 30 de enero de 1787; "Letter to William Stephens Smith", 13 de noviembre de 1787; "Letter to James Madison", 6 de septiembre de 1789; "Letter to John Wayles Eppes", 2 de junio de 1813; "Letter to Major John Cartwright", 5 de junio de 1824 en *Jefferson: Political Writings*, 107-11, 593-604, 382-388. Véase también Thomas Paine, *Common Sense* (Nueva York: Penguin Classics, 1986 [1776]), 16; y *Rights of Man. Part I*: 438-442, 518.

⁹⁹ Alexis de Tocqueville, *Democracy in America* (Nueva York: Vintage Books, 1990 [1835]), libro i: 4: 55.

¹⁰⁰ James Madison, "Letter to Thomas Jefferson", 4 de febrero de 1790, en *Political Writings*, 608; y "The Federalist" n.º 40, 49-50, 327-355.

¹⁰¹ Hannah Arendt, "The Revolutionary Tradition and its Lost Treasure", en *On Revolution*, 215-81; Antonio Negri, *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*, 1-35, 103-136; Horst Dippel, "The Changing Idea of Popular Sovereignty in Early American Constitutionalism: Breaking Away from European Patterns", *Journal of the Early Republic*, 16, 1 (1996): 21-45.

¹⁰² Egon Zweig, *Die Lehre vom pouvoir constituant: ein Beitrag zum Staatsrecht der Französischen Revolution* (Tubinga: J. C. B. Mohr, 1909); Bernard Groethuysen, *Philosophie de la révolution Française* (París: Gallimard, 1956), 247-304; Lucien Jaume, "Constituent Power in France: The Revolution and its Consequences", en M. Loughlin y N. Walker (eds.), *The Paradox of Constitutionalism*, 67-85.

¹⁰³ La Fayette, *Mémoires, Correspondance et Manuscrits* (Londres: Saunders & Otley, 1837), vol. IV, 36; vol. II, 263; vol. V, 445; M. Regnault-Warin, *Mémoires pour servir à l'histoire de la vie du Général La Fayette et à l'histoire de l'Assemblée Constituante* (París: Chez Hesse et C, Libraires, 1824); Édouard Laboulaye, *Questions Constitutionnelles* (París: Charpentier, 1872), 397.

¹⁰⁴ Marqués de Condorcet, "On the Influence of the American Revolution on Europe" [1786], "Essay on the Constitution and Functions of the Provincial Assemblies" [1788] y "On the Principles of the Constitutional Plan Presented to the National Convention" [1793], en K. M. Baker (ed.), *Condorcet. Selected Writings* (Indianápolis: The Bobbs-Merrill Company, Inc, 1976), 71-83, 84-87, 143-182; y Condorcet, "Sur la nécessité de faire ratifier la Constitution par les citoyens", en

Oeuvres de Condorcet (París: Firmin-Didot, 1847-1849), vol. ix, 413-430.

¹⁰⁵ Nadia Urbinati, *Representative Democracy: Principles and Genealogy* (Chicago: University of Chicago Press, 2008), 177-179.

¹⁰⁶ Jean-Baptiste Salle, *Examen critique de la Constitution de 1793* (París: Gorsas, 1795).

¹⁰⁷ Emmanuel Sieyes, *Qu'est-ce le Tiers état?* (Génova: Librairie Droz, 1970), 180-191; Lucien Jaume, “Constituent Power in France: The Revolution and its Consequences”, 84.

¹⁰⁸ Emmanuel Sieyes, “Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l'homme et du citoyen”, en F. Furet y R. Halévie (eds.), *Orateurs de la Révolution française. Les Constituants*, vol. I (París: Bibliothèque de la Pléiade, 1989), 1.013 (énfasis añadido).

¹⁰⁹ E. Sieyes, *Qu'est-ce le Tiers état?*, 180.

¹¹⁰ Ídem, ib., 184-186.

¹¹¹ Al convertirse en emperador en 1804, Napoleón declaró: “Yo soy el poder constituyente”. Véase Napoleón, *Correspondance de Napoleon I*, Vol. iii (París, 1859), 314. Sin embargo, es bajo el gobierno de su sobrino Louis-Napoleon Bonaparte que el poder constituyente fue convertido en un plebiscito nacional promovido desde arriba y transformado en un instrumento de gobierno protopopulista que pasó a ser casi un sinónimo de bonapartismo. Sobre este punto véase Andrew Arato, “Dilemmas Arising from the Power to Create Constitutions in Eastern Europe”, *Cardozo Law Review* 14 (1993): 674.

¹¹² François Guizot, “L'esprit d'insurrection est un esprit radicalement contraire à la liberté”, en *Discours à la Chambre des députés* (29 de diciembre de 1830) (énfasis añadido).

¹¹³ *Le Moniteur universel* (20 de agosto de 1842), 1807.

¹¹⁴ El redescubrimiento moderno de la democracia es anticolonial. Precede la era de conquistas mundiales pero, más importante aún, desafía normativa y analíticamente cualquier intento de imponer un orden político a aquellos que no participan en su establecimiento e institución. De hecho, los cinco siglos de intentos imperialistas de occidente por apropiarse espacio demandan la elaboración de un discurso crítico, como el provisto por el poder constituyente, para entender y oponer el déficit democrático de tales intentos imperiales discrecionales de comando global. En este sentido, la doctrina de la soberanía constituyente del pueblo es, en un centro, profundamente antiimperialista y anticolonialista.

¹¹⁵ Martin Loughlin, “Constituent Power”, en *The Idea of Public Law* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 112.

¹¹⁶ Andreas Kalyvas, “Popular Sovereignty, Democracy, the Constituent Power”, *Constellations*, 12, 2 (2005): 223-244.

¹¹⁷ Sobre el contenido normativo de estos principios inmanentes véase Andreas Kalyvas, “The Basic Norm and Democracy in Hans Kelsen's Legal and Political Theory”, *Philosophy and Social Criticism*, 32, 5 (2006): 587-592. Sobre los principios de los actos fundantes véase Hannah Arendt, *On Revolution*, 198-214; y “What is Freedom?”, en *Between Past and Future* (Nueva

York: Penguin Books, 1993), 152-153.

¹¹⁸ George Lawson, *Politica Sacra et Civilis*, 24.

¹¹⁹ Algernon Sidney, *Discourses Concerning Government*, 99.

¹²⁰ Respecto del trato más sistemático del poder de instituir como *pouvoir instituant* véase Cornelius Castoriadis, *The Imaginary Institution of Society* (Cambridge: Polity Press, 1987), 369-373; “The First Institution of Society and Second-Order Institutions”, *Free Associations*, 12 (1988): 39-51; “Power, Politics, Autonomy”, en D. A. Curtis (ed.), *Philosophy, Politics, Autonomy. Essays in Political Philosophy* (Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1991), 143-175; “Radical Imagination and the Social Instituting Imaginary”, en D. A. Curtis (ed.), *The Castoriadis Reader* (Oxford: Blackwell Publishers, 1997), 319-338.

¹²¹ Antonio Negri, *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*, 22, 305-307.

¹²² Carl Schmitt, *Constitutional Theory*, 125. Beaud propone la siguiente formulación: “Soberanía constituyente significa que, en los Estados contemporáneos, el soberano es aquel que hace la constitución”. Véase Beaud, *La puissance de l'état*, 208.

¹²³ Carl Schmitt, *Die Diktatur*, 134, 137-138; *Über die Drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* (Berlín: Duncker und Humblot, 1993 [1933]), 21, 23-24. En consecuencia, el académico constitucionalista francés Maurice Hauriou ha descrito al poder constituyente como “un poder legislativo fundante”. Véase Hauriou, *Précis de droit constitutionnel* (París: Sirey, 1929), 246.

¹²⁴ Thomas Paine, *The American Crisis III*, 124; *Rights of Man*, 464-468, 551-558; Sheldon Wolin, “Collective Identity and Constitutional Power”, en *The Presence of the Past: Essays on the State and the Constitution* (The Johns Hopkins University Press, 1990), 8-31.

¹²⁵ Antonio Negri, “Political Subjects: On the Multitude and Constituent Power”, 109-10.

¹²⁶ Johannes Althusius, *Politica methodice Digesta*, libro i, 17.

¹²⁷ George Lawson, *Politica Sacra et Civilis*, 24.

¹²⁸ Thomas Paine, *Common Sense*, 42, 52; *The Last Crisis XIII* [1783], 34854; *Rights of Man*, 512-513, 536-540, 547-551, 572-579; Thomas Jefferson, “Letter to James Madison”, 30 de enero de 1787, y “Letter to Stephens Smith”, 13 de noviembre de [1787], 107-11; Hannah Arendt, *On Revolution*, 141214; Andrew Arato, *Civil Society, Constitution, and Legitimacy*, cap. 7; Olivier Beaud, *La Puissance de l'Etat*, 359-376; Miguel Abensour, “De la démocratie insurgente”, en *La démocratie contre l'Etat*, 5-19.

¹²⁹ Respecto de la relación entre poder constituyente y crisis véase Antonio Negri, *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*: 1-36, 319; Jon Elster, “Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process”, *Duke Law Journal*, 45, 2 (1995): 370, 375.

¹³⁰ George Lawson, *Politica Sacra et Civilis*, 227.

¹³¹ Incluso pensadores liberales contemporáneos han llegado a reconocer que la legitimidad democrática presupone un quiebre con la legalidad heredada. John Rawls, por ejemplo, ha

reconocido que el “poder constituyente del pueblo establece un marco para regular al poder ordinario y solo entra en juego cuando el régimen existente ha sido disuelto”. Véase John Rawls, “The Idea of Public Reason”, en *Political Liberalism* (Nueva York: Columbia University Press, 1993), 23.

¹³² Pierre Rosanvallon, “Revolutionary Democracy”, en S. Moyn (ed.), *Democracy Past and Future* (Nueva York: Columbia University Press, 2007), 7997; Sheldon Wolin, “Norm and Form: The Constitutionalizing of Democracy”, 29, 37-41, 47-48, 53-57; Ulrich Preuss, *Constitutional Revolution*, 2-3.

¹³³ Martin Loughlin, *The Idea of Public Law*, 110, 113.

¹³⁴ Ídem, ib., 99-113.

¹³⁵ Para una distinción detallada de este punto véase Raymond Carré de Malberg, *La Loi, expression de la volonté générale* (París: Economica, 1984), 103-139.

¹³⁶ Frank Michelman, *Brennan and Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 1999), 48.

¹³⁷ De acuerdo con Maurice Duverger, “[e]s la constitución que deriva su autoridad desde el poder constituyente y no el poder constituyente que deriva su autoridad desde la constitución”. Véase Duverger, “Légitimité des gouvernements de fait”, *Revue du Droit Public* (1948): 78.

¹³⁸ Carl Schmitt, *Constitutional Theory*, 143, 112, 120-121, 136-139, 255-267. También véase Andreas Kalyvas, “Carl Schmitt and the Three Moments of Democracy”, *Cardozo Review of Law*, 21, 506 (2000): 1525-1545. A la pregunta “¿Tiene la gente el derecho de hacer una nueva constitución?”, Marx “irreservadamente contestó en afirmativo, en cuanto que una constitución que ha dejado de ser la real expresión de la voluntad del pueblo se ha vuelto una ilusión práctica”. Véase Marx, “Critique of Hegel's Doctrine of the State”, en *Early Writings* (Nueva York: Penguin Books, 1975), 120.

¹³⁹ Ídem, ib., 87.

¹⁴⁰ Cornelius Castoriadis, *The Imaginary Institution of Society*, 369-374; “The Greek Polis and the Creation of Democracy”, en *Philosophy, Politics, Autonomy*, 81-123; “Radical Imagination and the Social Instituting Imaginary”, 319-337.

¹⁴¹ Karl Marx, “Critique of Hegel's Doctrine of the State”, 87, 88.

¹⁴² Ídem, ib., 80, 90.

¹⁴³ Carl Schmitt, *Constitutional Theory*, 268-79.

¹⁴⁴ Cornelius Castoriadis, *Philosophy, Politics, Autonomy. Essays in Political Philosophy* (D. A. Curtis [ed.]), (Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1991), 152-153; Sheldon Wolin, “Transgression, Equality, and Voice”, en J. Ober y C. Hedrick (eds.), *Demokratia: A Conversation on Democracies Ancient and Modern* (Princeton: Princeton University Press, 1996), 64.

¹⁴⁵ Antonio Negri, *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*, 13.

¹⁴⁶ Karl Marx, “Preface to a Contribution to the Critique of Political Economy”, 20-21;

Hannah Arendt, *The Human Condition*, 243-247, y *On Revolution*, 165-178.

¹⁴⁷ Ulrich Preuss, “Constitutional-Making and the Foundation of a New Polity”, 4.

¹⁴⁸ Alexander Hamilton, “The Federalist” n.º 1, *The Federalist Papers*: 3. Madison coincide y explica: “el mejoramiento hecho por América en el antiguo modo de preparar y establecer planes regulares de gobierno” como “una revolución por medio de la intervención de un cuerpo deliberativo de ciudadanos”. Véase Madison, “The Federalist” n.º 38, 235, 234; Thomas Paine, *The American Crisis* v [1778], 169, y *Rights of Man*, 668; y Hannah Arendt, *On Revolution*, 46-47. Desde el siglo XVII en adelante, el término ‘*constitutio*’ designaba un documento escrito y un grupo de normas legales superiores, más altas y fundamentales y de procedimientos instituidos por seres humanos en oposición tanto a tradiciones y convenciones como a un derecho natural trascendental. Véase Gerald Stourzh, “Constitution: Changing Meanings of the Term from the Early Seventeenth to the Late Eighteenth Century”, en T. Ball y J. G. A. Pocock (ed.), *Conceptual Change and the Constitution* (Lawrence: University Press of Kansas, 1988), 43-44.

¹⁴⁹ Georges Burdeau, *Traité de Science Politique*, Vol. IV (París: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1983), 172-173; Andrew Arato, *Civil Society, Constitutionalism, and Legitimacy*, 170-175; Cornelius Castoriadis, “Institution of Society and Religion”, *World in Fragments*, 311-330.

¹⁵⁰ Karl Marx, “Economic and Philosophical Manuscripts of 1844”, 348, 366, y “Critique of Hegel’s Doctrine of the State”, 118-120.

¹⁵¹ C. Castoriadis, *The Imaginary Institution of Society*, 135-159, 353-368.

¹⁵² Stathis Gourgouris, “On Self-Alteration”, *Parrhesia*, 9 (2010): 1-17.

¹⁵³ Karl Marx, “Critique of Hegel’s Doctrine of the State”, 80, 87-88, 90, 98, 117-119; Miguel Abensour, *La démocratie contre l’Etat*, 105, 112-113; y Emiliós Christodoulidis, “Against Substitution: The Constitutional Thinking of Dissensus”, en *The Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form*, 195.

¹⁵⁴ Arendt, *On Revolution*, 201, 202.

¹⁵⁵ Karl Marx, “Critique of Hegel’s Doctrine of the State”, 80, 85, 87; y “The Civil Wars in France”, en R. C. Tucker (ed.), *The Marx-Engels Reader* (Nueva York: W. W. Norton, 1978), 633, 628; Miguel Abensour, *La démocratie contre l’Etat*, 106-107, 109-110, 127-130, 140-142.

¹⁵⁶ Hoy en día, con el proyecto de una constitución europea enfrentada a retos mayores, el problema de los fundamentos democráticos se vuelve nuevamente actual. De modo similar, la apropiación americana del poder constituyente para establecer nuevos regímenes demanda la elaboración de un discurso crítico en contra del déficit democrático de intentos imperiales en un comando global. El concepto democrático de soberanía popular como poder constituyente plantea que cualquier acto no puede reclamar ser constituyente ni que cualquier actor puede afirmar ser un fundador. Esto aún si el actor y el acto han sido exitosos, es decir, efectivos en crear un nuevo orden político. ¿Debiera una persona o grupo apropiarse del poder de constituir un orden legal

sobre la exclusión de todos aquellos a quienes estará dirigido? Un acto de tales características es no-democrático, un comando represivo, una expresión de imposición coercitiva. Como correctamente observó Friedrich: “Para hacer a la decisión constitucional genuina también es necesario que se haga participar en esta a algunos de aquellos que van a ser gobernados, y contrastada con aquellos que realizan la tarea de gobernar. Esto diferencia a este acto constituyente de un golpe de Estado”. Véase Friedrich, *Constitutional Government and Democracy*, 128; también Hannah Arendt, *On Revolution*, 146; y Carl Schmitt, *Constitutional Theory*, 104-105.

II. Poder constituyente y representación. Miguel Vatter

¹ Esta paradoja es objeto del reciente libro de Martin Loughlin y Neil Walker, *The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form* (Nueva York: Oxford University Press, 2008). Un tratamiento importante de la paradoja para mis propósitos se encuentra en Hannah Arendt, *On Revolution* (Nueva York: Penguin, 1990).

² En sus escritos sobre la Constitución chilena, Fernando Atria se demuestra sensible a la paradoja del constitucionalismo: según él, la legitimidad de una constitución dependería, al mismo tiempo, de la capacidad del pueblo de estar adentro y afuera de la constitucionalidad. Véase Fernando Atria, “Participación y alienación política: el problema constitucional”, en Claudio Fuentes (ed.), *En nombre del pueblo. Debate sobre el cambio constitucional en Chile* (Santiago: Ediciones Boll Cono Sur, 2010), 172-173. Véase también Fernando Atria, *La Constitución tramposa* (Santiago: LOM Editores, 2013).

³ Carl Schmitt, *Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty* (Cambridge: mit Press, 1988).

⁴ “All government rests on opinión”. James Madison, “The Federalist” XLIX, cit. en Hannah Arendt, *On Revolution*.

⁵ Nadia Urbinati, *Democracy Disfigured: Opinion, Truth and the People* (Cambridge: Harvard University Press, 2014). Para una discusión del poder constituyente en relación a este dualismo, véase Miguel Vatter, *Constitución y resistencia. Ensayos de teoría democrática radical* (Santiago: Ediciones UDP, 2010a). Para su aplicación a una teoría kantiana del poder constituyente, véase Miguel Vatter, “The People Shall Be Judge Reflective Judgment and Constituent Power in Kant's Philosophy of Law”, *Political Theory* 39, n.º 6 (2011): 749-776.

⁶ Véase Martin Loughlin, *Foundations of Public Law* (Nueva York: Oxford University Press, 2010).

⁷ David Runciman, “The paradox of political representation”, *Journal of Political Philosophy* 15, n.º 1 (2007): 93-114; Lisa Disch, “Democratic representation and the constituency paradox”, *Perspectives on Politics* 10, n.º 03 (2012): 599-616.

⁸ En el contexto del debate constitucional chileno, véase Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle, *La República en Chile. Teoría y Práctica del Constitucionalismo Republicano* (Santiago: LOM Editores, 2006); y Fernando Atria, *La Constitución tramposa*.

⁹ “For the constitution-making will of the people cannot be represented without democracy transforming itself into an aristocracy”. Carl Schmitt, *Constitutional Theory* (Durham: Duke University Press, 2008), 128 (sección 8, sobre *Verfassungslehre*) (traducción propia).

¹⁰ “Where the people as the subject of constitution-making power appear, the political form of

the state defines itself by the idea of an identity. The nation is there. It need not and cannot be represented". Ídem, ib., 239 (traducción propia).

¹¹ Ídem, ib., 247 (traducción propia).

¹² "The two principles of political form (identity and representation)". Ídem, ib., 239.

¹³ El poder de seducción del constitucionalismo de Schmitt para el "pensamiento conservador" chileno ha sido estudiado por Renato Cristi en *El Pensamiento Político de Jaime Guzmán: Autoridad y Libertad* (Santiago: LOM Editores, 2000a); véase también Renato Cristi y Carlos Ruiz, *El pensamiento conservador en Chile* (Santiago: Editorial Universitaria, 2015).

¹⁴ Andreas Kalyvas, *Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt and Hannah Arendt* (Nueva York: Cambridge University Press, 2009), 99 (traducción propia).

¹⁵ Mientras la posición de Atria parece cercana, bajo algunos aspectos, a la de Kalyvas, Cristi objeta que el criterio schmittiano del poder constituyente democrático haría ilegítima una reforma constitucional como la de 1989, la cual se fundaba sobre la hipótesis de que el pueblo había recuperado contra Pinochet su poder constituyente a través del plebiscito del 1988. Véase Renato Cristi, "Precisiones en torno a la noción de poder constituyente", en Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle (eds.), *El Constitucionalismo del Miedo. Propiedad, Bien Común y Poder Constituyente* (Santiago: lom, 2014). Una tesis similar ya se encuentra esbozada en Renato Cristi, "The Metaphysics of Constituent Power: Schmitt and the Genesis of Chiles 1980 Constitution", *Cardozo Law Review* 21 (1999): 1749-1775. Por otro lado, la argumentación de Cristi también parece presuponer consideraciones acerca de la soberanía de un pueblo que trata de salvar el poder constituyente como lo entiende Schmitt para un uso republicano. Cristi argumenta que el pueblo recuperó completamente su poder constituyente al "derrotar" a Pinochet en el plebiscito porque el legislador soberano no es quien establece las leyes en primer lugar, sino, más bien, aquel que tenga la autoridad para imponerlas en cualquier momento futuro; en este caso, entonces, el soberano después de 1988 no es Pinochet, sino el pueblo chileno. Cristi basa este argumento sobre una cita de Hobbes que se encuentra en el capítulo 26 del *Leviatán*: "Si el soberano de un Estado somete al pueblo, que había vivido bajo el imperio de otras leyes escritas, y luego lo gobierna por esas mismas leyes, esas leyes son las leyes civiles del vencedor, y no las del Estado vencido". Pero esta es claramente una idea antirrepublicana de la ley porque equipara el derecho a la voluntad, decisión o mandamiento del poder soberano, sin tomar en cuenta en absoluto la fundamentación de la autoridad del derecho en la opinión o juicio del pueblo (que es, en vez, la posición republicana).

¹⁶ Véase mi discusión en Miguel Vatter, "Republicanism or Modern Natural Right?: The Question of the Origins of Modern Representative Democracy and the Political Thought of Giuseppe Duso", *CR: The New Centennial Review* 10, n.º 2 (2010b): 99-120.

¹⁷ Quentin Skinner, "Hobbes on representation", *European Journal of Philosophy* 13, n.º 2

(2005): 170.

¹⁸ Ídem, ib., 171, 173.

¹⁹ Ídem, ib., 177-178.

²⁰ Sobre la idea de Constitución “absoluta” véase Cristi, “The Metaphysics of Constituent Power”.

²¹ Q. Skinner, “Hobbes on Representation”, 157.

²² Lucien Jaume, “Constituent Power in France. The Revolution and its Consequences”, en Neil Walker y Martin Loughlin (eds.), *The Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form*, 68-86; Gordon S. Wood, *Representation in the American Revolution* (Charlottesville: The University Press of Virginia, 1969).

²³ En las siguientes páginas, retomo la discusión de Miguel Vatter, “Il Potere del Popolo e la Rappresentanza in Rawls e nel Republicanesimo Civico”, *Filosofia Politica*, 24, n.º 2 (2010c): 263-284.

²⁴ Quentin Skinner, “Hobbes on Representation”, 162.

²⁵ Para una reciente defensa de la constitución mixta, véase Philip Pettit, *On the People's Terms. A Republican Theory and Model of Democracy* (Nueva York: Cambridge University Press, 2012).

²⁶ John Rawls, *Political Liberalism* (Nueva York: Columbia University Press, 1996), 422.

²⁷ Quentin Skinner, “Hobbes on Representation”, 162.

²⁸ John Rawls, *Political Liberalism*, 397.

²⁹ Ídem, ib.

³⁰ Hanna Pitkin, *The Concept of Representation* (Berkeley: University of California Press, 1967).

³¹ Philip Pettit, “Varieties of Public Representation”, en Susan Stokes et. al. (eds.), *Political Representation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 61-89.

³² Hasso Hofmann, *Rappresentanza-Rappresentazione. Parola E Concetto Dall'antichità All'ottocento* (Milán: Giuffrè Editore, 2007). Sobre la vuelta del sorteo en la democracia contemporánea, véase Nadia Urbinati, *Democrazia in Diretta. Le Nuove Sfide Alla Rappresentanza* (Milán: Feltrinelli, 2013).

III. Poder constituyente: ¿un mito católico versus un símbolo protestante? Gonzalo Bustamante

¹ No obstante, la reconstrucción de Sandro Chignola del pensamiento de Tocqueville, así como el de la gobernanza neoliberal, es relevante en este trabajo.

² Véase L. Jaume, “Défis et déficit démocratique: les revendications de légitimité”, en Mario Bertolissi, Giuseppe Duso, Antonino Scalone (eds.) *La Costituzione e Il Problema Della Pluralità* (Roma: Polimetria, 2008), 93-109.

³ Véase Rouhollah K Ramazani y Robert Fatton, *The Future of Liberal Democracy: Thomas Jefferson and the Contemporary World* (Palgrave: Macmillan 2004).

⁴ “I sincerely believe, with you, that banking establishments are more dangerous than standing armies”. Véase Jefferson T., *Political Writings* (Londres: Cambridge University Press, 2004), 209.

⁵ Sobre este problema, y su tratamiento fuera del mundo académico, véase, por ejemplo, Senadora Elizabeth Warren, *Huffington*, 17 de junio de 2013.

⁶ Véase Maurizio Viroli y Antony Shugar, *The Liberty of Servants: Berlusconi's Italy* (Princeton: Princeton University Press, 2012).

⁷ Véase, además, Carlo Galli, “La Italia de Silvio Berlusconi”, *Le Monde Diplomatique*, septiembre de 2009.

⁸ D. A. G. Hinks, *Tisias and Corax and the Invention of Rhetoric. The Classical Quarterly*, Vol. 34. 1-2 (april 1940): 61-69. Robert Danisch, *Pragmatism, Democracy, and the Necessity of Rhetoric* (South Carolina: The University of South Carolina Press, 2007).

⁹ Alexis de Tocqueville, *La democracia en América* (Madrid: Alianza Editorial, 2002), 99.

¹⁰ Emmanuel Sieyès, *¿Qué es el Tercer Estado?* (Madrid: Alianza Editorial, 2003).

¹¹ Para Arendt, lo “social” (que, conceptualmente, tomaría su origen de la tradición romana y medieval) sería, básicamente, un fenómeno moderno. El surgimiento de lo social se explicaría por la automatización del *oikos* como actividad económica y su extensión desde lo privado a lo público, y, paulatinamente, iría reemplazando lo político. La extensión de lo social sobre lo público y su expansión sería a costa de la biología y de lo natural, produciéndose, a su vez, una naturalización de lo social. Véase Hannah Arendt, *Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought* (Nueva York: Viking, 1968) y *The Human Condition* (Chicago: Chicago University Press, 1998). Sobre una crítica a la idea de Arendt sobre lo social, véase Hanna Pitkin, *The Attack of the Blob: Hannah Arendt's Concept of the Social* (Chicago: University of Chicago Press, 2000).

¹² En el caso de un país como Chile, la crisis político-institucional se manifiesta en la necesidad de una nueva constitución que signifique un abandono de la Constitución de Pinochet, así como un otorgamiento de legitimidad a un sistema político desgastado.

¹³ Respecto de la Constitución de 1980 en el caso chileno, existe un consenso: la ilegitimidad de su origen ya no es un eje de discusión. Lo anterior es producto de una hegemonía de su ilegitimidad, lo que hace que quienes son aún sus defensores, pero a la vez los entes racionales, opten, literalmente, por el silencio y se omitan de ese debate: la “fe en la Constitución del 80”, para quienes aún la poseen, se ha privatizado, pasando a ser un asunto de “credo que se practica o en la soledad o con un círculo muy cerrado de amigos”, como un club que se reconoce como “políticamente incorrecto”. Es así como Gonzalo Cordero (“La Derecha en la Encrucijada” [*Diario La Tercera*, 13 de abril de 2014]), histórico militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) —el partido político fundado por el mismo ideólogo de ese ordenamiento constitucional— indique que: “La constitución de 1980 es una especie de muerto jurídico caminando”. Después de 35 años de su promulgación, solo quedan como sus defensores públicos individuos opacos, sostenedores de ideas pintorescas, contribuidores a la provocación de humor espontáneo en las redes sociales. Su legitimidad es la propia de una película de baja factura de zombies. Es por eso que esa discusión se puede dar por cerrada.

¹⁴ Johann P. Arnason, Kurt A. Raaflaub y Peter Wagner (eds.), *The Greek polis and the invention of democracy: a politico-cultural transformation and its interpretations* (Oxford: John Wiley & Sons, 2013).

¹⁵ Es así como el uso en Herodoto de *Isokratia* como sinónimo de *Demokratia* implicaría una perífrasis que significaría el igual poder de un colectivo al cual no le correspondería un sujeto determinado, por lo cual tomaría la forma de una idea abstracta de “igualdad”.

¹⁶ McCormick mantendrá una división entre “*kratos*”/ “*arché*”, pero ahora desde la tradición florentina maquiaveliana donde las categorías definitorias de lo político serán “elite”/ “masa”. Defenderá un republicanismo popular (o, si se desea, un populismo estructural) en el cual el diseño institucional buscaría limitar la acumulación de poder político y económico de la elite por medio de un control directo del pueblo. Vale decir, lo que caracterizaría la tradición recogida por Maquiavelo y su prolongación histórica en el populismo democrático es la consideración de que el pueblo poseería una capacidad de razonar políticamente orientada a producir responsabilidad (*accountability*) por parte de los grupos dirigentes y autorregirse en varios aspectos de la vida política. La participación popular directa basada en el concepto *masa-ciudadana* como opuesto al de *potenti cittadini*, y no la del ciudadano-elector de la democracia representativa, sería la forma de una democracia popular que se encontraría en el florentino y que remitiría a la naturaleza propia de todo régimen democrático.

Como lo señalan Martin Loughlin y Neil Walker respecto de la visión constitucional de McCormick, en ella “exist[s] a critical distinction between traditional and modern constitutions. In traditional constitutions ‘the people’ signifies not only the body politic but also the common people with a distinctive interest in ensuring their freedom from oppression by the patrician class who invariably exerted a disproportionate influence in government. In modern constitutions, by

contrast, 'the people' is invariably treated as a unitary entity of formally equal citizens, with class-blind representative forms that tend to shield from view the reality of elective oligarchy. McCormick's argument points in the direction of acknowledging the necessity of maintaining within contemporary constitutional arrangements the tension between the instituted power of elected (patrician) rulers and the powers of the common people to check their more reckless or restrictive projects". Véase Martin Loughlin y Neil Walker, *The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form*,⁶. Por eso, McCormick considerará a la Escuela de Cambridge y afines (Pettit) como, básicamente, herederos del republicanismo elitista de Guicciardini. Véase John McCormick, *Machiavellian Democracy* (Nueva York: Cambridge University Press, 2011), 11. Incluye en esto a Pocock cuya obra, a su parecer, más que un "Momento Maquiavélico" debería ser considerado como un "Momento Guicciardiano".

¹⁷ Véase Antonio Camou, *Los desafíos de la gobernabilidad* (México DF: Flacso-ISUNAM, 2001). Respecto del análisis de la comisión bilateral, sigo de cerca el trabajo de Camou así como en lo referente a *governance* lo planteado por Chignola y Kooiman, especialmente.

¹⁸ Ídem, ib., 6.

¹⁹ Ídem, ib., 163-164.

²⁰ Para una crítica similar hacia el estado de bienestar, ver Niklas Luhmann, *Teoría Política en el Estado de Bienestar* (Madrid: Alianza Editorial, 2007).

²¹ Como señala Chignola, la gobernanza invierte el orden de la legitimidad desde su base en un "in-put" en el sistema representativo clásico a un "output" de tipo performativo.

²² De modo especial, véase Sandro Chignola, "In the Shadow of the State. Governance, Governamentalita, Governo", en G. Fiaschi (ed.), *Governance: oltre lo Stato* (Soveria Mannelli: Rubbettino, 2008), 117-141.

²³ El propio Fernando Atria en su consideración de lo que a su juicio es el carácter paleontológico y, por ende, despolitizado, del vocabulario jurídico, implícitamente está indicando que desde este se hace imposible responder a estos conceptos. Entre otras cosas, porque son polémicos (y polisémicos, al decir de Schmitt) y eso implica un vocabulario político, no-jurídico, o, si se quiere, la subordinación del sistema jurídico al político.

²⁴ Otros, como Francisco Zúñiga, criticarán lo que él designa como un "doble fetichismo constitucional": por un lado, aquellos que están embelesados con la Constitución y el orden que ha ocasionado y que son los "demonizadores" de la asamblea constituyente; así como otros, quienes con "prosa cuasi religiosa o mesiánica, y que deposita en el poder popular constituyente una potencia regeneradora y catártica, de un hombre nuevo y de un orden social, político, económico y jurídico nuevo por obra del nuevo sujeto popular que ya no es el proletariado o clase trabajadora". Gabriel Salazar. *En el nombre del poder popular constituyente (Chile, siglo XXI)* (Santiago: LOM Ediciones, 2011). El nuevo sujeto popular es una actualización radical y autoconsciente de los de abajo, del peonaje, del mestizaje, de los hombres y mujeres del mundo popular, de los

“perdedores” habituales o de siempre, de quienes se encuentran excluidos u olvidados. Es un lejano eco de la “verdadera democracia” de Marx, tributaria de Rousseau, en manos de una nueva clase en sí y para sí: los nuevos movimientos sociales, capaces de recrear una “comuna”, una democracia de comisiones, o una más autóctona y modernizada “democracia de los pueblos”. Véase “Nueva Constitución y Operación Constituyente. Algunas notas acerca de la Reforma Constitucional y de la Asamblea Constituyente”, *Estudios Constitucionales*, Año 11, n.º 1 (2013): 515-516. Zúñiga contrapondrá ambas formas de “fetichismo” a la idea de una operación constituyente que puede incluir una Asamblea Constituyente, un Referéndum Constituyente y/o un Congreso Constituyente, o una combinación de las anteriores. Una suerte de “católico a su manera”.

Más allá del deseo de lograr una propuesta políticamente viable que supere un simple análisis teórico, subyace al planteamiento de Zúñiga la cuestión de hasta dónde no implica una solución el tratar de rescatar la forma simbólica y ritualista del poder constituyente entendido como un *demos* con *kratos*-, como una instancia metafórica y no como una vuelta, revolucionaria, a su momento originario.

Ahora bien, respecto del problema constitucional chileno en particular, cabría indicar dos razones que explican su génesis: el origen antidemocrático de la Constitución en el contexto de una sociedad que constantemente desarrolla una mayor conciencia democrática y una crisis de la llamada democracia social weberiana respecto de la satisfacción de expectativas.

En relación a lo primero, quienes se han opuesto a una nueva constitución argumentan que su eficacia la legitimaría. El sistema político y jurídico operaría con menos trabas y mayor agilidad legislativa que con el ordenamiento constitucional anterior. Chile mostraría, así, indicadores de transparencia y valor institucional que lo acercaría más a los niveles de la oode que a los de nuestra región. Además, si se atiende al origen de muchas constituciones, lo que uno puede constatar es su falta de democracia originaria. Si es así: ¿Qué podría justificar una refundación constitucional?

²⁵ Lo mismo aplica para el caso chileno. La Constitución de 1980, tanto en su versión “firma Pinochet” como “firma Lagos”, muestra signos de falta de reconocimiento por su origen, no por su ineficacia jurídica. Ocurre que la convivencia social se sostiene no por tecnicismos, sino por la política. En el debate de Chile, esa tesis de oposición a una nueva constitución supone que su justificación (proceso constituyente) solo se produce en situaciones de crisis institucional profunda (lo cual no ocurriría hoy) y que la supuesta desafección constitucional sería un producto de las aulas universitarias (la gente estaría “en otra”). Es una tesis que desconoce la naturaleza de la racionalidad política, que consiste, justamente, en administrar la complejidad social para así evitar una crisis. Toda revolución es resultado de la falta de criterio y manejo político que le antecedió.

²⁶ Maurizio Lazzarato, “Biopolitique/Bioéconomie”, *Multitudes*, n.º 22 (2005).

²⁷ Jose. L Villacañas, “Oltre la democrazia o cómo abandonar la teología política. A propósito de G. Duso editor. Oltre la democrazia. Un itinerario attraverso i classici”, *Δαιμόν. Revista de Filosofía*, n.º 39 (2006): 61-68.

IV. Órdenes normativos transnacionales: el constitucionalismo del derecho intra y transnormativo. Poul F. Kjaer

¹ Niklas Luhmann, *Das Recht der Gesellschaft* (Fráncfort: Suhrkamp, 1993), 124.

² En general, véase Marc Amstutz y Vaïos Karavas, “Weltrecht: Ein Derridasches Monster”, en Galf-Peter Calliess et al. (eds.), *Soziologische Jurisprudence: Festschrift für Günther Teubner zum 75. Geburtstag* (Berlín: De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2009).

³ En general ver Jan Klabbers, Anne Peters y Geir Ulfstein, *The Constitutionalization of International Law* (Oxford - Nueva York: Oxford University Press, 2009).

⁴ Rudolf Stichweh, “Dimensionen des Weltstaats im System der Weltpolitik”, en M. Albert y R. Stichweh (eds.), *Weltstaat und Weltstaatlichkeit. Beobachtungen globaler politischer Strukturbildung* (Heidelberg: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007), 25. Se argumenta que toda comunicación política se encuentra integrada en un sistema de la política mundial y se discute la pregunta de si es que este sistema constituye un Estado mundial.

⁵ Véase Poul F. Kjaer, “The Concept of the Political in the Concept of Transnational Constitutionalism: A Sociological Perspective”, en C. Jorge y T. Ralli (eds.), *After Globalization - New Patterns of Conflict and their Sociological and Legal Reconstruction* (Oslo: ARENA, 2011), 285.

⁶ Véase Dieter Grimm, “The Achievements of Constitutionalism and its Prospects in a Changed World”, en P. Dobner y M. Loughlin (eds.), *The Twilight of Constitutionalism?* (Oxford - Nueva York: Oxford University Press, 2010), 3.

⁷ Martin Loughlin, “In Defence of Staatslehre”, *Der Staat* 48, n.º 1 (2009): 1.

⁸ Véase Chris Thornhill, *A Sociology of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 339.

⁹ Para la noción de pluralismo legal, véase Brian Z. Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global”, *Sydney L. Rev.* 30 (2008): 29.

¹⁰ Para un análisis extensivo, véase Thornhill, *A Sociology of Constitutions*.

¹¹ Véase Gunther Teubner, *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 21-24.

¹² Poul F. Kjaer, “Law and Order Within and Beyond National Configurations”, en P. F. Kjaer, G. Teubner y A. Febbrajo (eds.), *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation* (Oxford: Hart Publishing, 2011), 395.

¹³ Véase Kjaer, “The Concept of the Political in the Concept of Transnational Constitutionalism”, 285.

¹⁴ Ídem, ib., 285.

¹⁵ Véase Mathias Albert y Barry Buzan, “Securitization, Sectors and Functional Differentiation”, *Security Dialogue* 42, n.º 4-5 (2011): 413.

¹⁶ Amstutz y Karavas, “Weltrecht: Ein Derridasches Monster”, 652-653.

¹⁷ Kjaer, “The Concept of the Political in the Concept of Transnational Constitutionalism”, 285.

¹⁸ En general, véase Martti Koskeniemi, *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

¹⁹ En general, véase Philip C. Jessup, *Transnational Law* (New Heaven: Yale University Press, 1956).

²⁰ Peer Zumbansen, “Law and Legal Pluralism: Hybridity in Transnational Governance”, en P. Jurcys, P. F. Kjaer y R. Yatsunami (eds.), *Regulatory Hybridization in the Transnational Sphere* (Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013).

²¹ Robert N. Ross, “Ellipsis and the Structure of Expectation”, *San Jose State Occasional Papers in Linguistics*, 1 (1975).

²² Para un crítica de esta perspectiva, véase Amstutz y Karavas, “Weltrecht: Ein Derridasches Monster”, 645.

²³ Para más sobre este punto, véase Poul F. Kjaer, “Law of the Worlds Towards an Inter-Systemic Theory”, en S. Keller y S. Wiprachtiger (eds.), *Recht Zwischen Dogmatik und Theorie: Marc Amstutz zum 50. Geburtstag* (Zúrich: Dike Verlag, 2012), 159; Poul F. Kjaer, “The Political Foundations of Conflicts Law”, *Transnational Legal Theory* 2, n.º 2 (2011): 227.

²⁴ Poul F. Kjaer, “Systems in Context: On the Outcome of the Habermas/ Luhmann Debate”, *Ancilla Iuris*, 1 (2006): 70.

²⁵ Luhmann, *Das Recht der Gesellschaft*, 124.

²⁶ Talcott Parsons, *The System of Modern Societies* (Nueva Jersey: Prentice Hall, Inc., 1971), 11.

²⁷ Véase, por ejemplo, Christian Joerges, Poul F. Kjaer y Tommi Ralli, “A New Type of Conflicts Law as Constitutional form in the Postnational Constellation”, *Transnational Legal Theory* 2, n.º 2 (2011): 153.

²⁸ Amstutz y Karavas, “Weltrecht: Ein Derridasches Monster”, 657.

²⁹ Para una ilustración de esta relación para la “Europa social”, véase Christian Joerges, “Rechtsstaat and Social Europe: How a Classical Tension Resurfaces in the European Integration Process”, en L. Morlino y G. Palombella (eds.), *Rule of Law and Democracy. Inquiries into Internal and External Issues* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2010), 163.

³⁰ Véase, por ejemplo, Fritz W. Scharpf, “Legitimacy in the Multi-level European Polity”, en P. Dobner y M. Loughlin (eds.), *The Twilight of Constitutionalism?* (Oxford - Nueva York: Oxford University Press, 2010), 89.

³¹ Niklas Luhmann, *Soziale Systeme. Grundrifi einer allgemeinen Theorie* (Fráncfort:

Suhrkamp, 1984), 593.

³² Ídem, ib.

³³ En general, véase Martti Koskeniemi, “Empire and International Law: The Real Spanish Contribution”, *University of Toronto Law Journal* 61, n.º 1 (2011).

³⁴ En general, véase Torben M. Andersen y Tryggvi Thor Herbertsson, *Measuring Globalization*, en *iza Discussion Paper Series*, n.º 817 (2003).

³⁵ Niklas Luhmann, “Die Weltgesellschaft”, en *Soziologische Aufklärung, Band 2: Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft* (Fráncfort: Suhrkamp, 1970), 63.

³⁶ Ídem, ib., 68.

³⁷ Ídem, ib., 68.

³⁸ Martti Koskeniemi, “Miserable Comforters: International Relations as New Natural Law”, *European Journal of International Relations*, 15, n.º 3 (2009): 395.

³⁹ Ino Augsberg, “Observing (the) Law: The ‘Epistemological Turn’ in Public Law and the Evolution of Global Administrative Law”, en P. Jurcys, P. F. Kjaer y R. Yatsunami (eds.), *Public Law and the Evolution of Global Administrative Law: Regulatory Hybridization in the Transnational Sphere*, 11.

⁴⁰ Moritz Renner, “Death by Complexity — The Financial Crisis and the Crisis of Law in World Society”, en P. F. Kjaer, G. Teubner y A. Febbrajo (eds.), *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation*, 93, 98.

⁴¹ Niklas Luhmann, *Die Gesellschaft der Gesellschaft* (Fráncfort: Suhrkamp, 1997), 813.

⁴² Ídem, ib. 813.

⁴³ En general, véase Marc Amstutz, “Eroding Boundaries: On Financial Crisis and an Evolutionary Concept of Regulatory Reform”, en P. F. Kjaer, G. Teubner y A. Febbrajo (eds.), *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation*, 223.

⁴⁴ Rudolf Stichweh, *Inklusion und Exklusion. Studien zur Gesellschaftstheorie* (Bielefeld: transcript Verlag, 2005), 13.

⁴⁵ Ídem, ib.

⁴⁶ Ernst H. Kantorowicz, *The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology* (Princeton: Princeton University Press, 1957).

⁴⁷ Niklas Luhmann, “Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft”, en *Soziologische Aufklärung, Band 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft* (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1987), 67.

⁴⁸ Kantorowicz, *The King's Two Bodies*, 46.

⁴⁹ En general, véase Poul F. Kjaer, “Post-Hegelian Networks: Comments on the Chapter by Simon Deakin”, en M. Amstutz y G. Teubner (eds.), *Networks: Legal Issues of Multilateral Cooperation* (Portland: Hart Publishing, 2009), 75.

⁵⁰ Georg W. F. Hegel, “Grundlinien der Philosophie des Rechts. Oder Naturrecht und

Staatswissenschaft im Grundrisse”, en *Werke in 20 Bänden mit Registerband, Band 7* (Fráncfort: Suhrkam, 1986), 277.

⁵¹ Max Weber, “Bureaucracy”, en H. H. Gerth y C. Wright Mills (eds.), *From Max Weber: Essays in Sociology* (Abingdon: Routledge, 2009), 196.

⁵² Gunther Teubner, “A Constitutional Moment? The Logics of ‘Hitting the Bottom’”, en P. F. Kjaer, G. Teubner y A. Febbrajo (eds.), *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation*, 3, 25.

⁵³ Véase Moritz Renner, “Occupy the System! Societal Constitutionalism in Transnational Corporate Accounting”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 20, n.º 2 (2013): 941.

⁵⁴ Véase Teubner, *Constitutional Fragment*, 114.

⁵⁵ Para más sobre este punto, véase Kjaer, “Law and Order Within and Beyond National Configurations”, 395, 425.

⁵⁶ Hauke Brunkhorst, “Constitutionalism and Democracy in the World Society”, en P. Dobner y M. Loughlin (eds.), *The Twilight of Constitutionalism?*, 179, 197.

⁵⁷ Luhmann, *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, 826.

⁵⁸ Véase Martin Loughlin, “What is Constitutionalisation?”, en P. Dobner y M. Loughlin (eds.), *The Twilight of Constitutionalism?*, 47, 60.

⁵⁹ En torno a esta perspectiva, véase también Christopher Thornhill, “A Sociology of Constituent Power: The Political Code of Transnational Societal Constitutions”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 20, n.º 2 (2013): 551.

⁶⁰ Niklas Luhmann, “Die Zukunft der Demokratie”, en *Soziologische Aufklärung, Band 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft* (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1987), 126.

⁶¹ Poul F. Kjaer, *Between Governing and Governance. On the Emergence, Function and Form of Europe's Post-National Constellation* (Oxford-Portland: Hart Publishing, 2010), 37.

⁶² Véase Poul F. Kjaer, “The Metamorphosis of the Functional Synthesis: A Continental European Perspective on Governance, Law and the Political in the Transnational Space”, *Wisconsin Law Review* (2010): 489.

⁶³ Ídem, ib., 489.

⁶⁴ Thornhill, “A Sociology of Constituent Power...”.

⁶⁵ Ídem, ib.

⁶⁶ Ídem, ib.

⁶⁷ Véase Teubner, “A Constitutional Moment?”, 21.

⁶⁸ Luhmann mantiene un equilibrio formal entre las tres dimensiones, al tiempo que en sus descripciones empíricas de procesos sociales tienden a un solo lado de la dimensión de reflexividad. Para el diseño formal véase Luhmann, nota 25 arriba, 610.

⁶⁹ Véase Teubner, *Constitutional Fragments*, 89-90.

⁷⁰ Jürgen Habermas y William Rehg, “Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles?”, *Political Theory*, 29, n.º 6 (2001): 766, 774.

⁷¹ Ídem, ib.

⁷² Andreas Fischer-Lescano y Gunther Teubner, “Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law”, *Michigan Journal of International Law*, 25 (2004): 999.

¹ Theda Skocpol, Peter Evans y Dietrich Rueschemeyer, *Bringing the State Back In* (Nueva York- Cambridge: Cambridge University Press, 1985).

² Norberto Bobbio, “Is There a Marxist Theory of the State?”, *Telos*, 20 (1978): 5-16.

³ Thomas Hobbes, *Leviathan: Or the Matter, Forme, and Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civil*, editado por Ian Shapiro (New Haven: Yale University Press, 2010 [1651]).

⁴ Carl Schmitt, *The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol* (Chicago: The Chicago University Press, 2008).

⁵ Ídem, ib.

⁶ Carl Schmitt, *Dictatorship* (Cambridge: Polity Press, 2013).

⁷ Países de la Unión Europea como Portugal, Italia, Grecia y España.

⁸ Toni Negri, *Macchina tempo: rompicapi, liberazione, costituzione* (Milán: Feltrinelli, 1982).

⁹ Toni Negri, *Enciclopedia Fischer Feltrinelli (Stato e politica)* (Milán: Feltrinelli, 1970).

¹⁰ Toni Negri, *33 lezioni su Lenin* (Roma: Manifesto Libri, 2004).

¹¹ Michel Foucault, *The Courage of Truth (Lectures at the Collège de France)* (Londres: Palgrave Macmillan, 2011).

¹² Werner Naf, “Frühformen des modernen Staates im Spätmittelalter”, *Historische Zeitschrift*, 225 (1951).

¹³ Thomas Hobbes, *Leviathan*, capítulo XVI, 1ª parte.

¹⁴ “Der Stoff der Verfassungspolitik ist also nicht bloß ein gegebener, sondern auch ein lebendige”. Véase Ludwig August Von Rochau, *Grundsätze der Realpolitik. Angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands* (Berlín: Ullstein, 1972).

¹⁵ Por ejemplo, la desjerarquización de las fuentes normativas y la crisis del monopolio estatal en la producción del derecho, la globalización, la crisis de las instituciones de representación política, etc.

¹⁶ Saskia Sassen, *The global city: New York, London, Tokyo* (Princeton: Princeton University Press, 2001).

¹⁷ T. H. Marshall, “Citizenship and Social Class”, en *Class, Citizenship and Social Development* (Chicago: The University of Chicago, 1964).

¹⁸ Francois Ewald, *L'Etat providence* (París: Grasset, 1986).

¹⁹ Por ejemplo, Theda Skocpol et al., *Bringing the State Back In*.

²⁰ Como escribió, con una expresión que encuentro estrepitosa también, Toni Negri.

²¹ Quien será famoso, también entre nosotros, con *The Clash of Civilizations*.

²² Y este sería el aspecto participativo.

VI. Más allá del nexo soberanía-representación ¿un federalismo sin Estado? Giuseppe Duso

¹ Véase cuando Dieter Grimm dice: “*Insofern setzt die moderne Verfassung die Differenz von Staat und Gesellschaft voraus. Umgekehrt ist sie auf Akteure, Institutionen und Verfahren, die sich auf diese Grenzlinien nicht festlegen lassen, nicht eingerichtet*” en Grimm, *Die Zukunft der Verfassung* (Fráncfort: Suhrkamp, 1991), 431.

² Nota del traductor: El autor usa en reiteradas oportunidades el término ‘singolari’ que hemos decidido traducir como ‘singulares’. La decisión de mantener la literalidad del término se debe a que Duso utiliza también los términos ‘individui’, ‘cittadini’ y ‘soggetti’ con un sentido técnico. Sabemos que el término ‘singulares’ no es la traducción más habitual en español (la más corriente es ‘individuos’), sin embargo insistimos en que es la mejor opción para reflejar la complejidad y articulación del lenguaje filosófico-político elegido por el autor.

³ Véanse los trabajos del grupo de investigación de Padua dedicados a los conceptos políticos que deben tenerse en cuenta para entender las argumentaciones que están por debajo del presente razonamiento; en particular, aquel dedicado a las doctrinas del contrato social: Giuseppe Duso (ed.), *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna* (Milán: Francoangeli, 2006a). También disponible en español: *El contrato social en la filosofía política moderna* (Marta Rivero traductora) (Valencia: Leserwelt, 1998).

⁴ Véase Giuseppe Duso, “Crisi della sovranità: crisi dei diritti?”, en A. Carrino (ed.), *Il futuro dei diritti umani nella costruzione del nuovo ordine mondiale* (Napolés: Guida, 2003d), 83-103.

⁵ El problema planteado por Gustavo Zagrebelsky sobre la relación entre saber histórico y ciencia del derecho constitucional —véase Zagrebelsky, “Storia e costituzione”, en P. Grossi (ed.), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno* (Milán: Giuffré, 1993), 177-227; y Zagrebelsky et al. (eds.), *Il futuro della costituzione* (Einaudi, 1996), 35-82— debe ser asumido de modo radical, es decir, no como la relación y la comparación entre dos disciplinas o dos modos de considerar el derecho, sino como la interrogación sobre la génesis y sobre la determinación histórica del derecho constitucional.

Contra la costumbre de las disciplinas modernas de hacer su historia y de entender la historia sobre la base de la propia “cientificidad”. Se trata de entender la historicidad y, por lo tanto, la determinación y los presupuestos de la ciencia moderna y, con ello, mostrar también la contingencia y la precariedad que la connotan, contra una impostación dogmática.

⁶ Para la naturaleza histórica y filosófica del trabajo de investigación, véase Giuseppe Duso, “Storia concettuale come filosofia politica”, en *La logica del potere: storia concettuale come filosofia politica* (Monza: Polimetrica, 2001a), 19-60.

⁷ Sobre la duplicidad de un trabajo de filosofía política, el carácter arriesgado y no

“científicamente” fundado del discurso positivo y de una propuesta de orientación, véase Giuseppe Duso, “Dalla storia concettuale alla filosofia politica”, *Filosofia politica*, n.º 1 (2007a): 79-82.

⁸ En este momento estoy consultando el trabajo de Olivier Beaud, *Théorie de la Fédération* (París: Presses Universitaires de France, 2007), al que aún no he podido tener en cuenta en este ensayo. Me parece que en este texto está explícita la exigencia, que aquí busco demostrar, de pensar el federalismo más allá del concepto de soberanía y del concepto mismo de Estado. Una nota crítica sobre este texto fue publicada posteriormente en G. Duso, “Un dialogo con Olivier Beaud sul federalismo”, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 38 (2009), online, <http://goo.gl/HpXQRe>.

⁹ Véase Dieter Grimm, *Braucht Europa eine Verfassung?* (Múnich: Siemens-Stiftung, 1994). El término ‘democracia’ en mis trabajos ha sido entendido a partir de esta acepción de la forma constitucional y están citados en las notas que siguen a continuación. Una convincente puesta en discusión de la racionalidad formal del dispositivo de la soberanía, y del nexo poder/ derecho que está implicado, se encuentra en los trabajos de Paolo Grossi (véase la explicitación de la línea de investigación que propone Paolo Grossi, *Prima lezione di diritto* (Roma-Bari: Laterza, 2003) y Paolo Grossi, *Mitologie giuridiche nella modernità* (Milán: Giuffrè, 2007), que incluye también una síntesis aguda sobre el tema de la constitución que fue concebida como una introducción a un nuevo manual de derecho constitucional, pero se encuentra también como un artículo cuyo título —que pone en evidencia la relevancia para la presente reflexión— es: “Il costituzionalismo moderno fra mito e storia”, en *Giornale di Storia costituzionale*, 11 (2006): 25-72.

¹⁰ Sobre los problemas teóricos del camino actual hacia una constitución en Europa, sobre todo en relación con la diferencia entre *tratado* y *constitución*, y con el indispensable pluralismo que debe caracterizar a Europa, véase: Dieter Grimm, “Verfassung-Vertrag. Vertrag über eine Verfassung”, en O. Beaud et al. (eds.), *L'Europe en voie de Constitution Pour un bilan critique des travaux de la constitution* (Bruselas: Bruylant, 2004), 279-287. Sobre la dimensión teórica que caracteriza la constitución en el arco de la historia del estado moderno, véanse los trabajos de Hasso Hofmann, *Vom Wesen der Verfassung* (Berlín: Humboldt-Universität, 2002) y “Riflessioni sull'origine, lo sviluppo e la crisi del concetto di costituzione”, en S. Chignola y G. Duso (eds.), *Sui concetti politici e giuridici della costituzione dell'Europa* (Milán: Francoangeli, 2005), 227-237.

¹¹ Véase Dieter Grimm, “Una costituzione per l'Europa”, en Gustavo Zagrebelsky, Pier Paolo Portinaro y Jörg Luther (eds.), *Il futuro della Costituzione* (Roma: Einaudi, 1996), 353.

¹² Puede recordarse la conciencia puesta en evidencia por Kant en el momento en el que comprende que, si la vía para garantizar la paz a nivel internacional fuese la de la constitución de un estado mundial que realizase la unificación de derecho y fuerza, los Estados serían reducidos a súbditos y perderían su subjetividad política, como sucede con los ciudadanos singulares en el interior del Estado.

¹³ Sobre la estrecha relación entre la lógica de la soberanía y la democracia, sugiero también

el texto de Giuseppe Duso (ed.), *Oltre la democrazia. Un itinerario attraverso i classici* (Milán: Carocci, 2004), “Introduzione”, 9-29, y “Genesis e aporie dei concetti della democrazia moderna”, 107-138.

¹⁴ Véase Giuseppe Duso “Rappresentanza política e costituzione”, en *La logica del potere: storia concettuale come filosofia politica* (Monza: Polimetrica, 2001b), 157-183.

¹⁵ Sugiero Giuseppe Duso, “L'Europa e la fine della sovranità”, en *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2002, vol. 31, 123-126, donde tengo presente la interesante propuesta de Maurizio Fioravanti propuesta en sus últimos trabajos que culminan en una tentativa de plantear de un modo nuevo el problema de una constitución para Europa (véase Maurizio Fioravanti, “Stato e costituzione”, en *Lo stato moderno in Europa* (BariRoma: Laterza, 2002), 3-36, y *La scienza del diritto pubblico: dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento* (Milán: Giuffré, 2001), tomo ii, 835-906, especialmente 835-853.

¹⁶ Sobre este tema, véanse las agudas reflexiones de Ernst-Wolfgang Bóckenförde, “Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes. Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts”, en *Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zur Verfassungsrecht* (Fráncfort: Suhrkamp, 1991).

¹⁷ Para este resultado de las investigaciones realizadas sobre las doctrinas del contrato social, véase especialmente Alessandro Biral, “Hobbes: la societa senza governo”, en Giuseppe Duso (ed.), *Il contratto sociale nella filosofia política moderna*, 51-108; “Hobbes: la sociedad sin gobierno”, en Giuseppe Duso (ed.), *El contrato social en la filosofía política moderna* (Valencia: Leserwelt, 1998, 51-107); y “Il potere e la nascita dei concetti politici moderni”, en Sandro Chignola y Giuseppe Duso (eds.), *Sui concetti politici e giuridici della costituzione dell'Europa* (Milán: Francoangeli, 2010), 176-184.

¹⁸ Una situación tal en la que los conceptos, nacidos del iusnaturalismo, funcionaban como crítica a una organización que *de facto* era un centro de mando (decisión), no basada en una razón de derechos, lo cual era lo propio del período precedente tanto a la Revolución como a la subsiguiente época de las constituciones, pero no aquella abierta por esta última (época de las constituciones) en la que el poder es consecuencia de un fundamento jurídico.

¹⁹ Véase Duso, “Il potere e la nascita dei concetti politici moderni”, donde, recorriendo el texto hobbesiano, se busca mostrar que no es posible pensar la libertad como falta de impedimentos a la expresión de potencialidad de los individuos y como dependencia de la voluntad de otros, si no se piensa en las reglas que hacen posible para todos una libertad semejante, sin que alguien pueda imponerse a los demás; y estas reglas no son otra cosa que las leyes emanadas por el soberano.

²⁰ Véase Giuseppe Duso, “Genesis e lógica della rappresentanza política moderna”, en *La rappresentanza política: genesi e crisi del concetto*, 77-92.

²¹ En relación con el nexo existente entre iusnaturalismo y constitucionalismo, con particular

referencia a las constituciones modernas y a las constituciones del novecientos, se ha expresado recientemente P. Grossi (Véase “Il costituzionalismo moderno fra mito e storia”, 29, donde confirma también el nexo entre iusnaturalismo y absolutismo jurídico, 31). Debe recordarse, en efecto, que en el iusnaturalismo nace el dispositivo de la soberanía a partir de la absolutización de la ley que lo implica. En relación con la recaída de los conceptos del iusnaturalismo en las constituciones, sugiero también Duso “Genesi e logica della rappresentanza politica moderna”, 55-66.

²² Para una reflexión teórica sobre la representación, sugiero véase Giuseppe Duso, “La rappresentazione e l'arcano dell'Idea: introduzione a un problema di filosofia politica”, en *La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto*, 17-54. Sobre la historia de concepto, véase especialmente Hasso Hofmann, *Repräsentation: Studien zur Wort-und Begriffsgeschichte von der Antike bis zum 19. Jahrhundert* (Berlín: Duncker & Humboldt, 2003).

²³ Sobre este tema, véase las agudas observaciones de Bruno Karsenti, “Elezione e giudizio di tutti”, *Filosofia politica*, 20, n.º 3 (2006): 415-430; pero toda la sección monográfica de este número de la revista, dedicado justamente a la “democracia”, es relevante para las reflexiones aquí desarrolladas. Véase también Giuseppe Duso, *Crise de la démocratie et gouvernement de la vie* Giuseppe Duso y Jean Francois Kervegan (eds.) (Monza: Polimetrix, 2007b).

²⁴ Para las aporías del poder constituyente, en relación también con la discusión actual, véase Gaetano Rametta, “Le ‘difficolta’ del potere costituente”, *Filosofia politica*, 20, n.º 3 (2006): 391-402.

²⁵ En el escenario están los contratos señoriales, para los alemanes *Herrschaftsvertraege*. Son aquellos que el príncipe y los organismos populares estipulan en un documento; en él, el pueblo promete obediencia al príncipe y este, a su vez, reconoce las leyes fundamentales y las reglas que el pueblo impone (siempre teóricamente, enseña Althusius). De la primera Edad Moderna, la figura del contrato sirve, en efecto, para reconocer a sujetos diferentes que dan lugar al pacto y permanecen políticamente existentes y activos incluso después del pacto. En las doctrinas iusnaturalistas del contrato social, por el contrario, los sujetos que dan lugar al pacto (no es que haya pueblo y príncipe, sino individuos singulares) desaparecen como sujetos de decisión política en la realidad inaugurada (aunque sea solo idealmente) del pacto, a favor de la única decisión que, por una parte, está expresada por el soberanorepresentante, pero, por la otra, tiene a todos los individuos singulares como autores. La comparación entre Althusius y Hobbes es, a este propósito, particularmente iluminadora. Véase la “Introducción” en Giuseppe Duso (coord.), *El contrato social en la filosofía política moderna*.

²⁶ No es este federalismo el que está presente en el debate actual. Véase como ejemplo la comparación recordada por Beaud en el ensayo introductorio a los actos de un reciente congreso sobre los procesos de la Constitución europea entre federalistas y gubernamentalistas: los primeros, que tienden a acentuar el poder de los órganos centrales y asumen una óptica unitaria, y

los segundos, que tienden a atenuar la relación común, privilegiando la autonomía decisional de los Estados (véase Olivier Beaud, “Démocratie, fédéralisme et constitution”, en Olivier Beaud et al. [eds.], *L'Europe en voie de Constitution Pour un bilan critique des travaux de la constitution* [Bruselas: Bruylant, 2004], 8-9). Puede notarse como, en ambos casos, nos encontramos en el interior de la óptica de la soberanía y el problema consiste solo en decidir cuánto de esta permanece en los Estados y cuánto es cedido al *nuevo Estado europeo*. Como he recordado más arriba, por el contrario, me parece que en el nuevo trabajo *Théorie de la fédération*, Beaud sostiene la necesidad de pensar el federalismo más allá de los conceptos de Estado y de soberanía. El problema es el de tener presente todo el horizonte conceptual que *Estado y soberanía* implican para lograr pensar la política de un modo diferente de aquel que es habitual tanto en el lenguaje común como en las disciplinas científicas.

²⁷ Para la diferencia entre la concepción de gobierno y el moderno concepto de poder político en la forma de soberanía, y para la determinación del significado y de las implicaciones del principio del gobierno, sugiero Giuseppe Duso, “Fine del governo e nascita del potere”, en *La logica del potere: storia concettuale come filosofia politica* (Monza: Polimetrica, 2001c), 83-122. Me parece que la propuesta aquí adelantada sobre un modo diferente de comprender la unidad de una realidad política conduce a una decisiva superación del concepto de soberanía (justo en la dirección de comprensión de la realidad y, al mismo tiempo, de orientar los procesos en curso) respecto de aquello que sucede a través de la imagen de la elipsis con dos fuegos propuesta por Maurizio Fioravanti, “La forma política europea”, en Giuseppe Duso (ed.), *Ripensare la costituzione: la questione della pluralità* (Monza: Polimetrica 2008), 29-42.

²⁸ En relación con esto, es ejemplar el modo en el que Althusius trata la democracia como forma de gobierno: no es el gobierno democrático, que es una instancia unitaria y, por lo tanto, el elemento monárquico de la constitución (que no puede ser más que mixta, “cioè ogni costituzione è mixta”), el que expresa la voluntad del pueblo. Más bien, esta está presente en las organizaciones colegiadas, en las que, en modo plural, el pueblo está siempre institucionalmente presente y con las que el gobierno debe confrontarse continuamente. Véase Giuseppe Duso, “La costituzione mista e il principio del governo: il caso Althusius”, *Filosofia politica* 19, n.º 1 (2005): 11-96, especialmente 90-93.

²⁹ Para una precisión del sentido determinado y limitado de la expresión “conceptos políticos modernos”, sugiero Duso, “Dalla storia concettuale alla filosofia politica”, 11-14.

³⁰ El federalismo, al ser una concepción de la política basada en el pacto, en el acuerdo de los diferentes actores políticos, no puede tener aquella garantía de eliminación del conflicto que es perseguida desesperadamente por la forma política moderna basada en el monopolio de la fuerza y en la unicidad del sujeto político. Para la productividad de la referencia a Althusius en relación con la temática europea, pero también para las advertencias necesarias para evitar malentendidos haciendo del uso de su pensamiento, algo totalmente asimilado a los conceptos del Estado que se

pretende superar, sugiero Duso, “L'Europa e la fine della sovranita”, 126-134. Para una breve y simple presentación del pensamiento de Althusius véase Duso, “Il governo e l'ordine delle consociazioni”, en *Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna* (Roma: Carocci, 2001d), 11-94. Pero para el modo más pluralista y federalista de pensar la política por parte de Althusius, véase Duso, “Una Prima Esposizione del Pensiero Politico di Althusius: La Dottrina del Patto e la Costituzione del Regno”, *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno* 25 (1996): 65-126.

³¹ Véase lo que dice con la habitual claridad conceptual Dieter Grimm, “Vertrag oder Verfassung”, en *Staatswissenschaft und Staatspraxis* (1995), 152ss, que recuerda la diferencia estructural en relación con los sujetos implicados, lo que connota la forma del tratado y la de la constitución. Dicha distinción es innegable y hace justicia con muchas confusiones: permanece todavía anclada a la autonomía que es propia de los Estados en su soberanía y no se logra que la realidad política se piense de un modo diferente, esto es, como una y al mismo tiempo también plural. La misma dificultad me parece que se mantiene también en el análisis interesante de I. Pernice y F. Mayer, “La costituzione integrata dall'Europa”, en G. Zagrebelsky et. al. (eds.), *Diritti e costituzione nell'Unione Europea* (Bari-Roma: Laterza, 2003), 43-68. De este último ensayo, también debe compartirse la idea de “constitución sin Estado”, fórmula que se acerca a la que presentamos aquí, pero con la conciencia de que esto requiere un cambio radical en el modo de pensar la política que pone en crisis el concepto de poder político y la misma modalidad de pensar desde un punto de vista constitucional su legitimación.

³² Para recuperar la categoría de gobierno en el corazón de la misma legitimación, sugiero Giuseppe Duso, “La democrazia e il problema del governo”, *Filosofia politica*, 20, n.º 3 (2006a): 381-385.

³³ Ver Hofmann, “Riflessioni sull'origine, lo sviluppo e la crisi del concetto di costituzione”, 221-231, y Hofmann, *Vom Wesen der Verfassung*, 19. Sobre las dificultades que encuentra la capacidad normativa de la constitución, véase Grimm, *Die Zukunft der Verfassung*, 241 y ss.; y también Gustavo Zagrebelsky (“I paradossi della riforma costituzionale”, en G. Zagrebelsky et. al. [eds.], *Il futuro della costituzione* [Einaudi, 1996], 293-314), quien critica los tentativos abstractos de una gran reforma, a favor de una actitud que intente constantemente con intervenciones particulares, aparentemente limitadas, unificar procesos materiales y forma constitucional. Sobre el tema de la deconstitucionalización, resulta eficaz la descripción de Adone Brandalise, “Democrazia e deconstituzionalizzazione”, *Filosofia politica*, 20, n.º 3 (2006): 403-414.

VII. Hacia una deconstitucionalización del particularismo normativo en América Latina. Aldo Mascareño

¹ Gunther Teubner, *Constitutional Fragments* (Oxford: Oxford University Press, 2012); Marcelo Neves, *Transconstitutionalism* (Oxford: Hart Publishing, 2013); Poul Kjaer, *Constitutionalism in the Global Realm* (Oxon: Routledge, 2014).

¹ Fritz Scharpf, “Legitimacy in the Multilevel European Polity”, *European Political Science Review*, 1, n.º 2 (2009): 113-204.

³ Aldo Mascareño, *Die Moderne Lateinamerikas* (Bielefeld: Transcript, 2012).

⁴ Horst Pietschmann, *Die staatliche Organisation des kolonialen Iberoamerika* (Stuttgart: Klett-Cotta Verlag, 1980); C. Véliz, *The Centralist Tradition of Latin America* (Princeton: Princeton University Press, 1980); W. Ansaldi y V. Giordano, *América Latina. La construcción del orden* (Barcelona: Ariel, 2012); Mascareño, *Die Moderne Lateinamerikas*.

⁵ Chris Thornhill, *A Sociology of Constitutions* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 113.

⁶ Ídem, ib., 114.

⁷ L. Bethell, *Historia de América Latina. Vol. 7* (Barcelona: Crítica, 1991); L. Benton, *Law and Colonial Cultures* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

⁸ Thornhill, *A Sociology of Constitutions*, 116.

⁹ Domingo Faustino Sarmiento, *Facundo. Civilisation and Barbarism* (Londres: University of California Press, 2003).

¹⁰ J. B. Alberdi, *Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina* (Buenos Aires: Editorial Jackson, 1951).

¹¹ Andrés Bello, “Las repúblicas hispanoamericanas”, en L. Zea (comp.), *Fuentes de la cultura latinoamericana* (México DF: Fondo de Cultura Económica, 1995).

¹² Aldo Mascareño, “Sattelzeit y transición. Fundamentos estructurales y semánticos de la modernidad en América Latina”, en *América Latina Moderna*, A. Strück (ed.) (Caracas: Ediciones Universidad Central de Venezuela, 2013a), 1-44.

¹³ Marcelo Neves, *A constitucionalização simbólica* (Sao Paulo: Editora Acadêmica, 2001).

¹⁴ Aldo Mascareño, *Diferenciación y contingencia en América Latina* (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010); Mascareño, *Die moder-ne Lateinamerikas*.

¹⁵ Roberto Gargarella, “Latin American Constitutionalism, 1810-60”, *Latin American Research Review*, 39, n.º 2 (2004): 141-153.

¹⁶ Ídem, ib., 144.

¹⁷ Ídem, ib., 147.

- ¹⁸ Gino Germani, *The Sociology of Modernization* (Londres: Transaction Books, 1981).
- ¹⁹ Gargarella, "Latin American Constitutionalism"; Brian Loveman y Elizabeth Lira, *Arquitectura política y seguridad interior del Estado, 1811-1990* (Santiago: DIBAM-LOM Ediciones, 2000).
- ²⁰ Miguel Schor, "Constitutionalism through the looking glass of Latin America", *Texas International Law Journal*, 41 (2006): 1-37.
- ²¹ Ídem, ib., 7.
- ²² Ídem, ib., 19.
- ²³ Véase C. Véliz, *The New World of the Gothic Fox. Culture and Economy in English and Spanish America* (Berkeley: University of California Press, 1994); Pedro Morandé, *Cultura y modernización en América Latina* (Madrid: Ediciones Encuentro, 1981); Cristián Parker, *Otra lógica en América Latina: religión popular y modernización capitalista* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 1996).
- ²⁴ Niklas Luhmann, "Globalization or World Society: How to Conceive of Modern Society?", *International review of sociology*, 1, n.º 1 (1991): 74-75, 76.
- ²⁵ Helmut Willke, *Regieren* (Wiesbaden: Springer VS, 2014).
- ²⁶ Reinhart Koselleck, Otto Brunner y Werner Conze (eds.), *Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zurpolitisch-sozialen Sprache in Deutschland. Band 4* (Stuttgart: Klett Cotta, 2004), 135.
- ²⁷ Talcott Parsons y Edward Shils, *Toward a General Theory of Action*(Cambridge: Harvard University Press, 1962), 81-82.
- ²⁸ Teubner, *Constitutional Fragments*, 65.
- ²⁹ Jürgen Habermas, *Zeit der Übergänge* (Fráncfort: Suhrkamp, 2001); Otfried Hoffe, *Wirtschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürger: Politische Ethik im Zeitalter der Globalisierung* (Múnich: C.H. Beck, 2004); Karl-Heinz Ladeur y Lars Viellechner. "Die transnationale Expansion staatlicher Grundrechte. Zur Konstitutionalisierung globaler Privatrechtsregimes", *Archiv des Völkerrechts*, 46, n.º 1 (2008): 42-13.
- ³⁰ Niklas Luhmann, "Verfassung als evolutionare Errungenschaft", *Rechtshistorisches Journal*, 9, n.º 1 (1990): 116-220; Niklas Luhmann, *Grundrechte als Institution* (Berlín: Duncker & Humblot, 1999); Giancarlo Corsi, "Sociologia da Constituigao", *Revista da Faculdade de Direito da ufmg* 39 (2001): 169-189; Chris Thornhill, "Niklas Luhmann and the Sociology of the Constitution", *Journal of Classical Sociology* 10, n.º 4 (2010): 315-331.
- ³¹ Teubner, *Constitutional Fragments*, 10.
- ³² Aldo Mascareño, "Justicia global y justicia sectorial en la sociedad mundial. Momentos de universalidad en la lex mercatoria", *Dilemata*, 13 (2013b): 45-68.
- ³³ Teubner, *Constitutional Fragments*, 126.
- ³⁴ Aldo Mascareño y Elina Mereminskaya, "The making of world society through private

commercial law: the case of the unidroit Principles”, *Uniform Law Review-Revue de droit uniforme*, 18, n.º 3-4 (2013): 447-472.

³⁵ Karel van Hulle, “Prudence: a principle or an attitude?”, *European Accounting Review* 5, n.º 2 (1996): 377.

³⁶ Diana Festl-Pell, “Applying Macro-prudence in Financial Standard Setting”, *acrn Journal of Finance and Risk Perspectives*, 1, n.º 1 (2012): 16.

³⁷ Eric Dunning, “The Development of Modern Football”, en *The Sociology of Sport: A Selection of Readings* (ed. por Eric Dunning) (Londres: Frank Cass, 1971).

³⁸ Roland Renson, “Fair play: its origins and meanings in sport and society”, *Kinesiology*, 41, n.º 1 (2009): 7.

³⁹ Poul Kjaer, “Legitimacy Through Constitutionalism”, en Aldo Mascareño y Katia Araujo (eds.), *Legitimization in World Society* (Surrey: Ashgate, 2012).

⁴⁰ Poul Kjaer, “Transnational Normative Orders: The Constitutionalism of Intra- and Trans-normative Law”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 20, n.º 2 (2013): 799.

⁴¹ Rafael Arráiz, *Las constituciones de Venezuela (1811-1999)* (Caracas: Editorial Alfa, 2012).

⁴² Luis Díaz (ed.), *Golpe al vacío. Reflexiones sobre los sucesos de abril de 2002* (Caracas: Lugar Común, 2012).

⁴³ Ana Teresa Torres, *La herencia de la tribu* (Caracas: Editorial Alfa, 2009).

⁴⁴ Talcott Parsons, “On the Concept of Value-Commitments”, *Sociological Inquiry*, 38 (1968): 135-160.

⁴⁵ Miguel Martínez, “Golpes de Estado en Venezuela durante el período 1989-2004: Evolución del conflicto y contexto sociopolítico”, *Análisis Político*, 64, (2008): 3-21.

⁴⁶ República Bolivariana de Venezuela 1999, “Corte Suprema de Justicia de Venezuela sobre el referendo para convocar a una Asamblea Constituyente”, Fallo 11: 5, 1, online, <<http://infovenezuela.org/democracy/attachments-spanish/T1%20STo1%20N2%20Fallos%20N11%20y%2018%20de%20la%20CSJ%20sobre%20el%20R%20consultivo%20.pdf>> (consulta: febrero de 2016).

⁴⁷ Joel Colón-Ríos, “Carl Schmitt and Constituent Power in Latin American Courts: The Cases of Venezuela and Colombia”, *Constellations*, 18, n.º 3 (2011): 365-388.

⁴⁸ República Bolivariana de Venezuela 1999, “Corte Suprema de Justicia de Venezuela sobre el referendo para convocar a una Asamblea Constituyente”, Fallo 17: 8.

⁴⁹ Ana Teresa Torres, *La herencia de la tribu*, 209.

⁵⁰ Ryan Brading, “From passive to radical revolution in Venezuela's populist Project”, *Latin American Perspectives*, 41, n.º 6 (2014): 48-64.

⁵¹ Ryan Brading, *Populism in Venezuela* (Nueva York: Routledge, 2013).

⁵² Para esto, véase los detallados relatos en Luis Díaz (ed.), *Golpe al vacío. Reflexiones sobre los sucesos de abril de 2002* (Caracas: Lugar Común, 2012).

⁵³ José Antonio Leone, “Precariedad jurídica y militarismo en Venezuela 2000-2012”,

Provincia, 26: 61.

⁵⁴ Ídem, ib., 18.

⁵⁵ Thais Maignon y Friedrich Welsch, “Venezuela 2008: Hoja de ruta hacia el socialismo autoritario”, *Revista de Ciencia Política*, 29, n.º 2 (2009): 639.

⁵⁶ República Bolivariana de Venezuela 2016, Consejo Nacional Electoral, “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, online, <http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/indice.php>. (consulta: febrero de 2016).

⁵⁷ República Bolivariana de Venezuela, “Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan”, *Gaceta Oficial*, n.º 38.617 (2007).

⁵⁸ República Bolivariana de Venezuela, “Ley que autoriza al ciudadano Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan”, *Gaceta Oficial*, n.º 40.297 (2013).

⁵⁹ Dario Azzellini, “Venezuela's Solidarity Economy: Collective Ownership, Expropriation, and Workers Self-Management”, *The Journal of Labor and Society*, 12 (2009): 111-191.

⁶⁰ Mark Dinnen, “The Chávez' Government and the Battle over the Media in Venezuela”, *Asian Journal of Latin American Studies*, 25, n.º 2 (2012): 25-53.

⁶¹ Roger Burbach y Camila Piñeiro, “Venezuela's Participatory Socialism”, *Socialism and Democracy*, 21, n.º 3 (2001): 181-200.

⁶² S. Valenzuela, “La Constitución de 1980 y el inicio de la redemocratización en Chile”, *Working Paper 242*, The Hellen Kellogg Institute for International Studies (1997); Manuel Antonio Garretón, *Política y sociedad entre dos épocas* (Rosario: HomoSapiens, 2000).

⁶³ Gargarella, “Latin American Constitutionalism”.

⁶⁴ Gobierno de Chile, *Declaración de Principios del Gobierno de Chile* (Santiago: República de Chile, 1974).

⁶⁵ Jaime Bassa y Christian Viera, “Contradicciones de los fundamentos teóricos de la Constitución chilena con el Estado constitucional: Notas para su reinterpretación”, *Revista de Derecho*, 21, n.º 2 (2008): 131-150.

⁶⁶ Paul E. Sigmund, “Revolution, counterrevolution, and the catholic church in Chile”, *The annals of the American Academy of Political and Social Science* (1986): 33.

⁶⁷ Pius XI, *Encyclia Quadragessimo Anno* (1931), online, <<http://goo.gl/Q5YtK3>>. (consulta: diciembre de 2013), §XX.

⁶⁸ Ídem, ib., §80.

⁶⁹ Teubner, *Constitutional Fragments*.

⁷⁰ Lisa Hilbink, “The Constituted Nature of Constituents' Interests Historical and Ideational Factors in Judicial Empowerment”, *Political Research Quarterly*, 62, n.º 4 (2009): 190.

⁷¹ Javier Couso, “Trying Democracy in the Shadow of an Authoritarian Legality: Chiles

Transition to Democracy and Pinochet's Constitution of 1980", *Wisconsin International Journal*, 29, n.º 2 (2011): 408.

⁷² Ver Patricio Meller, "A review of Chilean privatization experience", *The Quarterly Review of Economics and Finance* 33 (1993): 95-112; Judith A. Teichman, *The politics of freeing markets in Latin America: Chile, Argentina, and Mexico* (Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 2001); Hector Schamis, *Re-forming the state: the politics of privatization in Latin America and Europe* (Michigan: University of Michigan Press, 2002).

VIII. El debate constitucional en Chile. La Cuestión de la legitimidad. Valentina Verbal

¹ Por ejemplo, la organización Marca ACque, desde la sociedad civil, ha liderado esta postura, sostiene que el país “requiere la construcción de un marco institucional que nos represente a todas y todos”. Véase “Manifiesto de Marca AC, 11 de septiembre de 2014, online, <<http://goo.gl/ysgPq8>>”><http://goo.gl/ysgPq8>>. (consulta: 15 de junio de 2015).

² Tanto por razones prácticas como de fondo. Entre las primeras, la ilegitimidad en que ha devenido la actual Constitución. Entre las segundas, el hecho de que la actual constituye una especie de *trofeo* de un sector ideológico en contra de otro. Sobre este tema, volveré en las conclusiones.

³ Juan J. Linz, *La quiebra de las democracias* (Buenos Aires: Alianza Editorial, 1991), 38.

⁴ Giovanni Sartori, *¿Qué es la democracia?* (México DF: Taurus, 2007), 74.

⁵ Ídem, ib., 75.

⁶ Según Linz, cuando la oposición le niega legitimidad al gobierno se convierte en una “oposición desleal”. Véase Linz, *La quiebra de las democracias*, 38.

⁷ Aunque, evidentemente, no se trata de visiones mutuamente excluyentes, sí representan acentos marcados. La primera, mucho más idealista y normativa que la segunda.

⁸ Siempre se agradecen los planteamientos de larga duración y no meramente presentistas.

⁹ Por ejemplo, referidas al modelo económico.

¹⁰ “La Constitución de 1828 ha sido, en dos siglos de historia, *la única acordada libremente por la ciudadanía chilena*”. Véase Gabriel Salazar, *En el nombre del poder popular constituyente (Chile siglo XXI)* (Santiago: LOMEdiciones, 2011), 47 (énfasis en el original).

¹¹ Sergio Grez, “La ausencia de un poder democrático en la historia de Chile”, en *Asamblea Constituyente. Nueva Constitución* (Santiago: Le Monde Diplomatique-Editorial Aún creemos en los sueños), 53-54.

¹² Incluso en torno a la Carta de 1828. En efecto, el 28 de junio, menos de dos meses antes de su promulgación (8 de agosto) se produjo el célebre alzamiento con tinte federalista del coronel Pedro Urriola, quien estuvo a un paso de derrocar al gobierno. Si no entró al palacio presidencial, fue solo porque no contó con suficiente apoyo civil, un requisito esencial para la efectividad de las insubordinaciones castrenses. En la línea de Salazar, el constitucionalista Francisco Zúñiga ha señalado que la Constitución de 1828 fue la expresión de un “poder democrático”. Véase Francisco Zúñiga, “Nueva Constitución y operación constituyente: algunas notas de la reforma constitucional y de la Asamblea Constituyente”, *Estudios constitucionales*, 11, n.º 1 (2013): 522.

¹³ Para este tema, es muy recomendable la investigación inédita de Lorena Recabarren, *Lógicas de rechazo a la democracia en América Latina. Más allá de una aproximación*

dicotómica al apoyo a la democracia (Tesis doctoral Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2014).

¹⁴ Samuel Huntington, *El soldado y el Estado. Teoría y práctica de las relaciones cívico-militares* (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1985), 91.

¹⁵ Gonzalo Vial, *Chile. Cinco siglos de historia. Desde los primeros pobladores hasta el año 2006, Tomo 2* (Santiago: Editorial Zig-Zag, 2009), 1391-1396.

¹⁶ Ídem, ib., 1384.

¹⁷ Sofía Correa Sutil, “Los procesos constituyentes en la historia de Chile. Lecciones para el presente”, *Estudios Públicos*, n.º 137 (2015): 74.

¹⁸ Para una buena síntesis de este proceso, véase Julio Heise, *Evolución histórica del pensamiento parlamentario en Chile* (Santiago: Instituto de Chile -Academia de Ciencias Sociales, 1986). Estas reformas fueron, entre otras, la supresión de la reelección presidencial, la disminución de los *quorum* parlamentarios para sesionar y la limitación de las facultades extraordinarias a materias específicas y a una duración anual. Todas apuntaron a reducir el presidencialismo reforzado de la Carta de 1833. A esto hay que agregar las leyes periódicas, que vienen del texto original, y un conjunto de prácticas que se fueron estableciendo con el paso del tiempo, siendo la interpelación la más relevante.

¹⁹ Alberto Edwards, “Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos”, en Alberto Edwards y Eduardo Frei (eds.), *Historia de los partidos políticos chilenos* (Santiago: Editorial del Pacífico, 1949), 100-111. La edición original de esta obra es de 1903.

²⁰ Gonzalo Vial aporta la cifra de “ochenta ministerios durante veintinueve años, siendo por tanto la duración promedio de cada uno, alrededor de cuatro meses y medio”. Véase Vial, *Chile. Cinco siglos*, 1025.

²¹ Denominación frecuente en historiografía para diferenciarlo del parlamentarismo clásico, especialmente en su versión británica. Una buena explicación, puede verse en Bernardino Lira, “Parlamentarismo a la chilena”, *Revista Chilena de Derecho*, 18, n.º 3 (1991): 363-373.

²² Se trató de seis reformas que apuntaron a fortalecer las facultades del presidente de la República frente al Congreso o, más bien, frente a los partidos políticos.

²³ Incluyendo las que fueron opositoras a la dictadura militar de Pinochet.

²⁴ El mismo Linz afirma que en la legitimidad del sistema político resulta crucial el rol desempeñado por los intelectuales: “Como en el caso de otras creencias sociales, los intelectuales tienen el papel principal a la hora de formular, elaborar y transmitir la fórmula de legitimidad”. Véase Linz, *La quiebra*, 41.

²⁵ Sobre todo, si se estaba antes o después de las reformas de 2005.

²⁶ Esta palabra tiene un carácter básicamente denostativo y da cuenta de la construcción de un *hombre de paja* en torno al sistema de libre mercado. Para este concepto, ver Enrique Gherzi, “El mito del neoliberalismo”, *Estudios públicos* 95 (2004): 293-313.

²⁷ Manuel Antonio Garretón, *La sociedad en que vivi(re)mos. Introducción sociológica al cambio de siglo* (Santiago: LOMediciones, 2000), 153.

²⁸ *Ibíd.*, 157. Un ejemplo citado por el autor es el de la inamovilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, lo que se derogaría en 2005.

²⁹ *Ibíd.*, 164.

³⁰ *Ibíd.*, 168.

³¹ Para el consenso elitario al que se llegó en torno a las reformas del 2005, ver Claudio Fuentes, *El pacto. Poder, Constitución y políticas públicas en Chile (1990-2010)* (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2012).

³² Pablo Ruiz-Tagle, “La trampa del neopresidencialismo: la Constitución gatopardo”, en Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle (eds.), *La República de Chile. Teoría y práctica del constitucionalismo republicano* (Santiago: LOMediciones, 2008), 197.

³³ *Ídem*, *ib.*, 198.

³⁴ *Ídem*, *ib.*, 200.

³⁵ *Ídem*, *ib.*, 201.

³⁶ *Ídem*, *ib.*, 201.

³⁷ Manuel Antonio Garretón, *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010* (Santiago: Editorial Arcis-CLACSO, 2012), 10.

³⁸ Fernando Atria, *Veinte años después. Neoliberalismo con rostro humano* (Santiago: Catalonia, 2013), 3.

³⁹ *Ídem*, *ib.*, 3-4.

⁴⁰ Merecería un punto aparte el tratamiento del movimiento estudiantil como catalizador de la deslegitimación aquí analizada, pero no cabe duda que este, a su vez, fue legitimado por la ex Concertación, quien le dio *carta de ciudadanía*. Y no en términos meramente “gremiales”, sino en un sentido político-ideológico amplio. Expresión intelectual de este resultado es el libro de Fernando Atria, et al., *El otro modelo. Del orden neoliberal al orden de lo público* (Santiago: Debate, 2013).

⁴¹ Un ejemplo emblemático de un intelectual de izquierda extra Concertación ha sido el de Alberto Mayol, *El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo* (Santiago: LOM Ediciones, 2012); y también Gabriel Salazar, citado varias veces en este artículo.

⁴² René León E., *Evolución histórica de los partidos políticos chilenos* (Buenos Aires: Editorial Francisco de Aguirre, 1971), 39.

⁴³ Para una explicación clara de este concepto, ver Humberto Nogueira A., “Consideraciones sobre Poder Constituyente y Reforma de la Constitución en la Teoría y la Práctica Constitucional”, *Ius et praxis*, 15, n.º 1 (2009): 229-262.

⁴⁴ En opinión del autor, el concepto más adecuado de utilizar sería “traba” en vez de

“trampa”. Ella sería más precisa con su idea a desarrollar. Con todo, a fin de mantener una coherencia argumental en la discusión con Fernando Atria, el autor ha optado por valerse de la noción “trampa”.

⁴⁵ Fernando Atria, *La Constitución tramposa* (Santiago: LOM Ediciones, 2013).

⁴⁶ Cabe recordar que esta crisis generó la convocatoria, por parte de la presidenta Bachelet, de un consejo asesor, conocido como Comisión Engel, dado que fue presidida por el economista Eduardo Engel. Véase *Consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Informe final* (Santiago: 24 de abril de 2015).

⁴⁷ Entrevista a Fernando Atria: “El parlamento no tiene legitimidad suficiente para el proceso constituyente” (*La Tercera*, 25 de mayo de 2015), 11.

⁴⁸ Otros casos, asociados al mismo movimiento, son los de Miguel Crispi, excoordinador nacional de RD, quien trabaja como asesor en el Ministerio de Educación, y Javiera Parada, actual agregada cultural en Washington, antes vocera de Marca AC.

⁴⁹ Jorge Correa Sutil, “¿Ha llegado la hora de una nueva Constitución?”, *Anuario de Derecho Público*, 1 (2013): 23.

⁵⁰ A este punto, me referí a comienzos de 2014 a través de una columna de opinión. Véase Valentina Verbal, “Asamblea queremos: el argumento de la representatividad”, *Publimetro*, 14 de enero de 2014, online, <<http://goo.gl/zDTWpn>>. (consulta: 8 de junio de 2015).

⁵¹ Rodrigo Borja Cevallos, “Corporativismo”, *Enciclopedia de la Política*, online, <<http://goo.gl/DbvSjK>>. (consulta: 2 de junio de 2015).

⁵² Considerando que la bibliografía sobre este tema es extensa, y para el conjunto de las revoluciones europeas, me parecen fundamentales las siguientes dos obras: Eric Hobsbawm, *La era de la revolución 1789-1848* (Buenos Aires: Crítica, 2007); y Louis Bergeron, François Furet y Reinhart Koselleck, *La época de las revoluciones europeas 1780-1848* (Madrid: Siglo XXI Editores, 2006).

⁵³ Una explicación desmitificadora sobre el individualismo liberal, puede verse en Friedrich Hayek, “El individualismo: el verdadero y el falso”, *Estudios Públicos*, 22 (1986): 1-28.

⁵⁴ Stanley Payne, *El fascismo* (Madrid: Alianza Editorial, 2009), 32. Esta obra asume una concepción amplia del fascismo, no reduciéndolo al movimiento del mismo nombre que se dio en Italia en torno a la figura de Benito Mussolini.

⁵⁵ Gabriel Salazar, “Dispositivo histórico para asambleas populares de base que se proponen desarrollar su poder constituyente” (Santiago: 2013), 16 (destacado en el original).

⁵⁶ Ídem, ib.

⁵⁷ Salazar, *En el nombre*, 82.

⁵⁸ Esta propuesta aparece descrita en el artículo de Sofía Correa, referido en este trabajo, “Los procesos constituyentes”, 74-80. Según esta autora, fue difundido por la organización Marca AC vía correo electrónico. Sin embargo, no aparece publicada en su sitio web. De cualquier manera, al

escuchar a los dirigentes de esta entidad, resulta bastante fácil constatar que adhiere a un mecanismo de carácter corporativista.

⁵⁹ Ídem, ib., 77.

⁶⁰ Ídem, ib., 78.

⁶¹ Esto no contradice la necesidad de ampliar los espacios de participación ciudadana, pero siempre como un complemento (y no como un sustituto) de la democracia representativa.

⁶² Se podría contraargumentar que esto era válido en épocas de voto restringido. Pero, precisamente, la mayoría de ciudadanos que hoy se abstiene de concurrir a las urnas, confirma el carácter elitario de la política. En otras palabras, podría sostenerse —al menos como hipótesis— que la mayoría de la población desea que los políticos resuelvan ellos mismos los asuntos del poder.

⁶³ Correa, “¿Ha llegado?”, 26.

⁶⁴ José Francisco García, “Minimalismo e incrementalismo constitucional”, *Revista chilena de derecho*, 41, n.º 1 (2014): 270.

⁶⁵ Para este tema, véase Arturo Valenzuela, *El quiebre de la democracia en Chile* (Santiago: Flacso, 1988). En esta obra, Valenzuela sostiene que la principal causa de la ruptura institucional en Chile de 1973 se debió a la polarización del país como consecuencia de la transformación de un centro político pragmático en uno ideológico, impidiendo, así, el acomodo y la transacción, y, finalmente, el respeto mayoritario por las reglas del juego democrático.

⁶⁶ Correa, “¿Ha llegado?”, 27.

⁶⁷ Para este tema, la literatura es extensa, pero como explicación general véase Sebastián Salazar P., “Fundamentación y estructura de los derechos sociales”, *Revista de derecho (Valdivia)*, 26, n.º 1 (2013): 69-93.

⁶⁸ Giovanni Sartori dice que las “Constituciones fachada” o “Constituciones-trampa”, en cuanto a “la libertad y los derechos de los destinatarios de las normas, son letra muerta”. Véase Sartori, *Elementos de teoría política* (Madrid: Alianza Editorial, 1992), 21.

¹ Paulo Hidalgo, *El Ciclo Político de la Concertación (1990-2010)* (Santiago: Uqbar Editores, 2011), 30 y ss.

² Véase Fernando Atria, “La Constitución tramposa y la responsabilidad del jurista”, en F. Zúñiga (ed.), *Nueva Constitución y Momento Constitucional. Visiones, antecedentes y debates* (Santiago: Legal Publishing-Thomson Reuters, 2014), 39-47. Véase también el monográfico colectivo titulado “Reformas Constitucionales” en *Revista de Derecho Público*, Número especial “Reformas Constitucionales”, marzo (2014).

³ Programa de gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).

⁴ Thomas Darnstadt, *La trampa del consenso* (Madrid: Trotta, 2005).

⁵ Tom Ginsburg, “Fruto de la parra envenenada? Algunas observaciones comparadas sobre la constitución chilena”, *Revista de Estudios Públicos*, 133 (2014): 1-36.

⁶ Hans Kelsen, *Esencia y valor de la democracia* (Barcelona: Editorial Labor, 1977). También Norberto Bobbio, *El futuro de la democracia* (Barcelona: Plaza & Janes editores, 1985) y *Teoría general de la política* (Madrid: Trotta, 2003), 459-462.

⁷ Carlos Sánchez, *El Poder Constituyente* (Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1957), 575 y ss. También Jorge R. Vanossi, *Teoría Constitucional. 2 Vol* (Buenos Aires: Depalma, 1975), Tomo I, 123 y ss.; Giuseppe de Vergottini, *Las transiciones constitucionales. Desarrollo y crisis del constitucionalismo a finales del siglo XX* (Bogotá: Universidad Externado de COLOMBIA, 2002), 182-183.

⁸ Hans Kelsen, *Teoría pura del Derecho* (México DF: Editorial Porrúa-UNAM, 1991).

⁹ También Paul Laband, *Le Droit de L'Empire Allemand. 6 Vols.*, V. Giard y E. Briere (eds.) (París: 1900-1901), Tomo I, 158 y ss., Tomo II, 313 y ss.

¹⁰ Alf Ross, *El concepto de validez y otros ensayos* (México: Editorial Fontamara, 2001).

¹¹ Alain Rouquié, *A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina* (Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2011).

¹² Dolf Sternberger, *Patriotismo Constitucional* (Bogotá: Universidad Externado de COLOMBIA, 2001). Véase también Jürgen Habermas, *La necesidad de revisión de la izquierda* (Madrid: Tecnos, 1991).

¹³ Bruce Ackerman, *El futuro de la revolución liberal* (Barcelona: Ariel, 1996), 55-61.

X. Proceso constituyente originario. Renato Cristi

¹ En pleno proceso de discusión constitucional, el autor sostuvo un intenso debate con Fernando Atria a través de un conocido medio de comunicación. Además de los tópicos que en este libro se desarrollan, la polémica también tuvo otras confrontaciones de contenido. La secuencia de argumentos y contrargumentos fue la siguiente: Renato Cristi, “Revolución y legalidad” (*El Mostrador*, 9 de diciembre de 2015) y “La Revolución abstracta y la nueva Constitución” (*El Mostrador*, 15 de diciembre de 2015). Fernando Atria respondió a Cristi con “Sobre el problema constitucional y el extremismo de centro I” (*El Mostrador*, 21 de diciembre de 2015) y en “Sobre el problema constitucional y el extremismo de centro II” (*El Mostrador*, 28 de diciembre de 2015). Finalmente, Cristi respondió a Atria con “Teoría Constitucional y Violencia” (*El Mostrador*, 4 de enero de 2016).

² Hernán Cisternas, “Denominación de la Constitución abre debate entre juristas y parlamentarios” (*El Mercurio*, 21 de septiembre de 2005).

³ Véase Fernando Atria, *La Constitución tramposa* (Santiago: LOM Ediciones, 2013), 17.

⁴ Dieter Blumenwitz y Sergio Gaete Rojas, “Declaración de Profesores de Derecho de la Universidad Católica de Chile”, en *La Constitución de 1980. Su legitimidad* (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1981), 47-54; véase Renato Cristi, *El pensamiento político de Jaime Guzmán. Una biografía intelectual* (Santiago: LOM Ediciones, 2011a).

⁵ El hecho de que uno de sus firmantes sea Jaime Guzmán le da a este documento una especial relevancia. Otros firmantes de esta Carta, además de Chadwick, son: Hernán Larraín Fernández, Arturo Irarrázabal Covarrubias, Jaime del Valle, Gustavo Cuevas Farren, Gonzalo Rojas Sánchez y Javier González Echenique. Véase Renato Cristi, “La noción de poder constituyente en Carl Schmitt y la génesis de la Constitución de 1980”, *Revista Chilena de Derecho*, 20 (1993): 247-249; cf. Claudio Fuentes, *El fraude* (Santiago: Hueders, 2013).

⁶ Blumenwitz, “Declaración de Profesores de Derecho de la Universidad Católica de Chile”, 48.

⁷ Ídem, ib., 49 (énfasis añadido).

⁸ Ídem, ib., 48.

⁹ Ídem, ib., 49.

¹⁰ Ídem, ib., 49.

¹¹ Arturo Ferandois, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afirma taxativamente que “solo puede considerarse como ente constituyente a la Junta de Gobierno, órgano que sí detentaba esa función suprema del Estado por obra del decreto N.º 788, de 4 de diciembre de 1974”. Véase Ferandois, *Derecho Constitucional Económico*.

Regulación, tributos y propiedad (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2010), il, 211. Afirmar esto en 2010 sin cualificaciones presupone una aquiescencia y conformidad irreflexiva con respecto a la legitimidad de origen y ejercicio del régimen dictatorial de Pinochet.

¹² Blumenwitz, “Declaración de Profesores de Derecho de la Universidad Católica de Chile”, 50; cf. Sergio Gaete, “El Poder constituyente”, en *La Constitución de 1980. Su legitimidad* (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1981), 37.

¹³ Blumenwitz, “Declaración de Profesores de Derecho de la Universidad Católica de Chile”, 50-51.

¹⁴ Cisternas, “Denominación de la Constitución abre debate entre juristas y parlamentarios”.

¹⁵ Atria, *La Constitución tramposa*, 84.

¹⁶ Ídem, ib., 27.

¹⁷ Ídem, ib., 69.

¹⁸ Ídem, ib., 26.

¹⁹ Ídem, ib., 60.

²⁰ Ídem, ib., 63.

²¹ Ídem, ib., 63-64.

²² Lagos citado en ídem, ib., 76.

²³ Cf. Fuentes, *El Fraude*.

²⁴ Atria, *La Constitución tramposa*, 64.

²⁵ Ídem, ib., 64.

²⁶ Ídem, ib., 79.

²⁷ Ídem, ib., 79-80.

²⁸ Fernando Atria, “Sobre la soberanía y lo político”, *Revista de Derecho y Humanidades*, n.º 12 (2006): 47-93.

²⁹ Renato Cristi, *El pensamiento político de Jaime Guzmán*.

³⁰ Atria, “Sobre la soberanía y lo político”, 53; cf. Cristi, *El pensamiento político de Jaime Guzmán*, 161. La cita completa que Atria omite es la siguiente: “Si bien es cierto que este plebiscito, y el sentido de las reformas que introduce, confirma que el Poder constituyente ha sido retomado por el pueblo, esa toma de posesión es parcial. Persisten en el texto constitucional aprobado ciertas instituciones que no permiten la plena expresión del nuevo sujeto de Poder constituyente. Esto podría explicar por qué se ha manifestado en Chile, en estos últimos años, un creciente desencanto político y constitucional. El pueblo aún no parece sentirse comprometido con las instituciones democráticas dispuestas en la Constitución. Tal como la Constitución de 1822 fue interpretada en una oportunidad por Guzmán como ‘un ardid’ de O’Higgins para ‘prolongar su mandato’, hoy día se interpreta nuestra Constitución como un ardid para soslayar los efectos del sufragio universal y anular el gobierno de la mayoría. Es una cuestión abiertamente discutida si las reformas constitucionales introducidas por el plebiscito de 1989 efectivamente expresaron el

anhelo democrático que guió a la movilización popular a partir de 1982”.

³¹ Atria, “Sobre la soberanía y lo político”, 53.

³² Renato Cristi, *Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism: Strong State and Free Economy* (Cardiff: University of Wales Press, 1998).

³³ Cf. Carl Schmitt, “Das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich”, *Deutsche Juristen-Zeitung*, 38, n.º 1 (1933): 455-458.

³⁴ Atria, “Sobre la soberanía y lo político”, 54.

³⁵ La disposición transitoria 13 de la Constitución de 1980 establece: “Decimotercera. El período presidencial que comenzará a regir a contar de la vigencia de esta Constitución, durará el tiempo que establece el artículo 25”. Y la disposición transitoria 18 establece: “Decimoctava. Durante el período a que se refiere la disposición decimotercera transitoria, la Junta de Gobierno ejercerá, por la unanimidad de sus miembros, las siguientes atribuciones exclusivas; A. Ejercer el Poder Constituyente sujeto siempre a aprobación plebiscitaria, la que se llevará a efecto conforme a las reglas que señale la ley”. Debo esta referencia a Patricio Espinoza.

³⁶ Cf. Carl Schmitt, *Teoría de la Constitución* (Madrid: Alianza, 1982 [1934]), 98.

³⁷ Cf. Renato Cristi, “Schmitt on Constituent Power and the Monarchical Principle”, *Constellations*, 18, n.º 3 (2011b): 352-364. El principio monárquico se extingue con la abdicación de Carlos X en 1830, pero solo en 1848, al inicio de la Segunda República francesa, se restaura el poder constituyente del pueblo.

³⁸ Renato Cristi, “The Metaphysics of Constituent Power: Schmitt and the Genesis of Chile’s 1980 Constitution”, *Cardozo Law Review*, 21 (1999): 1749-1745.

³⁹ Atria, *La Constitución tramposa*, 80-84.

⁴⁰ En *El otro modelo*, Fernando Atria et al. definen, en términos generales, los “mecanismos de discusión y decisión política” requeridos para la génesis de una nueva constitución para Chile. Véase Atria et al., *El otro modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público* (Santiago: Debate, 2013), 111. Fijan en el año 2011 la fecha en que se inicia esta discusión, precisamente cuando el movimiento estudiantil plantea la necesidad “de encontrar formas de darnos una nueva constitución” (Ídem, ib., 109). Desde ese momento, queda claro que el énfasis no cae tanto en el contenido mismo de la nueva constitución, sino en el método de cómo lograrlo. Tomando como ejemplo el artículo 19 de la Constitución de 1980, que enumera los derechos constitucionales que configuran el régimen neoliberal, los autores señalan: “la cuestión de cuáles son los mecanismos de discusión y decisión política que contemple la Constitución es mucho más importante que cuál es el texto que señala los derechos fundamentales que consagra” (Ídem, ib., 110-111). Por mi parte, pienso que enfatizar la cuestión de los mecanismos de discusión política es indicador de que Atria no busca, estrictamente, un nuevo contenido constitucional, es decir, una nueva constitución, sino que solo intenta hacer expedito el poder constituyente derivativo de la Constitución actual mediante el cual se la puede reformar. Por esto ya supone que es el pueblo, y

no Pinochet y la Junta Militar, el sujeto del poder constituyente. Ningún opositor a la dictadura militar aceptaría pensar que se trata de reformar la Constitución de 1980, pues con eso no habría, estrictamente hablando, una nueva constitución, y tendría razón Chadwick.

⁴¹ Gabriel Salazar, *En el nombre del poder popular constituyente (Chile siglo XXI)* (Santiago: LOM Editores, 2011), 76.

⁴² Ídem, ib.

⁴³ Atria, *La Constitución tramposa*, 63.

⁴⁴ Ídem, ib., 64.

⁴⁵ Ídem, ib.

⁴⁶ Ídem, ib., 54.

⁴⁷ Ídem, ib., 55 (énfasis añadido).

⁴⁸ Atria no toma en cuenta lo que Hobbes escribe en el *Leviatán*, cap. 26: “Si el soberano de un Estado somete al pueblo, que había vivido bajo el imperio de otras leyes escritas, y luego lo gobierna por esas mismas leyes, esas leyes son las leyes civiles del vencedor, y no las del Estado vencido. El legislador no es quien por cuya autoridad las leyes fueron promulgadas en primera instancia, sino quien por cuya autoridad esas leyes continúan siendo leyes”. En el caso chileno, el vencedor fue el pueblo, bajo cuya autoridad (es decir, bajo su poder constituyente originario) la Constitución que Pinochet, el vencido, promulgó en primera instancia, continuó siendo la Constitución del vencedor. Que el vencedor no haya querido o podido asumir en plenitud el ejercicio poder constituyente derivativo que le correspondía en derecho no es más que una contingencia histórica.

⁴⁹ Atria, *La Constitución tramposa*, 74.

⁵⁰ Salazar, *En el nombre del poder popular constituyente*, 69-72.

⁵¹ En cuanto a la “nueva” constitución, Atria et al. dejan en claro que su novedad no consistiría en su texto (es decir, en su contenido), sino en “como la Constitución estructura el proceso político” (Atria et al., *El otro modelo*, 117). De ese modo, es posible que “la nueva Constitución [...] reproduzca en buena parte el mismo texto de la Constitución de 1980, tal como la de 1980 reprodujo una cantidad considerable de disposiciones de la de 1925” (Ídem, ib.). Esto confirma lo que Atria et al. señalan más arriba, a saber, que “si los procedimientos de discusión y decisión política cambiaran, entonces interpretaciones ideológicamente distintas del *mismo texto constitucional* se harían posibles” (Ídem, ib., 110, énfasis añadido). No es, por tanto, un proceso constituyente originario lo que buscan activar Atria et al., sino un proceso constituyente derivativo.

⁵² Atria, *La Constitución tramposa*, 72.

⁵³ Ídem, ib., 74, cf., 55.

⁵⁴ Ídem, ib., 76.

⁵⁵ No me parece correcto equiparar a Guzmán con Madison, cuyo republicanism podría

caracterizarse como democrático (véase Fernando Muñoz León, “Recensión: Cristi, Renato, El pensamiento político de Jaime Guzmán: una biografía intelectual”, *Revista de Derecho*, Universidad Austral, vol. 25 [2012]: 268). Si bien Madison en *El Federalista* 10 se refiere a los inconvenientes de la democracia, lo hace solo respecto a la “democracia pura”, es decir, a la democracia directa y no representativa. Pienso que una comparación con Schmitt es más apropiada debido a que el papel que este último juega en la destrucción de la Constitución de Weimar es similar al que juega Guzmán en la destrucción de la Constitución de 1925 y la transición a la dictadura soberana de Pinochet. Mal que mal, ambos fueron admiradores del pensador carlista Donoso Cortés. No obstante, debo reconocer que Muñoz León tiene toda la razón cuando afirma que el papel que le correspondió a Schmitt en la consolidación del nuevo régimen “fue mínimo en comparación con el de Guzmán” (Ídem, ib., 268). Su pensamiento político y jurídico, comparado con el de Schmitt, careció de peso teórico, algo que Guzmán compensó con su extraordinaria capacidad argumentativa, extensa actividad constituyente y gran dexteridad política.

XI. Nueva constitución y poder constituyente: ¿qué es “institucional”? Fernando Atria

¹ Remitimos a la nota 1 del artículo anterior.

² La opinión editorial de *El Mercurio* fue publicada el 23 de septiembre de 2005. La opinión de Chadwick está consignada en “Denominación de la Constitución abre debate entre juristas y parlamentarios” (*El Mercurio*, 21 de septiembre de 2005).

³ Hans Kelsen, *Teoría pura del derecho* (México: Porrúa, 1991 [1960]), 119120 (énfasis añadido).

⁴ Para el argumento véase Fernando Atria, *La Constitución tramposa* (Santiago: LOM Ediciones, 2013), 38-41.

⁵ Véase Fernando Atria, *Veinte años después. Neoliberalismo con rostro humano* (Santiago: Catalonia, 2013), 3-6.

⁶ Carl Schmitt, *Teoría de la constitución* (Madrid: Alianza, 1992 [1928]), 114.

⁷ Me interesa explicar la peculiar esterilidad de la reflexión “constitucional” en Chile, en relación a las cuestiones importantes que uno pensaría que son las materias de competencia específica de los “constitucionalistas”, que después de todo se supone que se dedican profesionalmente al estudio de las formas institucionales de la democracia representativa. La “doctrina constitucional”, aun la autodenominada “progresista”, ha sido sistemáticamente deficitaria, no ha estado a la altura. Tres consideraciones pueden ilustrar esta afirmación. La primera es sobre las trampas constitucionales: los especialistas en las formas institucionales de la democracia no fueron capaces de identificar las trampas constitucionales, y por eso muchos profesores (“progresistas”) de derecho constitucional se sumaron a la declaración del expresidente Lagos en 2005 — de que la constitución había cambiado— a pesar de que las neutralizaciones vigentes permanecían en ella. La segunda se refiere al rol del Tribunal Constitucional y sobre la justificación de la jurisdicción constitucional en general. Cualquiera que esté al tanto de la discusión constitucional en otros países, sabe que este es uno de los temas importantes de la discusión constitucional. Con esto no estoy diciendo que la doctrina constitucional comparada esté en contra de un tribunal constitucional (no es así, aunque la cuestión se ha puesto menos obvia en el último tiempo), pero sí que ella es consciente de que hay ahí un problema que debe ser tratado. No así en Chile. Aunque recientemente han salido algunas voces al respecto, la doctrina constitucional chilena bajo la Constitución de 1980 es unánime en esta materia, y no se da el trabajo siquiera de discutir con un mínimo de seriedad el asunto. Y aquí me refiero no solo a constitucionalistas de derecha, que no sería raro que defendieran la jurisdicción constitucional (es su cerrojo, después de todo), sino también a los de izquierda. Y nótese que esto ocurre en ese país que, en términos constitucionales, tiene la dudosa distinción de ser el único cuya democracia

posdictatorial se basa en la Constitución dada por el dictador (!), y se trata de un tribunal cuya integración hasta 2005 era garantía de una interpretación neoliberal de la Constitución (!). La tercera es que hay pocas cuestiones que hayan obsesionado más a la doctrina constitucional “progresista” en las últimas décadas que la de lo que ellos llaman “derechos sociales”. Y, entonces, cuando un gobierno asume como parte central de su programa la transformación de la educación de una mercancía en un derecho social, uno habría esperado que la doctrina constitucional nos pudiera dar luces acerca de las cuestiones de organización propiamente institucional de los derechos sociales: ¿es compatible la lógica de los derechos sociales con la educación privada? ¿Excluye toda forma de selección, o solo algunas? ¿Es lo mismo la selección escolar (básica o media) y la universitaria? ¿Pueden los derechos sociales ser provistos por particulares con fines de lucro? ¿Por qué si/ no? Y las preguntas podrían multiplicarse. Pero no es la doctrina constitucional la que contribuirá a resolverlas. La reflexión sobre los “derechos sociales” nunca estuvo orientada a preguntas como estas, sino solo a la cuestión de si (y cómo) ellos podían ser protegidos por tribunales de justicia. Hay entonces una pregunta importante que debe ser respondida acerca de la peculiar esterilidad de la reflexión constitucional chilena, el hecho de que cuando hay cuestiones importantes respecto de las cuales uno esperaría que ella contribuyera a clarificar o entender mejor, no tenga nada interesante que decir. Personalmente, he intentado algunas respuestas a estas interrogantes en Fernando Atria, “La Constitución tramposa y la responsabilidad del jurista”, en *Nueva Constitución y Momento Constitucional* (F. Zúñiga [ed.]) (Santiago: Legal Publishing, 2014).

⁸ El joven egresado de derecho aludido era Eugenio Velasco, y el argumento con el que sorprendió a sus profesores (la llamada “tesis Velasco”) está hoy explicada en cualquier texto de derecho civil. Su exposición completa la hizo en su memoria de grado, que fue luego publicada por la Editorial Jurídica: Eugenio Velasco, *El objeto ante la jurisprudencia* (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1941).

⁹ Para una explicación completa y detallada del argumento, véase Atria, *La Constitución tramposa*, 103-160.

¹⁰ Ídem, ib., 38-41.

¹¹ Para las afirmaciones (siempre sin argumentos), véase Ídem, ib., 105-109.

¹² Ídem, ib., 128-136.

¹³ Y permitiría además, en caso de ser necesario, la dictación de una ley que convocara a una elección especial de representantes para decidir sobre la nueva constitución. Por esta razón, es preferible a la solución de una disposición transitoria que autorice la convocatoria por una sola vez a un plebiscito.

¹⁴ Esta es la mejor manera de entender ese momento de validación institucional que abra posibilidades y no decida. Pero, por supuesto, no hay razón alguna para pensar que no surgirán otras posibilidades en el futuro. Yo he oído algunas otras: la introducción de un capítulo XVI

adicional al texto constitucional, que trate del cambio constitucional completo, o la dictación de una nueva disposición transitoria que autorice por una vez un plebiscito constitucional. Todas estas opciones, y otras que todavía no han surgido en el caso de que lo hagan, deberán ser considerados con cuidado. Lo que aquí me importa no es defender la que me parece más adecuada, sino ilustrar el argumento.

¹⁵ Por ahora quiero mostrar solo un ejemplo (para otro, véase la nota n.º 48 de mi libro *La Constitución tramposa*). Cristi cita y discute profusamente mi afirmación de que la “constitución” hoy vigente es la de 1980, es decir, la misma de Pinochet, pese a las reformas. La razón por la que yo creo que se trata de la misma “constitución” es que una constitución en este sentido no es un texto, es una decisión. Y la decisión fundamental de 1980 fue neutralizar al pueblo, y esa neutralización quedó alojada en diversos mecanismos que funcionan como cerrojos o trampas constitucionales, que en lo relevante todavía subsisten. Por eso, “la subsistencia de esos cerrojos es la marca de la continuidad entre la constitución actual y la de Pinochet” (véase Atria, *La Constitución tramposa*, 54). Cristi afirma que, en este pasaje, hay “un extraordinario reconocimiento” porque aquí yo estaría distinguiendo “la constitución de Pinochet, es decir, la de 1980, y la constitución actual”, a la vez que afirmando la continuidad entre ellas (véase Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle) (eds.), *El constitucionalismo del miedo. Propiedad, bien común y el poder constituyente* (Santiago: LOM Editores, 2014), 172. Es verdad que uno puede usar la expresión “x marca la continuidad entre a y b” para afirmar que a y b son dos cosas distintas, aunque tienen en común x. Así, por ejemplo, si uno dijera “la marca de la continuidad entre el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación es que ocupan los mismos inmuebles” estaría diciendo que hay algo común a dos entidades distintas. Pero también puede significar otra cosa, como cuando uno dice “la marca de la continuidad entre el modelo económico de Pinochet y el de la Concertación es la focalización del gasto social”. Aquí lo que se está diciendo es que, aunque a y b parecen ser dos entidades distintas, x muestra que son la misma. Cuál de estas dos cosas se afirma al decir que x es la marca de la continuidad entre a y b depende, evidentemente, del contexto. Yo creo que el contexto de *La Constitución tramposa* hace evidente que lo afirmado ahí era que, a pesar de que parece que se tratara de dos entidades distintas, las trampas constitucionales muestran que la Constitución de 1980 y la actualmente vigente son la misma. Que, teniendo disponibles estas dos interpretaciones, Cristi haya elegido la primera, a sabiendas de que entendida así la frase era totalmente incoherente con el resto del texto (lo que le lleva a celebrar un inexistente “extraordinario reconocimiento”) da plausibilidad, a mi juicio, a la afirmación del texto principal: que (lamentablemente) Cristi no hace un intento serio de reconstruir la posición que critica.

¹⁶ Renato Cristi, *El pensamiento político de Jaime Guzmán: Autoridad y Libertad* (Santiago: lom Editores, 2000). La declaración que Cristi discute está reproducida en Dieter Blumenwitz, *La nueva constitución de la república de Chile* (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1983).

¹⁷ Cristi y Ruiz-Tagle (eds.), *El constitucionalismo del miedo*, 165.

¹⁸ En orden cronológico, véase: Cristi, *El pensamiento político de Jaime Guzmán*, 83; Fernando Atria, “Sobre la soberanía y lo político”, *Revista Derecho y Humanidades*, 12 (2006): 48-51; y Renato Cristi et al., *La república en Chile: teoría y práctica del constitucionalismo republicano* (Santiago: LOMEditores, 2006), 190-192.

¹⁹ En “Sobre la soberanía y lo político” yo me preocupé de aclarar qué quería decir por *tiranía*: “la tiranía es una fuerza en potencia que se niega a negar sus posibilidades no actualizadas, la dictadura es una fuerza en potencia que por la vía de constituir va progresivamente negando su potencialidad de noser” (Atria, “Sobre la soberanía y lo político”, 60). En *La república en Chile*, Cristi distingue el concepto *tiranía* de Hobbes (que lo niega en tanto lo reduce a un concepto puramente expresivo:) es “el término que emplean aquellos que se declaran descontentos con una monarquía” (Cristi et al., *La república en Chile*, 193) del de Montesquieu (como “el gobierno de uno solo, sin ley y sin reglas, que conduce todo por su voluntad y sus caprichos” [Ídem, ib., 194]). Cristi continua notando que Montesquieu hace referencia al dominio de “sultanes, califas, emires, visires, pachás, jeques, nabobs, shahs, rajahs y maharajás” (Ídem, ib., 194), y concluye: “a nadie se le ocurriría pensar que algunas de estas figuras tiránicas pudieran corresponder a Pinochet y los miembros de la Junta Militar” (Ídem, ib., 195). Yo diría exactamente lo contrario: nadie que recuerde el contenido de la disposición 24^a transitoria de la Constitución, o el frenesí asesino que siguió al atentado contra Pinochet, o el hecho de que, la noche del 6 de octubre de 1988, Pinochet pidió a la Junta una ley de poderes especiales para desconocer la derrota puede dejar de ver que, desde el punto de vista de Pinochet, él no pretendía negar las posibilidades no actualizadas, sino mantenerlas abiertas. El más sorprendido con la Constitución de 1980 fue el mismo Pinochet, que en 1988 se enfrentó, en la madrugada del 6 de octubre, con la sorpresa de que, después de todo, lo suyo no era una tiranía, porque las posibilidades no actualizadas, entre ellas la de ignorar el plebiscito, habían quedado cerradas. En todo caso, hay cierta ironía en que Cristi deseche la calificación de “tiranía” para lo de Pinochet, apelando precisamente a Montesquieu. Montesquieu declara al despotismo (la tiranía) como algo esencialmente ajeno a Occidente: para él (como para Cristi), despotismo “es el otro Estado, geográficamente distante de Europa, socialmente separado de la civilización occidental”, como, por otro lado, explica notablemente Blandine Kriegel en *The State and the Rule of Law* (Princeton: Princeton University Press, 1995), 18. Con esto, Montesquieu perseguía la finalidad de defender el orden feudal. Porque, antes de Montesquieu, “los teóricos del Estado y de los derechos naturales habían demostrado los paralelos entre el despotismo oriental y el feudalismo occidental” (Ídem, ib., 19). Al hacerlo, esos juristas “buscaban desacreditar un enemigo más formidable que los turcos o los persas, un enemigo más familiar que el déspota oriental; ellos buscaban descalificar el poder feudal” (Ídem, ib., 19). Pero la teorización de Montesquieu participaba de una empresa distinta, del “esfuerzo general de la filosofía feudal de negar los defectos del feudalismo y

disociar la crítica del despotismo de la crítica de la dominación feudal” (Ídem, ib., 19). Al orientalizar radicalmente el concepto de tiranía (despotismo), Montesquieu estaba defendiendo los regímenes que habían sido llamados *despóticos* en Occidente. Y el argumento de Cristi (quíralo o no su autor) tiene exactamente el mismo sentido: al volver radicalmente ajeno el concepto de tiranía, cierra la puerta a la pregunta de si lo de Pinochet era o no una tiranía, algo que “a nadie se le ocurriría pensar”.

²⁰ Con algún detalle sobre lo que justifica esta interpretación, véase Atria, “Sobre la soberanía y lo político”, 160-168.

²¹ Cristi et al., *La república en Chile*, 192.

²² Ídem, ib., 193.

²³ Cristi y Ruiz-Tagle (eds.), *El constitucionalismo del miedo*, 170.

²⁴ Ernst-Wolfgang Böckenförde, “El poder constituyente del pueblo. Un concepto límite del derecho constitucional”, en *Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia* (Madrid: Trotta, 2000), 164-165.

²⁵ Véase “Actas de las Sesiones de la Comisión Constituyente”, sesión 337, celebrada el 7 de marzo de 1978.

²⁶ Conforme a las actas, al discutir el mecanismos de elección del presidente de la República, el comisionado Bertelsen “propone, en cambio, elegir al presidente de la República por un organismo, que podría llamarse ‘Consejo de la República’, integrado por parlamentarios —tanto diputados como senadores—, por delegados regionales, por delegados locales e, incluso, aunque no es esencial, por un número reducido de electores por derecho propio, o sea, personas que han tenido una alta participación en la vida republicana: expresidentes del Senado, expresidentes de la Corte Suprema o exministros que hayan ejercido el cargo por tres o cuatro años. Agrega que la persona elegida debería contar con una mayoría calificada del Consejo, la que representaría un respaldo amplio. Piensa que con esta forma se pueden evitar algunos males inherentes a una campaña presidencial con sufragio universal” (“Sesiones de la Comisión Constituyente”, sesión 404, celebrada el 18 de julio de 1978).

²⁷ Ídem.

²⁸ Guzmán tenía conciencia (a diferencia de Bertelsen) de que no había alternativa al principio democrático, pero rechazaba al principio democrático (al respecto véase Jaime Guzmán), “El sufragio universal y la nueva institucionalidad”, *Realidad*, n.º 1 (1979): 33-44. Su solución fue la Constitución de 1980, que afirma el principio democrático (art. 4) pero lo neutraliza con sus trampas.

²⁹ Jaime Guzmán, “El camino político”, *Realidad*, n.º 7 (1979): 19.

³⁰ Atria, *La Constitución tramposa*, 17.

³¹ Cristi y Ruiz-Tagle (eds.), *El constitucionalismo del miedo*, 166. Digo “abusando los términos”, porque Cristi está en desacuerdo con Chadwick, supongo, pero eso no justifica calificar

su postura de “tramposa”. Cuando yo calificué de “tramposa” la Constitución de 1980, lo hice a la sombra de Guzmán: fue él quien afirmó que la constitución configura la cancha de modo tal que solo un equipo puede ganar, y la metáfora es de su propia autoría. No hay abuso en calificar las reglas de un juego en el que en virtud de ellas solo un equipo puede ganar como reglas “tramposas”. Pero la diferencia entre Cristi y Chadwick es una diferencia teórica o política, y no veo qué trampa hay en ello ni por qué la postura de Chadwick es “tramposa”. Yo estoy en desacuerdo con Cristi, por ejemplo, pero no creo que él haga trampas.

³² Ídem, ib., 173.

³³ Ídem, ib., 69.

³⁴ Ídem, ib., 18.

³⁵ Ídem, ib., 69.

³⁶ En realidad, no “lo reconozco”, lo que sugiere un intento previo por evitarlo. Lo afirmo, aunque la frase mía que Cristi cita no significa lo mismo que la que él me atribuye haber “reconocido”. Véase la discusión a la que la n.º 49 hace referencia.

³⁷ Cristi y Ruiz-Tagle (eds.), *El constitucionalismo del miedo*, 167.

³⁸ Para una explicación de qué quiero decir por “hablar al revés”, y por qué esto es importante, véase Atria, *La Constitución tramposa*, 16-29.

³⁹ No hay nada lógicamente contradictorio en que los diputados y senadores de la UDI voten en masa para abolir todas las trampas y permitir la creación de un Estado de bienestar en Chile. Por consiguiente, no se trata de que las exigencias del art. 127 hagan “lógicamente” imposible la nueva constitución. Solo la hacen políticamente imposible.

⁴⁰ Atria, *La Constitución tramposa*, 71-77.

⁴¹ Cristi, *El pensamiento político de Jaime Guzmán*, 141. Cristi no ofrece argumento alguno para justificar su idea de que la transición es “instantánea, completa y no gradual”. En realidad, se limita a notar la asimetría entre decir que la transición de la democracia a la dictadura en 1973 fue instantánea y decir que la transición de la dictadura a la democracia es gradual. Esta asimetría le parece “paradójica” (Ídem, ib., 140). Por qué le resulta paradójico es para mí un misterio. Lo normal es que construir sea un proceso más o menos gradual, pero destruir no lo sea.

⁴² Ídem, ib., 139. Cristi se queja dos veces (Cristi y Ruiz-Tagle [eds.], *El constitucionalismo del miedo*, 168) de que este pasaje haya sido citado de forma “incompleta” o “trunca”, con lo que parece insinuar que lo omitido cambia el sentido de lo citado. Primero dice que la cita en *La Constitución tramposa* es “incompleta”, pero que “Sobre la Soberanía y lo Político” aparece “una cita más completa” (Ídem, ib.) que él mismo reproduce (y que es la que aparece aquí en el texto principal). Después de haber citado esta cita, reconocidamente “más completa”, Cristi olvida su propio reconocimiento e insiste: “a continuación de esta cita trunca, Atria añade...” (Ídem, ib., 88). Luego Cristi hace una cita aún más completa, que espero mostrará al lector que las dos citas anteriores reflejaban genuinamente, en lo relevante, lo que Cristi sostenía. En efecto, no alcanzo a

ver en las partes omitidas del pasaje de Cristi dimensión alguna que cambie el sentido en que dicho pasaje fue comentado en *La Constitución tramposa* o en “Sobre la soberanía y lo político”. En todo caso lamento, si ese fue el caso, que el profesor Cristi haya quedado con la sensación de que manipulaba sus afirmaciones. Debo decir que el comentario de Cristi abunda en un lenguaje que supone imputaciones más allá de nuestro desacuerdo que me resultan enteramente injustificadas. A la imputación de citar en forma incompleta (trivial, en la medida en que toda cita es por definición incompleta, o falsa, en la medida en que insinúa que hay manipulación de sus dichos) se añade, por ejemplo, la de que yo me permito “descalificar” a quienes consideran que el pueblo recuperó su poder constituyente en 1989 (Ídem, ib.). Lo que yo afirmé en *La Constitución tramposa* era que una constitución puede ser apropiada por el pueblo, lo que quiere decir que su “legitimidad” no es una cuestión que quede decidida de una vez por todas en el momento del inicio: que es posible que una decisión que es originalmente impuesta (heterónoma) sea apropiada por el agente al que se le impone y entonces devenga autónoma. La idea de apropiación, por supuesto, crea un riesgo de autoengaño: que el agente se engañe a sí mismo para convencerse de que se ha apropiado de algo que sigue siendo heterónimo, para evitar el malestar de saberse oprimido. Esto ocurre cuando se dice a sí mismo que una decisión que lo oprime es su propia decisión. “Aquí la idea de apropiación funciona como una forma de autoengaño” (Atria, *La Constitución tramposa*, 79). La afirmación de que, en 1989, el pueblo recuperó su poder constituyente es, a mi juicio, un caso de apropiación prematura en este sentido. Con esto manifiesto mi desacuerdo con autores que, como Cristi, afirman esa tesis, pero no veo qué hay en lo que digo que justifique decir que lo que yo hago es “descalificar” a Cristi. “Descalificar”, después de todo, consiste en (Def.=) ‘desacreditar, desautorizar o incapacitar’. Lo que hago con la idea de Cristi no es descalificar, sino calificar (Def.= ‘atribuir a algo una cierta calidad’) en este caso a su afirmación la calidad de incorrecta. Tampoco entiendo por qué en este mismo pasaje Cristi reclama que yo le imputo “mala conciencia” (Cristi y Ruiz-Tagle [eds.], *El constitucionalismo del miedo*, 168). Y lo hace así, con comillas, sugiriendo que es una cita textual del libro. Esa expresión, sin embargo, no aparece en el libro. ¿Necesito decir que no tengo razón alguna para imputarle mala conciencia a Cristi?

⁴³ Citado por Renato Cristi, *Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism: Strong State, Free Economy* (Cardiff: University of Wales Press, 1998), 40. Véase adicionalmente a Schmitt, *Teoría de la Constitución*, 126-133.

⁴⁴ Cristi, *Carl Schmitt*, 44 (cursivas agregadas, por lo que se explicará infra, n.º 51).

⁴⁵ Cristi y Ruiz-Tagle (eds.), *El constitucionalismo del miedo*, 169.

⁴⁶ Ídem, ib., 171. Para evitar reclamos sobre citas “truncas”, conviene dejar aquí expresado la frase con la que Cristi continúa: “[...] pero cuyo ejercicio democrático, como Poder constituyente derivado, es reconocidamente parcial por razones circunstanciales y no de principio”. Para lo que me interesa, esta frase es irrelevante. Lo que importa es lo que la frase citada en el texto principal

implica respecto de las instituciones que esa Constitución (la de 1989) contenía: senadores designados, sistema binominal, Tribunal Constitucional, *quorum* contramayoritarios, inamovilidad de los comandantes en jefe, etcétera.

⁴⁷ Cristi recuerda una afirmación de Hobbes: “El legislador no es aquel por cuya autoridad las leyes fueron promulgadas en primera instancia, sino quien por cuya autoridad las leyes continúan siendo leyes” (Ídem, ib., 173, n.º 90). Esto es verdad, y es parte importante de la explicación de la posibilidad de apropiación de una decisión originalmente impuesta. Pero en el caso que nos interesa, podríamos nosotros preguntar: ¿quién era, durante los noventa, el “legislador” de la ley orgánica constitucional de enseñanza^{18.962}? La LOCE fue publicada en el Diario Oficial el último día de la dictadura, el 10 de marzo de 1990, y requería para su modificación o derogación ⁴/7 de los votos de los senadores y diputados en ejercicio, como toda ley orgánica constitucional. Eso quiere decir que la derecha siempre tuvo veto para impedir su reforma, incluso cuando ella fue derogada en 2009 por la ley general de educación 20.370 ¿Quién es aquel “por cuya autoridad” la LOCE rigió desde 1990 hasta 2009? ¿El pueblo chileno?

⁴⁸ Ídem, ib., 168.

⁴⁹ Cristi, *El pensamiento político de Jaime Guzmán*, 108.

⁵⁰ Cristi alega (Cristi y Ruiz-Tagle [eds.], *El constitucionalismo del miedo*, 173) que por el solo hecho de que he dicho que “el poder constituyente no es un poder normativo conferido por una norma anterior” (Atria, *La Constitución tramposa*, 27) estoy aceptando que es ilimitado. Esto es correcto e incorrecto a la vez. El poder constituyente no puede estar vinculado por normatividades anteriores a él, porque entonces sería poder constituido, pero eso no quiere decir que sea un poder ilimitado: “el *pouvoir constituant*, como su propio nombre indica, está determinado por una voluntad de constitución. Y ‘constitución’ significa ordenación y organización jurídica del poder político del Estado [...]. Un poder absoluto, y que quiera seguir siendo absoluto, no cabe en una constitución”, es decir, no es capaz de constituir nada. Por esto, Bockenforde nota que “en la Alemania que siguió a 1933 no se intentó, ni era posible, incorporar el poder del *Führer* que Hitler asumió en una constitución, ni se intentó elaborar una ‘constitución’ para ese *Führerstaat*” (Bockenforde, “El poder constituyente del pueblo”, 176). La cuestión es más importante de lo que puede discutirse aquí. Véase Atria, “Sobre la soberanía y lo político”, 60-67.

⁵¹ Ídem, ib., 51, n.º 17.

⁵² Véase el capítulo 2 de *La Constitución tramposa* (“¿Qué es una Constitución y cuándo es nueva? Sobre constitución y leyes constitucionales”, 31-56). Cristi ignora esta distinción cuando reprocha a Schmitt el haber afirmado, después de la ley de poderes especiales de 1933, que en virtud de ella Hitler tenía “una porción” del poder constituyente (véanse supra, el texto que acompaña a las notas 42 y 43, y obsérvese en este sus frases destacadas). Pero Schmitt usa el lenguaje con rigor, y deja claro que no se refiere al poder constituyente, sino al poder de dictar leyes constitucionales [*verfassungsgesetzgebende Gewalt*], que es una especie de poder

legislativo, no constituyente. Cristi prefiere (ahora, no en *El pensamiento político de Jaime Guzmán*, como acabamos de notar) el lenguaje de “poder constituyente originario” y “poder constituyente derivado”, un lenguaje confuso porque niega la relevancia de la distinción entre lo constituyente y lo constituido, al suponer que ambos son especies de un mismo género. Pero eso no es razón para que olvide que Schmitt precisamente rechaza esa distinción, porque para Schmitt no puede confundirse el poder de dictar leyes constitucionales con el poder constituyente. Es difícil ser más claro que lo que es Schmitt al respecto: “Todo lo que se verifica en regulación legal-constitucional a base de la constitución, y en el marco de las competencias constitucionales a base de la regulación legal-constitucional, es, en esencia, de naturaleza distinta a un acto del poder constituyente”. Y por si no quedara claro, insiste un par de párrafos más abajo: “Es especialmente inexacto caracterizar como poder constituyente, o *pouvoir constituant*, la facultad, atribuida y regulada sobre la base de una ley constitucional, de cambiar, es decir, de revisar determinaciones legal-constitucionales. También la facultad de reformar o revisar leyes constitucionales (por ejemplo, según el art. 76, C. a.) es, como toda facultad constitucional, una competencia legalmente regulada, es decir, limitada en principio” (Schmitt, *Teoría de la Constitución*, 114). El artículo 76 de la Constitución de Weimar, a la que Schmitt se refiere en este pasaje, es el equivalente al artículo 127 del texto constitucional chileno (reforma constitucional). Cristi sabe que para Schmitt esta distinción es fundamental (*El pensamiento político de Jaime Guzmán*, 107-108), pero la ignora cuando se trata de juzgarlo.

⁵³ Cristi y Ruiz-Tagle (eds.), *El constitucionalismo del miedo*, 171. Que Cristi crea que el argumento puede ser descrito así muestra que él no es consciente de la necesidad de tematizar el lenguaje que usamos para hablar de estas cuestiones. Compárese con Atria, *La Constitución tramposa*, 64-71, y juzgue el lector. Adicionalmente, no entiendo por qué, a continuación del pasaje citado en el texto principal, Cristi sostiene: “Para Atria [...] lo que importa es el proceso constituyente y no el resultado”. *La Constitución tramposa* dedica uno de sus cuatro capítulos (titulado “Entre proceso y producto [forma y substancia]”) a explicar precisamente que “aquí no podemos distinguir entre proceso y producto” (68), porque “la forma es la substancia” (63).

⁵⁴ Cristi y Ruiz-Tagle (eds.), *El constitucionalismo del miedo*, 174. Cristi, sin embargo, no dice cuál es la forma “institucional” de hacer esto, por lo que su sugerencia todavía no es completa. Cuando lo sea, tendrá que ser agregada a la lista mencionada en la n.º 13.

⁵⁵ Ídem, ib.

Discutir sobre la Constitución es plantear la pregunta sobre el país que queremos. En nuestra época, esta inquietud se canaliza a través de ciudadanos descontentos y movilizados en las calles del mundo, con un desafío común: cuestionar las estructuras tradicionales de dominación y legitimación, exigiendo una revisión a los modos en que se ejerce el poder. Las oleadas de protestas registradas en Europa, Asia y América Latina no han buscado más que esclarecer, en último término, quiénes son los encargados de instituir las formas de autoridad política y, en consecuencia, organizar la vida en sociedad.

¿Dónde reside la soberanía en la democracia de nuestros días? ¿Estamos frente a un incipiente proceso constituyente global y local? Este libro contribuye a esa discusión desde un enfoque diferente, uno que sintoniza con *amplias preguntas y escasas respuestas* en torno a los fundamentos de la democracia y el poder constituyente. El objetivo de esta obra es claro: exponer los principales debates contemporáneos y proporcionar las herramientas conceptuales y analíticas que permitan comprender las razones que explican el cambio constitucional a la luz de los acontecimientos de Chile y el mundo.

¿Quién podría extrañarse de que la cuestión constitucional esté hoy a la base del problema político? Pues bien, este libro ayuda a acercarse reflexivamente a cada uno de los problemas teóricos y conceptuales que esta última plantea.

CARLOS PEÑA
Universidad Diego Portales

Los autores no solo nos ofrecen los elementos necesarios para trazar la historia del poder constituyente, sino sobre todo demuestran la centralidad de este concepto para pensar la democracia contemporánea, con especial atención al caso chileno.

ANTONIO RIVERA GARCÍA
Universidad Complutense de Madrid